MATHEUS CUNHA I MARCIO EL KALAY

ORGANIZADORES

MANUAL DE COMPLIANCE

Compliance Mastermind Vol.1

Autores

ALESSANDRA GONSALES
ALEXANDRE C. SERPA
CAROLINA GAZONI
DANIELA LEME
DANIEL SIBILLE
FELIPE FARIA
GUSTAVO LUCENA
MARILIA ZULINI C. LOOSLI
MARCELO ZENKNER
MASSAMITSU ALBERTO IKO
MATHEUS CUNHA
PATRÍCIA PUNDER
RODRIGO PIRONTI

Prefácio

HUI CHEN

LEC® LEGAL ETHICS COMPLIANCE

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha
Márcio El Kalay
(Organizadores)

MANUAL DE
COMPLIANCE
Compliance Mastermind Vol. 1

Autores

Alessandra Gonsales
Alexandre da Cunha Serpa
Carolina Gazoni
Daniela Leme
Daniel Sibille
Felipe Faria
Gustavo Lucena
Marília Zulini da Costa Loosli
Marcelo Zenkner
Massamitsu Alberto Iko
Matheus L. Rodrigues da Cunha
Patrícia Punder
Rodrigo Pironti Aguirre de Castro

Prefácio
Hui Chen

LEC – Legal, Ethics and Compliance

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha
Márcio El Kalay
(Organizadores)

MANUAL DE
COMPLIANCE

Compliance Mastermind Vol. 1

LEC EDITORA
São Paulo
2019

MANUAL DE COMPLIANCE
Compliance Mastermind – Vol. 1

Organização: Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha; Márcio El Kalay
Autores: Alessandra Gonsales; Alexandre da Cunha Serpa; Carolina Gazoni; Daniela Leme; Daniel Sibille; Felipe Faria; Gustavo Lucena; Marília Zulini da Costa Loosli; Marcelo Zenkner; Massamitsu Alberto Iko; Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha, Patrícia Punder; Rodrigo Pironti Aguirre de Castro
Prefácio: Hui Chen
Colaboração Editorial: Aûani Cusma de Paula
Revisão: Responsabilidade dos autores
Tradução: Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha
Capa: Mamutt Design

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico, inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

LEC Editora e Organização de Eventos Ltda.
CNPJ 16.457.791/0001-13
Av Paulista, n. 1274, Conj. 32, Edificio Asahi, Bela Vista
São Paulo/SP, CEP 01310-925, Brasil
+ 55 11 3259 2837
lec@lecnews.com
http://www.lecnews.com

Impresso no Brasil | *Printed in Brazil*
Impresso por Interfill Gráfica
São Paulo/SP
2019

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Manual de compliance : compliance mastermind vol. 1 / Márcio El Kalay, Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha ; Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha, Márcio El Kalay (organizadores). -- São Paulo : Lec - Legal, Etichs and Compliance, 2019.

Vários autores.
ISBN 978-65-80798-00-1

1. Administração de empresa 2. Compliance 3. Governança corporativa 4. Programas de compliance I. Cunha, Matheus Lourenço Rodrigues da. II. El. Kalay, Márcio

19-28417 CDD-658.46

Índices para catálogo sistemático:

1. Programas de compliance : Administração 658.46

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964

Apresentação

Um Manual de Compliance Verdadeiramente Prático

Imagine a situação. De um dia para o outro você descobre que, a partir daquele momento, será o responsável pela área de Compliance da sua empresa, com a necessidade de implementar o programa para ontem. Ou, insatisfeito com sua atividade profissional, resolve empreender uma transição de carreira e descobre no Compliance uma excelente oportunidade, mas não sabe, ao certo, por onde começar. Pode parecer uma situação surreal ou desesperadora, não importa. A verdade é que essa é uma realidade cada vez mais presente no ambiente corporativo brasileiro, que aflige desde diretores experientes de áreas já estabelecidas, como Jurídico ou Finanças, até jovens profissionais que acabaram de fazer um curso e tem uma boa base teórica, mas...

Compliance é uma atividade prática!

Claro, é importante conhecer legislações locais e internacionais pertinentes, metodologias de avaliação de risco, de implementação de controles, de investigações internas, etc. Entretanto, todo esse cabedal teórico, por si só, não vai ajudar na sua missão mais importante naquele momento, diante do que a empresa em que trabalha ou cliente contratado realmente esperam de você: implementar o bendito Programa de Compliance.

Não é uma tarefa fácil, nem simples. Mas, existem ferramentas que podem ajudar profissionais sem grande vivência na área a executar essa missão de forma mais rápida e objetiva. E dentre essas ferramentas, este Manual de Compliance é, muito provavelmente, uma das mais simples, práticas e acessíveis.

O Manual de Compliance foi escrito pelos participantes do *Compliance Mastermind* – programa de afiliação anual da LEC para profissionais de Compliance em posição de gestão. Isso dá a esta obra, a experiência de décadas e décadas, obtida por quem atua tanto dentro de empresas, como em consultorias, trazendo um olhar amplo, mas sempre a partir de uma abordagem real do funcionamento da área.

Neste primeiro volume da publicação Compliance Mastermind, o Manual de Compliance, você terá uma visão prática sobre como implementar um Programa de Compliance Anticorrupção, com um *overview* do funcionamento das principais legislações internacionais e locais e de como essas atividades estão cada vez mais globalizadas e integradas. Para ajudar você a colocar o programa de pé, os autores partem da metodologia usada pela LEC em seus cursos, dos nove pilares de Compliance. Cada pilar é tratado em um artigo dedicado, numa abordagem fácil e prática, sobre o que você pode fazer para implementá-los, como um código de conduta, o *risk assessment*, os treinamentos e comunicações, o canal de denúncias, conquistar o *tone at the top*, gerir o risco de terceiros e muito mais.

A obra foi concebida para ser um material de referência, que centraliza um conjunto de informações e diretrizes nacionais e internacionais que ficam dispersas por aí. Em seus artigos, os autores incorporam estas diretrizes com o conhecimento de diferentes metodologias e documentos, apresentando-os de forma clara e segura, que permite guiar o leitor na construção de um programa efetivo, considerando as exigências das principais autoridades locais e/ou estrangeiras.

Obviamente, não se trata de uma Programa de *Compliance* "de prateleira" ou de uma preconcebida "receita de bolo" a ser repetida em larga escala. Talvez o principal desafio do leitor seja absorver aos *insights* propostos pelos autores e, por meio de uma boa metodologia de gestão de projetos, adequá-los à sua realidade e sua necessidade no caso concreto. Afinal, dois princípios fundamentais dos Programas de *Compliance* verdadeiramente efetivos são: *no one-size-fits-all* (não há um tamanho único para todas as organizações) e *risk-based approach* (deve ser baseado no risco real de cada organização).

Por isso, além dos textos trazerem uma abordagem prática (até porque, quem os escreveu, já fez aquilo acontecer), eles são repletos de referências, *guidelines* e indicadores referendados local e internacionalmente (*kpi's*, *kri's*, *ksi's*, etc.). Assim, o leitor já sabe aonde ir para se aprofundar num determinado tema sempre que ache necessário, para depois colocar as ideais na prática.

Boa leitura!

Matheus Cunha e Márcio El Kalay

Organizadores

Sumário

Prefácio
Hui Chen 11

Capítulo 1
FCPA - *Foreign Corrupt Practices Act*: o Começo de Tudo!
Patricia Punder 17

Capítulo 2
Responsabilização de Empresas no Cenário Internacional: Um Sistema Global
Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha 37

Capítulo 3
O Microssistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Corrupção
Marcelo Zenkner..... 61

Capítulo 4
Pilar 1 - *Tone from the Top*: Comprometimento e Suporte da Alta Administração
Carolina Gazoni 87

Capítulo 5
Pilar 2 - *Risk Assessment*: Metodologia de Análise de Riscos para Conformidade Legal
Gustavo Lucena 123

Capítulo 6
Pilar 2 – *Compliance Risk Assessment*: Análise de Caso de Participação em Licitações e Contratos Públicos
*Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha e Rodrigo Pironti Aguirre de Castro*135

Capítulo 7
Pilar 3 - Código de Ética e de Conduta, Políticas e Procedimentos: Os Documentos Normativos Relacionados ao Programa de Integridade da Empresa
Marilia Zulini da Costa Loosli e Massamitsu Alberto Iko..... 157

Capítulo 8
Pilar 4 - Controles Internos no Programa de Compliance: Mitigando os Riscos de Integridade
Daniela Leme.....171

Capítulo 9
Pilar 5 - Comunicação e Treinamento de Compliance: Difundindo a Cultura de Integridade
Felipe Faria..... 209

Capítulo 10
Pilar 6 - Canais de Comunicação com o Programa de Compliance
Marilia Zulinida Costa Loosli, Massamitsu Alberto Iko e Matheus Lourenço Rodriguesda Cunha 231

Capítulo 11
Pilar 7 - Investigações Internas e Medidas Disciplinares
Alessandra Gonsalese e Daniel Sibille 247

Capítulo 12
Pilar 8 - *Due Diligence* de Integridade: Uma Estratégia para a Gestão de Riscos de Terceiros
Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha 261

Capítulo 13

Pilar 9 – Monitoramento e Auditoria de Compliance: Melhoria Contínua e Sustentação do Programa de Integridade
Daniela Leme 297

Capítulo 14
Tomada de Decisão [Ética]
Alexandreda Cunha Serpa 347

Capítulo 15
A Importância dos Sistemas de Integridade na Prevenção ao Assédio Moral
Marcelo Zenkner e Patrícia Punder 367

Autores
Currículos..... 387

Prefácio

Over the recent years, the scandals exposed through the Lava Jato investigations have brought about a rapidly growing recognition of the importance of integrity in public and business life. This recognition has spurred the development of the compliance profession as governments and companies seek to meet the social demands for integrity. This is an unprecedented time and opportunity for compliance to make a difference in the future of Brazil, and this book is part of the important collective effort in making that difference.

If public integrity is the goal, ethics is the compass and compliance is a vehicle for reaching that goal. On this journey, Brazil can benefit from lessons learned elsewhere in order to avoid pitfalls and unnecessary detours. Brazil will also make its own paths that are uniquely suited to its landscapes and realities.

Focus on outcome, not just efforts. One of the most common pitfalls for compliance programs to date is the focus on efforts rather than outcome. Companies and regulators have been busy counting how many training sessions have been held and how many people have been trained, but not asking whether the training changed behavior; they have set up hotlines but don't know why people still are not raising concerns; they have written lengthy and numerous policies and procedures but don't verify if people are following them. We have become so focused on replicating a formula that we have forgotten to ask if that formula has actually produced the outcome for which it was designed. As we examine compliance programs and its elements – policies, training, internal reporting, etc. - it would be beneficial for us to ask the question: "What is this suppose to achieve?" In other words, contemplate what is the desired for outcome for the efforts we are making.

Integrate, not segregate. While much of compliance programs has focused on bribery and corruption, it would be a mistake to ignore other critical areas of integrity risks such as finance, safety, labor, environment, competition, privacy, sustainability, governance, and other issue impacting legal, ethical, and social responsibilities. When a company misrepresent it financial health to shareholders, cheats its consumers on the quality of its products, harms its workers by creating dangerous or hostile environments, it may not be committing bribery, but its integrity undoubtedly would be called into question by any of these acts. Currently, however, organizations tend to manage these risks in segregated silos: operations manage

Nos últimos anos, os escândalos expostos nas investigações da Lava Jato trouxeram um reconhecimento crescente sobre a importância da integridade na vida pública e empresarial. Esse reconhecimento estimulou o desenvolvimento profissional em Compliance, à medida que governo e empresas buscam atender às demandas sociais por integridade. Esse é um tempo e uma oportunidade sem precedentes para que o tema faça a diferença no futuro do Brasil e este livro faz parte de um importante esforço coletivo para fazer essa diferença.

Se a integridade pública é o objetivo, a ética é a bússola e o Compliance é o meio para alcançar esse objetivo. Nesta jornada, o Brasil pode se beneficiar das lições aprendidas, para evitar armadilhas e desvios desnecessários. O país também trilhará seu próprio caminho, adequado ao seu cenário e realidades.

***Foco no resultado, não nos meios**. Uma das armadilhas mais comuns para programas de compliance até hoje é o foco nos meios e não nos resultados. Empresas e reguladores se preocupam em contar quantos treinamentos foram realizados e quantas pessoas participaram, mas não perguntam se o comportamento das pessoas mudou; criaram canais para comunicação, mas não sabem por que as pessoas ainda não o utilizam; escrevem políticas e procedimentos longos e numerosos, mas não verificam se as pessoas cumprem. Nos tornamos tão focados em replicar uma fórmula que esquecemos de perguntar se ela realmente produz o resultado para o qual ela foi projetada. À medida que examinamos os programas de compliance e seus elementos - políticas, treinamentos, relatórios internos, etc. - seria benéfico fazer a pergunta: "O que é que isso deve alcançar?". Em outras palavras, pense no que se espera como resultado. pelos esforços que são feitos.*

***Integrar, não segregar**. Embora os Programas de Compliance se concentrem em suborno e corrupção, seria um erro ignorar outros riscos de integridade, como financeiros, de segurança, trabalhistas, ambientais, concorrenciais, privacidade, sustenta-bilidade, governança e outros que afetam aspectos legais, éticos e de responsabilidade social. Quando uma empresa desvirtua sua saúde financeira a acionistas, engana consumidores quanto a qualidade de seus produtos, prejudica colabo-radores criando ambientes perigosos ou hostis, pode não estar sendo corrupta, mas sua integridade, sem dúvida, seria questionada.*

safety and quality control risks, human resources manage labor and employment risks, legal manages regulatory and enforcement risks, etc. Compliance often narrowly defines itself to those risks that lead to enforcement actions such as bribery and collusion. This fragmented approach obscures the fundamental values underlying these areas. An integrity and mission-driven compliance function needs to be an integrator of the silos, working to safeguard and empower the company's values and missions in all aspects of the business. To do so, we need to recognize all the risk areas, identify their commonalities, and develop strategies to integrate approaches. We need to design our systems, processes and controls from the employees' perspectives, so that they are not overwhelmed and overburdened by overlapping and repetitive demands from every risk area.

Scale and adapt. The commonly cited elements of compliance programs were developed mostly by and for large, publicly traded, multinational corporations. It is important to recognize that when implemented in different settings, such as small and medium sized enterprises, family-owned or privately held businesses, compliance programs may – and should – look different. Consider a 100-person family-owned business: instead of expecting a compliance "department" or "officer", it may be more appropriate to look for the person who actually plays that role and how she or he exercises compliance-like responsibilities, whether or not that person has a "compliance" title or not. Such a company may or may not need an anonymous "hotline", because everyone knows everyone else's email address or phone number, and could easily set up an anonymous email account to raise a concern, or because the environment is such that nothing is truly anonymous. Here we come back to the consideration of the desired outcome: what is each of these elements suppose to achieve? What is the purposes? How does our particular organization achieve that outcome and fulfill that purpose? There are typically more than one way to arrive at a certain goal, and it is incumbent upon each organization to find its own way, and for regulators and enforcers to hold organizations accountable not just by how they do compliance, but by why they do it that way and what outcomes they have achieved.

I look forward to being part of this continuing journey with you.

Atualmente, no entanto, as organizações tendem a gerenciar riscos em áreas segregadas: operações gerenciam riscos de segurança e controle de qualidade; recursos humanos, riscos trabalhistas; jurídico, os riscos regulatórios e processuais etc. O compliance, frequentemente se restringe a riscos que levam a demandas específicas, como suborno e cartel. Essa abordagem fragmentada encobre os valores fundamentais dessas áreas. A função de compliance orientada pela missão de integridade precisa ser fator de integração entre as áreas, trabalhando para zelas e divulgas os valores e a missão da empresa em todos os aspectos do negócio. Precisamos reconhecer os donos dos riscos, identificar suas semelhanças e desenvolver estratégias para integrar abordagens. Projetar sistemas, processos e controles a partir das perspectivas dos colaboradores, para não os sobrecarregar por exigências repetitivas e burocráticas de todas as áreas de riscos.

Escale e adapte. *Os elementos comumente citados dos programas de compliance foram desenvolvidos principalmente por e para grandes multinacionais de capital aberto. É importante reconhecer que se implementados em diferentes estruturas, como companhias de pequeno e médio porte ou empresas familiares, podem - e devem - ser diferentes. Considere uma empresa familiar com 100 pessoas: em vez de esperar um "departamento" ou "profissional" de compliance dedicado, pode ser mais apropriado procurar alguém que já desempenha um papel e responsabilidades semelhantes, que possa ter ou não um título de "compliance". Essa empresa pode não precisar de um "canal de denúncias" anônimo. Todos os colaborares conhecem os endereços de e-mail ou números de telefone da empresa e podem facilmente criar uma conta de e-mail anônima para fazer uma denúncia. Ou talvez o ambiente não seja favorável para que realmente seja anônimo. Aqui volta-se a considerar o resultado desejado: o que cada um desses elementos espera alcançar? Quais são os seus propósitos? Como nossa organização em particular alcança esse resultado e cumpre esse objetivo? Normalmente, há mais de uma maneira de chegar a uma determinada meta e cabe a cada organização encontrar seu próprio caminho. Os órgãos reguladores e de fiscalização responsabilizam as organizações, não pela estrutura do seu Programa de Compliance, mas pelo que fazem com ele e pelos resultados que alcançam com ele.*

Estou ansiosa para fazer parte desta jornada contínua com você.

Hui Chen[1]
Tradução: Matheus Cunha

Capítulo 1
FCPA - *Foreign Corrupt Practices Act*
O começo de tudo!

Patrícia Punder[2]

Introdução

A Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (*Foreign Corrupt Practices Acts*) ou para os íntimos FCPA foi a primeira lei do gênero na história da humanidade; nenhuma outra nação ou império jamais criminalizou o pagamento de suborno em jurisdições estrangeiras. Podemos dizer que foi o primeiro esforço de uma nação com o fim específico de criminalizar o ato de subornar funcionários estrangeiros. Sua agenda era abrangente, uma mistura de preocupação com a integridade pública, estabilidade dos governos e potenciais danos nas relações dos Estados Unidos com outros países.

1. Histórico

Como os Estados Unidos se transformou na mais famosa *polícia* anticorrupção? O século XIX e início do século XX foram notoriamente períodos corruptos na história americana. Durante o período pós-Guerra Civil, conhecido como *Era Dourada*, máquinas políticas desenfreadas, como *Tammany Hall*, em Nova York, forneceram votos em troca de patrocínio político, enquanto os chamados barões da indústria pressionaram políticos para limitar a regulamentação governamental. A construção das ferrovias transcontinentais trouxe escândalos de corrupção envolvendo fraudes em ações e propinas para congressistas e, em 1868, foi aprovado um projeto de lei em Nova York que essencialmente legalizou a corrupção. [3]

A Comissão de Valores Mobiliários (*Securities and Exchange Commission*) ou para os íntimos *SEC* somente foi estabelecida em 1934, exatamente durante a Grande Depressão, com o objetivo de restaurar a confiança do investidor no mercado de capitais fornecendo aos investidores e ao mercado informações mais confiáveis e regras claras de negociação honesta.[4]

Mas, foi o escândalo *Watergate*[5] que ocorreu no começo dos anos 70, nos últimos estágios da Guerra Fria, que forneceu o ímpeto para passar a FCPA. Escândalos políticos interligados a administração do presidente Richard M. Nixon, que foram revelados após a prisão de cinco assaltantes no quartel-general do Comitê Nacional Democrata (DNC) no complexo de apartamentos em Washington, DC, em 17 de junho de 1972, foram o gatilho de tudo. Não se tratava de um roubo comum: os vilões estavam ligados à campanha de reeleição do presidente Richard Nixon, e eles haviam sido pegos escutando telefones e roubando documentos.

Nixon tomou medidas agressivas para encobrir o crime depois, e em agosto de 1974, depois que seu papel na conspiração foi revelado, Nixon renunciou. O escândalo Watergate mudou a política americana para sempre, levando muitos americanos a questionar seus líderes e pensar mais criticamente sobre a presidência.

As investigações que se seguiram após o escândalo Watergate revelaram que empresas haviam realizado contribuições políticas ilegais, tanto domésticas como estrangeiras, que foram escondidas em fundos secretos. Isto levantou a preocupação que os livros e registros contábeis dessas empresas não estavam sendo reportados com precisão para a SEC. Como consequência, em 1976, foi emitido um relatório denominado de *Report on Questionable and Illegal Corporate Payments and Practice*. [6]

No supramencionado relatório, a SEC determinou que a corrupção no estrangeiro pelas empresas americanas era grave e suficientemente generalizada para ser uma causa de profunda preocupação. Investigações realizadas por essa Comissão revelaram que centenas de companhias americanas haviam realizados pagamentos de corrupção no exterior envolvendo milhões de dólares.

Com este cenário, o Senado americano concluiu que existia uma forte necessidade de ser criada uma legislação anticorrupção nos Estados Unidos. “A corrupção corporativa é um mal negócio”, define o relatório, o qual ainda ressalta que “O princípio básico do sistema de livre mercado americano é que

a venda de produtos deva ocorrer com base no preço, qualidade e serviço. O suborno corporativo é fundamentalmente destrutivo deste princípio básico".[7]

Como resposta, o Congresso dos Estados Unidos promulgou a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (*Foreign Corrupt Practices Acts*) visando interromper suborno de autoridades estrangeiras e restaurar a confiança do público na integridade do sistema de negócios americano. A lei foi assinada pelo presidente Jimmy Carter em 19 de dezembro de 1977.

Desde 1977, as disposições anticorrupção da supramencionada lei tem sido aplicadas para todas as pessoas dos Estados Unidos e a determinados emissores estrangeiros de valores mobiliários. Devido a certas alterações no ano de 1988[8], que foram projetadas para implementar a Convenção Anti-suborno da OECD (*OECD Anti-Bribery Convention*[9]), as disposições anticorrupção também são aplicáveis as empresas estrangeiras e pessoas físicas que causem, direta ou através de agentes, um ato na promoção de pagamento de corrupção que ocorra além do território americano.

A FCPA também exige que as empresas cujos valores mobiliários sejam listados nos Estados Unidos cumpram com suas disposições contábeis. Estas disposições contábeis, que foram designadas para operar em conjunto com as provisões anticorrupção, exigem que as empresas sigam as seguintes determinações: (i) fazer e manter livros e registros que reflitam de maneira precisa e justa as transações da empresa; e (ii) elaborar e manter um sistema adequado de controles contábeis internos.

A aplicação da FCPA foi dominante desde sua introdução até por volta de 2010, quando outros países começaram a introduzir suas próprias legislações anticorrupção, tal como fez a Inglaterra através do *United Kingdom Bribery Act 2010*.[10]

2. Disposições Legais, Penalidades e Acordos

A FCPA proporciona ao Departamento de Justiça Americano (*U.S. Department of Justice*), ou DoJ, e à SEC discricionariedade para perseguir o suborno internacional.[11] O Departamento de Justiça é responsável quando as violações são de natureza criminal. Já a SEC é responsável quando as violações são primariamente de natureza civil.

Para que um indivíduo seja criminalmente responsável sob a FCPA, ele deve agir intencionalmente na violação de qualquer disposição de referido estatuto jurídico. Contudo, nenhum indivíduo escapará de uma eventual penalização sob a alegação de desconhecimento da conduta do ato ilícito. Trata-se do conceito do dever de conhecer a respeito de determinada conduta ou circunstância onde existem razoáveis alertas de potencial violação de provisões da FCPA; a exigência de saber se destina a abranger a "desconsideração consciente" e padrões de "cegueira voluntária ou deliberada", incluindo um propósito consciente para evitar aprender sobre a verdade da conduta e do que fato está ocorrendo.

Estamos diante do velho problema onde os indivíduos/executivos decidem colocar simplesmente a "cabeça na areia", com o objetivo de alegar desconhecimento da corrupção, por exemplo, ou da necessidade de implementar os controles internos necessários na empresa com o intuito de prevenir e detectar a potencial corrupção.

A corrupção existe, seja ela causada direta ou indiretamente por uma empresa. Consequentemente, alegar desconhecimento é algo que não será considerado nem pelo Departamento de Justiça, muito menos pela SEC.

As disposições de combate ao suborno da FCPA criminalizam:

- Oferecer, pagar, prometer pagar ou autorizar o pagamento corrupto ou de outro item de valor;
- De maneira direta ou indireta;
- A funcionário público estrangeiro, candidato a cargo político estrangeiro, funcionário de empresa pública multinacional ou partido político estrangeiro;
- Para influenciar ato ou decisão oficial, inclusive ato ou omissão que viole um dever oficial legal ou que assegure alguma vantagem indevida;
- Auxiliar na obtenção, retenção ou direcionamento de negócios para qualquer pessoa.

Um ponto relevante a se considerar é a definição de funcionário público para a FCPA. Segundo o resultado conjunto entre a SEC e o Departamento de Justiça em 2012 (*v.* item 3, a seguir), tal

definição é ampla e incluí oficiais ou empregados de um departamento, agência ou entidades estatais ou controladas pelo governo estrangeiro. Considerando o cenário brasileiro, tal definição aplica-se a todos os níveis, seja federal, estadual, municipal, bem como entidades parcialmente controladas pelo governo federal via bancos estatais ou agentes fomentadores da economia.

A proibição de suborno da FCPA contém uma exceção restrita para "facilitar ou agilizar pagamentos", também chamados de "pagamentos de facilitação", feitos em prol da rotina governamental. A exceção para os referidos tipos de pagamentos aplica-se somente quando um pagamento é feito para promover uma "ação governamental de rotina" que envolva um ato não discricionário. Exemplos de "ação governamental de rotina" incluem o processamento de vistos, fornecimento de proteção policial ou serviço de correio, fornecimento de serviços públicos como telefonia, energia e água.

A ação governamental de rotina não inclui a decisão de conceder novos negócios ou continuar negócios com uma determinada parte. Também não inclui atos que estejam a critério do funcionário ou que constituam uso indevido do cargo de um funcionário. Ou seja, decidir pagar uma quantia para um inspetor público para que o mesmo ignore o fato de a empresa não ter uma licença válida para operar a fábrica não seria um pagamento facilitador, mas sim corrupção.

As penas criminais pela violação da disposição anticorrupção são:

- Para indivíduos: (i) pena de até cinco anos de prisão; e/ou (ii) multa de até US$ 250.000,00;
- Para pessoas jurídicas: (i) multa de até US$ 2.000.000,00, ou até o dobro do valor da propina ou o ganho com a propina; e (ii) podem ainda ser impostas sanções não monetárias como obrigações de autodenúncia ou fiscalização/monitoramento.

As disposições de penas criminais pela violação dos livros e registros contábeis e controles internos são:

- Para indivíduos: (i) pena de até 20 anos de prisão; e/ou (ii) multa de até US$ 5 milhões;
- Para pessoas jurídicas: multa de até US$ 25 milhões.

As penas cíveis e medidas judiciais pela violação dos livros de registros contábeis e dos controles internos são:

- Pessoas físicas: (i) US$ 7.500,00 a US$ 160.000,00 dependendo da seriedade da violação; (ii) restituição (*disgorgement*) de valores auferidos de forma ilícita; e (iii) proibição de exercer função de membro de Conselho de Administração ou cargo de diretor de empresa estatal.
- Para pessoas jurídicas: (i) US$ 75.000,00 a US$ 775.000,00 dependendo da seriedade da violação; (ii) restituição (*disgorgement*) de valores auferidos de forma ilícita; e (iii) podem ainda ser impostas sanções não monetárias como obrigações de autodenúncia ou fiscalização/monitoramento.

Além das penas acima citadas, existem as consequências colaterais que indivíduos e empresas podem vir a sofrer por violarem as disposições da FCPA. Tais consequências incluem a suspensão ou proibição de contratar com o governo federal americano, revogação de certos privilégios concedidos pelo governo americano a empresa para exportação de seus produtos/serviços e não ter mais acesso aos programas dos bancos multilaterais de desenvolvimento.

Também pode ser considerado como um efeito colateral a indicação de um monitor para, durante um período determinado pelo Departamento de Justiça, que terá como função monitorar a aderência da empresa aos requisitos do acordo firmado com o referido Departamento, visando reduzir a recorrência da má-conduta da empresa. Importante frisar, que o monitor deverá ser independente e todos os custos referentes a implementação e operacionalização do monitoramento serão da empresa infratora.

O Departamento de Justiça poderá concordar em resolver um caso criminal contra empresa quer através de um *declination* ou, em caso apropriados, resolução negociada consubstanciada em um *plea agreement*, *deferred prosecution agreement* (DPA) ou *non-prosecution agreement* (NPA). Para indivíduos, a resolução negociada geralmente toma forma de um *plea agreement*, no qual está incluído

como será a cooperação desse individuo, ou através de um *non-prosecution agreement* (NPA). Quando a resolução negociada não é alcançada pela empresa ou por um indivíduo, o tema poderá avançar para um julgamento nas cortes americanas.

Por *plea agreement*, o réu geralmente admite os fatos que apoiam as acusações, admite a culpa e é condenado pelos crimes quando o acordo é apresentado e aceito por um tribunal. Já no DPA, o Departamento de Justiça entra com uma ação no tribunal, mas simultaneamente solicita que a acusação seja adiada, isto é, a mesma é adiada com o propósito de permitir que a empresa demonstre sua boa conduta. As DPAs geralmente exigem que um réu concorde em pagar uma multa financeira, coopere com o governo, admita os fatos relevantes e entre em certos compromissos de conformidade e remediação, incluindo potencialmente um monitor de conformidade corporativa.

Já por NPA, o DOJ mantém o direito de apresentar acusações, mas se abstém de fazê-lo para permitir que a empresa demonstre sua boa conduta durante o prazo do NPA. Ao contrário de um DPA, um NPA não é apresentado a um tribunal, mas é mantido pelas partes. Em circunstâncias em que um NPA está com uma empresa para delitos relacionados a FCPA, ele é disponibilizado ao público através do site do DOJ. Os requisitos de um NPA são semelhantes aos de um DPA e geralmente requerem cooperação contínua, admissão de fatos relevantes e compromissos de cumprimento e remediação, além do pagamento de uma multa monetária.

A SEC pode seguir pela resolução via DPA ou NPA, mas também existe a possibilidade de entrar com uma *civil injuction action*, por meio dessa ação cautelar, a SEC busca uma ordem judicial que obrigue o réu a obedecer à lei no futuro. Violar tal ordem pode resultar em processos de desrespeito civil ou criminal. As sanções por desacato civil, trazidas pela SEC, são de natureza reparatória e não punitiva e servem a um de dois propósitos: compensar a parte lesada como resultado da violação da liminar ou forçar o cumprimento dos termos da liminar.

3. Evolução

Em 2012, foi publicado o documento denominado de *A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act*[12], trabalho conjunto entre o Departamento de Justiça e SEC com o objetivo de fornecer ao público em geral informações detalhadas sobre a abordagem na aplicabilidade da FCPA, bem como serve como um guia a empresas de todas as formas e tamanhos - de pequenas empresas fazendo suas primeiras transações no exterior para corporações multinacionais com subsidiárias em todo o mundo.

Já no dia 10 de setembro de 2015, em um discurso da Procuradora Geral Sally Quillian Yates, proferido para os alunos da Universidade de Direito de Nova York, a seguinte frase foi proferida: “Crime é crime! Não importa se ocorre em uma esquina nas ruas ou em uma sala de diretoria”. [13]

Conjuntamente com o discurso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou o *Memorando Yates*[14], que reforçou o conceito da responsabilidade dos executivos envolvidos em atos inapropriados. Trata-se de uma mudança institucional na forma como o Departamento de Justiça investiga, acusa, processa e resolve os casos.

Agora, qual o motivo que levou o Departamento de Justiça a voltar o foco nos indivíduos? A resposta oficial que se encontra no referido discurso e memorando foi: “nós não podemos permitir que pessoas de carne e osso responsáveis por um ato inapropriado vão embora, deixando somente os empregados da companhia e seus acionistas para pagar o preço…. nada desencoraja mais uma atividade criminal corporativa que a perspectiva de pessoas irem para a prisão”.[15]

Sendo assim, dando continuidade à nova estratégia focada na responsabilidade das empresas e dos indivíduos (cumulativamente e não excludente), o Departamento de Justiça lançou, no dia 05/04/2016, o documento denominado *Foreign Corrupt Practices Act Enforcement Plan and Guidance*[16] (sendo o apelido mais amigável de “Programa Piloto”). Esse projeto foi destinado a incentivar as empresas, de forma proativa e voluntária, a informar crimes corporativos ao Departamento de Justiça, o que permitirá que o mesmo possa processar indivíduos cuja prática criminosa poderia nunca ter sido descoberta para a aplicação da lei.

O que será que aconteceu para o Departamento de Justiça agir dessa forma? Será que a postura desse departamento mudou? Ou simplesmente se trata de um realinhamento estratégico? Claramente podemos afirmar que o Departamento de Justiça não mudou, nem mesmo os princípios da FCPA.

Desde o lançamento desse marco jurídico em 1977, o mesmo já versava sobre a responsabilização dos executivos de corporações envolvidos em atos inapropriados.

A estratégica original do Departamento de Justiça era focar em penalidades nas grandes corporações. Na ocasião, acreditava-se que o bolso era a parte mais frágil de uma empresa. Totalmente de encontro com uma das missões do Departamento de Justiça, que é a proteção da economia americana.

Se uma empresa agisse de forma inapropriada causando danos à economia americana, mediante o pagamento de uma penalidade, a mesma iria "restaurar" o dano pelo transtorno causado. Acreditava-se que essa prática iria ser um inibidor eficaz do comportamento corporativo inapropriado.

A estratégia foi seguida e deu resultado por alguns anos, até que mais e mais empresas começaram a serem investigadas e penalizadas por comportamentos inapropriados. Em alguns casos, empresas foram penalizadas duas, três e até quatro vezes ao longo dos anos. Ou seja, houve um movimento de repetição de atos inapropriados por muitas empresas de diferentes mercados e em vários países. Um ciclo vicioso que não foi interrompido, mesmo com a aplicação de multas milionárias como, por exemplo, o caso Siemens – 2008.[17]

Então, o que mudou foi a estratégia do Departamento de Justiça de enfrentar os crimes corporativos. Foi uma tentativa de responder ao descontentamento da sociedade americana e mudar sua imagem perante a mesma.

Em 2 de fevereiro de 2017, a Seção de Fraudes do Departamento de Justiça publicou nova orientação sobre programas de conformidade: *Evaluation of Corporate Compliance Programs*[18]. A orientação, embora não seja inteiramente nova ou inovadora, é a declaração mais clara da Seção de Fraudes até a data referente às questões a qual considera avaliar a efetividade dos programas de conformidade corporativa. Particularmente, a orientação ocorre pouco mais de um ano após a Seção de Fraudes ter nomeado Hui Chen como advogada de conformidade dedicada no fim de 2015.

Entre suas funções designadas, Chen recebeu a tarefa de fornecer orientação para os procuradores da Seção de Fraudes e desenvolver marcos para a avaliação da efetividade da conformidade corporativa e medidas de remediação. Embora os tópicos destacados na referida orientação também apareçam em outras publicações de organizações do governo dos Estados Unidos e internacionais, o fato de serem realizadas através de questões específicas, fornece as empresas quais são as percepções das análises da Seção de Fraudes por trás das onze principais áreas de avaliação de conformidade e, portanto, servirá como uma ferramenta útil para o desenvolvimento e a implantação de programas de conformidade, assim como a avaliação de risco após uma violação.

4. Programas de Compliance/Conformidade

O Departamento de Justiça considera a existência e a efetividade de um programa de compliance ou de conformidade de uma empresa sujeita à FCPA para decidir se irá realizar uma investigação, fazer acusações ou negociar um acordo. Referidas decisões são tomadas de acordo com os *Principles of Federal Prosecution of Business Organizations*[19]. Estes princípios definem que o indiciamento por crimes corporativos é de alta prioridade para o Departamento de Justiça.

De acordo com o supramencionado documento, as corporações não devem ser tratadas lenientemente por causa de sua natureza artificial, nem devem estar sujeitas a um tratamento mais severo. A aplicação vigorosa das leis criminais contra os infratores corporativos, quando apropriada, resulta em grandes benefícios para a sociedade, particularmente na área de crimes de colarinho branco. Processar empresas por transgressão permite que o governo seja uma força para a mudança positiva da cultura corporativa e uma força para prevenir, descobrir e punir crimes graves.

Sendo assim, são definidas diretrizes a serem seguidas pelos promotores federais ao decidirem se devem ou não propor ações de natureza penal contra pessoas jurídicas. Ou seja, Departamento de Justiça irá levar em consideração:

- "a existência e eficácia do programa de compliance da empresa";
- "ações de remediação da empresa, incluindo todos os esforços para implementar um programa de compliance corporativo eficaz ou aprimorar um já existente, substituir uma gerência responsável, punir ou demitir infratores, pagar restituição e cooperar com as agências governamentais relevantes."

Isto significa que o programa de compliance poderá influenciar se as acusações formais devam ou não serem resolvidas através de um *deferred prosecution agreement* (DPA) ou por meio de um *non-prosecution agreement* (NPA), bem como que será a duração de cada um desses tipos de acordos e a existência ou não da aplicação de um monitoramento na empresa. O valor da multa a ser aplicada também leva em consideração o mencionado programa, assim como a cooperação da empresa e seus executivos durante todo o processo de investigação, acusação e negociação com o Departamento de Justiça (*v.* item 2, supra).

A questão sobre a efetividade dos programas de compliance é realmente importante e desafiador para as empresas e profissionais de compliance globalmente falando. O Departamento de Justiça levou muito a sério esse tema e sinalizou que não aceitaria mais programas do tipo *check in the box* ou programas existentes só no papel. Essa sinalização foi realizada através da contratação da expert Hui Chen para o setor de fraudes do Departamento de Justiça (*v.* item 3, supra).

Os supramencionados programas são aqueles que até possuem estrutura desenvolvida, mas, na grande maioria das vezes, não recebe o verdadeiro e explícito suporte da alta liderança. Ou, então, não possui independência – é apenas uma figura decorativa. Outra vezes, não possui sequer um orçamento digno para subsistir adequadamente. Infelizmente, ainda é possível encontrar grandes corporações internacionais que ainda acreditam que apenas a existência do programa é suficiente para "ajudar" a minimizar a situação perante o Departamento de Justiça. O que é uma total inverdade!

5. A Grande Interrogação

A última eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos foi realizada no dia 8 de 2016. Foi a 58ª eleição presidencial do país, a qual oficialmente elegeu Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Nessa ocasião, a Procuradora Geral do Departamento de Justiça era a Sally Yates. Antes mesmo de ser naturalmente substituída, uma vez que essa função depende de indicação presidencial e posterior aprovação pelo Senado, a mesma foi demitida do governo Trump por descumprir ordem executiva proibindo temporariamente a entrada de cidadãos de Iraque, Síria, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen.

Em julho de 2017, Hui Chen, que servia na seção de fraudes do departamento da divisão criminal como responsável por desenvolver marcos para a avaliação da efetividade da conformidade corporativa, solicitou sua renúncia antecipada. Isso devido a sua dificuldade em trabalhar para o braço máximo do governo federal quando o presidente domina as manchetes com o que ela descreve como possíveis conflitos de interesse e abusos de poder, algo que ala considera como inaceitável por parte de um CEO de uma empresa sob investigação federal.

Segundo Hui Chen, "sentar-se do outro lado da mesa e questionar o quanto eles (executivos) estavam comprometidos com a ética e a conformidade não só era hipócrita, mas muito parecida com o arrastar de cadeiras no Titanic. Mesmo enquanto eu me envolvia naqueles questionamentos e avaliações, em minha mente, foram as inúmeras ações pendentes contra o Presidente dos Estados Unidos, desde violações da Constituição até conflitos de interesse [...] e os investigadores e promotores foram demitidos por suas buscas de princípios e fatos". [20]

Contudo, apesar de em 2012, o presidente Trump ter chamado a FCPA de ridícula e de *lei horrível* por dificultar as empresas americanas no exterior, aparentemente sua administração continuou a aplicar as disposições da FCPA em níveis comparados com a administração anterior de Barak Obama[21].

Em maio de 2018, foi anunciada nova política interna do Departamento de Justiça destinada a coordenar-se com outros órgãos de fiscalização para evitar a imposição de múltiplas penalidades pela mesma conduta – *Anti-Piling On Policy*. O Procurador Geral Adjunto do Departamento de Justiça, Rod Rosenstein, observou que o "objetivo da nova política é melhorar as relações com nossos parceiros de aplicação da lei nos Estados Unidos e no exterior, evitando penalidades duplicadas injustas".[22]

Especificamente, a nova política exige que os advogados do Departamento de Justiça "coordenem uns com os outros, com o objetivo de evitar a imposição desnecessária de multas duplicadas, penalidades e/ou caducidade contra a empresa"[23], e instrui ainda o pessoal do DOJ a "esforçar-se, conforme apropriado, para considerar o valor das multas, penalidades e/ou caducidade pagas ao governo federal, estadual, autoridades policiais locais ou estrangeiras que estão tentando resolver um caso com uma empresa pela mesma má conduta".[24]

Conclusão

É inegável a importância da FCPA no combate a corrupção e sua influência em outros ordenamentos jurídicos internacionais. A corrupção sempre existiu, desde que o mundo é mundo, mas pela primeira vez, uma lei reconheceu o quão danoso é a corrupção para a sociedade em geral e como a mesma pode vir a deturpar a livre concorrência entre empresas.

Afirmativamente, a FCPA é o começo de tudo para quem acredita que um mundo sem corrupção é um mundo melhor. A corrupção mata, gera desemprego, caos social e econômico. Consequentemente, deve ser combativa por toda a sociedade mundial, cabendo a cada um de nós o dever de fiscalizar e denunciar. Esse é o legado de todos para o futuro.

A esperança que, lá na frente, o termo corrupção seja algo difícil de ser compreendido pelas futuras gerações e que as mesmas tenham que buscar em um dicionário o significado dessa nociva palavra.

Referências Bibliográficas

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission. *A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act.* Disponível em <https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance>. Acesso em 20 nov. 2018.

_____. Criminal Division of U.S. Department of Justice. Fraud Section. *Evaluation of Corporate Compliance Programs*. Disponível em <https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download>. Acesso em 20 nov. 2018.

_____. U.S. Department of Justice. *Deputy Attorney General Sally Quillian Yates Delivers Remarks at New York University School of Law Announcing New Policy on Individual Liability in Matters of Corporate Wrongdoing*. Disponível em <https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-sally-quillian-yates-delivers-remarks-new-york-university-school>. Acesso em 20 nov. 2018.

_____. U.S. Department of Justice. Individual Accountability for Corporate Wrongdoing. Memorandum Yates. Disponível em <https://www.justice.gov/archives/dag/individual-accountability>. Acesso em 20 nov. 2018.

_____. U.S. Department of Justice. *Principles of Federal Prosecution of Business Organizations*. Disponível em <https://www.justice.gov/jm/jm-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations>. Acesso em 20 nov. 2018.

_____. U.S. Department of Justice. *The Fraud Section's Foreign Corrupt Practices Act Enforcement Plan and Guidance*. Disponível em <https://www.justice.gov/archives/opa/blog-entry/file/838386/download>. Acesso em 20 nov. 2018.

_____. U.S. Department of Justice. *United States v. Siemens court docket number: 08-cr-367-rjl.* Disponível em <https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-siemens-aktiengesellschaft-court-docket-number-08-cr-367-rjl>. Acesso em 20 nov. 2018.

_____. U.S. Securities and Exchange Commission. *Report of the Securities and Exchange Commission on questionable and illegal corporate payments and practices*. Submitted to the Committee on Banking, Housing and Urban Affairs of United States Senate, mai. 1976. Disponível em <https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/sec-report-questionable-illegal-corporate-payments-practices-1976.pdf>. Acesso em 20 nov. 2018.

_____. U.S. Securities and Exchange Commission. *What we do. Creation of the SEC*. Disponível em < https://www.sec.gov/Article/whatwedo.html#create>. Acesso em 20 nov. 2018.

_____. U.S. Senate. *Domestic and Foreign Investment Improved Disclosure Acts of 1977*. Report of the Committee on Banking, Housing and Urban Affairs of United States Senate, 2 may 1977. Disponível em <https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2010/04/11/senaterpt-95-114.pdf>. Acesso em 20 nov. 2018.

HISTORY.COM. Watergate Scandal. Disponível em <https://www.history.com/topics/1970s/watergate>. Acesso em 20 nov. 2018.

JARRETT, Laura. *Justice Department anti-fraud expert resigns, disturbed by Trump's 'stunning' conduct.* CNN Politics, 4 jul. 2017. Disponível em <https://edition.cnn.com/2017/07/04/politics/justice-hui-chen-resignation/index.html>. Acesso em 20 nov. 2018.

GRAHAM, Victoria. *Anti-Bribery Enforcement Remains Steady Under Trump*. Bloomberg BNA. The Bureau of National Affairs, 20 jun. 2018. Disponível em <https://www.bna.com/antibribery-enforcement-remains-n73014476694/>. Acesso em 20 nov. 2018.

KARP, Brad S. The DOJ's New "Piling On". *Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation Policy*, 23 fev. 2019. Disponível em <https://corpgov.law.harvard.edu/2018/05/24/the-dojs-new-piling-on-policy/>. Acesso em 24 fev. 2019.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*. Disponível em <http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.html>. Acesso em 20 nov. 2018.

REINO UNIDO. *Bribery Act 2010*. Disponível em <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents>. Acesso em 20 nov. 2018.

SEITZINGER, Michael V. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): *Congressional Interest and Executive Enforcement, In Brief*. Disponível em <https://fas.org/sgp/crs/misc/R41466.pdf>. Acesso em 20 nov. 2018.

WIKIPEDIA. *Erie War.* Disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/Erie_War>. Acesso em 20 nov. 2018.

Capítulo 2

Responsabilização de Empresas no Cenário Internacional
Um Sistema Global

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha[25]

Introdução

A consciência ética da sociedade pós-moderna passa por mudanças estimáveis. A globalização, o acesso à informação e o desenvolvimento tecnológico, que foram grandes fomentadores da corrupção, se tornaram aliados a um processo de mudança comportamental pautado na conduta ética e íntegra.

O termo corrupção, etimologicamente derivado do latim *corrumpere*, significa decompor, quebrar em pedaços. Na antiguidade clássica, foi utilizado por Platão e Aristóteles para representar o caminho natural que todos os corpos físicos percorrem, da geração ao seu desfazimento. Por exemplo, todo ser vivo que nasce, cresce e morre, durante a sua existência é afetado pelo processo da corrupção da matéria. Aristóteles o importou para a sociedade.

Já a expressão integridade, do latim *integritate*, significa inteireza, e também pode se materializar na questão física ou moral. A integridade física está ligada à preservação de bens e indivíduos em suas estruturas corpóreas, já a integridade moral se relaciona à personalidade ou valores, se correlacionando com temas da honra, moral e da própria ética. Podemos dizer assim que corrupção e integridade são, então, antônimos ou opostos.

De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos que, em última análise, influenciam os resultados da administração de uma empresa ou entidade, e não apenas seus processos. A organização compreende como sistema de integridade o conjunto de arranjos institucionais, gerenciamento, controle e regulamentações. Nesse sentido, a gestão da integridade refere-se às atividades empreendidas para estimular e reforçar o tema (ou valor), e também para prevenir a corrupção e outros desvios dentro de uma determinada organização.

De forma inegável, o maior fomentador da corrupção na sociedade é a impunidade. O sentimento de que cometer atos ilícitos, desfavoráveis aos interesses coletivos, para a satisfação de interesses pessoais, geralmente com relevância financeira, se torna cada vez maior caso o sujeito não se sinta monitorado, mas principalmente, se não vê de muito perto o risco de sofrer sanções pela prática de seus atos.[26]

O objetivo deste estudo é demonstrar uma evolução de orientações e normas internacionais de combate à corrupção, que influenciaram o Brasil a se tornar um país com um dos mais rigorosos sistemas legais de prevenção e combate à corrupção, não apenas pela punição de pessoas físicas e jurídicas, mas especialmente por meio da disseminação da prevenção advinda da cultura de *Compliance* ou de Integridade.

1. Corrupção Globalizada

A prática de atos de corrupção é antiga na história da humanidade, no entanto, para a conduta, se impõe como fator essencial um ambiente propício e fértil. Assim como a vegetação seca é favorável ao fogo, pela teoria triangular da fraude, a corrupção precisa de combustíveis, como a pressão, oportunidade e racionalização.[27]

A pressão externa é aquela capaz de alterar a essência da pessoa ao ponto de se impor como elemento mais intenso que culmina na prática do ilícito. A falta de controles deixa com que as vulnerabilidades sejam o fomentador de atos de corrupção de qualquer proporção. Mas a racionalização é o fator mais preocupante, certo que a prática do ato se justifica pela busca racional de sustentáculos, em sua maioria infundados, (*v.g.,* “todo munda faz”; “essa é a regra do jogo”; “se eu não fizer, alguém vai fazer”; entre outras).

Para se ter uma ideia da gravidade da situação, por muito tempo, empresas multinacionais se preocuparam por não praticar corrupção em seus países de origem, todavia, caso filiais ou subsidiárias estivessem em países subdesenvolvidos, a prática era aceitada e fomentada por seus países de

origem, inclusive para fins de deduções fiscais. Para Lucas Furtado a "questão era apresentada no sentido de que o pagamento de comissões era considerado uma etapa necessária à obtenção de contratos ou de concessões nestes países, de que fazia parte das regras do jogo, e que, nessa condição, seria normal ou natural que essas despesas pudessem ser deduzidas dos impostos a serem pagos pelas empresas sedes".[28]

Diante de uma sociedade global capitalista, nada mais favorável para a corrupção, senão o fomento da prática de atos ilícitos internacionais em países subdesenvolvidos, racionalizada como conduta necessária na conquista de mercados. Ainda mais se agraciado com a dedução tributária sobre o lucro, em relação aos valores pagos de propina inseridos.

Mas as investigações do FBI e do Senado Americano sobre o Caso Watergate, que não se limitaram à descoberta do envolvimento do presidente Nixon no arrombamento no escritório do Partido Democrata e na iniciativa de espionagem do Partido Republicano, trouxeram à tona uma série de doações corporativas para fins políticos, as quais revelaram um grande esquema de pagamentos indevidos a funcionários públicos estrangeiros como uma prática muito comum em países subdesenvolvidos, com o objetivo de garantir mercado, não somente por empresas americanas, que, no entanto, se revelou um verdadeiro choque à população americana.

Mais de 400 empresas admitiram pagamentos questionáveis ou ilegais que somaram cerca de US$ 300 milhões para autoridades governamentais estrangeiras, políticos e partidos políticos. Neste rol estavam algumas das maiores empresas públicas dos Estados Unidos e 117 delas figuravam na lista das principais empresas da Fortune 500.[29]

1.1. FCPA: Primado Americano

O pagamento de suborno a agentes públicos, no território americano, sempre foi combatido com veemência. Mas a corrupção deliberada destinada a funcionários públicos de países subdesenvolvidos, com o objetivo estritamente de expansão de negócios e majoração dos lucros, somada ao processo de *impeachment* e a primeira renúncia presidencial na história dos EUA, trouxeram indignação à opinião pública. Em resposta ao clamor social, o Congresso aprovou em 1977 a *Foreign Corrupt Practies Act* (FCPA) a fim de mitigar os casos de suborno transnacional de agentes públicos. Assim, o objetivo final seria reestabelecer a confiança da sociedade na forma com que as empresas norte-americanas realizavam seus negócios fora do país.

A norma tornou ilegal a oferta ou consumação de pagamentos em dinheiro ou de qualquer vantagem indevida, a funcionários de governos, partidos políticos ou candidatos a cargos políticos estrangeiros em troca de vantagens, não só comerciais, mas também econômicas, realizados com o intuito de obter ou manter negócios.

Ademais, não se limitou a empresas com sede nos EUA ou sujeitas a sua legislação (*domestic concerns*), mas também àquelas que negociam ações nas bolsas de valores americanas (*issuers*) e que pratiquem atos de corrupção no território dos EUA (*foreign nationals and entities*). Nesta última hipótese, advinda por uma a reforma de 1988, o ato não necessariamente precisa ser praticado no país, mas por simples "passagem" (*v.g.* uma quantia paga por suborno em transação financeira por intermédio de instituição financeira sediada nos EUA, troca de e-mails em que se negocia propina por um servidor localizado no espaço americano, etc.).

A iniciativa norte-americana de impor sanções a empresas que pagam suborno em países estrangeiros se apresentou como algo inovador, pois, ao contrário dos regulamentos comuns que concentram sanções ao servidor público corrupto ou à pessoa física corruptora, prevê a punição para o principal beneficiário econômico dos esquemas de pagamento de propina no exterior e verdadeiro financiador dessas condutas ilícitas: as pessoas jurídicas. Ademais, impor tais consequências às empresas corruptoras trouxe maior competitividade aos mercados, porque, com o comum pagamento de propina para a reserva de mercado em países subdesenvolvidos, certamente quem paga mais tem maior vantagem, e não aquelas empresas que tem o melhor preço conjugado com a melhor qualidade.

Mais de três décadas depois, sanções por violações da FCPA têm ocorrido com frequência e cada vez mais está atraindo a atenção da comunidade internacional. Apenas de 2008 a 2005, DOJ e SEC processaram mais de 100 empresas em ações de execução relacionadas ao descumprimento da lei e as multas ultrapassaram US$ 5,2 bilhões.[30]

Diversas empresas brasileiras estão incluídas neste rol de investigadas e processadas pelo DOJ e pela SEC. Em 2016 a Embraer firmou um acordo (*Deferred Prosecution Agreement*) no valor de US$ 206 milhões. No mesmo ano, como desdobramento da operação Lava Jato, Odebrecht e Braskem

acordaram pagar US$ 419,8 milhões, mas em abril de 2017, devido a redução do faturamento da Odebrecht, o valor de sua multa foi reduzido de US$ 260 milhões para US$ 93 milhões (*ability to pay principle*). O destaque fica a Petrobras, que até o momento é a multa acordada que atingiu o patamar mais elevado, US$ 1,78 bilhões.

1.2. Perda de Competitividade das Empresas Americanas

Em decorrente dessa aplicabilidade restrita, as empresas sujeitas à FCPA sofreram desvantagens comerciais nos mercados emergentes pois, ao respeitarem as regras de livre concorrência, abriram caminho para aquelas que não respeitavam, por não estarem sujeitas à norma antissuborno. "No final dos anos 1990, poucos países criminalizavam o pagamento de propina a agentes públicos por suas empresas. Na França e na Alemanha, tal prática era disseminada e podia, inclusive, ser oficialmente lançada nos livros e deduzida do imposto de renda".[31]

Dessa forma, o impacto financeiro foi evidente e os acionistas das empresas americanas prejudicadas passaram a amargar prejuízos. A partir daí, buscaram suas reivindicações perante o governo dos EUA. Ressalta Alessandra Gonsales que "isso colocava as empresas norte-americanas, regidas pelas FCPA, em franca desvantagem nas competições com empresas de outros países – principalmente as europeias – na hora de brigar por contratos governamentais fora do primeiro mundo. E, os acionistas das empresas norte-americanas estavam sendo prejudicados, porque as regras de livre concorrência estavam, de fato, sendo violadas".[32]

A bem da verdade, é preciso esclarecer que a comunidade internacional jamais havia se interessado em debater o pagamento de suborno a agente públicos de países subdesenvolvidos. Na realidade, os altos índices de corrupção na América Latina, África e Ásia eram de evidente conhecimento, mas tal prática inefável chegou a ser até mesmo fomentada de diversas razões políticas, econômicas e sociais. Para Furtado, "outro obstáculo à adoção de posturas mais efetivas no plano internacional para combater a corrupção estava relacionado à visão até então dominante de que as tentativas de controlá-la não poderiam estar relacionadas ao comércio internacional e, portanto, às organizações internacionais que zelavam pelas finanças e economias internacionais. Entendia-se a corrupção como um problema não econômico e se concluía pela impossibilidade de organizações internacionais relacionadas ao financiamento internacional e de forte atuação na área econômica interferirem".[33]

Em que pese a desvantagem econômica das empresas americanas frente à concorrência internacional de empresas de países desenvolvidos que persistiram na corrupção a agentes públicos de países subdesenvolvidos, desde a edição da FCPA até o início da década de 1990 não havia interesse de organismos internacionais no combate à corrupção internacional. O próprio governo dos Estados Unidos, durante vários anos, se valeu da facilidade e frequência com que as empresas corrompiam autoridades e pessoas influentes em países subdesenvolvidos, com finalidades políticas e estratégicas, em especial durante a Guerra Fria contra a União Soviética. A falta de transparência nos países sob o domínio de regimes ditatoriais ocultava a percepção da corrupção aos olhos dos organismos internacionais.

A democratização vivida em diversos países ao final da década de 1980, somado ao fato de maior transparência e crescente evolução dos meios de comunicação, deixaram expostas a feridas da corrupção, especialmente em países subdesenvolvidos, e assim, fomentaram a mudança do cenário internacional. Importante frisar também que países em desenvolvimento se mostraram excelentes peças de investimentos em razão dos mercados promissores, mas os índices alarmantes de corrupção colocavam em risco os investimentos. Destaca-se que "no início da década de 1990, foi divulgado pela Secretaria de Comércio (US Departamento of Commerce), do Governo Clinton, um instrumento sobre "os grandes mercados emergentes" e sobre os setores mais atrativos para a realização de investimentos internacionais. De acordo com esse informe, Argentina, Brasil, México, Singapura, Indonésia, China, Índia, Turquia apresentavam perspectivas de investimento na área de estrutura da ordem de aproximadamente 2 trilhões de dólares".[34]

Dessa forma, denota-se que a corrupção é um acontecimento mundial que não se restringe a determinados países, culturas ou períodos históricos. Contudo, importante ressaltar que diferenças significativas entre os povos e suas realidades fazem que que a magnitude, ocorrência e consequências da corrupção se evidenciem mais ou menos.

O poderio econômico das empresas americanas e a capacidade de mobilização dos EUA, como financiadores dos principais organismos internacionais (*v.g.,* OEA, OCDE e ONU), trouxeram a

imposição de disseminar pelo mundo os ideais da FCPA, a fim de obrigar companhias não sujeitas à jurisdição americana, a não praticarem suborno em países subdesenvolvidos, estimulando a livre concorrência no mercado internacional.

2. Instrumentos Internacionais Anticorrupção

As pressões do Governo dos Estados Unidos, impulsionado pelas empresas americanas prejudicadas pela rigidez da FCPA que as atingia, mas que não punia concorrentes que persistiam na prática, somado ao fato da maior percepção da corrupção em patamar internacional diante da globalização, organismos internacionais passaram a tratar com prioridade o tema, que culminou na redação de diversas convenções internacionais de combate e prevenção à corrupção.

Algumas dessas convenções são de âmbito regional, *v.g. Convenção Interamericana contra Corrupção*, adotada em 1996 pela Organização dos Estados Americanos (OEA), *Convenção do Conselho da Europa*, consolidada em 1997 pelo Conselho Europeu e *Convenção da União Africana*, assinada em 2003. Outros acordos internacionais receberam patamar global, *v.g. Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais*, adotada em 1997 no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e *Convenção das Nações Unidas contra Corrupção*, desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2003.

Além dessas, outras medidas também são relevantes para a internacionalização do combate à corrupção como o *Código de Boas Práticas de Transparência em Políticas Monetárias,* aprovado em 1999 pelo Banco Mundial, o *Acordo Plurilateral sobre Contratação Pública*, firmado em 1996 pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e a *Declaração de Arush sobre Cooperação e Integridade Aduaneira* aprovado pela Organização Mundial de Aduanas, no ano de 1993.

Contudo, a celebração de acordos internacionais, apenas, não será suficiente para enfrentar a corrupção que se entranha na história da humanidade e que se mostra em crescimento exponencial, especialmente nas últimas décadas, em razão da ganância financeira e de poder das instituições e pela falta de mecanismos de transparência e controle.

Mas inegável é a importância da criação de padrões internacionais de mecanismos para a luta contra corrupção, principalmente por meio da assistência e da cooperação. Ademais, definem princípios e programas ambiciosos para a evolução institucional e legal nos países signatários, criando um padrão mínimo de referência para a estruturação de sistemas de integridade.

Como observa Furtado, “não é possível afirmar que nos dias atuais os níveis de corrupção sejam menos reduzidos que no passado. É possível afirmar, no entanto, que jamais se despendeu tanto esforço em seu combate e que nunca se apresentou um cenário internacional tão favorável à adoção de políticas de combate à corrupção quanto as que temos assistido nos dias atuais”.[35]

O que se viu a partir desse movimento é que a corrupção passou a ser um problema internacional. Assim, nota-se uma maior predisposição de países desenvolvidos, com suas estruturas internas anticorrupção, em compartilhar experiências e cooperar com os menos desenvolvidos, em que o enfrentamento à corrupção não eram prioridade.

2.1. Convenção Interamericana contra a Corrupção (OEA/ 1996)

A Organização dos Estados Americanos é uma organização internacional fundada em 1948, composta hoje por 35 países[36] do continente americano e criada com o objetivo de alcançar “uma ordem de paz e de justiça, para promover sua solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua soberania, sua integridade territorial e sua independência[37]”, como disposto no artigo 1º, da Carta da OEA, firmada em 1948 em Bogotá - Colômbia.

A referida carta dispõe em seu preâmbulo que a “democracia representativa é condição indispensável para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento da região”.[38] Assim, cada vez mais os Estados membros se tornaram perceptivos no fato de que a corrupção constitui uma das ameaças mais graves aos sistemas democráticos.

Tal reconhecimento fez com que diversos instrumentos da organização se voltem ao enfrentamento da corrupção, *v.g. Compromisso de Santiago com a Democracia e a Renovação do Sistema Interamericano* (1991); a *Resolução n. 1159 da Assembleia Geral da OEA* (1992); o texto

Práticas corruptas no comércio internacional (1993); a *Declaração de Manágua para a Promoção da Democracia e o Desenvolvimento* (1993); a *Declaração de San José sobre Direitos Humanos* (1993); e a *Declaração de Belém do Pará* (1994).

No entanto, o marco do tratamento aprofundado no combate e prevenção à corrupção se deu no *Processo de Cúpulas de Chefes de Estado e de Governo das Américas*. Logo primeira cúpula (Miami, dezembro de 1994), os Chefes de Estado e de Governo reconheceram o caráter internacional e globalizado da corrupção e a partir daí firmaram o compromisso de negociar um acordo interamericano sobre a questão.

Como resultado evolutivo, após um amplo processo de análise e deliberações, em março de 1996 os países membros aprovaram em Caracas-Venezuela a *Convenção Interamericana contra a Corrupção*, o primeiro tratado internacional de repressão ao tema, em que consta do seu preâmbulo: "Convencidos da necessidade de adotar o quanto antes um instrumento internacional que promova e facilite a cooperação internacional para combater a corrupção e, de modo especial, para tomar as medidas adequadas contra as pessoas que cometam atos de corrupção no exercício das funções públicas ou especificamente vinculados a esse exercício, bem como a respeito dos bens que sejam fruto desses atos".[39]

A Convenção da OEA é composta de vinte e oito artigos, sendo que são quatro os principais temas tratados: medidas preventivas; atos de corrupção; suborno transnacional e enriquecimento ilícito; e cooperação e assistência técnica. Os propósitos são: "promover e fortalecer o desenvolvimento dos mecanismos necessários para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção. Promover, facilitar e regular a cooperação entre os Estados a fim de assegurar a eficácia das medidas e ações para prevenir, detectar, punir e erradicar os atos de corrupção no exercício das funções públicas e os atos de corrupção especificamente vinculados a seu exercício".[40]

Dessa forma, a Convenção da OEA definiu, especialmente em seu artigo 3º, medidas sobre a prevenção como uma das formas de combate à corrupção, subdividindo-se em doze conjuntos de políticas anticorrupção, a serem adotadas pelos países membros. Entre essas medidas, destaca-se o "requerimento de criação, manutenção e fortalecimento das normas de conduta para o adequado e correto desempenho das funções públicas; das instruções ao pessoal dos órgãos públicos a fim de garantir o adequado entendimento de suas responsabilidades e das normas éticas que regem as suas atividades; dos sistemas para proteger funcionários públicos que denunciarem, de boa-fé, atos de corrupção, inclusive a proteção de sua identidade; e dos mecanismos para estimular a participação da sociedade civil e de organizações não-governamentais nos esforços de prevenção da corrupção".[41]

Define, no artigo V, a necessidade de que cada Estado membro estabeleça em sua jurisdição a tipificação dos delitos ligados aos atos de corrupção (previstos no artigo VI), quando o delito for cometido em seu território, por cidadãos ou pessoas com residência habitual em seu território, sem isentar a aplicação da lei penal de cada país. Estabelece também mecanismos para a extradição de pessoas por delitos de corrupção; para a cooperação e assistência entre os Estados com vistas à obtenção de provas e à realização de outros atos que facilitem os processos e ações referentes à investigação ou julgamento de atos de corrupção; e para a identificação, o rastreamento, a imobilização, o confisco e a apreensão de bens obtidos ou derivados do cometimento de delitos de corrupção, dos bens utilizados nesse cometimento ou do produto desses bens.

Por fim, a Convenção da OEA possui o *Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana Contra a Corrupção* (MESICIC) responsável pela análise técnica da implementação da Convenção, além de melhorar a cooperação técnica de atividades nos Estados Partes.

2.2. Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (OCDE/ 1997)

Em 1948, período pós 2ª Guerra Mundial, com o objetivo de gerir o *Plano Marshall* e reconstruir os países aliados dos EUA na Europa, fundou-se a Organização Europeia para o Desenvolvimento Econômico (OECE), que sob a regência da França, contava com 16 países membros. Já em 1961, sua filiação foi estendida a outros países, dentre eles não europeus, como Estados Unidos e Canadá, dando origem à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Também chamado de "Grupo dos Ricos" é composta por 34 países, na sua maioria descritos como economias

de renda média-alta na Banco Mundial, produzindo sozinhos mais da metade do Produto Interno Bruto do mundo.

É pautada nos princípios da democracia representativa e da economia livre de mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas internas dos países-membros e internacionais, também. Tem por principais objetivos apoiar um crescimento econômico duradouro, desenvolver o emprego, aumentar o nível de vida e manter a estabilidade financeira nos países-membros, além de ajudar os outros Estados a desenvolverem as suas economias e contribuir para o crescimento do comércio mundial.

Dessa forma, como a partir de 1990, as consequências da corrupção na condução de negócios internacionais passaram a chamar a atenção da comunidade internacional, e seu o combate subsidiou a concepção da *Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais*, datada de 1997. Mas o trabalho na OCDE teve início anteriormente. "O suborno de funcionários públicos estrangeiros foi um tema inicialmente tratado pelo Grupo de Trabalho da OCDE sobre Suborno em Transações Comerciais Internacionais. O trabalho desse Grupo resultou, em 1994, no primeiro acordo multilateral relacionado ao combate do suborno de servidores estrangeiros, que foi firmado em 1997 pelos membros da OCDE, aos quais se somaram outros países como o Brasil, Argentina e Chile, tendo entrado em vigor em 1999".[42]

O texto ganhou rapidamente repercussão internacional, primeiramente porque foi o primeiro instrumento com o intuito de combater a corrupção de âmbito mundial. No entanto, algo mais chamou atenção, o fato de que o objetivo da convenção é atingir não o lado o corrupto, mas sim do corruptor, de que paga o suborno.

Aborda como aspectos chave a definição de suborno, a criminalização da corrupção ativa, orientações para a sanção de corruptores. Também estabelece a fixação de regras para a assistência judicial e legal nos países signatários e de parâmetros para sistemas de contabilidade e auditoria, com o monitoramento para a implementação das medidas.

Por fim, define a proibição de lançamento contábil do pagamento de propina, para a fins de dedução tributária. O principal item da Convenção da OCDE está relacionado à tipicidade da conduta indicada no art. 1 do texto, de "oferecer, prometer e dar qualquer vantagem pecuniária indevida ou de outra natureza, seja diretamente ou por intermediários, a um funcionário público estrangeiro, para esse funcionário ou para terceiros, causando a ação ou a omissão do funcionário no desempenho de suas funções oficiais, com a finalidade de realizar ou dificultar transações ou obter outra vantagem ilícita na condução de negócios internacionais", a qual é denominada pela própria Convenção como crime de "corrupção de funcionário público estrangeiro.[43]

Um dos principais trabalhos desempenhados pela OCDE após a vigência de sua convenção contra a corrupção é o auxílio na estruturação legislativa dos Estados signatários, para a criação e melhoria de medidas voltadas à prevenção e combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros, no contexto do comércio internacional, e por consequência no seu próprio cenário interno.

Desta forma, a Convenção determina que "os Estados signatários criminalizem o oferecimento, a promessa ou concessão de vantagem indevida, pecuniária ou de qualquer outra natureza, a funcionário público estrangeiro que, direta ou indiretamente, por meio de ação ou omissão no desempenho de suas funções públicas, realize ou dificulte transações na condução de negócios internacionais".[44]

Outro viés de atuação advém do monitoramento das atividades de diversos setores (público, privado, terceiro setor, etc.) quanto ao cumprimento das normas estruturadas. Tais frentes são objeto de análises de um Grupo de Trabalho sobre Suborno, que ao final de cada uma delas emite um relatório em que indicadas as observações avaliadas, firmando também recomendações a serem adotadas pelos países analisados.

Ademais, outro ponto que merece destaque na Convenção da OCDE é o disposto no seu artigo 2: "Cada Parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento das responsabilidades de pessoas jurídicas pela corrupção de funcionário público estrangeiro, de acordo com seus princípios jurídicos".[45] Com o referido dispositivo a OCDE orientou aos Estados-partes a adotarem medidas de punição de pessoas jurídicas que pagassem suborno a agentes públicos, nos moldes da Lei Anticorrupção americana, a FCPA.

2.3. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (ONU/ 2003)

A Organização das Nações Unidas é formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais. Sua origem nos remete a 1945, período pós 2ª Guerra Mundial, com a união de 51 países, quando recebeu o nome de Liga das Nações, tendo com um objetivo principal promover a paz, a fim de evitar outro conflito catastrófico como aquele.

Após o processo global de descolonização na década de 1960, a entidade abriu suas portas e fez crescer em muito o número de integrantes, contando hoje com 193 países membros. Nos anos 70 voltou seus olhos para programas de desenvolvimento social e econômico, que ultrapassaram o intuito inicial de manutenção da paz mundial, que, no entanto, não foi abananado, certo que com o fim da Guerra Fria, assumiu as principais missões militares e de paz no mundo.

Seis órgão principais compõe a ONU: a Assembleia Geral (deliberativa principal); o Conselho de Segurança (decide determinadas resoluções de paz e segurança); o Conselho Econômico e Social (auxilia na promoção da cooperação econômica e social internacional e desenvolvimento); o Conselho de Direitos Humanos (promove e fiscaliza a proteção dos direitos humanos e propõe tratados internacionais sobre esse tema); o Secretariado (fornece estudos, informações e facilidades necessárias para a ONU), e o Tribunal Internacional de Justiça (órgão judicial principal). Há também os órgãos complementares de todas as outras agências como a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Programa Alimentar Mundial (PAM) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Em relação ao combate à corrupção internacional, no ano 2000, após a 81ª Plenária da Assembleia-Geral das Nações Unidas, a organização distinguiu, a exemplo de outros organismos internacionais precursores (OEA e OCDE, por exemplo) a relevância de desenvolver um instrumento jurídico internacional voltado aos seus membros, para direcioná-los no combate e prevenção à corrupção.

Assim, estabeleceu um Comitê *ad hoc*, aberto a todos os Estados, com a tarefa de elaborar o documento que ficou conhecido como Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida). “O texto do instrumento jurídico mencionado deveria considerar a criminalização de todas as formas de corrupção, cooperação internacional, aspectos regulamentares da corrupção e sua relação com a lavagem de dinheiro. De acordo com essa Resolução, foi solicitado ao Secretário-Geral que convocasse um Grupo Intergovernamental de Peritos que examinaria e prepararia uma minuta dos termos de referência para negociação posterior do instrumento. O texto da Convenção das Nações Unidas contra Corrupção foi negociado em sete sessões do Comitê, entre os dias 21 de janeiro de 2002 e 1º de outubro de 2003. O texto aprovado pelo Comitê foi adotado pela Assembleia-Geral da ONU pela Resolução 58/4, de 31 de outubro de 2003”.[46]

Dessa forma, o enfoque da Convenção, conforme seu artigo I, é “promover e fortalecer medidas voltadas para prevenir e combater de forma mais eficaz e eficiente a corrupção; promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência técnica anticorrupção, incluída a recuperação de ativos; bem como promover a integridade, a obrigação de prestar contas e a devida gestão dos assuntos e dos bens públicos”.[47]

Os mais variados temas sobre as citadas finalidades da Convenção forma tratados, como políticas e práticas de prevenção da corrupção; estruturação de órgãos voltados para a integridade; medidas de prevenção da corrupção para gestão no setor público; códigos de conduta para funcionários públicos; contratação pública e gestão da fazenda pública; medidas para promoção da transparência; medidas para assegurar a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público; medidas de prevenção da corrupção no setor privado; fomento do controle social; e medidas para prevenir a lavagem de dinheiro.

Dessa forma, um tema que merece destaque no referido instrumento de pacto internacional são as diversas formas de se prevenir os atos de corrupção, evitando assim que aconteçam, trazendo danos, às vezes, irreparáveis ao Estado e à coletividade. “O primeiro grande tema abordado pela Convenção é a prevenção da corrupção. É, de fato, muito importante que este acordo tenha dado tanta ênfase às medidas preventivas, pois reforça a indispensabilidade da luta contra a corrupção também, e especialmente, pela prevenção. Neste sentido, o segundo capítulo da Convenção foi inteiramente dedicado a este tema. Além das medidas preventivas amplamente conhecidas, a Convenção trouxe algumas novidades no que diz respeito às maneiras de prevenir a corrupção, tal como o artigo que trata especificamente de medidas para evitar atos de corrupção no setor privado”.[48]

No artigo 12 da Convenção estão contempladas uma série de medidas a serem adotadas pelos membros em suas normativas internas, voltadas para o setor privado. No item I define a necessidade

de “melhoria nas normas contábeis e de auditoria, com previsão das respectivas sanções civis, administrativas e penais em caso de descumprimento”.[49]

Nos itens 2 e 3 do referido dispositivo, fomenta “a cooperação entre órgãos públicos e privados voltados ao combate da corrupção; a promoção da transparência nas empresas; a estruturação de mecanismos de prevenção de ilícitos na concessão, pelo Estado, de subsídios e licenças, ao setor privado; e a criação de normas e procedimento de prevenção de conflito de interesses em relação a funcionários e ex-funcionários públicos”. [50]

Nestes tópicos, promove a criação de normas e procedimentos que favoreçam a disseminação do *Compliance* às empresas, com instrumentos como código de condutas, política de boas práticas na interação com o Estado e registros contábeis reais e eficientes. Assim, tem-se que a Convenção da ONU contra a Corrupção é o mais importante instrumento jurídico internacional de prevenção e combate à corrupção, influenciando diretamente a criação de normas nos países signatários voltadas para o tem, em especial leis similares à FCPA, americana.

Conclusão

A corrupção tornou-se uma mazela recorrente em todo o mundo e sua percepção evidenciou-se no final do século XX com revelações de diversos escândalos de suborno de agentes públicos internacionais por empresas multinacionais em busca de manutenção ou ampliação de mercados em países emergentes. É flagrante a preocupação mundial com essa problemática. A partir daí organismos internacionais, por meio de Convenções, influenciaram países signatários a criar em seus ordenamentos jurídicos medidas cada vez mais severas na tentativa de mitigar os riscos e ocorrência deste mal de tanto prejudica a sociedade mundial.

Hoje o instrumento da OCDE, que em seu artigo 2º vincula (*pacta sunt servanda*) os 41 (quarenta e um) Estados-partes e signatários a estabelecerem em seus sistemas jurídicos internos normas de responsabilização de pessoas jurídicas por atos de corrupção de agentes públicos estrangeiros, se tornou um poderoso instrumento de disseminação de normas anticorrupção pelo mundo.

Atualmente, 12 (doze) dos países reconhecem a responsabilidade de natureza não penal de pessoas jurídicas (*v.g.,* Brasil, Bulgária, Colômbia, Alemanha, Grécia, Itália, Letônia, México, Polônia, Rússia, Suécia e Turquia). Os demais 29 (vinte e nove) países reconhecem a responsabilidade penal das pessoas jurídicas por ilícitos dessa natureza. O último país a regulamentar a Convenção foi a Argentina, com a promulgação da *Ley de Responsabilidad Penal Empresarial*, em novembro, 2017. Não se trata um fenômeno sazonal ou passageiro.

A sociedade global, à exemplo do que aconteceu com a escravidão e outras violações de direitos humanos, ainda passa pelo processo de compreensão sobre a importância de se enfrentar (combater e prevenir) a corrupção. Muitos avanços foram propostos, mas ainda há muito o que progredir!

Referências Bibliográficas

AZEVEDO, André Mauro Lacerda. Bribery act 2010: as principais mudanças trazidas pela nova lei britânica de combate à corrupção. Disponível em: <http://andremauro2.jusbrasil.com.br/artigos/121816422/bribery-act-2010-as-principais-mudancas-trazidas-pela-nova-lei-britanica-de-combate-a-corrupcao> Acesso em 02 ago. 2016.

BRASIL. Controladoria Geral da União. *Cartilha sobre a Convenção da OCDE contra o suborno transnacional.* Brasília, 2016.

_____. *Cartilha sobre a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção.* Brasília, 2016.

_____. *Cartilha sobre a Convenção Intermericana contra a corrupção.* Brasília, 2016.

_____. Departamento de Polícia Federal do Brasil. *Curso de Alinhamento Conceitual do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD).* Un. 2. Corrupção. Brasília, 2015.

CAMPOS, Patrícia Toledo de. *Comentários à Lei nº 12.846/2013 – Lei Anticorrupção*. São Paulo: Universidade de São Paulo. Revista Digital de Direito Administrativo, v. 2, n. 1, p. 160-185, 2015.

CANDELORO, Ana Paula P., MARTINS DE RIZZO, Maria Balbina, PINHO, Vinicius. *Compliance 360°: riscos, estratégias, conflitos e vaidades no mundo corporativo*. São Paulo: Trevisan, 2015.

CAPANEMA, Renato de Oliveira. *Inovações da Lei nº 12.846/2013*. In: NASCIMENTO, M. D. do. (Org.). Lei Anticorrupção empresarial aspectos críticos à Lei 12.846/2013. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

CARVALHO, Paulo Roberto Galvão de. *Legislação anticorrupção no mundo: análise comparativa entre a lei anticorrupção brasileira, o Foreign Corrupt Practices Act norte-americano e o Bribery Act do Reino Unido*. Lei Anticorrupção. In: SOUZA, J. M.; QUEIROZ, R. P. (Orgs.) Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 47.

CASSIN, Richard L. *The 2015 FCPA Enforcement Index*. Disponível em <www.fcpablog.com/blog/2016/1/4/the-2015-fcpa-enforcement-index.html#sthash.gRRmyVeb.dpuf>. Acesso em 14 jul. 2016.

CRESSEY, Donald R. The criminal violation of financial trust. American Sociological Review, 15 (6), p.738-743, December, pp.1-15, 1950.

ESTADOS UNIDOS. United States Sentencing Comission (USSC). *Guidelines Manual. Chapter eight "Sentencing of Organizations".* Washington, EUA: 2014. Disponível em: <http://www. ussc.gov/guidelines-manual/2014/2014-individual-chapters-and-guidelines-html. Acesso em 18 jul. 2016.

FERREIRA, Luciano Vaz. *The Foreign Corrupt Practices Act handbook*. Bookreview. Revista Conjuntura Austral. Vol. 4, nº 15/16, Dez. 2012 - Mar 2013.

FERREIRA, Luciano Vaz; MOROSINI, Fabio Costa. *A implementação da lei internacional anticorrupção no comércio: o controle legal da corrupção direcionado às empresas transnacionais*. Revista Conjuntura Austral. Vol. 2, nº 3, Jan-Jun. 2013.

FURTADO, Lucas Rocha. *As raízes da corrupção no Brasil*. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.

GIN, Camila de Moura. *Uma breve análise sobre a legislação anticorrupção no mundo*. XII Seminário Nacional de Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea. Mostra Nacional de Trabalhos Científicos. 2016.

GONSALES, Alessandra. *Compliance. A nova regra do jogo*. São Paulo: LEC, 2016.

KAHNEMAN, Daniel; EGAN, Patrick. *Thinking, fast and slow.* New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

MANZI, Vanessa Alessi. Compliance no Brasil. São Paulo: Saint Paul, 2008.

MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Malheiro, 2007.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção das Nações Unidas contra Corrupção, 2000.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. *Convenção Interamericana Contra a Corrupção*. Caracas, 1996.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. *Convenção da OCDE sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais*. 1997.

_____. *Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance*. Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44884389.pdf>. Acesso em 01 ago. 2016.

Capítulo 3

O Microssistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Corrupção

Marcelo Zenkner[51]

1. O desafio de conceituar "corrupção"

Alguns autores afirmam que definir *corrupção* é quase um trabalho de Sísifo, já que o fenômeno ultrapassa a dimensão jurídica e alcança também o âmbito da sociologia, da política e das relações transnacionais. Entretanto, há mais de 250 anos, Samuel Johnson, em seu pioneiro dicionário de 1755, já definia o adjetivo corrupto como "viciado; contaminado com maldade; sem integridade".[52] Aliás, sempre que a incorruptibilidade é estudada mais profundamente, suas referências muito se aproximam da integridade, o que muito bem demonstra a correlação de uma expressão em relação à outra:

> *Good character includes a conception of what is worthy of oneself. Persons who truly have no price consider it beneath them to give in to temptations for illicit gratification or profit. Peer pressure, weakness in others, impulse, opportunity, and personal rationalization or consolation do not excuse lapses of character. […] Incorruptibility is a form of personal freedom that consists of control of one's life in accordance with standards of excellence and self-respect that are more important than anything else, including life itself. No other disposition makes our lives our own, and no other disposition can make anyone trustworthy to the very end. Although few of us may ever reach full incorruptibility we all should keep its nature clearly before us.*[53]

A corrupção, assim, é frequentemente vista como uma séria *violação da integridade*[54], ou seja, um comportamento que viola os valores e normas morais relevantes. O vocábulo, inclusive, é o resultado da junção de dois elementos: "ruptura" e "co". Luiz Fernando Veríssimo esclarece que a primeira palavra tem por origem a expressão latina *rumpere*, que quer dizer "quebrar completamente, inclusive moralmente, o que significa que quem foi corrompido não tem conserto"[55]; já o prefixo "co" foi unido ao radical para dar a indicação de que na corrupção normalmente há uma bilateralidade decorrente de um pacto que importa na conjugação dos interesses comuns de corrupto e corruptor.[56]

A ideia de que a corrupção funciona como um elemento que contamina o tecido social faz com que essa prática seja frequentemente comparada como uma patologia análoga a uma doença, a uma enfermidade física[57] ou a alguma forma de decadência de um estado ideal hipotético. Essas metáforas orgânicas têm permanecido notavelmente persistentes, como ocorre no conceito de Inge Amundsen sobre corrupção política: "A corrupção é uma doença, um câncer que corrói o tecido cultural, político e econômico da sociedade, e destrói o funcionamento de órgãos vitais".[58]

Na mesma linha, no famoso discurso de abertura da reunião anual do Banco Mundial, em 1996, o então presidente James D. Wolfensohn afirmou: "[...] precisamos de abordar a transparência, responsabilidade e capacidade institucional. E não vamos medir as palavras: temos de lidar com o câncer da corrupção".[59] A analogia é interessante na medida em que a corrupção, caso não haja controle, prolifera dentro das instituições públicas e corporações, assim como a doença que não é tratada se transmite pelo contato corporal.

Robert Brooks conceituou corrupção como "o desempenho intencional ou a negligência de um dever reconhecido, ou o exercício indevido do poder, com o objetivo de ganhar alguma vantagem mais ou menos pessoal".[60] Esta última definição traz consigo vários elementos importantes para o conceito contemporâneo de corrupção: o ato intencional, o abuso do exercício de uma posição e a busca de uma vantagem pessoal. Na mesma linha, João Maurício Adeodato explica que a corrupção:

> *[...] não seria propriamente uma disfunção, mas sim um mecanismo para assegurar uma legitimação que não poderia ser garantida pelas instituições do procedimento democraticamente organizado. Era e é um mecanismo de azeitar a máquina estatal incompetente e unir as elites subdesenvolvidas em torno de um sistema prebendário e predatório de distribuição de dinheiro, vantagens e poder em geral.*[61]

São muitos os autores que entendem que o abuso em questão deve estar vinculado a uma posição pública, ou seja, de que há a necessidade de envolvimento do Estado para a qualificação de atos como corruptos. Os defensores desta corrente partem da ideia de que a caracterização de um determinado comportamento como "corrupto" exigiria não apenas a presença obrigatória de conflito entre interesses públicos e privados, mas também o exercício indevido das funções públicas para obtenção de vantagens indevidas para si ou para terceiros. Mark Philp, por exemplo, aponta que:

> *There is some consensus in the literature that we have a case of corruption when: a public official (A), acting for personal gain, violates the norms of public office and harms the interests of the public (B) to benefit a third party (C) who rewards (A) for access to goods or services which (C) would not otherwise obtain.*[62]

Talvez a definição mais amplamente citada de corrupção pela doutrina seja a da Transparência Internacional, a qual, inclusive, é mais ampla que todas as outras anteriormente mencionadas: "o abuso do poder investido para ganhos privados".[63] A esse respeito é importante considerar, em primeiro lugar, que a noção de "abuso" guarda relação direta com a (in)correta utilização do poder, o que, inevitavelmente, é interpretado com um alto grau de subjetividade. Por outro lado, tal definição enfrenta desafios conceituais importantes. Quando vincula a corrupção à *investidura*, pode exemplo, pode forçar conclusão no sentido de que um governante ilegitimamente investido no poder (um ditador, por exemplo) jamais poderá ser considerado um corrupto.

Além disso, é problemática a exigência de "ganhos privados" para a caracterização da corrupção: se um agente público desviar recursos do erário para repasse imediato a uma instituição sem fins lucrativos de apoio a pessoas marginalizadas que está passando por dificuldades financeiras, essa conduta poderia ser caracterizada como corrupta?

Também não deve ser descartada a chamada *corrupção benévola*, ou seja, aquela que é praticada objetivando benefícios imediatos, específicos e concretos não do próprio agente, mas de grupos que poderiam estar completamente alienados da sociedade.[64] A corrupção, assim, estaria atrelada não ao enriquecimento ilícito daquele que a pratica, mas sim à transgressão de uma orientação econômica errada ou ineficiente, à superação das limitações de um sistema político imperfeito ou ao contorno das deficiências de determinadas regras organizacionais, o que pode fazer com que seja gerada, em casos tais, até mesmo uma simpatia popular pela prática ilícita.[65]

Mesmo diante da corrupção benévola, pode-se dizer que esse tipo de transgressão é, de modo geral, profundamente prejudicial a todos os setores da Administração Pública, da economia e da sociedade.

Por isso, a Transparência Internacional também classifica a corrupção considerando a quantidade de dinheiro envolvido e o setor em que ela ocorre, nos seguintes termos:

> *A grande corrupção consiste em atos cometidos em um alto nível de governo que geram a distorção das políticas ou do funcionamento central do estado, permitindo que os líderes se beneficiem às custas do bem público. A pequena corrupção refere-se ao abuso diário do poder confiado a funcionários públicos de níveis baixo e médio em suas interações com os cidadãos comuns, os quais, muitas vezes, estão tentando acessar bens ou serviços básicos em lugares como hospitais, escolas, departamentos de polícia e outras agências. A corrupção política é uma manipulação de políticas, instituições e regras de procedimento para alocação de recursos e financiamentos pelos decisores políticos, que abusam de sua posição para sustentar seu poder, status e riqueza.*[66]

Para Susan Rose-Ackerman e Bonnie J. Palifka[67], a palavra-chave do conceito da Transparência Internacional é *investidura* (poder confiado), o qual, para as autoras, pode ser atribuído pela população a um líder do governo ou por um empregador a um empregado. Assim, se ocorre o "abuso do poder investido ou confiado", as regras seriam quebradas e os objetivos declarados por aquele que conferiu tal poder estariam subvertidos, seja na esfera pública ou exclusivamente privada.

Haveria espaço, desse modo, para se falar em "corrupção privada"? Exemplos práticos bem ilustram a questão: o funcionário de uma empresa que, em troca de uma vantagem indevida, revela à concorrente a estratégia de sua empregadora em uma licitação praticaria o crime de corrupção? Poderiam, também, receber a pecha de "corruptos" os atos praticados pelos altos dirigentes de

associações esportivas de direito privado que, objetivando o enriquecimento pessoal, cobram comissões na venda dos disputados ingressos de famosas e populares competições esportivas?

A corrupção privada, assim, seria aquela ligada a uma série de outras infrações conexas como a associação criminosa (*conspiracy*, no direito norte-americano), a fraude e a lavagem de dinheiro. Aliás, se o fato original não puder ser tratado como delito, tampouco se poderá falar em eventual lavagem dos valores dali provenientes, já que estes não possuiriam procedência ilícita. Apesar de serem crescentes os movimentos jurídicos e políticos por sua criminalização, não são todos os países que admitem a corrupção privada como ilícito. Desde 1998, a União Europeia já adota essa postura (Ação Comum n.º 98/742/JAI do Conselho da União Europeia[68]), que foi seguida pela Convenção Penal sobre Corrupção e, em 2003, pela Decisão-Quadro 2003/568/JAI, emanada do Parlamento Europeu, a qual determina aos Estados-membros a criminalização da hipótese.[69]

Muitos países europeus, inclusive Portugal[70], deram tratamento especial à corrupção privada em suas legislações criminais internas, somando-se à Alemanha, a Inglaterra e à França, que já o faziam desde o início do último século.[71] É nessa linha que Luís de Sousa conceitua corrupção como:

> *[...] o abuso de funções por parte de eleitos, funcionários públicos ou agentes privados, mediante promessa ou aceitação de vantagem patrimonial ou não patrimonial indevida, para si ou para terceiros, para prática de qualquer acto ou omissão contrários aos deveres, princípios e expectativas que regem o exercício do cargo que ocupam, com o objectivo de transferir rendimentos e bens de natureza decisória, pública ou privada, para um determinado indivíduo ou grupos de indivíduos ligados por quaisquer laços de interesse comum.*[72]

A conclusão a que se pode chegar, ao final, é no sentido de que, apesar das diversas tentativas, a doutrina ainda não conseguiu alcançar um conceito definitivo e completo do termo “corrupção” que seja capaz de alcançar todas as suas vertentes e variantes.

2. As Diversas Classificações Doutrinárias da “Corrupção” em Sentido Amplo

Talvez em razão da grande dificuldade de conceituação, muitos autores acabam por se ocupar em classificar a corrupção a partir de suas várias e diferentes facetas.

Francisco Nieto, por exemplo, classifica a corrupção, quanto à sua intensidade, em três tipos: ocasional, endêmica ou sistêmica.[73] A primeira (*ocasional* ou *esporádica*) é aquela tolerável, de baixa magnitude e que não transcende o dia a dia do cidadão. Na corrupção *endêmica* ou *estrutural*, frequentemente são identificados repetidos e vulgarizados atos de corrupção, tanto no setor público como no privado, os quais são considerados necessários por seus praticantes em uma sociedade carente de confiança social e institucional diante do péssimo funcionamento da máquina burocrática estatal. É verificada em países que já identificaram a corrupção como um mal a ser enfrentado e que, por isso, estão passando por reformas no sentido de preveni-la e combatê-la.

A corrupção *sistêmica* ou *institucionalizada*, por fim, é aquela que envolve a prática corrupta inevitável, generalizada, enraizada, conhecida e tacitamente tolerada, sendo o governo, inclusive, conduzido no sentido de atender exclusivamente os interesses privados.[74] É detectada em sociedades onde a penalização da corrupção é considerada arbitrária ou apenas uma consequência de perseguição política, enquanto aqueles que contra ela se insurgem sofrem represálias, intimidações e são obrigados a se manter em silêncio.

Luiz Hanns[75] fala, ainda, na *corrupção sindrômica* ao afirmar que a corrupção, em verdade, deve ser tratada como uma “síndrome”, ou seja, um conjunto de características que, quando associadas a situações críticas, podem gerar uma certa insegurança. Chega-se a essa conclusão quando a corrupção é associada a outras duas outras grandes causas – a primeira é aquela vinculada a uma burocracia desmedida tanto na esfera privada como na pública. Diante de leis impossíveis de serem cumpridas, algumas que inclusive contradizem outras, a corrupção acabaria funcionando como um oxigênio capaz de viabilizar os negócios ou impedir que o cidadão morra sufocado. A outra causa seria exatamente a má gestão pública, como ocorre, por exemplo, em numa licitação que achata os preços dos fornecedores que, posteriormente, terão que buscar a realização de aditivos, muitas vezes por vias ilícitas, para evitar que a empresa vá à bancarrota.

Já Arnold Heidenheimmer utiliza os índices de reprovação da opinião pública para classificar a corrupção em três espécies principais: a corrupção *negra*, a *cinza* e a *branca*[76]. A primeira compreende as práticas mais graves, ordinariamente reprimidas pelo direito penal. A corrupção cinza, por sua vez, é condenada pela opinião pública, mas tolerada pela classe dirigente, e envolve o financiamento clandestino de setores públicos, por determinado empresariado preocupado com a defesa de seus interesses. A corrupção branca, por fim, é aquela que vem travestida de juridicidade ou encaixada numa juridicidade formal e normalmente é considerada, pela sociedade, como uma prática natural e, em alguns casos, até mesmo benigna. Para a consumação de pequenas vantagens, a corrupção branca é traduzida pela prática corriqueira do "jeitinho", da troca de favores e das remunerações ilícitas no serviço público, como, por exemplo, pagamento de diárias em valor muito superior e desproporcional às despesas que são realizadas durante a viagem[77].

James Scott, por fim, classifica a corrupção quanto ao grau de proximidade entre corrupto e corruptor: a *corrupção paroquial* é aquela que ocorre a partir da existência de vínculos estreitos previamente estabelecidos entre corrupto e corruptor, os quais podem decorrer de relações familiares, de amizade, étnicas ou partidárias. A *corrupção de mercado*, por outro lado, é aquela em que os bens e serviços do Estado são entregues pelo corrupto àquele que efetuar o pagamento do preço mais alto, independentemente de existir com ele uma relação prévia ou de confiança, e, por isso, numa economia de mercado, tende a prevalecer, segundo o autor[78], em relação à primeira.

Mesmo que um político, um agente público, um empresário ou um funcionário de uma empresa seja sistematicamente corrupto, a corrupção sempre se manifestará em ações específicas e, assim, o momento em que ela ocorre pode ser passageiro. Por isso, a maioria das conceituações vigentes de corrupção têm limitações importantes que podem torná-las, em última análise, inadequadas para a tarefa de melhorar ou reforçar a integridade no âmbito da administração pública ou das relações negociais particulares. Este é um problema particularmente importante no trato da corrupção: muitas vezes se sabe que determinada pessoa é corrupta, mas a convivência com a mesma acaba por permanecer, pois a acusação e as respectivas providências que daí decorrem dependem sempre de um fato concreto e provado. Essa situação fica ainda pior quando adicionada ao fato de que aqueles que se envolvem em corrupção fazem o seu melhor para mascarar suas atividades, o que tornam os esforços anticorrupção bastantes difíceis na prática.

Além disso, o fato de que a corrupção ocorre em eventos específicos que são geralmente detectados apenas após sua ocorrência pode levar a um viés reativo (ao invés de proativo) de esforços anticorrupção. Normalmente, iniciativas anticorrupção ocorrem em resposta ao surgimento de algum tipo de escândalo político associado à atividade corrupta em questão. Por isso, normalmente minimiza-se o aspecto preventivo para contentar-se apenas com o aspecto repressivo, buscando fechar brechas ou introduzir novos quadros legislativos.

É interessante notar, por fim, que o fato de uma pessoa não ser considerada corrupta não significa que ela seja íntegra. Um funcionário público que ocasionalmente subtrai material de escritório ou que utiliza o veículo oficial uma vez ou outra para fins particulares não é considerado um corrupto, mas certamente não é um profissional dotado de integridade. Da mesma forma, um parlamentar que vota favoravelmente a aprovação de um projeto de lei de interesse do governo, em troca na nomeação para determinado cargo de uma pessoa por ele indicada, está apenas fazendo um jogo político que em muito se distancia da integridade, apesar de sua conduta se encaixar em um conceito técnico de corrupção. Ademais, alguém pode estar se comportando com aparente integridade apenas porque foi excluído do grupo que comanda as ações corruptas ou porque ainda não apareceu a oportunidade ideal para a prática do ilícito.

Todas essas dificuldades na conceituação de corrupção, na identificação de uma pessoa corrupta e na descrição de um comportamento corrupto impedem uma elaboração teórica mais profunda, fazem com a corrupção sejam um fenômeno difícil de ser definido e, via de consequência, oferecem um guia problemático na projeção de políticas que promovam a integridade no âmbito governamental e empresarial.

Não é por outro motivo que o sistema normativo de contenção das práticas corruptas precisa estar bem alinhado, justaposto, ser de fácil compreensão e, principalmente, funcionar de forma perfeitamente integrada.

3. Interpretação, Integração e Aplicação das Normas Brasileiras Anticorrupção

O Brasil possui com um vasto conjunto normativo anticorrupção que envolve não apenas a descrição de condutas ilícitas, mas também a aplicação de sanções de natureza penal e administrativa a agentes públicos dos três Poderes da União e a particulares. Pode afirmar-se, inclusive, que, ante a sua gravidade, uma única conduta relacionada à corrupção, considerada aqui a expressão em seu sentido mais amplo, pode dar ensejo à incidência simultânea de várias normas de caráter repressivo, tanto no âmbito penal quanto no âmbito administrativo.

A Constituição Federal é o fundamento de validade de todas essas normas, tanto pelo critério de sua formação como na verificação de sua conformidade com os princípios e garantias constitucionais no momento de sua aplicação. Assim, se a Carta Magna prevê, no *caput* de seu art. 37, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência como princípios fundamentais da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é óbvio que esses princípios devem orientar todas as normas que tratam dos ilícitos que podem ser praticados contra a Administração Pública, sejam elas de que natureza forem.

Fica claro, assim, que nenhuma lei pode ser interpretada e aplicada isoladamente, mas sim dentro do subsistema do qual faz parte, pois, nos termos da lição de Fábio Medina Osório:

> *A interpenetração entre ordenamentos do direito é uma realidade extremamente veloz e inevitável, deslocando critérios formais que, tradicionalmente, reclamavam primazia. O que dita a funcionalidade do direito é um conjunto dinâmico de fatos ligados ao mercado judicial, mercado administrativo, mercado privado e todas as poderosas interfaces com outros tantos múltiplos mercados paralelos ou emergentes. Tais espaços se condicionam por valores sociais, culturais, econômicos e institucionais bastante velozes, interferindo na produção normativa legislada, judicializada ou administrativa. Os instrumentos postos à disposição dos atores vão desde dispositivos abstratos, redigidos na Constituição, nas leis e nos diplomas administrativos, até a jurisprudência judicial e administrativa, passando pela infinita doutrina, com toda a sua criatividade inovadora.*[79]

A existência de uma aproximação entre o direito administrativo sancionador e o direito penal, em se tratando de combate à corrupção em sentido amplo, não pode ser negada, pois é vasto o arsenal legislativo brasileiro: além do próprio Código Penal, do Código de Processo Penal e da legislação descrita no Item 3.1 *supra*, também devem ser consideradas:

- Lei Complementar n.º 64/1990 (estabelece a inelegibilidade de agentes políticos);
- Decreto n.º 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal);
- Lei n.º 4.898/1965 (Lei de Abuso de Autoridade);
- Lei n.º 1.079/1950 (Lei dos Crimes de Responsabilidade);
- Decreto-Lei n.º 201/1967 (Responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores);
- Lei n.º 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais);
- Lei n.º 8.027/1990 (Código de Conduta dos Servidores Públicos Federais);
- Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)[80];
- Lei n.º 10.257/2001 (Estatuto da Cidade)[81];
- Decreto n.º 7.203/2010 (vedação ao nepotismo);
- Exposição de Motivos n.º 37/2000 (Código de Conduta da Alta Administração Federal);
- Decreto n.º 4.081/2002 (Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos em Exercício na Presidência e Vice-Presidência da República); e
- Lei n.º 8.443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União).

Ora, se todas essas normas são esculpidas a partir da Constituição Federal e possuem o mesmo objetivo, é fundamental o reconhecimento da existência de um “Microssistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Corrupção”, ou seja, de uma instrumentalização harmônica dos diversos diplomas legais destinados ao trato específico da corrupção *lato sensu*, cuja amplitude e peculiaridades exigem interpretação e aplicação conjunta de seus comandos, sem apego a classificações puramente

formais ou abstratas, em prol de uma unidade e de uma harmonia normativa. Claus-Wilhelm Canaris, ao justificar a necessidade de um pensamento sistemático no campo da ciência do Direito, registra que:

> *[...] a ideia do sistema jurídico justifica-se a partir de um dos mais elevados valores do Direito, nomeadamente do princípio da justiça e das suas concretizações no princípio da igualdade e na tendência para a generalização. Acontece ainda que outro valor supremo, a segurança jurídica, aponta na mesma direção.*[82]

Essa mesma segurança jurídica que gera a unidade do microssistema também estabelece algumas exceções, exatamente para que ele possa funcionar com um mínimo de coerência interna. Assim, excepcionalmente, alguns dos institutos jurídicos que compõem um determinado microssistema possuem aplicação específica: o foro por prerrogativa de função, por exemplo, em razão de sua previsão estritamente constitucional, aplica-se única e exclusivamente às ações penais, não podendo ser disciplinado por lei infraconstitucional e, muito menos, deslocar a regra de competência originária de ações de natureza não-penal previstas no mesmo microssistema[83].

Vale ressaltar, por fim, que a ideia de "microssistema" não é exclusiva da prevenção e do combate à corrupção, havendo que se falar, também, *v.g.*, na existência de um microssistema de defesa do consumidor, um microssistema dos Juizados Especiais e em um microssistema de tutela coletiva. Em todos os casos, evidencia-se e caracteriza-se o *policentrismo* do direito contemporâneo, os vários centros de poder e a harmonização sistemática, com a Constituição ao centro prevalecendo sobre todos os demais estatutos que integram qualquer microssistema, em razão de ser ela o fundamento de validade formal e material do ordenamento jurídico.[84]

4. Aplicação Prática do Microssistema Brasileiro de Combate à Corrupção

Na legislação brasileira, em muitos casos, diferentes normas descrevem condutas praticamente idênticas, sem qualquer distinção ontológica entre os diversos ilícitos administrativo, civil, penal e político, a não ser para atribuir sanções de naturezas diversas para o mesmo ato de corrupção. A imperiosa necessidade de segurança jurídica, por isso, impõe que os diversos diplomas legais anticorrupção sejam intercambiantes entre si, em um sistema de *cross-fertilization* hermenêutico e legislativo.

Assim, por exemplo, deve ser interpretada de modo unívoco a expressão "vantagem indevida", seja como elemento do ato ilícito do Código Penal (arts. 317 e 333), da Lei de Defesa da Probidade Administrativa (art. 9º, *caput*), da Lei Anticorrupção Empresarial (art. 5º, inciso I), do Decreto n.º 1.171/1994 (Capítulo I, inciso XIV, alínea "i" do Anexo) e de quaisquer outros diplomas legais que compõem o microssistema. Isso é fundamental, até porque ainda existe certa discussão doutrinária acerca da necessidade (ou não) de vinculação dessa vantagem a um conteúdo econômico ou patrimonial.[85]

A importância dessa conclusão se consolida à medida que o ordenamento jurídico consagra a independência entre as instâncias penal, cível e administrativa, qualificando-se as respectivas sanções como respostas autônomas do Estado aos ilícitos praticados por agentes públicos e particulares. Assim, encontra-se diluída por toda a legislação brasileira uma série de dispositivos que permitem, salvo exceções, que o resultado do julgamento em uma determinada instância não repercuta em outra, inclusive com cumulação de sanções.[86]

Isso significa, em outras palavras, que não há nenhum obstáculo jurídico que impeça uma pessoa de responder, pela mesma conduta, a diversos processos – de natureza penal, cível ou administrativa – e sofrer diferentes sanções em cada um deles, sendo também possível que em determinado julgamento se decida pela aplicação de sanção e em outro não.

O mesmo raciocínio deve ocorrer no plano processual. Assim, por exemplo, um agente público pode ser judicialmente afastado do cargo que ocupa em uma ação penal ou em uma cível, quando a medida se fizer necessária à instrução processual (parágrafo único do art. 20 da Lei n.º 8.429/92) ou quando houver justo receio da utilização daquele cargo para a prática de atos ilícitos (inciso VI do art. 319 do Código Processo Penal).[87]

Certamente também devem ser levadas em consideração na aplicação da Lei n.º 12.846/2013, com as devidas adaptações, todo o acervo doutrinário e jurisprudencial já produzido em relação ao

“acordo de leniência” da Lei n.º 12.529/2011 e à “colaboração premiada” da Lei n.º 12.850/2013. Ainda a título meramente exemplificativo, não pode ser descartada a tutela de urgência de indisponibilidade de bens prevista no art. 7º da Lei n.º 8.429/92 para o processo judicial afeto ao ressarcimento dos danos causados ao erário e à aplicação das sanções previstas na Lei de Integridade das Pessoas Jurídicas.

Além disso, diante da insuficiência de critérios para a fixação das penas a serem aplicadas em uma ação por ato de improbidade administrativa, além de levar em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente (parágrafo único do artigo 12 da Lei nº 8.429/92), o juiz também deverá considerar a gravidade da infração, a consumação ou não da infração, o grau de lesão ou perigo de lesão, o efeito negativo produzido pela infração, a situação econômica do infrator e a cooperação para apuração das infrações (art. 7º da Lei nº 12.846/2013).

Contra o argumento de ser inviável agrupar-se em um único microssistema normas de natureza penal e administrativa, vale o argumento de que todas elas possuem repercussão sancionatória, seja no âmbito do processo judicial sancionador ou do processo administrativo sancionador, além do que não existe nenhum óbice no sentido de que uma autoridade judiciária aplique uma sanção de natureza administrativa[88]. A própria Lei n.º 12.846/2013, aliás, deixa claro que, “[n]as ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no art. 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa” (art. 20).

Conclusão

Apesar da enorme dificuldade encontrada pela doutrina em conceituar “corrupção”, existem diversas classificações capazes de contribuir para a compreensão de suas causas e para o estudo de estratégias que sejam capazes de mitigar os seus efeitos.

Entretanto, é também profundamente importante entender como funciona o sistema normativo interno de repressão à corrupção em seu sentido mais abrangente, pois um excesso de normas aplicáveis nas searas administrativa, cível e penal pode, ao contrário do seu objetivo original, acabar por contribuir para o enraizamento de um aparelho destorcido de impunidade.

Por isso, é muito importante a correta compreensão e aplicação das normas que buscam coibir o alastramento da corrupção pelas esferas da administração pública e da iniciativa privada. Isso somente será possível a partir do reconhecimento de que se está diante de um feixe normativo que não se repele, se completa e facilita a boa aplicação do Direito, garantindo a plena segurança jurídica não apenas para aquele que está sendo processado, mas também para o aprimoramento das mais complexas relações do Poder Público.

Referências Bibliográficas

ADEODATO, J. M., *Corrupção sistêmica, democracia e “natureza humana” – Uma velha tese*, Diário de Pernambuco, edição de 8 de novembro de 2015. Disponível em <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/opiniao/46,97,43,74/2015/11/08/interna_opiniao,130469/corrupcao-sistemica-democracia-e-natureza-humana-uma-velha-tese.shtml>. Acesso em 20 jul. 2016.

AMUNDSEN, I., *Political Corruption: An Introduction to the Issues*. Bergen, Chr. Michelsen Institute, 1999.

BANCO MUNDIAL, Discurso de abertura de James D. Wolfensohn na reunião anual, 1º de outubro de 1996 Disponível em <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTPRESIDENT/EXTPASTPRESIDENTS/PRESIDENTEXTERNAL/0,,contentMDK:20025269 Acesso em 20 jul. 2016.

BARROS FILHO, C.,/PRAÇA, S., *Corrupção: Parceria degenerativa*, Campinas, Papirus 7 Mares, 2014.

BOBBIO, N.,/MATTEUCCI, N.,/PASQUINO, G., *Dicionário de Política* [Trad. Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto Cacais e Renzo Dini, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1998].

BOLT, R., Public Corruption for Profit, in *Character and Cops – Ethics in Policing*, 4ª ed., coord. E. J. DELATTRE, Washington, The AEI Press, 2002.

BROOKS, R., The Nature of Political Corruption, in *Political Corruption: Readings in Comparative Analysis*, Londres, Holt, Rinehart and Winston, 1910.

BUCHAN, B.,/HILL, L., *An Intellectual History of Political Corruption*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014.

CANARIS, C.-W., *Pensamento sistemático e o conceito de sistema na ciência do direito*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.

CUNHA, A. F., *Combate à corrupção – Da teoria à prática*, Lisboa, Quid Juris, 2015.

DIDIER Jr., F.,/ZANETI Jr., H., *Curso de Direito Processual Civil – Processo Coletivo*, 10ª ed., Salvador, Editora JusPodivm, 2016.

HEIDENHEIMMER, A. J., *Readings in comparative analysis on political corruption*, New York, Holt, Rinegart and Winston, 1970.

HUBERTS, L., *The integrity of governance – What it is, what we know, what is done, and where to go*, Cambridge, Palgrave Macmillan, 2014.

JOHNSON, S., Corrupt (adjective), in *A Dictionary of the English Language: A Digital Edition of the 1755 Classic by Samuel Johnson*, ed. B. BESALKE, last modified November 7, 2013. Diposnível em <http://johnsonsdictionaryonline.com/?p=16538>.

MENDES, G. F., A improbidade administrativa no Supremo Tribunal Federal, in *Improbidade administrativa: temas atuais e controvertidos*, coord. M. C. MARQUES, et al., Rio de Janeiro, Forense, 2016.

NIETO, F., Desmitificando la corrupción en América Latina, in *Revista Nueva Sociedad*, n.º 194, Caracas, Fundación Friedrich Ebert, 2004.

NUCCI, G. S., *Corrupção e Anticorrupção*, Rio de Janeiro, Forense, 2015.

OSÓRIO, F. M., *Teoria da improbidade administrativa – má gestão pública – corrupção – ineficiência*, 3ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013.

_____, *Direito Administrativo Sancionador*, 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015.

PHILP, M., Corruption Definition and Measurement, in *Measuring Corruption*, Londres, Ashgate, 2006.

ROSE-ACKERMAN, S.,/PALIFKA, B. J., *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*, 2nd ed., New York: Cambridge University Press, 2016.

SCOTT, J. C., *Comparative Political Corruption*, New Jersey, Prentice-Hall, 1972.

SOUSA, L., *Corrupção*, Lisboa, Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2011.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL, *Faqs on Corruption – How do you define corruption?*, 2015 Disponível em <http://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption>. Acesso em 12 set. 2016.

VERISSIMO, L. F., Etimológicas, in *O Estado de São Paulo*, Caderno 2, edição de 30 de abril de 2015.

Capítulo 4

Pilar 1 - *Tone from the Top*
Comprometimento e Suporte Da Alta Administração

Carolina Gazoni[89]

Introdução

O maior segredo de eficiência de um programa de compliance está no fato de haver o suporte da Alta Administração. De um lado, ela prove recursos para mitigar riscos. E, de outro, por ser quem é, absorve qualquer risco ao ser, em si mesma, o tomador de decisão necessário para atingimento do objetivo almejado. É com cada palavra e comportamento inspirador que os líderes reforçam valores e princípios. Estes que não são estabelecidos para estarem apenas postos por meio de palavras em um Código de Conduta, Ética ou Integridade. Em uma organização que possui um Programa de Compliance efetivo o Comprometimento e Suporte da Alta Administração, valores e princípios são postos para o atingimento final de objetivos estratégicos.

Primeiro escreva sobre o vilão, para depois achar o herói. Para que exista Compliance são necessários muitos vilões. Somente assim uma estrutura grande de proteção pode ser necessária em uma empresa. Havendo riscos para serem conhecidos, protegidos, olhados e enfim, controlados e evitados.

A melhor forma de estabelecer um alinhamento entre o comportamento desejado e aquele realizado é olhar para o próprio comportamento. É o reflexo dele que ditará se a organização caminha ou não em direção aos valores e princípios estabelecidos. Neste sentido, a estratégia e o compliance se unem, estão integrados. É a Alta Administração aplicando valores e princípios ou conhecendo, agindo e decidindo com base na ética e integridade que ditará a força da efetividade de um Programa.

Para vilões, importa o fim. Para heróis, é o fim e o meio em si mesmos integrados que guiam e inspiram. É o Programa de Compliance que poderá atestar e confirmar o caminho para atingimento dos objetivos estratégicos. Compliance naquilo que se fala e, ao mesmo tempo, no que se acredita e faz. Para a existência de um Programa de Compliance ou de um sistema de gestão para o respeito à ética e normas para o controle de riscos de forma preventiva, o nível absoluto de efetividade é direcionado pela Alta Administração, já que ela possui a responsabilidade de proteção maior da organização, dos valores e objetivos necessários ao atingimento de seu propósito.

A Alta Administração, por meio do Programa de Compliance, resguarda a si e a todos. A Alta Administração será sempre herói dentro de um Programa efetivo. Tudo fará sentido para um Programa de Compliance quando ele estiver inserido estrategicamente dentro da estrutura da organização por meio de princípios e valores. Isto significa que em qualquer condição que os valores forem os guias e, ao mesmo tempo, o compliance estiver dentro da estratégia e modelo de negócio, um Programa será efetivo.

São muitos os autores e muitas as referências que afirmam: não existe compliance efetivo sem o Comprometimento da Alta Administração para que seja seguido e cumprido. Comprometimento significa, pacto, obrigação, missão, promessa, acordo, dívida. O Comprometimento da Alta Administração com o Programa se demonstra, por exemplo, por meio de seu interesse na inclusão de dados sobre o compliance em pautas de reuniões do Conselho, ou de atitudes diárias perante o público interno e externo da organização.

E também, não existe programa efetivo sem verdadeiro Suporte da Alta Administração com recursos e sistemas que proporcionem o atestado desta realidade. A não ser que vilões não existissem e que somente heróis sejam líderes, o programa seria desnecessário. Um exemplo de Suporte da Alta Administração é bem colocado no Guia de Integridade para Empresas Privadas, da CGU: “No caso de indícios de falta de efetividade das medidas de integridade, ou da ocorrência de irregularidades, da alta direção deve garantir meios para que sejam feitos os aprimoramentos necessários no Programa e adotadas as medidas corretivas cabíveis”. [90]

Segundo o Guia Programa de Integridade para Empresas Privadas, da Controladoria Geral da União, o Comprometimento da Alta Administração é:

O comprometimento da alta direção da empresa com a integridade nas relações público-privadas e, consequentemente, com o Programa de Integridade, é a base para a criação de uma cultura organizacional em que funcionários e terceiros efetivamente prezem por uma conduta ética. Possui pouco ou nenhum valor prático um Programa que não seja respaldado pela alta direção. A falta de compromisso da alta direção resulta no descompromisso dos demais funcionários, fazendo o Programa de Integridade existir apenas "no papel".[91]

Aos estudantes de Compliance, fica a observação que não podemos dissociar a liderança de uma organização, ou seja, o Comprometimento e Suporte da Alta Administração com a efetividade de um Programa de Compliance, porque em última instância, ele serve para atestar, resumir e consolidar todos os mecanismos necessários para o atingimento de valores e princípios declarados.

Este artigo está dividido em três partes. A primeira, descreve como o Comprometimento e Suporte da Alta Administração se afirma em cada um dos pilares de um Programa de Compliance. Não adentraremos em de cada um dos pilares já que isto será abordado pelo Manual em capítulos específicos. A segunda, apresenta como diretrizes fundamentais de compliance instituem este pilar dentro de suas estruturas, e como o Apoio e Suporte da Administração é relevante para um Programa de Compliance efetivo em uma visão histórica do conceito de compliance e sistema de gestão. Aqui também não adentraremos em especificidades das normas, mas tão somente sobre a relação delas com o Apoio e Suporte da Administração. A terceira, discorre sobre um apanhado geral da responsabilização dos Administradores dentro de um universo jurídico amplo, apenas para ilustrar como os deveres de probidade, boa fé e integridade são distribuídos em nosso ordenamento objetivo.

1. Comprometimento e Suporte da Alta Administração dentro dos Pilares de Compliance

O Comprometimento e Suporte da Alta Administração é considerado pilar elementar de todo Programa de Compliance efetivo, pois em si representa a possibilidade e poder de avaliação de elementos como comportamentos, dados e registros formados a partir dos processos de tomadas de decisão pautadas em ética e integridade. Ou, quanto mais alinhados estes elementos (comportamento, dados, registros) e a estratégia do Programa de Compliance estão com o processo de tomada de decisão, mais correspondência haverá entre o Programa de Compliance e a consolidação do negócio pautado em valores, princípios e integridade.

O comprometimento com a efetividade e eficiência de um Programa de Compliance se manifesta no desejo da empresa de que valores e princípios declarados sejam incorporados em todo o sistema de gestão de seu modelo de negócio. É neste sentido é que o *Tone of the Top* deve ser incorporado desde a estratégia da organização.

Na realidade, o compliance estará instituído em uma organização por meio de comportamentos realizados com base no exemplo da aplicação dos valores e princípios que são instituídos como regras externas (leis, regulamentos) ou internas (políticas, procedimentos). Portanto, não há sentido para o estabelecimento de uma estrutura robusta de regras, políticas e procedimentos (*policies & procedures*) pautados em normas regulamentares ou leis ou riscos, por exemplo, se o desejo de se cumprir estas regras e normas não está presente no topo da organização.

1.1. *Tone of the Top* no *Risk Assessment*

O Programa de Compliance deve ser desenhado com base nos riscos assumidos pela Alta Administração. De fato, o programa efetivo serve para evitar a ocorrência de riscos assumidos e/ou mitigá-los no momento de seu nascimento. Neste sentido, se de um lado o Conselho define os riscos estratégicos ou apetite ao risco da organização, de outro, o Compliance o resguarda por meio de informações, dados e sistemas de controles daqueles riscos. Ou seja, um Conselho que assume os riscos sem a devida e fundada informação do impacto daquela decisão para os demais membros da organização ou partes interessadas, que não conhece ou controla aquele risco, desconhece sua responsabilidade tanto em relação ao atingimento das metas estratégicas assumidas, quanto em relação à sua própria responsabilidade individual como Conselheiro, Diretor, presidente ou administrador.

O processo de tomada de decisão em uma organização não é uma atividade simples. Ele envolve a consideração de diversos fatores, de diferentes ordens de relevância, hierarquia. A tomada de decisão íntegra e de acordo com valores e princípios declarados exige que a Alta Administração avalie o risco de não cumprimento de forma coerente, verdadeira e transparente em relação à estratégia do negócio.

O Compliance e a Alta Administração trabalhando conjuntamente no processo de tomada de decisões, neste sentido, revigoram a força e a certeza de que a decisão tomada atingirá os objetivos e metas da organização. Se de um lado, o Compliance conhece os riscos, de outro, ele recolhe constantemente as informações e dados relevantes para, então, que a decisão seja tomada.

1.2. *Tone of the Top* em Políticas e Procedimentos

A relação do *Tone of the Top* com o pilar Políticas e Procedimentos refere-se à distancia ou proximidade destas ferramentas com a responsabilidade de sua liderança em fazer valer sua observância. Neste contexto, o *Tone of the Top* segue dentro da estrutura de Compliance por meio da liderança que está no comando das atividades cotidianas necessárias ao desempenho da organização. De fato, a Alta Administração não tem como conhecer todas as minúcias inseridas naqueles muitos processos, procedimentos, sistemas, pessoas e desempenho de pessoas ou correspondência com o que realmente se deseja para atingimento daqueles valores, princípios e propósito da organização.

É aqui que reside o papel fundamental do Comprometimento e Apoio da Alta Administração: ele determina o desempenho da organização, os caminhos por onde ela segue e a forma como ela o percorre. Ele determina os objetivos e as metas estratégicas. É o topo que dá o tom e a abertura para o Compliance e a liderança que absorve e maneja estas consequências por meio de políticas e procedimentos.

Políticas e Procedimentos observadas e conhecidas permitem a reunião das informações essenciais ao Programa de Compliance e à tomada de decisão fundamentada. Elas são também ferramentas essenciais para manejar consequências.

Políticas e procedimentos formalizam princípios e valores e permitem que a liderança exija seu cumprimento. A existência de informações documentadas permite, de outro lado, a absoluta transparência perante todos, consolidando uma forma objetiva de se comprovar, atestar e afirmar os próprios valores e as respectivas responsabilidades de cada um. É a liderança que cuida e resguarda esta informação. É seu comportamento que ditará o que será ou não cumprido e observado.

1.3. *Tone of the Top* no Treinamento e Comunicação

A comunicação ou melhor, como estes valores e princípios são comunicados, percebidos e cobrados dos integrantes da organização necessariamente requer a resiliência, a persistência, a afirmação constante da importância do Compliance para a segurança e prevenção dos riscos estratégicos assumidos.

Treinar pessoas, mais um dos pilares do Programa efetivo, torna-se relevante para o Compliance quando os valores e os princípios da organização fazem sentido para quem os observa e para quem tem a responsabilidade cotidiana de fazê-los cumprir de forma direta. É a coerência entre a estratégia ou modelo de negócio e a mensagem de integridade passada pela liderança que confirma a existência de Comprometimento da Alta Administração dentro de um Programa de Compliance.

Por exemplo, dentro de um sistema de avaliação de efetividade, um dos indicadores do *Tone of the Top* dentro do Programa de Compliance, seria a quantidade de treinamentos realizado pela liderança e Alta Gestão.

1.4. *Tone of the Top* e Sistemas de Controle Interno

Uma organização estratégica confere seus riscos. A conferência de riscos ocorre por meio de auditorias e sistemas de monitoramento ou controle. Esta checagem e controle de informações permite uma análise de dados obtidos dentro de um Programa de Compliance, portanto, a auditoria e monitoramento servem à Alta Administração dados. Alimentam dados de segurança e proteção aos riscos estratégicos, vinculados aos processos e sistemas de proteção à valores e princípios verdadeiramente instituídos. O cumprimento e o compliance devem sempre ser *checados*.

Se valores e propósito de cumprimento estão instituídos pela Alta Administração, o sistema de checagem os expande pela organização, trazendo a robustez e a comprovação de que o que foi instituído está sendo observado e cumprido. Observado, concretizado, propagado, inserido. Efetivado.

Deste contexto, a Alta Administração, por outro lado, tem elementos para aferir tanto sua responsabilidade perante os riscos assumidos quanto a sua tendência a controlá-los para melhor atingimento dos objetivos estratégicos da organização.

1.5. *Tone of the Top* nos Canais de Comunicação

Quando a Alta Administração desenvolve um canal de suporte para que todos possam relatar afronta aos sistemas de valores e princípios, eliminando medos e possibilidades de desvirtuamento. A Alta Administração, ao dar suporte para a criação deste canal, garante que a integridade é valorizada para a organização. É de sua responsabilidade qualquer problema e qualquer não cumprimento dentro dos valores declarados. Cumprir e fazer cumprir dentro de um Programa robusto não é a meta isolada. Um Programa robusto tem também como meta tratar o não cumprimento para que seja sempre valorizado, e, assim, estratégico.

1.6. *Tone of the Top* em Investigações Internas

É a Alta Administração que prove recursos internos para uma apuração imparcial de fatos que possam violar valores e princípios dentro de uma organização. Na verdade, o recurso do Programa de Compliance que permite a investigação interna parte da abertura e confiança de um órgão que suporte tal investigação de forma independente e como um valor em si mesmo necessário ao atingimento dos objetivos estratégicos do negócio.

O Apoio da Alta Administração em investigações internas ocorre de duas formas principais: a primeira quando ao processo de investigação é assegurado tratamento independentemente do tipo, forma, nível ou espécie da denuncia. A segunda, quando independentemente de quem é atingido, assegura-se a apuração imparcial, baseada em fatos e evidencias, e aplicação uniforme em relação às consequências.

1.7. *Tone of the Top* e *Due Diligence* de Terceiros

A existência de um sistema de avaliação de terceiros está presente em um sistema de integridade para que possa comprovar que qualquer terceiro presente dentro de uma estrutura organizacional segue os mesmos princípios e valores almejados pela organização. A Alta Administração, neste sentido, tem como função permitir que tais verificações ocorram sistematicamente, evitando, em qualquer momento, hipóteses de favorecimento indevido que possam desnortear, distorcer e corromper o sistema interno de valores construído.

Aqui reside um ponto elementar, sob a perspectiva de mercado, que visa uma evolução conjunta das organizações que atuam e promovem valores, princípios e resguardam, em cadeia, através de seus líderes, a ética e integridade.

1.8. *Tone of the Top* em Auditoria, Monitoramento e Melhoria Contínua

O monitoramento é a observação contínua da liderança sobre tais processos e sistemas de segurança. É por meio do engajamento dos líderes nos valores e propósitos que isso pode ser realizado de maneira eficiente. É quando a liderança observa e absorve os valores que o monitoramento de um Programa de Compliance começa a acontecer.

Dentro de uma organização, é função do compliance reunir dados e informações decorrentes de processos de auditoria e monitoramento. A sistematização de informações ligadas à compliance é uma incumbência própria deste departamento. Neste sentido, é obrigação da Alta Administração dar-lhe autonomia e independência. Quem assegura e transfere a informação de valores e princípios, segundo a estratégia do modelo de negócio, e fiscaliza seu cumprimento deve, necessariamente, ser independente e autônomo.

A autonomia e a independência do departamento de compliance é necessária para atender os próprios objetivos da Alta Administração. É ela que deseja receber a informação verdadeira, esclarecida, imparcial e fundamentada sobre os riscos e sobre a evolução de valores e propósitos declarados.

Nada mais natural que um Programa efetivo comporte uma supervisão autônoma e independente. É na confiança da Alta Administração, assim, sobre a efetividade e utilidade do Programa de Compliance que a independência e autonomia residem.

Sistemas de segurança são instituídos para prover recursos à organização que não tolera o desrespeito aos valores e princípios declarados.

Na revisão, avaliação e entendimento da Alta Administração destes próprios recursos do Programa de Compliance que reside a melhoria contínua. É por meio da preocupação da Alta Administração que o Programa de Compliance é avaliado. Ao se importar com o comprometimento e cumprimento, a Alta Administração avalia a eficácia do Programa. Esta é a confirmação de seu próprio comprometimento e da contínua evolução em direção a um Programa cada vez mais robusto.

2. Diretrizes fundamentais de Compliance e o Apoio e Suporte da Alta Administração

No âmbito das principais referências de compliance, que discorrem especificamente sobre cada um dos pilares de um Programa efetivo, o Comprometimento e Suporte da Alta Administração é apresentado, sempre, em primeiro lugar. Como deixamos claro no capítulo anterior, a verdadeira intenção de se propagar valores, princípios, ética e integridade exige o interesse real de que estes sejam sempre incorporados dentro da cultura organizacional por meio do exemplo e de ações do topo a eles condizentes.

Abordaremos, assim, como algumas das principais diretrizes explicitam este requisito elementar de efetividade dentro de um Programa de Compliance.

2.1. Lei *Sabarnes-Oxley* (“SOx”)

A Lei *Sarbanes-Oxley* visa aprimorar a governança corporativa e a prestação de contas (informações sobre receitas, despesas, balanço patrimonial e total de ativos e passivos). Em outras palavras, o objetivo é identificar, combater e prevenir fraudes que impactam no desempenho financeiro das organizações, garantindo o compliance. Segundo o relatório da Deloitte - Guia para melhorar a Governança Corporativa através de Controles Internos:

> *A Lei Sarbanes-Oxley e as regras relacionadas emitidas pela SEC são leis e regulamentações complexas que geraram confusão e consternação na comunidade empresarial. Mas, por trás de todas as regras e regulamentações, a Lei Sarbanes-Oxley é* ***simplesmente uma forma encontrada pelo governo para estabelecer recursos legais nos preceitos básicos da boa governança corporativa e das práticas empresariais éticas****. A Lei Sarbanes-Oxley codifica a concepção de que a administração da companhia deve conhecer as informações materiais arquivadas na SEC e distribuídas aos investidores e deve, também, responsabilizar-se pela probidade, profundidade e precisão dessas informações.*[92] (Grifos do autor).

Na Seção 302 da Lei exige que a Alta Administração, geralmente CEO e CFO, certifique e aprove a exatidão das demonstrações financeiras e a eficácia dos controles e procedimentos de divulgação internos.

2.2. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* - COSO

O *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* - COSO fornece um roteiro para a construção de uma base fundamental de controle interno para garantir que os riscos assumidos por uma organização sejam monitorados e mitigados por meio de decisões comerciais

sólidas e seguras. Este documento serve de base para muitos dos conceitos atualmente aplicados por organizações em seus Programas de Compliance.

Em 1992, o COSO publicou o Guia *Internal Control - Integrated Framework* ("COSO-IC" ou "COSO I"), com o objetivo de orientar as organizações quanto a princípios e melhores práticas de controle interno, em especial para assegurar a produção de relatórios financeiros confiáveis e prevenir fraudes.

Em 2004, o COSO publicou o *Enterprise Risk Management - Integrated Framework* ("COSO-ERM" ou "COSO II"), documento tido como referência no tema gestão de riscos corporativos. Esse modelo foi projetado com o objetivo de orientar as organizações no estabelecimento de um processo de gestão de riscos corporativos e na aplicação de boas práticas sobre o tema.

Em 2018, o COSO - *ERM - Integrating with Strategy and Performance* ("*Framework*"), foi atualizado e passa a destacar a importância de considerar os riscos tanto no processo de estabelecimento da estratégia quanto na melhoria da performance. São cinco pilares fundamentais desenvolvidos que podem ser aplicados ao gerenciamento de riscos e compliance: (i) governança e cultura (ii) estratégia e definição de objetivos; (iii) performance; (iv) monitoramento do desempenho e revisão; e (iv) informação, comunicação e divulgação.

O processo corporativo de gestão de riscos previsto no COSO-ERM, além de ser aplicável na realização normal das atividades - operacionais, administrativas e de suporte – passa a ser, assim, aplicado também nas atividades de planejamento voltadas à definição da estratégia da organização. A perspectiva do COSO-ERM relativa aos objetivos inclui um novo tipo de objetivo a ser assegurado e que não era listado no COSO-IC, a categoria dos objetivos estratégicos.

O importante a ressaltar aqui é que no mais novo modelo, o qual abarca os conceitos de compliance, o Apoio e Suporte da Alta Administração se desenvolve e se fundamenta em toda a estratégia de controle interno e mitigação de riscos, conforme apetite ao risco, desde a governança, até a estratégia de mitigação de riscos, conforme falamos no capitulo 1 do presente artigo. O sistema de governança e controle de riscos é assim ilustrado pelo documento:

Figura 1 - Organograma COSO - ERM

A ilustração demonstra claramente uma integração completa entre o sistema de controle de riscos e o Apoio e Suporte da Alta Administração com o controle de riscos e compliance. Como é possível identificar, toda a organização está permeada pelos valores e princípios, os quais consubstanciam a entrada principal aos demais sistemas de controle instituídos em um Programa de Compliance, especialmente no que tange à estratégia e modelo de governança corporativa.

2.3. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBCG

Em 1995 ocorreu a criação do Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração (IBCA), que a partir de 1999 passou a ser intitulado Instituto Brasileiro de Governança Corporativa ("IBGC"), com o objetivo de influenciar os protagonistas da sociedade brasileira na adoção de práticas transparentes, responsáveis e equânimes na administração das organizações. Ainda em 1999 o IBGC lançou seu primeiro Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Sendo referência atual na concepção de cursos, metodologias, grupos de estudos, o IBGC consolidou-se como um grande difusor das melhores práticas em organizações empresariais.

Não adentraremos nas específicas diferenças existentes entre tipos societários, uma vez que os princípios pregados no Código de Melhores Práticas do IBGC, referem-se a proteção da sociedade empresária a longo prazo e regulamentam as relações entre sócios/acionistas, sendo extensíveis a companhias abertas ou fechadas.

Segundo as premissas da atual versão do Código de Melhores Práticas do Instituto:

(...) conceito de cidadania corporativa deriva do fato de a empresa ser uma pessoa que deve atuar de forma responsável. Na prática, para operar, uma empresa depende não apenas das licenças previstas em dispositivos legais e regulatórios, mas também do aval de um conjunto de partes interessadas que a afeta ou é afetado pelas suas atividades. Os agentes de governança devem considerar, portanto, as aspirações e a forma pela qual a sociedade em geral entende e absorve os efeitos positivos e negativos – as externalidades – da atuação das organizações e responde a eles. Nesse novo ambiente, a ética torna-se cada vez mais indispensável. ***Honestidade, integridade, responsabilidade, independência****, visão de longo prazo e preocupação genuína com os impactos causados por suas atividades são fundamentais para o sucesso duradouro das organizações.*[93] (Grifos do autor).

A Alta Administração de uma organização representa uma parte crítica do ambiente interno e é capaz de influenciar os seus elementos de forma significativa. Cada fator, como a existência de um processo de tomada de decisão pautado em fatos e em dados, a experiência e desenvolvimento de seus membros, o grau de participação de cada líder e exame das atividades, bem como a adequação de suas ações, tem a sua importância.

Por exemplo, a remoção ou a redução de tentações e de incentivos inadequados são muito eficazes na eliminação do comportamento indesejável. A fixação de metas realistas, por outro lado, é uma prática capaz de reduzir o estresse contraproducente e o incentivo à elaboração de relatórios fraudulentos. Do mesmo modo, um sistema de relatórios adequadamente controlado poderá servir de salvaguarda contra a tentação de mascarar o desempenho real atingido.

Outra causa de práticas duvidosas é a ignorância. Os valores éticos não devem ser apenas comunicados, mas acompanhados de orientação específica em relação ao certo e ao errado. Segundo o IBGC, isso se consubstancia na própria função e incumbência do Conselho de Administração (ou Alta Administração), conforme destacado abaixo:

O conselho de administração é o órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce o papel de guardião dos princípios, valores, objeto social e sistema de governança da organização, sendo seu principal componente. Além de decidir os rumos estratégicos do negócio, compete ao conselho de administração, conforme o melhor interesse da organização, monitorar a diretoria, atuando como elo entre esta e os sócios.[94]

A Alta Administração, neste sentido, possui responsabilidade direta para a consolidação de princípios e valores, como ressaltado no decorrer deste artigo. Outras diretrizes relevantes pregadas pelo IBGC referem-se aos deveres do Conselho de Administração, tais como, por exemplo, o dever de identificar, discutir e garantir a disseminação dos valores e princípios da organização e de definir estratégias e tomar decisões que protejam e valorizem a organização.

Seguindo na mesma linha e de acordo com o IBGC, é responsabilidade da Alta Administração promover uma cultura organizacional centrada nos valores e princípios da organização e proporcionar um ambiente em que as pessoas possam expressar pensamentos dissonantes e discutir dilemas éticos.

No que diz respeito aos aspectos práticos de um Programa de Compliance, ressaltamos os deveres da Alta Administração quanto à obrigação do estabelecimento de formas de monitorar, permanentemente, se as decisões e ações empresariais (e seus resultados e impactos diretos e indiretos) estão alinhadas aos seus princípios e valores. Em caso de desvios, por fim, é sua incumbência propor as medidas corretivas e, em última instância, punitivas, previstas no Código de Conduta.

2.4. ISO 19600 – Sistemas de Gestão de Compliance - Diretrizes

A *International Organization for Standardization* (ISO) é uma federação mundial de órgãos nacionais de normalização (órgãos membros da ISO). O trabalho de preparação de Normas Internacionais é normalmente realizado pelos Comitês Técnicos da ISO. De acordo com a ISO 19600, o compliance é:

(...) a consequência de uma organização cumprir as suas obrigações, e é feito de forma sustentável, incorporando-o na cultura da organização e no comportamento e atitude de pessoas que trabalham para ela. Apesar de manter a sua independência, é preferível que a gestão de compliance seja integrada aos processos de gestão financeira, de risco, da qualidade, ambiental, de saúde e segurança da organização e aos seus requisitos e procedimentos operacionais.[95]

No mesmo sentido, a norma esclarece que:

É na abordagem de uma organização quanto ao compliance é idealmente moldada pela liderança ao aplicar valores fundamentais de governança corporativa e padrões éticos e comunitários geralmente aceitos. Incorporar o compliance no comportamento das pessoas que trabalham para uma organização depende, sobretudo, da liderança em todos os níveis e da transparência dos valores de uma organização, bem como de um reconhecimento e implementação de medidas para promover um comportamento compatível. Se não for assim em todos os níveis de uma organização, existe o risco de não cumprimento.[96]

Segundo o capítulo 5 da ISO 19600, que discorre sobre liderança e comprometimento, convém que o Conselho de Administração e a Alta Direção demonstrem liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão de compliance por: (i) estabelecer e defender os valores fundamentais da organização; (ii) assegurar que os objetivos e a política de compliance sejam estabelecidos e consistentes com os valores, objetivos e direcionamento estratégico da organização; (iii) assegurar que as políticas, procedimentos e processos sejam desenvolvidos e implementados para atingir os objetivos de compliance; (iv) assegurar que os recursos necessários para o sistema de gestão de compliance estejam disponíveis, reservados e atribuídos; (v) assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão de compliance aos processos do negócio da organização; (vi) comunicar a importância de um sistema de gestão de compliance eficaz e a importância da conformidade nos requisitos do sistema de gestão de compliance; (vii) dirigir e apoiar as pessoas que contribuem para a eficácia do sistema de gestão de compliance; (viii) apoiar outros papéis de gestão pertinentes para demonstrar à sua liderança como se aplicam as suas áreas de responsabilidade de compliance; (ix) assegurar o alinhamento entre as metas operacionais e as obrigações de compliance; (x) estabelecer e manter mecanismos de responsabilização por prestar contas, incluindo o relato tempestivo sobre assuntos de compliance, inclusive o não cumprimento; (xi) assegurar que o sistema de gestão de compliance atinja o(s) seu(s) resultado(s) pretendido(s); (xii) promover melhoria contínua.

Todos os elementos previstos na norma nada mais são do que os pilares de compliance, estimulados, desde o início, por meio do Comprometimento e Suporte da Alta Administração. Neste sentido, em suma, este comprometimento é assegurado a partir do momento em que, na organização, tanto o órgão regulamentador interno, quanto todos os níveis da administração, demonstrem ativamente o comprometimento em estabelecer, desenvolver, implementar, avaliar, manter e melhorar um sistema de gestão de compliance eficaz e ágil por meio de suas ações e decisões.

2.5. Foreign Corrupt Practices Act – FCPA

O FCPA é um regramento norte americano extremamente importante para combater a corrupção no mundo. Falaremos especificamente sobre ele, pois este documento contém previsões específicas sobre Programas de Compliance efetivos. Da mesma forma, considerando a evolução do conceito de compliance no Brasil, o risco relacionado à corrupção nas organizações pode ser considerado a porta de entrada para ampliar a perceção de gestores no sentido da obrigatoriedade da implantação de Programas de Compliance como sistemas de gestão.

A legislação americana surge em um contexto de proteção transacional de atos lesivos ao mercado e aos sistemas de transações internacionais. De acordo com o documento – *FCPA – Resource Guide*[97], a corrupção tem efeitos corrosivos sobre as instituições democráticas, minando a responsabilidade pública e desviando recursos públicos de importantes prioridades, como saúde, educação e infraestrutura.

A FCPA aborda o problema da corrupção internacional de duas maneiras: (i) primeiramente, explicita diversas disposições anticorrupção, as quais proíbem indivíduos e empresas de subornar funcionários de governos estrangeiros para obter ou reter negócios e; (ii) em uma segunda linha,

apresenta regras e determinações sobre provisões contábeis, impondo exigências de manutenção de registros e de controles internos adequados, reais e condizentes com as operações executadas por companhias que transacionam valores mobiliários que, de alguma forma especificada na Lei, perpassem pelos Estados Unidos. Violações do FCPA podem levar a penalidades civis e criminais e sanções, tais como multas, dever de ressarcimento e até, prisão.

Os órgãos regulamentadores norte americanos, DOJ e a SEC, não estabelecem requisitos formais objetivos e específicos para aferir a efetividade ou validade de programas de compliance para fins da aplicação de sanções decorrentes da Lei. Em vez disso, empregam uma abordagem pragmática e de bom senso para avaliá-los, fazendo uma análise que pode ser resumida em três questões fundamentais: O programa de conformidade da empresa é bem desenhado às atividades da empresa? Está sendo aplicado de boa-fé? Funciona?

O documento *FCPA - Resource Guide* contém informações sobre alguns dos elementos básicos que o DOJ e a SEC consideram ao avaliar programas de compliance. Embora o foco deste documento seja a conformidade com o FCPA, ele deixa claro que dada a existência de leis anticorrupção em muitos outros países, as empresas devem considerar a conformidade anticorrupção de forma ampla, ou seja, devem prezar pela aplicabilidade destes requisitos aos modelos de negócios realizados em cada um dos países que atua.

O fato é que, de acordo com este documento, dentro de uma organização empresarial, a conformidade começa sempre com o *Tone of the Top* dado pela Alta Administração e pela liderança, os quais são responsáveis por comandar o "tom" dos negócios, em relação ao cumprimento de normas, para todo resto de toda organização.

Segundo este Guia, colaboradores aceitam (ou são obrigados a aceitar) recomendações destes líderes. Neste sentido, para fins de aferição do programa, o DOJ e a SEC sempre considerarão o compromisso dos líderes corporativos com a "cultura de conformidade" e buscarão avaliar se esse compromisso de alto nível também é reforçado e implementado por gerentes e funcionários em todos os demais níveis do negócio.

O Guia refere-se a este elemento com a noção da aplicação e execução, de boa-fé, de normas e sistemas de controle por parte de toda a organização. Ou seja, quando a gestão corporativa encoraja, explicita ou implicitamente, o engajamento em condutas impróprias para alcançar os objetivos estratégicos, o compliance não será efetivo.

Esta ideia é importante, pois refere-se diretamente ao real interesse da Alta Administração em agir de acordo com os valores e princípios que estabelece: o DOJ e a SEC não aceitam a efetividade de programas de compliance que são fortes no papel, mas que, no entanto, têm violações significativas do FCPA porque a administração não implementou efetivamente o programa, mesmo diante de sinais óbvios de corrupção.

De acordo com o Guia, isso pode ser demonstrado, por exemplo, quando uma política comercial agressiva impede a equipe de compliance de realizar seu trabalho ou quando a liderança, mais preocupada em garantir determinada oportunidade de negócio, deixa de atestar a cultura de conformidade perante a equipe comercial.

A avaliação pelos órgãos reguladores americanos passará pela ideia de que uma forte cultura ética apoia diretamente um forte e exemplar programa de conformidade. Ao aderir a padrões éticos, a Alta Administração inspirará os demais a reforçar tais padrões. DOJ e SEC, portanto, avaliarão sempre se os princípios e valores da empresa foram bem articulados pela Alta Administração, por ela comunicados em termos inequívocos, pelos demais aderidos e, assim, disseminados por toda a organização.

2.6. Lei Anticorrupção (Lei Federal Nº. 12.846/2013) e suas Regulamentações

A Lei 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, instituiu no Brasil a responsabilização objetiva administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos que sejam cometidos em seu interesse ou benefício, contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Fato é que, ainda que restrita às pessoas jurídicas, a fixação da responsabilidade objetiva implica um ponto de extrema atenção, pois como a lei não exige a necessidade de prova de culpa da pessoa jurídica, a empresa será responsabilizada ainda que não tenha concordado, autorizado ou tenha tido ciência prévia do ato ilícito praticado por um gestor ou funcionário.

Para além do seu caráter punitivo, a referida Lei também atribui especial relevância às medidas anticorrupção adotadas por uma empresa, que podem ser reconhecidas como fator atenuante em um eventual processo de responsabilização, as quais, conjuntamente, são denominadas pela lei de Programa de Integridade.

Os mecanismos e procedimentos de integridade que devem ser adotados pela organização para fins de aferição da responsabilidade objetiva, foram detalhados pelo Decreto Federal nº. 8.240/2015, de 18 de março de 2015.

Segundo a regulamentação, o programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais (estratégia) das atividades de cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa. O Decreto definiu no seu art. 41 o que é Programa de Integridade:

> *Programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.* [98]

De uma forma geral, os mesmos critérios estabelecidos nas demais legislações e orientações ou diretrizes internacionais vistas acima, são replicadas na legislação nacional. Segundo o documento "Programas de Integridade – Diretrizes para Empresas Privadas", publicado pela Controladoria Geral da União, os pilares estabelecidos na regulamentação são os mesmos descritos neste manual, sendo certo que o primeiro deles é o Comprometimento e Apoio da Alta Administração, que constitui um dos requisitos elementares para a efetividade do Programa de Compliance, conforme estabelece o artigo 42 do disposto legal, a saber:

> *Art. 42. Para fins do disposto no § 4º do art. 5º, o programa de integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros:*
>
> *I - Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa;*

Desta forma, e mais uma vez, o Apoio da Alta Administração é considerado pela regulamentação condição indispensável e permanente para o fomento a uma cultura ética e de respeito às leis e para a aplicação efetiva do Programa de Integridade.

A espécie de responsabilidade imposta para as pessoas jurídicas, no contexto da lei, é a objetiva, a qual não exige comprovação de dolo ou culpa para se determinar a responsabilização, bastando a verificação do ato ilícito e do respectivo autor. Por outro lado, é importante ressaltar que a responsabilidade específica dos administradores e dirigentes das sociedades será avaliada de forma independente da responsabilidade da pessoa jurídica.

2.7. Verificação e Checagem do Comprometimento e Apoio da Alta Administração dentro do Programa de Compliance – *Check list*

A atividade de avaliar a existência ou não do Comprometimento e Apoio da Alta Administração para disseminação da cultura de integridade e ética dentro de uma organização pode parecer bastante subjetiva ou distante da realidade. Neste sentido, apresentamos um *check list* de verificação, resumindo tal aferição nas perguntas descritas no quadro abaixo.

Apoio e Comprometimento da Alta Administração	Não aplicado	Dúvida	Implementado	Parcialmente efetivo	Efetivo
O conselho de administração e a alta direção estabelecem e disseminam os valores fundamentais da organização?					
O conselho de administração e a alta direção asseguram que os objetivos e a postura do Programa de Compliance sejam estabelecidos e consistentes com os valores, objetivos e direcionamento estratégico da organização?					
O conselho de administração e a alta direção asseguram que as políticas, procedimentos e processos sejam desenvolvidos e implementados para atingir os objetivos de compliance?					
O conselho de administração e a alta direção asseguram que os recursos necessários para o Programa de Compliance estejam disponíveis, reservados e atribuídos?					
O conselho de administração e a alta direção asseguram a integração dos requisitos do Programa de Compliance aos processos de negócio da organização?					
O conselho de administração e a alta direção comunica a importância de um Programa de Compliance eficaz e a importância da conformidade aos requisitos do SGC?					
O conselho de administração e a alta direção dirige e apoia as pessoas que contribuem para a eficácia do Programa de Compliance? O conselho de administração e a alta direção apoia outros papéis de gestão pertinentes para demonstrar a sua liderança como se aplicam às suas áreas de responsabilidade de compliance?					
O conselho de administração e a alta direção asseguram o alinhamento entre as metas operacionais e as obrigações de compliance?					
O conselho de administração e a alta direção estabelece e mantém mecanismos de responsabilização ou prestação contas, incluindo relatórios tempestivos sobre assuntos de compliance, incluindo o não cumprimento?					
O conselho de administração e a alta direção assegura que o Programa de Compliance atinja o seu resultado pretendido?					
A alta direção assegura que as responsabilidades e autoridades nos papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas dentro da organização?					
O conselho de administração e a alta direção atribuem a responsabilidade e a autoridade para a função de compliance para relatar o desempenho do Programa de Compliance para o órgão regulamentador da Alta Administração?					
O Conselho de Administração e a Alta Administração promove a melhoria contínua do Programa de Compliance?					

Figura 2 – *Check List* sobre o Comprometimento e Suporte da Alta Administração

As respostas apresentadas neste documento, ainda que classificadas segundo seu grau ou estágio de implementação, devem ser justificadas e registradas, para fins de constante evolução ou comprovação do real Comprometimento e Apoio da Alta Administração.

3. Responsabilidade Legal da Alta Administração

As sociedades têm existência distinta da dos seus sócios e capacidade de adquirir direitos e assumir obrigações (personalidade jurídica). Em princípio, segundo o sistema jurídico brasileiro, os bens da sociedade, e não os bens de seus sócios e/ou administradores, constituem a garantia de credores.

A aplicação de normas jurídicas a empresas e a pessoas são independentemente. A interpretação jurídica envolve a avaliação do caso concreto e os aspectos a ele aplicáveis variam segundo diversos fatores relevantes para o caso em si.

De uma forma geral, um Programa de Compliance resguarda e protege os interesses da organização. O pilar Comprometimento e Apoio da Alta Administração serve, dentro deste contexto, ainda, para atestar a legitimidade ou não do cumprimento da legislação por parte dos administradores de uma sociedade.

Neste sentido, diante da importância do Apoio e Comprometimento da Alta Administração para o Programa de Compliance, cumpre destacar os aspectos principais de sua responsabilidade como administrador, gestor e líder de uma sociedade com personalidade jurídica que representa funções e distribui consequências extremamente relevantes dentro das relações no mundo.

Assim, são considerados deveres do Administrador: (a) agir no interesse da sociedade; (b) agir com cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios (dever de diligência); (c) servir com lealdade à sociedade e manter a reserva sobre os negócios sociais, sigilo sobre informações confidenciais e não utilizar informações privilegiadas em benefício próprio ou alheio (dever de lealdade); e (d) informar os sócios sobre fatos relevantes (dever de informação).

3.1. Aspectos Gerais

O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; pelos atos praticados pelo administrador em nome da

sociedade, responderá a própria sociedade.

Responde o administrador pessoalmente (com seu próprio patrimônio) perante a sociedade e seus sócios, e/ou em face de terceiros, pelos prejuízos que causar quando proceder (i) dentro de seus poderes e atribuições, com culpa ou dolo, ou (ii) com violação da lei ou dos limites impostos pelo contrato social.

O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, ao conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembleia/reunião de sócios da sociedade.

Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da sociedade (exemplo: levantamento das demonstrações financeiros na época própria), ainda que, pelo contrato social, tais deveres não caibam a todos eles.

A legislação nacional refere-se diretamente, em cada uma de suas disposições, aos deveres de probidade, integridade, coerência, conhecimento, diligência, honestidade, transparência, zelo, boa-fé. São deveres do Administrador que estão intimamente relacionados com a ética e compliance, essência de um Programa de Compliance efetivo.

3.2. Aspectos Societários

A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta a responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que os receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade. Ademais, responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria do capital social.[99]

3.3. Aspectos Trabalhistas

De acordo com os tribunais brasileiros, o empregado não deve ficar exposto aos riscos do empreendimento empresarial; cabe aos sócios, que auferem os resultados (lucro) da atividade empresarial, assumir a responsabilidade quando a pessoa jurídica se mostrar incapaz de cumprir suas obrigações trabalhistas. Todavia, os tribunais brasileiros (com fundamento no artigo 1.016 do Código Civil “os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções”) autorizam, por vezes, a execução de bens particulares do administrador, caso ele tenha atuado em desconformidade com a lei ou o contrato social e a sociedade não disponha de bens suficientes para responder pelos débitos laborais.

3.4. Aspectos Tributários/ Previdenciários:

Os administradores de uma sociedade podem ser considerados pessoalmente responsáveis pelo pagamento de créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei ou do estatuto social. Embora a obrigação de recolher tributos seja da empresa (contribuinte), o Fisco defende a tese de que a falta de recolhimento de um tributo, na forma e prazo definidos por lei, constitui em si uma infração à lei, geradora da responsabilidade de administradores. Embora controversa, essa tese é, por vezes, aceita pelos tribunais brasileiros, notadamente em caso de dissolução irregular da sociedade e na ausência de bens que possam garantir a execução de suas dívidas fiscais.

3.5. Desconsideração da Personalidade Jurídica

Segundo a lei brasileira, a personalidade jurídica não será considerada nula, mas apenas desconsiderada com referência ao caso específico levado a juízo, permitindo que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores e sócios da pessoa jurídica. A desconsideração aplica-se em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (utilização da sociedade para fins estranhos ao seu objetivo

social), ou pela confusão patrimonial (utilização de bens ou direitos da sociedade em proveito de seus acionistas e/ou administradores).

Outros aspectos relativos à desconsideração da personalidade jurídica estão relacionados à legislação de proteção do consumidor, do meio-ambiente e da concorrência e a jurisprudência dos tribunais brasileiros, que preveem a possibilidade de desconsideração da personalidade quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação do contrato social. Ademais, referidas leis também estabelecem a desconsideração quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, bem como nos casos em que a personalidade da sociedade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados.

As hipóteses de desconsideração referem-se diretamente, da mesma forma, a todas as questões inerentes à aplicação prática de princípios e valores de integridade perante a sociedade, pelos administradores, como líderes e responsáveis que são.

A lei de concorrência (antitruste) brasileira apresenta uma lista de violações contra a ordem econômica; em situações de violações causadas direta ou indiretamente pelos administradores da pessoa jurídica, eles poderão estar sujeitos a uma multa pessoal e exclusiva definida em uma porcentagem da multa aplicável à pessoa jurídica.

3.6. Aspectos Criminais

O Código Penal brasileiro não prevê a responsabilidade penal dos administradores em qualquer capítulo especial, mas tipifica certas condutas que podem atingir os administradores da empresa.

Não obstante os crimes previstos no Código Penal, a responsabilidade penal dos administradores é aplicada mais especificamente em caso de crimes contra a economia popular (Lei nº 1.521/51), crimes contra a ordem tributária e econômica (Lei nº 8.137/90), crimes contra a propriedade intelectual e a concorrência desleal (Lei nº 9.279/96).

É importante mencionar que a lei brasileira (Lei nº 9.983/2000) prevê um tipo específico de desfalque conhecido por apropriação indébita previdenciária: "Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional".

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) também prevê infrações penais que alcançam os administradores: (i) omissão em informar sobre a periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade; (ii) deixar de retirar os produtos nocivos ou perigosos do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente; (iii) prestar afirmações enganosas acerca das propriedades dos produtos; (iv) deixar de organizar dados técnicos que dão base à publicidade.

A Lei de Falências, por fim, prevê a responsabilidade penal dos administradores na eventualidade de determinados atos tipificados serem praticados e contribuírem com a falência da empresa.

Todas estas questões técnicas e objetivas determinadas pela legislação criminal, quando abarcadas pelo Programa de Compliance, servem como diretrizes para resguardar também direitos dos administradores e da Alta Administração. Sendo, assim, diretamente responsáveis, como não se preocupariam em assegurar a aplicação de normas voltadas à integridade?

Conclusão

O Comprometimento e o Apoio da Alta Administração, no âmbito de um Programa de Compliance, pode ser considerado o pilar fundamental para a efetividade do programa, seja para a incorporação da cultura ética, seja para a sua validade perante órgãos reguladores.

A comprovação da existência de comprometimento se torna simplificada quando, dentro de uma organização, a aplicação cotidiana de valores e princípios está incorporada. Objetivos estratégicos, neste sentido, devem estar inteiramente integrados às metodologias adotadas pelo Programa de Compliance para mitigação de riscos, ou definição de apetite a riscos. Tais sistemas de controle interno não podem se distanciar da realidade prática do negócio, porém também não podem passar desapercebido pela Alta Administração.

No decorrer da evolução de normas e diretrizes para a adoção de sistemas de gestão, a incorporação da ética e da integridade nos modelos de negócios tornou-se e vem se tornando cada vez mais uma condição obrigatória. A adoção, ou melhor, a promoção de negócios éticos e íntegros que levem em consideração partes interessadas, a legislação, as políticas internas e, em suma, que possam concretizar a missão, a visão e objetivos declarados pela empresa dentro dela e para o mundo configuram a possibilidade de tornar a sociedade cada vez mais sustentável, ainda que dentro de um mundo competitivo.

O Comprometimento e o Apoio da Alta Administração com o Programa de Compliance ocorre, portanto:

- Através do Comportamento da Alta Administração em relação a valores e princípios declarados, afirmando-os constantemente dentro da organização;
- Através da disponibilidade da Alta Administração em conhecer os requisitos do Programa e alinhá-los com a estratégia da organização, admitindo, em qualquer circunstância, que em integridade não há negociação;
- Através verdadeira consciência, ou ciência, da Alta Administração de que a responsabilidade pela tomada de decisão no sentido da ética e integridade dentro de uma organização a ela lhe cabe, seja para a efetividade do programa, seja perante as consequências juridicamente estabelecidas.

Referências Bibliográficas

ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS (ACFE). Disponível em: <http://www.acfe.com/>.

ETHICS AND COMPLIANCE INITIATIVE (ECI). Disponível em: <https://www.ethics.org>.

GLOBAL COMPLIANCE NEWS. Disponível em: <http://globalcompliancenews.com/>.

HEALTH CARE COMPLIANCE ASSOCIATION. Disponível em: <http://www.hcca-info.org>.

INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION. Disponível em: <https://www.int-comp.org/>.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF RISK AND COMPLIANCE PROFESSIONALS – <http://www.risk-compliance-association.com/>.

LEGAL ETHICS AND COMPLIANCE (LEC). Disponível em: <http://www.lecnews.com/web/#>.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OECD). *Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business*. Disponível em: <http://www.oecd.org/corruption/anti-corruption-ethics-and-compliance-handbook-for-business.htm>.

SOCIETY OF CORPORATE COMPLIANCE AND ETHICS (SCCE). Disponível em: <http://www.corporatecompliance.org/>.

_____. *The Compliance and Ethics Manual*, 2015.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Disponível em: <http://www.transparency.org/>.

Capítulo 5

Pilar 2 – *Risk Assessment*
Metodologia de Análise de Riscos para Conformidade Legal

Gustavo Lucena[100]

Introdução

Com mais de 4.000 mudanças na legislação brasileira ocorridas nos últimos 02 anos, as normas aplicáveis a cada organização variam de uma para outra, dependendo do tipo de indústria, natureza e protocolos comerciais. Toda organização tem a responsabilidade de identificar a legislação existente para seus negócios e garantir que os riscos regulatórios que possam surgir dos requisitos de conformidade sejam bem compreendidos pelo conselho de administração, comitê de auditoria, alta administração e alta gerência.

Os riscos que podem resultar em uma conformidade com as principais regulamentações podem ser muito onerosos e prejudiciais para uma organização e para os responsáveis pela governança e pela administração da organização. As consequências da não conformidade variam de penalidades e multas à prisão, retirada de licenças, litígios e risco de reputação que podem individualmente e/ou coletivamente ter um impacto fundamental sobre a sustentabilidade da organização; bem como o impacto que a falta de boa governança corporativa nos níveis de diretoria e negócios pode ter na organização.

O impacto e a probabilidade dos riscos que a legislação representa dependem da atenção dada à legislação e de quão bem o tratamento do risco e o *compliance-officer* estão presentes na organização. Portanto, é essencial que uma organização implemente estruturas e processos relevantes para gerenciar e monitorar com eficiência o processo de conformidade, a fim de garantir que eles estejam arraigados de forma que a conformidade seja incorporada nos processos normais de negócios.

O risco residual relacionado a toda a legislação permanecerá alto até que a organização seja capaz de implementar medidas ou controles que efetivamente mitiguem os riscos decorrentes dos requisitos de conformidade, especialmente em relação à nova legislação. Quando uma nova legislação é sancionada e publicada, o risco inerente sempre será alto, pois as falhas operacionais têm uma probabilidade/ probabilidade maior de ocorrer na organização.

1. Funções e Responsabilidades na Gestão da Conformidade Regulatória

A incorporação da gestão de riscos de conformidade para toda a legislação-chave da organização é uma função de certas atividades críticas e decorre da colaboração entre as principais funções de governança, como Jurídico, Compliance, Gerenciamento de Riscos e Auditoria Interna. Todas essas funções fazem parte das “três linhas de defesa” dentro de uma organização. Os negócios e sua gestão operacional, no entanto, também formam uma linha de defesa crítica (se não a mais importante) para garantir uma organização “compatível”. O sucesso de qualquer *compliance-officer* e do programa de monitoramento depende da existência, funcionamento e integração dessas linhas de defesa no desempenho de suas funções. Estas três linhas de defesa, bem como uma visão geral de suas principais responsabilidades, estão descritas no diagrama abaixo:

Figura 1: Metodologia Deloitte: Integrating Risk Advisory and Assurance

1.1. 1ª Linha de Defesa - Garantia de Gestão

- Auxilia na definição e execução de estratégias;
- Fornece direcionamento, orientação e supervisão;
- Promove uma forte cultura de risco e um pensamento de risco-retorno sustentável;
- Promove uma forte cultura de conformidade e gerenciamento da exposição ao risco;
- Implementa controles;
- Implementação da melhoria contínua de controles e gerenciamento de riscos.

1.2. 2ª linha de defesa – Gestão de Riscos, Jurídico e Compliance-Officer

- Gestão de riscos formal, robusta e eficaz, dentro da qual as políticas da organização e padrões mínimos são definidas;
- Interpretação dos requisitos de conformidade regulamentar;
- Supervisão objetiva e desafio contínuo de mitigação de riscos, gerenciamento e desempenho, enquanto os relatórios consideram o envolvimento de todas as unidades de negócios;
- Supervisão global do risco em todos os tipos de risco;
- Monitoramento contínuo da Gestão de Riscos, Jurídico e Compliance-Officer;
- Gestão de Riscos, Jurídico e Compliance-Officer assessoram a 1ª linha de defesa.

3ª linha de defesa – Auditoria Interna e outras formas independentes de *Assurance*/ Garantia

- Garantia independente e objetiva da adequação e eficácia geral da governança, gestão de riscos e controles internos dentro da organização, conforme estabelecido pela 1ª e 2ª linhas de defesa;
- Capacidade de vincular os riscos de negócios aos processos estabelecidos e garantir a eficácia dos planos de mitigação para gerenciar com eficácia os riscos organizacionais.

É responsabilidade da função do Compliance-Officer e do Jurídico estimular e capacitar o conselho de administração, comitê de auditoria, alta administração e alta gerência sobre a legislação pertinente à organização. A função do Compliance-Officer e do Jurídico deve contemplar:

- Compilar e manter um universo regulatório para a organização;
- Facilitar a priorização dos esforços da companhia com base nos riscos de todas as regulamentações no seu mapa de universo regulatório. Isso deve ser feito trabalhando em conjunto com a equipe de gerenciamento de riscos e usando a estrutura de gerenciamento de riscos da organização;
- Iniciar e gerenciar projetos para cumprir novos requisitos regulamentares dentro da organização. Primeiro, é necessário rever o regulamento para confirmar se este de fato afeta a organização e como;
- Analisar e enviar alertas sobre o novo regulamento para informar a organização destes novos requisitos, juntamente com os prazos para a organização de adequar à nova regulamentação;
- Facilitar uma revisão executiva do regulamento pelo Jurídico ou escritórios de advocacia externos;
- Facilitar a conclusão de um Plano de Gerenciamento de Risco de Conformidade interpretando a legislação-chave em linguagem simples e assegurando a identificação de problemas a serem enfrentados pela organização para estar em conformidade com a nova regulamentação, controles, exposição ao risco, partes responsáveis e planos de monitoramento por outras partes participantes, como área de Negócios e Auditoria Interna;
- Encaminhar questões de conformidade para a alta gerência;
- Realizar relatórios regulares de conformidade com reporte direto à governança da companhia.

2. Metodologia e Programa de Avaliação de Riscos de Conformidade para dar suporte às Funções e Responsabilidades do *Compliance-Officer*

Para que o *compliance-offcer* consiga compilar e manter um universo regulatório para a organização com foco e priorização nos riscos regulatórios considerados-chave, é necessário ter uma metodologia e um programa de avaliação de riscos de conformidade aprovado pela governança da companhia e aceito pela Alta Administração e Alta Gerência.

Esta metodologia deve considerar a identificação e avaliação regulares e sistemáticas dos riscos regulatórios. Depois que a companhia identifica e prioriza os seus riscos, ela desenvolve e implementa um plano de ação para controlar, minimizar ou excluir os riscos. O ponto de partida para a avaliação de risco é o desenvolvimento de um inventário de risco de conformidade a partir do qual a classificação de riscos é desenvolvida. Uma metodologia de inventário de risco precisa ser desenvolvida para fornecer assistência no desenvolvimento de um inventário de risco de conformidade e na condução das fases iniciais de uma avaliação de risco de conformidade para todos os negócios companhia e em todas as localidades.

Quando do levantamento do risco regulatório, somente deve ser cadastrado Matriz Regulatória aquelas legislações que constarem algum indicativo de que esta lei ou regulamento é considerado como sendo crítico para a companhia em estar em conformidade. Os critérios para se considerar que uma lei ou regulamento pode ser considerado crítico estão descritos mais a seguir.

Quando do levantamento requerimentos regulatórios, todas as informações que possam dar margens a erros operacionais (intencionais ou não intencionais) deverão ser considerados como sendo críticos para ser estar em conformidade e deverão ser cadastrados na respectiva Matriz Regulatória. Diversos são os critérios para se considerar que uma lei ou regulamento pode ser considerado crítico, para este capítulo citamos somente os principais que são facilmente adaptados para qualquer segmento de negócio e estão citados mais a seguir.

2.1. Possuam Algum Impacto para a Companhia

- **Impacto na base de clientes**: impacto que a lei/regulamento tem nos clientes (exemplo, se a legislação identificada for de uma seção do Código de Defesa do Consumidor o impacto poderá ser médio ou alto).

- **Impacto no portfólio de negócios**: estabelecer se a lei/regulamento identificada possui impacto na forma de se fazer negócios ou licença para se operar.
- **Sanções possíveis, potenciais e eventuais multas severas** (perdas da licença): penalizações previstas pela lei, que podem ocorrer.
- **Potenciais perdas consequenciais** (contencioso/compensação/reputação): perdas financeiras que podem ocorrer.
- **Sanções aos administradores**: a lei/regulamento prevê alguma culpabilidade dos administradores nas esferas cível, criminal e societário.

2.2. Possuam Alguma Probabilidade de Acontecer na Companhia

- **Complexidade e clareza do regulamento**: determinar o risco em escala do entendimento do regulamento.
- **Lei ou Regulamento novo ou recentemente alterado**: determinar a probabilidade (alto, médio, baixo) em função de ser um regulamento novo ou de alteração recente.
- **Complexidade das Características do Produto**: alto, médio, baixo para estabelecer se a lei/regulamento afeta mais de um processo dentro de uma cadeia de valor de um produto aumentando o risco do seu possível não cumprimento por haver mais de um processo envolvido dentro e fora da companhia.
- **Risco Operacional devido à dependência de processos complexos ou manuais**: determinar (alto, médio ou baixo) a probabilidade de exposição ao risco de não cumprir a lei/regulamento em função de processos trabalhosos, complexos ou com grandes quantidades de inputs manuais.
- **Volume elevado de reclamações de Clientes**: probabilidade de ocorrências de muitas reclamações de clientes caso a organização se exponha ao não cumprimento da lei/regulamento.
- **Área identificada de preocupação/interesse regulatória(o)** (de toda indústria ou negócio específico): alto, médio, baixo para estabelecer se a lei/regulamento está sempre sendo mencionada pela mídia, pelos auditores externos, pelos órgãos fiscalizadores/reguladores e pelas agências de rating nas empresas do Grupo e/ou pelo mercado no mesmo segmento de atuação.
- **Houveram não conformidades identificadas nesta legislação/regulamento ou que estão em processo de fiscalização ou em relatórios de inspeção recentes (2 anos) ou sujeito a repetir a não conformidade**? determinar se a probabilidade de ocorrência é alta, média ou baixa neste caso.

2.3. Risco Regulatório Residual

Para se proceder a avaliação do risco residual em relação ao risco de conformidade após o levantamento regulatório deve-se efetuar perguntas para cada gerente e administrador na companhia em relação a lei/regulamento:

- Tenho total certeza de que esta obrigação e requerimento se aplica ao nosso produto?
- O que fazemos para estar em conformidade com esta obrigação e requerimento?
- Qual a nossa percepção de risco de não estar em conformidade com esta obrigação e requerimento?
- Como garantimos que estamos em conformidade?
- Tenho políticas e procedimentos formais e atualizados que enderecem os temas abordados na lei/regulamento?
- Existem controles internos nos processos e atividades direta e indiretamente relacionada a lei/regulamento?
- Os profissionais que executam os controles internos foram treinamentos nos últimos 12 meses em relação as políticas e procedimentos?
- Como monitoro a performance das minhas atividades operacionais para estar integralmente aderente com esta lei/regulamentação?
- Como posso ajuda-lo a aumentar a conscientização do que precisa ser feito?

Com base nas respostas obtidas, na experiência do Compliance-Officer e na tolerância ao risco da governança e alta administração da companhia nas leis/regulamento, no ambiente de controles internos e na cultura de estar em compliance da companhia, deverá ser realizada a avaliação dos riscos de conformidade por meio das etapas a seguir:

- **Identificação de Risco**: Identificar aonde a companhia está posicionada em relação ao risco de não estar em conformidade e as suas causas potenciais.
- **Análise do Risco**: Determinar qual a probabilidade de se não estar em conformidade acontecer e quais seriam as consequências.
- **Avaliação do Risco**: Determinar o nível e o tipo de tratamento necessário para mitigar o risco e o desenvolvimento de um plano de ação (controles, treinamento, terceirização etc.).

2.4. Gestão Eficiente do Risco Regulatório Residual

Após a conclusão da avaliação de riscos de conformidade se inicia o desenho do Programa Compliance Regulatório e as atividades necessárias para a execução deste programa. Para a realização do desenho do Programa de Compliance Regulatório e suas respectivas atividades determinadas informações precisarão ser obtidas para cada lei/regulamento identificado pela companhia:

- Área responsável pelo controle do processo para se estar em conformidade;
- Nome do gestor;
- Profissionais a serem treinamentos nas políticas e procedimentos;
- Narrativa do controle e frequência da execução do controle;
- Monitoramento do controle executado;
- Teste de conformidade a ser aplicado diretamente sobre o controle identificado.

Concluído o Programa de Compliance Regulatório e de atividades necessárias para a execução deste programa deverá ser efetuada uma marcação, para cada teste, se áreas de Negócios, de Controles Internos, de Gestão de Riscos, Jurídico e Auditoria Interna já realizam algum teste de conformidade e que se possa programar sinergias de atuação entre a área de Compliance e as demais áreas.

Validada a sinergia entre as demais áreas, poderão ser desenhados *Key Compliance Risk Indicators* (KCRI) para cada teste de conformidade, caso este seja passível de apuração/identificação poderá realizada pela auditoria interna e pelo compliance:

- Execução dos testes de conformidade previstos no Programa de Compliance Regulatório.
- Desenho do modelo de gestão de consequência com base no Programa de Compliance Regulatório.
- Relatório das exceções identificadas
- Preenchimento completo da Matriz Regulatória.

Conclusão

Com o atual cenário de negócios, onde a legislação emerge e muda continuamente com requisitos crescentes para manter os negócios no caminho certo, é fundamental que todas as organizações implementem estruturas adequadas e eficazes para incorporar uma cultura de conformidade regulatória.

Os *Compliance-Officer's* devem assumir a responsabilidade de se familiarizar com o universo legislativo de suas organizações e auxiliar no fornecimento de garantias de que as estruturas e processos são adequados e eficazes para mitigar os riscos de conformidade regulatória e os membros do conselho de administração, do comitê de auditoria, da alta administração e da alta gerência estão cientes do seu dever de diligência em relação a estas leis/regulamentos e suas responsabilizações para os casos de não cumprimento.

Capítulo 6

Pilar 2 – *Compliance Risk Assessment*
Análise de Caso de Participação em Licitações e Contratos Públicos

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha[101]
Rodrigo Pironti Aguirre de Castro[102]

Introdução

Dada a sintaxe do risco: *devido ao recebimento de vantagens indevidas por membros da administração pública licitante, poderá ocorrer fraude no processo licitatório, o que poderá ocasionar a aquisição de produtos e/ou serviços com valores destoantes do mercado (sobrepreço ou inexequíveis)*.

Se sua percepção inicial não permitiu, de maneira rápida e clara, o conhecimento sobre quais os passos que você deverá tomar para obter o resultado pretendido, ou melhor, o resultado exigido pela Lei nº. 8.666/1993 (Lei de Licitações), Lei nº. 10.520/202 (Lei do Pregão) e Lei nº. 13.303/2016 (Lei das Estatais), conjugadas com a Lei nº. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e suas regulamentações, a análise realizada neste breve artigo seguramente importará à sua atividade.

1. Sistema de Compras Públicas x Sistema Anticorrupção

O sistema de compras públicas no Brasil é bastante complexo. A Constituição Federal de 1988, que no artigo 37 estabeleceu os princípios da administração (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). No inciso XXI do mesmo artigo estabeleceu que "as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".[103]

Em meio a um emaranhado de normas no âmbito da União, dos estados, municípios e do Distrito Federal, merece destaque a Lei Federal nº. 8.666/1993, que regulamenta o artigo constitucional supramencionado e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e a Lei Federal nº. 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Por fim, a Lei Federal nº. 13.303/2016 estabeleceu o regime de contratação no âmbito das empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista).

1.1. A Cláusula de Matriz de Risco nos Contratos Administrativos das Estatais

O mês de junho de 2018 foi o marco temporal para a obrigatoriedade de implantação de uma efetiva gestão de riscos e compliance nas Empresas Estatais, ainda que não sejam consideradas de "grande porte" (acima de 90 milhões de receita bruta anual). Essa regra, pela intelecção do artigo primeiro, parágrafo primeiro; conjugado ao artigo sexto, é cogente a toda e qualquer estatal a partir de 30 de junho de 2018[104]. Ou seja, qualquer estatal, para além da criação de estruturas práticas de gestão de risco e compliance, deverá incluir nos anexos de seus contratos, uma efetiva e necessária matriz de riscos (incluindo, a análise de eventos de risco de *Compliance*).[105]

Para elaborar a matriz de risco como cláusula contratual, é necessário mapear e identificar os riscos. Neste trabalho podemos citar três grandes categorias de riscos: (i) riscos de origem externa; (ii) riscos operacionais; (iii) e riscos estratégicos. Todos eles, passíveis de conjugação aos chamados riscos de compliance ou de integridade. Para identificar os riscos dentro desses três grandes agrupamentos, é necessário valer-se de técnicas genéricas de identificação de riscos, tais como registro de riscos, entrevista com especialistas, *brainstorming*, *slip* de *crawford* entre outros.

Nesta nova sistemática, os riscos não devem ser alocados de forma aleatória pela Estatal, mas, ao contrário, devem ser alocados de forma racional e eficiente, de acordo com a maior ou menor capacidade de cada um dos parceiros em mitigá-los. Assim, deve-se buscar imputar cada um dos riscos à parte que, ao menos em tese, tiver maior condições de evitá-los, mitigá-los ou eliminá-los a um menor custo, onerando de forma mínima a execução contratual. Daí porque a repartição objetiva de

riscos não impõe uma distribuição *equivalente* de riscos, mas sim, uma distribuição *equitativa,* de base *racional*, alocando-se a cada parceiro os riscos que podem individual e mais eficientemente gerir.

Deve-se tomar cuidado, nessa medida, para que a alocação de riscos ao privado não seja excessiva a ponto de onerá-lo em demasia, obrigando-o a assumir e mitigar riscos que seriam muito melhor absorvidos pela Estatal. Tal situação fatalmente desembocaria em casos como uma excessiva oneração do contrato, à medida que quanto mais riscos o particular assumir, maior será o custo exigido para geri-los.[106]

Por outro lado, é igualmente certo que os riscos não são todos previsíveis e antecipáveis pela Administração Pública no momento da licitação – senão não haveria que se falar em teoria da imprevisão e álea extraordinária, expressamente referidas no próprio artigo quinto, inciso terceiro da lei 13.303/16. Diante disso, a nova sistemática não elimina a possibilidade de ocorrência de eventos imprevisíveis (e nem teria como, ainda mais num contrato de longa duração),[107] mas ao menos determina que já se proceda de antemão a indicação de quem será o responsável por arcar com cada espécie de imprevisibilidade – podendo tal indicação ser revisada ao longo do contrato, em períodos previamente estipulados na política de gerenciamento de riscos da Estatal.

1.2. Normas Anticorrupção Relacionadas às Compras Públicas

Além da complexidade normativa e procedimental acima destacada, a Lei Federal nº. 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, trouxe um impacto exponencial às organizações que participam de licitações ou celebram contratos com administração pública. Prevendo sanções severas no âmbito administrativo (multa de até 20% do faturamento bruto e publicação da decisão condenatória) ou judicial (perdimento de bens, suspensões de benefícios públicos e até mesmo dissolução compulsória), a norma permite aplicação subsidiária das leis de licitações e suas penas, como aquelas previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/1993 (multa contratual, suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar por prazo até 2 anos e declaração de inidoneidade).

Algumas hipóteses de violação da Lei Anticorrupção, elevam a probabilidade de aplicação da norma em relação às empresas que licitem ou celebrem contratos com a administração pública, como àquelas descritas no inciso I e inciso IV, do artigo 5º.[108] Assim, com o objetivo de prevenir, *detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira*, que possam ensejar a aplicação da referida lei, deve a pessoa jurídica a ela sujeita, implementar um programa de integridade, que consiste no *conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes*, conforme previsão do art. 41 do Decreto Federal nº. 8.420/2015, que regulamentou a Lei Anticorrupção no âmbito da União, e que foi replicado na grande maioria das normas relacionadas a Compliance Anticorrupção no Brasil.[109]

Ademais, algumas unidades da federação passaram a adotar normas que exigem dos contratantes com a administração pública local, a implementação de Programas de Integridade após a assinatura do contrato pública, sob pena de multa (de natureza diversa da cláusula penal) e impedimento de contratar. Essa imposição já é uma realidade no estado do Rio de Janeiro (Lei nº. 7.753/2017) e no Distrito Federal (Lei nº. 6.112/2018).

Dessa maneira, um excelente caso prático para ser trabalhado na *análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade*, com o objetivo de prevenir a aplicação da Lei Anticorrupção, suas regulamentações ou desdobramentos, está relacionado a licitações e contratos públicos.

2. Passo a Passo para a Elaboração da Matriz de Risco de Integridade para Empresas que Licitem ou Celebrem Contratos Públicos

Talvez um dos temas mais complexos em se tratando de gerenciamento de risco, seja o tema da elaboração de uma efetiva matriz de riscos, não só pela dificuldade natural de se conceber uma possível matriz, mas também, pelo conflito conceitual existente entre o que pode ou não pode ser considerado uma matriz de risco nos contratos.

Aqui já lançamos a primeira observação importante, quando a Lei das Estatais prevê a necessidade de previsão de uma matriz contratual, o faz tendo em vista a necessidade de se mapear e mitigar riscos potenciais e aferíveis em uma escala de priorização, portanto, em nossa concepção, não aceita que sejam lançados mapas de riscos ou tabelas de *check-list*, como se matriz fossem. Mapas de riscos (registros de riscos) e *check-lists* são processos de identificação de riscos e não matriz.

Tendo certo que existe a necessidade de priorização dos riscos contratuais, para que seja possível tratá-los adequada e oportunamente, resta entender, de acordo com a metodologia de formação da matriz de riscos, qual aquela que se adequa melhor à realidade dos contratos firmados pelas estatais (e em larga escala, pela Administração Pública de maneira geral).

2.1. Metodologia: Impacto x Probabilidade

A matriz de impacto x probabilidade, não só pelo seu fundamento em apuradas metodologias de gestão de riscos (COSO ERM 2017, ISO 31000:2018, dentre outras), mas por sua adequação à logica dos riscos passíveis de enfrentamento em um contrato administrativo, parece ser aquela que melhor se adequa à esta nova exigência legal, qual seja, da previsão de uma efetiva matriz de risco como parte integrante dos contratos firmados.

Uma matriz de impacto x probabilidade, como o próprio nome induz, irá aquilatar e conjugar dois critérios para a obtenção do nível de riscos: um critério de impacto e outro de probabilidade. A conjugação destes dois critérios em um diagrama de cálculo de riscos, permitirá a confirmação do nível de risco da atividade verificada e, a depender do apetite de riscos da Entidade, determinará sua correção ou aceitação.

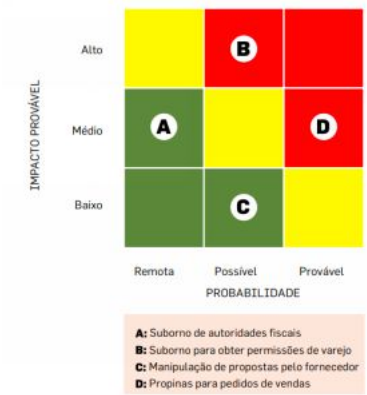


Figura 1: Matriz Impacto x Probabilidade[110]

2.2. Estabelecimento dos Critérios de Avaliação

Como destaca o Pacto Global das Organização das Nações Unidas, “para alocar recursos eficiente e eficazmente para os riscos de corrupção identificados em uma empresa e os esquemas correlatos, uma boa prática é classificar conjuntamente a probabilidade de ocorrência de cada esquema e o correspondente impacto potencial desta ocorrência. O objetivo é dar prioridade às respostas a esses riscos de corrupção em um formato lógico, com base em uma combinação da sua probabilidade de ocorrência e seu impacto potencial”.[111]

A escala de impacto, que determina o grau de afetação do evento de risco no objetivo da Entidade, pode ser qualitativa ou quantitativa, a depender o interesse e do nível de maturidade do gerenciamento de risco da entidade. Para auxiliar na visualização do tema, vejamos o primeiro quadro[112]:

ESCALAS DE IMPACTO DE MATERIALIZAÇÃO DO RISCO Análise em 5 níveis com critérios	

quantitativos e qualitativos		
Nível de Impacto	**Critério Quantitativo**	**Critério Qualitativo**
Muito Alto (5 pontos)	De 10% a 20% da receita operacional bruta	Danos complexos que impedem a operação da empresa; danos de elevadíssimo custo ou de improvável reparação; repercussão muito alta na mídia nacional e internacional; repercussão perante órgãos reguladores com multas e indenizações diversas ou de valores incertos.
Alto (4 pontos)	De 5% a 9% da receita operacional bruta	Danos complexos que afetam a operação da empresa; danos de elevado custo ou de incerta reparação; repercussão muito alta na mídia nacional e local; repercussão perante órgãos reguladores com multas e indenizações de valores elevados.
Médio (3 pontos)	De 2% a 4% da receita operacional bruta	Danos que atrapalham a operação da empresa; danos de alto custo ou reparação; repercussão moderada na mídia nacional e local; repercussão perante órgãos reguladores com multas e indenizações de valores altos.
Baixo (2 pontos)	De 0,5% a 1% da receita operacional bruta	Danos de fácil reparação à operação da empresa; repercussão moderada na mídia local; repercussão perante órgãos reguladores com multas e indenizações de valores moderados.
Muito Baixo (1 ponto)	Abaixo de 0,5% da receita operacional bruta	Danos de muito fácil reparação ou insignificante à operação da empresa; repercussão baixa ou despercebida na mídia local; pouco ou nenhuma repercussão perante órgãos reguladores com multas e indenizações de valores insignificantes.

Já a probabilidade, decorre dos níveis de possibilidade que o evento (risco) possa se materializar. Na terminologia de gestão de riscos, a palavra "probabilidade" é utilizada para "referir-se à chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada, ainda que objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, e se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (como probabilidade ou frequência durante um determinado período de tempo)".[113] Assim, da mesma forma que ocorre com a classificação das escalas de impacto de materialização dos riscos (vide tabela supra), a classificação das escalas de probabilidade de materialização dos riscos também pode (deve) seguir critérios quantitativos e qualitativos. Vejamos o exemplo abaixo:

ESCALAS DE PROBABILIDADE DE MATERIALIZAÇÃO DO RISCO Análise em 5 níveis com critérios quantitativos e qualitativos		
Nível de Probabilidade	**Critério Quantitativo**	**Critério Qualitativo[114][115]**
Muito Alto (5 pontos)	Evento acontece mais de 12 vezes ao ano.	Evento esperado que ocorra, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.
Alto (4 pontos)	Evento acontece entre 6 e 12 vezes ao ano.	Evento provavelmente ocorra, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.
Médio (3 pontos)	Evento acontece entre 3 e 5 vezes ao ano.	Evento deve ocorrer em algum momento, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.
Baixo (2 pontos)	Evento acontece entre 1 e 2 vezes ao ano.	Evento pode ocorrer em algum momento, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.
Muito Baixo (1 ponto)	Evento acontece menos de 1 vez ao ano.	Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.

Definida a metodologia (Matriz Impacto x Probabilidade), os riscos a serem analisados, avaliados e geridos (em nosso caso aqueles descritos no art. 5º, inciso I e IV, da Lei Anticorrupção), assim como os critérios de avaliação (escala de impacto e probabilidade), caberá ao *gestor dos riscos*[116] fazer sua analisa individualizada (análise de risco inerente), para na sequência contrapô-la ao gestor do processo afetado pelo risco (análise de risco residual).

2.3. Análise de Riscos Inerentes

De acordo com a Controladoria-Geral da União, o risco inerente "é aquele que uma organização está exposta sem considerar quaisquer medidas de controle que possam reduzir a probabilidade de

sua ocorrência ou seu impacto”.[117]

Na escala de impacto qualitativa, o que interessa ao gestor dos riscos é estabelecer parâmetros subjetivos de análise sobre a atividade analisada. Vê-se, claramente em razão dos níveis de riscos em uma escala de 1 a 5, que o grau de priorização será obtido por uma análise subjetiva do gestor, o que não é negativo, tendo em vista que a decisão subjetiva obviamente estará pautada em análises históricas e de melhor atendimento ao interesse da Entidade.

A escala de impacto quantitativa, levará em conta aspectos mensuráveis de forma objetiva nas atividades/cláusulas contratuais analisadas, como critérios de preço, prazo, objetivo, qualidade aferível, para que seja possível se determinar o nível de risco dentro de cada um dos aspectos analisados.

Obviamente que, neste caso, para uma melhor aplicação da própria matriz, será necessário para a formação do nível de risco analisado, que a entidade determine exatamente qual critério foi objeto de sua opção quantitativa, uma vez que seria bastante mais complexo a conjugação desses fatores para a formação do nível de risco[118].

Realizada a análise da escala de impacto, cabe ao gestor anotar o nível de risco encontrado para aquela atividade e confrontá-lo com a escala de probabilidade.

É a escala de probabilidade, que determinará qual a frequência de ocorrência do evento de risco identificado, para que seja possível prever a maior ou menor preocupação em enfrentá-lo e terá uma analise também pautada por critérios objetivos, ou seja, pelo número (real ou percentual) de acontecimentos de determinado evento de risco em razão do atingimento do objeto pretendido.

Após realizada esta análise, o gestor do risco também anotará seu resultado, para confrontá-lo, desta vez, com o nível de risco encontrado na escala de impacto. Com esses dois critérios aferidos, será possível o cotejo dos níveis de riscos no denominado “diagrama de cálculo de risco”.

É o resultado do diagrama de cálculo de risco que indicará qual o nível de risco a que está exposta a Entidade em razão do evento identificado. Por esta razão, não se pode confundir a matriz de risco com procedimentos simplificados de identificação de riscos, como é o caso do mapa de risco, registro de risco, *check-lists* dentre outros.

Veja que a composição numérica encontrada no diagrama também segue uma lógica de objetivação do risco, pois a multiplicação dos níveis de risco encontrados em suas escalas de impacto e probabilidade, permitem uma priorização objetiva na matriz de quais riscos serão enfrentados de maneira prioritária ou preferencial, ainda que dentre de um mesmo nível de risco no diagrama de cálculo.

Vejamos:

Diagrama de Riscos de Integridade	**PROBABILIDADE**					
Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto		
I M P A C T O	Muito Alto	5 x 1 = 5	5 x 2 = 10	5 x 3 = 15	5 x 4 = 20	5 x 5 = 15
Alto	4 x 1 = 4	4 x 2 = 8	4 x 3 = 12	4 x 4 = 16	4 x 5 = 20	
Médio	3 x 1 = 3	3 x 2 = 6	3 x 3 = 9	3 x 4 = 12	3 x 5 = 15	
Baixo	2 x 1 = 2	2 x 2 = 4	2 x 3 = 6	2 x 4 = 8	2 x 5 = 10	
Muito Baixo	1 x 1 = 1	1 x 2 = 2	1 x 3 = 3	1 x 4 = 4	1 x 5 = 5	

Importante se designar neste momento, também, quais são os níveis de atenção aos riscos que serão inseridos no diagrama. Esse ponto facilita a tomada de decisão em relação à gestão dos riscos, assim como o processo de priorização. Vejamos:

Trivial	Aceitável	Moderado	Crítico	Extremo

Com esses critérios é possível a formação de uma matriz de risco, que ganhará contornos mais ou menos complexos, a depender da maturidade da Entidade e da qualificação do gestor de risco para identifica-lo, descrevê-lo, diagrama-lo e tratá-lo.

2.4. Matriz Impacto x Probabilidade

Nesse ponto já podemos conversar sobre a matriz. Os critérios de uma efetiva matriz de risco, ao menos os critérios idealizados neste texto, deveriam ser estabelecidos dentro da seguinte dinâmica: a) identificação numérica do risco; b) evento de risco identificado (com suas causas e consequências); c) categoria do risco encontrado (para melhor priorizá-lo); d) probabilidade, impacto e cálculo de nível de risco; d) respostas; e) controles; e f) responsáveis pelos riscos. A sua visualização seria, tratando-se dos critérios de análise, a seguinte:

ID	DESCRIÇÃO	P	I	NR (PxI)	RESPOSTA	CONTROLE	
EVENTO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA					

Voltemos à sintaxe de risco dada no problema (após a sua devida identificação e descrição[119]): *Devido ao recebimento de vantagens indevidas por membros da administração pública licitante, poderá ocorrer fraude no processo licitatório, o que poderá ocasionar a aquisição de produtos e/ou serviços com valores destoantes do mercado (sobrepreço ou inexequíveis)*.

Como estabelecer uma matriz de risco de compliance nos contratos para esta sintaxe? Neste caso, identificado o evento de risco (na primeira hipótese da matriz apresentada abaixo), "poderá ocorrer fraude no processo licitatório", o primeiro passo seria descrever na matriz qual a causa do risco para seu registro histórico, que neste caso, foi fixada como sendo o "recebimento de vantagens indevidas por membros da administração pública licitante", em seguida, elencaríamos a própria consequência estimada descrita na sintaxe "aquisição de produtos e/ou serviços com valores destoantes do mercado (sobrepreço ou inexequíveis)".

ID	DESCRIÇÃO	P	I	NR (PxI)	RESPOSTA	CONTROLE
EVENTO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA				
1	Fraude em Licitação	Vantagem Indevida a Agente Público	Multa de 20% sobre o faturamento; Impedimento de contratar			

Diante disso, passaríamos para a classificação do nível de risco na matriz, elegendo em um primeiro momento a estimativa correspondente a probabilidade do evento que, neste caso, ficou avençada, após análise da planilha de probabilidade de ocorrência, como sendo - por exemplo - de "média probabilidade". É dizer, no entender do gestor do risco que a probabilidade, após análise da causa do risco, que ocorrer o evento "*fraude no processo licitatório*" é mediana, pois a empresa participa apenas de cinco licitações no ano.

Em seguida, devemos verificar o critério de impacto, que a depender do objeto da matriz (como antes visto) poderá seguir um critério qualitativo ou quantitativo. Neste caso e abstraindo qual o critério utilizado, o gestor do risco classificou a consequência "*aquisição de produtos e/ou serviços com valores destoantes do mercado (sobrepreço ou inexequíveis)*" como de muito alto impacto. Isso se deve ao fato de que, no caso de materialização dos riscos seria aplicada a Lei Anticorrupção em relação à empresa e com isso, eventuais sanções impostas (multa de até 20% do faturamento bruto, impedimento de contratar com administração pública etc.) estariam dentro dos critérios máximos da escala criada.

ID	DESCRIÇÃO	P	I	NR (PxI)	RESPOSTA	CONTROLE
EVENTO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA				
1	Fraude em Licitação	Vantagem Indevida a Agente Público	Multa de 20% sobre o faturamento; Impedimento de contratar	3	5	15

Esses dois critérios, porém, não permitem uma informação gerencial e uma priorização dos riscos, por isso, nesse momento, é necessário que os resultados encontrados nas duas hipóteses (P x I) sejam lançados no diagrama de cálculo de risco. Feito isso, e considerando uma matriz 5 x 5 (cinco por cinco), chegaremos a um risco alto, com nível de priorização de fator “15” (probabilidade média 3 x impacto muito alto 5). Vejamos abaixo:

Diagrama de Riscos de Integridade	**PROBABILIDADE**				
Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto	
IMPACTO	Muito Alto				
Alto					
Médio					1
Baixo					
Muito Baixo					
Trivial	Aceitável	Moderado	Crítico	Extremo	

2.5. Análise de Risco Residual

Um fator fundamental para se aproximar ao máximo da realidade vivenciada pela organização e, assim, tornar a avaliação mais precisa possível é conversar com os parceiros de negócios internos, responsáveis pelo processo em análise. No caso do nosso exemplo, certamente haverá uma área na empresa responsável pelos processos de licitação e por interação com os agentes públicos designados (órgão demandante da contratação, comissão de licitação etc.). Em regra, mediante entrevistas com as áreas afetadas pelos riscos, que devem ser registradas e documentadas, o gestor dos riscos consegue absorver maiores informações e detalhes que contribuem para uma melhor avaliação dos critérios de impacto e probabilidade.

Por exemplo, conforme expõe o Pacto Global da ONU, alguns dos fatores a serem considerados podem estimar a probabilidade de cada esquema de corrupção, como: a natureza da transação ou processo (por exemplo, se há uma interação com os funcionários de governo); incidentes que ocorreram anteriormente na empresa; incidentes no setor da empresa; a cultura de corrupção no ambiente local; o número de transações individuais; a complexidade do processo e o nível de conhecimento e habilidade exigida para execução; o número de pessoas necessárias; e o número de pessoas envolvidas na aprovação ou análise do processo ou transação.[120]

Ainda, eventuais controles internos já implementados devem ser levados em consideração, desde que sejam efetivos, como *Código de Conduta, Política Anticorrupção e Procedimento Interno de Participação em Licitações e Contratos Públicos.*

Em nosso caso, vamos imaginar que o gestor do Processo de Participação em Licitações e Contratos Públicos da empresa confirme o fato de que a companhia participa de até cinco licitações por ano, o que quantitativamente mantém a probabilidade de materialização do risco no nível médio. No entanto, durante a mesma entrevista, o gestor confirma que em todas as licitações, cestas de Natal com champanhe e caviar foram entregues aos agentes públicos responsáveis pela elaboração do termo de referência (documento interno do órgão da administração pública que dá início a uma licitação e que define o objeto que será contratado e os requisitos técnicos do eventuais fornecedores).

Tais informações, anteriormente desconhecidas, logo desconsideradas na análise de risco inerente, eleva exponencialmente a probabilidade de materialização do risco. Dessa forma, deve ser revista na Matriz de Riscos. Vejamos:

ID	**DESCRIÇÃO**	**P**	**I**	**NR (PxI)**	**RESPOSTA**	**CONTROLE**
EVENTO	**CAUSA**	**CONSEQUÊNCIA**				

1	Fraude em Licitação	Vantagem Indevida a Agente Público	Multa de 20% sobre o faturamento; Impedimento de contratar	5	5	25

Perceba que antes o risco tinha como resultado o fator “15” e pelo diagrama de riscos se classificava como “crítico”. Com a reavaliação pela análise de risco residual o fator foi renumerado para “25” e a classificação como “extremo”. Vajamos o resultado no diagrama:

Diagrama de Riscos de Integridade	**PROBABILIDADE**				
Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto	
IMPACTO	Muito Alto				1
Alto					
Médio					
Baixo					
Muito Baixo					

Trivial	Aceitável	Moderado	Crítico	Extremo

2.6. Gestão dos Riscos

É fundamental que após a realização da avaliação de riscos inerente e residual os resultados sejam catalogados e apresentados à alta administração da organização para que tomem ciência do resultado, assim como daqueles processos que são mais críticos e extremos na organização, afim de que a gestão destes riscos adequada seja imposta a cada um.

De acordo com o Coso, replicado metodologicamente pela Controladoria-Geral da União, a gestão dos riscos pode acontecer de quatro formas:

QUADRO DE OPÇÕES DE TRATAMENTO DOS RISCOS	
Opção de Tratamento	**Descrição**
Mitigar	Um risco normalmente é mitigado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”. A implementação de controles, neste caso, apresenta um custo/benefício adequado. Na CGU, mitigar o risco significa implementar controles que possam diminuir as causas ou as consequências dos riscos, identificadas na etapa de Identificação e Análise de Riscos.
Compartilhar	Um risco normalmente é compartilhado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, mas a implementação de controles não apresenta um custo/benefício adequado. Na CGU, pode-se compartilhar o risco por meio de terceirização ou apólice de seguro, por exemplo.
Evitar	Um risco normalmente é evitado quando é classificado como “Alto” ou “Extremo”, e a implementação de controles apresenta um custo muito elevado, inviabilizando sua mitigação, ou não há entidades dispostas a compartilhar o risco com a CGU. Na CGU, evitar o risco significa encerrar o processo organizacional. Nesse caso, essa opção deve ser aprovada pelo Comitê de Gestão Estratégica.
Aceitar	Um risco normalmente é aceito quando seu nível está nas faixas de apetite a risco. Nessa situação, nenhum novo controle precisa ser implementado para mitigar o risco.

A alta administração deve deliberar pelas estratégias de gestão de cada risco diagnosticado, de acordo com o apetite de risco da organização, que não deve levar em conta apenas os critérios financeiros e operacionais, mas também os riscos de integridade advindos da Lei Anticorrupção e da cultura de integridade que se tem implementado na administração pública nacional. Com isso, o gestor dos riscos deverá estabelecer junto com a área gestora de cada processo afetado pelos riscos, tão logo

proprietária dos riscos, planos de ações para a gestão dos riscos, de acordo com as estratégias de tratamento estabelecidas pela alta administração. Vejamos nosso exemplo:

ID	DESCRIÇÃO	P	I	NR (PxI)	RESPOSTA	CONTROLE
EVENTO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA				
1	Fraude em Licitação	Vantagem Indevida a Agente Público	Multa de 20% sobre o faturamento; Impedimento de contratar	5	5	25

Com isto, é possível mediante o apetite de risco e controles internos estabelecidos, realizar de forma eficaz o controle gerencial dos riscos encontrados, responsabilizando (no sentido de responsividade e não responsabilização) aqueles que são encarregados da atividade de risco analisada. Esta atividade quando executada em todos os eventos de riscos encontrados na fase de identificação do risco, permitirá uma matriz de risco de compliance que acompanhe de forma eficaz as variações (positivas ou negativas) da avença.

Conclusão

É perceptível, portanto, que para a adequação pretendida, as pessoas jurídicas que se relacionam com a administração (todas), não penas as que participam de licitações e contratos públicos, deverão implementar o processo de análise, avaliação e gestão dos riscos de integridade, especialmente previstos pela Lei Anticorrupção, o que chamamos de *Compliance Risk Assessment*.

Este processo permitirá, não apenas a identificação dos riscos de compliance, mas para além disso, a alocação destes riscos em uma efetiva matriz, distante dos *check-lists* e registros de riscos (mapas de riscos) até então utilizados, uma vez que apenas uma real matriz de riscos permite uma análise evolutiva dos riscos de integridade e de sua mitigação.

Após todos os passos demonstrados, a tarefa parece muito mais simples e a matriz, efetivados os critérios sugeridos, passará a se relacionar diretamente entre a alta administração, que conhecerá melhor os riscos de integridade da organização e estabelecerá as estratégias para tratamento (*tone from the top*), e as áreas proprietárias dos riscos, que serão encarregadas de estabelecer os controles para mitigação do riscos e implementá-los na forma estabelecida nos planos de ação, fortalecendo a primeira linha de defesa. Por fim, o gestor dos riscos será efetivamente um gestor e não um executor, podendo dispensar mais do seu tempo para buscar estratégias de implementação de uma cultura de integridade em sua organização.

Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR ISO 31000*, 2018.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. *Matriz de riscos: gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão*. Brasília, 2016.

BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. *Metodologia de gestão de riscos*. Brasília, 2018.

CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; GONÇALVES, Francine Silva Pacheco. *Compliance e gestão de riscos nas empresas estatais*. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION. *COSO Gerenciamento de Riscos Corporativos: Estrutura Integrada*. Jersey City, 2007.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Global. *Guia de avaliação de riscos de corrupção*. Nova York, 2013.

Capítulo 7

Pilar 3 - Código de Ética e de Conduta, Políticas e Procedimentos
Os Documentos Normativos Relacionados ao Programa de Integridade da Empresa

Marilia Zulini da Costa Loosli[121]
Massamitsu Alberto Iko[122]

1. Legislação Aplicável e Objetivos

Conforme o artigo 41 do Decreto Federal nº. 8.420/15 (*Decreto Anticorrupção*), que regulamentou a Lei Federal nº. 12.846/13 (*Lei Anticorrupção*), o programa de integridade de uma empresa consiste "no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de **códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes** com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira".[123]

Dos dezesseis parâmetros de avaliação do programa de integridade descritos no artigo 42, do mencionado Decreto Anticorrupção, três deles referem-se diretamente a padrões de conduta, códigos, políticas e procedimentos de integridade: (i) *inciso II* determina que tais diretrizes e regras devem ser aplicáveis a todos os empregados e administradores da empresa, independentemente de cargo ou função exercidos; (ii) *inciso III* estabelece que tais diretrizes e regras devem ser estendidas a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados, quando necessário; e (iii) *inciso VIII* traz a obrigação de serem implementados procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos em licitações públicas, execução de contratos administrativos e outras interações com o setor público.

Além das determinações legais expostas acima, há vários manuais de melhores práticas que definem como pilar fundamental do programa de integridade da empresa a publicação e implementação de códigos, políticas e procedimentos, além de guias sobre legislações estrangeiras que podem oferecer importantes definições e considerações sobre a eficácia deste pilar no combate a corrupção, como por exemplo:

- Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas, da CGU;[124]
- Manual Prático de Avaliação de Programa de Integridade em Processos Administrativos de Responsabilização, da CGU;[125]
- *Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business*, da OCDE, UNODC e Banco Mundial;[126]
- *A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, do *Department of Justice* (DOJ) e da *Securities and Exchange Commission* (SEC);[127]
- *The Bribery Act 2010 – Guidance (UK Bribery Act),* do *UK Ministry of Justice*.[128]

Quais são os objetivos de códigos, políticas e procedimentos? Entende-se que esses instrumentos têm a missão de *despersonificar* a gestão da empresa, uniformizando comportamentos e processos internos, direcionando condutas, independentemente de crenças e interpretações pessoais dos gestores e colaboradores. Ademais, tais regras escritas, aprovadas e publicadas, em conjunto com outros controles internos, promovem maior segurança aos administradores, investidores e *stakeholders*, uma vez que trazem maior transparência a respeito de como se dá a condução dos negócios da empresa e a relação com colaboradores, clientes, terceiros e o setor público.

Em suma, os códigos, políticas e procedimentos são essenciais para que a empresa alcance a efetividade do programa de integridade. A seguir, serão abordos aspectos práticos para auxiliar no desenvolvimento e implementação de tais instrumentos.

2. Hierarquia das Normas: uma analogia com a Pirâmide de Kelsen

Como diferenciar códigos de ética e conduta de políticas e procedimentos? Que temas cada documento deve abordar e, em caso de conflitos entre as regras, quais devem prevalecer?

Para responder a essas questões, propõe-se uma analogia com o que os bacharéis em Direito estudam nos primeiros anos de faculdade: a teoria da hierarquia das normas jurídicas ou a *Pirâmide de Kelsen*, proposta pelo jurista alemão Hans Kelsen[129]. De forma simplificada, pois o estudo do direito não é o objetivo deste artigo, Kelsen propôs uma estrutura de graduação do ordenamento jurídico, estabelecendo a supremacia da *Norma Constitucional*, que direciona as *normas infraconstitucionais* que, por sua vez, direcionam e regulam as *normas infralegais*.

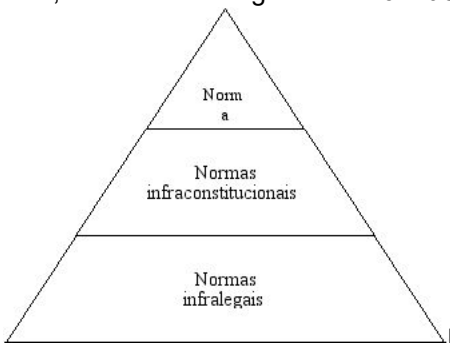


Figura 1 – Pirâmide da Hierarquia das Normas de Kelsen.

Aplicando-se a hierarquia das normas ao *ordenamento jurídico da empresa*, isto é, os códigos, políticas e procedimentos, ter-se-ia a supremacia do código de ética e conduta, o qual deve trazer diretrizes para as políticas internas e essas, por sua vez, regulariam outros procedimentos, orientações e regras da empresa, conforme ilustrado a seguir:

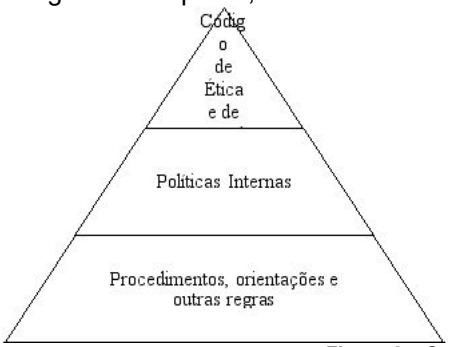


Figura 2 – Sugestão de hierarquia das normas de uma organização.

2.1. Código de Ética e de Conduta

O *Código de Ética e de Conduta* é o principal instrumento da empresa para divulgar os princípios e valores corporativos, bem como estabelecer as diretrizes básicas relacionadas ao padrão de comportamento esperado de seus administradores, funcionários e de todos os públicos que se relacionam com a empresa, tais como, clientes, servidores públicos, fornecedores, agentes intermediários, dentre outros.

Não há regras ou padrões determinados para se elaborar o código de ética e de conduta da empresa. No entanto, se traz aqui algumas recomendações, baseadas nas melhores práticas de mercado:

- **Título do documento**: *Código de Ética*, *Código de Conduta*, *Manual de Ética e de Conduta*, *Guia de Conduta Ética*, são alguns dos formatos que se encontra nas empresas. Embora o Decreto Anticorrupção traga a expressão "código de ética e de conduta" em seu artigo 41, entende-se que as demais alternativas também podem ser adotadas sem prejuízos para a avaliação do programa de integridade.
- **Temas a serem abordados**:
  1. A análise de riscos da empresa pode ser um ponto de partida para se definir os temas essenciais que devem estar contidos no código de ética e de conduta, bem como nas políticas e procedimentos;

2. A partir do Código de Ética e de Conduta, ramificam-se as políticas do programa de integridade. Portanto, todos os temas que forem abordados nas políticas devem ser tratados no código. Por exemplo: anticorrupção, prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro, brindes e presentes, segurança das informações e proteção de dados, conflito de interesses, doações, contribuições e patrocínios, dentre outros. Vide listagem exemplificativa no próximo capítulo;
3. O Código também pode conter outros temas específicos para o setor onde a empresa atua, como questões de segurança do trabalho em indústrias ou de segurança das informações em empresas de tecnologia. Sugere-se pesquisar e analisar os códigos de outras empresas em diferentes setores da economia e diferentes países, para ajudar o profissional de *Compliance* a eleger os temas essenciais para a sua empresa.

- **Estrutura**: o Código de Ética e de Conduta deve abordar diversos temas pertinentes à empresa. Portanto, não é recomendável que seja um documento exaustivo, contendo todas as regras, para todos os assuntos que aborda, sob pena de ficar demasiado extenso. Ademais, os princípios, valores e diretrizes da empresa não mudam com tanta frequência, diferentemente de regras e procedimentos. Se o Código conter muitas regras e procedimentos, corre o risco de ficar desatualizado em curto prazo. Definidos os temas do Código, esses devem ser abordados de forma objetiva, sucinta e clara, fazendo referência a políticas ou procedimentos específicos que detalharão cada assunto. Além dos temas, é uma boa prática que o código de ética e de conduta contenha:

1. Mensagem da administração ou da diretoria executiva: uma mensagem da alta administração logo no início do documento, reafirmando os valores e princípios da empresa, bem como o objetivo do código reforça o *tone at the top* do programa de integridade;
2. Canais de denúncias e dúvidas: inserir as informações de acesso aos canais e áreas responsáveis, além de reforçar os preceitos de confidencialidade, imparcialidade, possibilidade de anonimato e garantia de não retaliação. Isso ajuda a garantir a divulgação do canal, em atenção ao inciso X, do artigo 42, do Decreto Anticorrupção;
3. Comitê de Ética (ou similar): divulgar a existência de um comitê responsável pela gestão, eficácia e aplicação do código;
4. Responsabilidade de todos os funcionários de conhecer, divulgar e cumprir o Código em suas atividades, bem como dos gestores em dar suporte aos seus subordinados no entendimento de suas diretrizes.
5. Linguagem, formatos e publicidade: o Código de Ética e de Conduta deve ser público, acessível para todos os colaboradores, terceiros, clientes e outros públicos que se relacionam com a empresa. Dessa forma, dado o seu alcance, é recomendável que o documento tenha uma boa edição, com visual atrativo e que a linguagem seja adequada à cultura organizacional e objetiva, contendo apenas o essencial, já que os detalhes estarão nas políticas. Essas características contribuem para a clareza e credibilidade do documento. Para maior alcance e facilidade na divulgação, é interessante que o Código seja publicado em formato eletrônico, no site da empresa. Caso a empresa esteja presente em diversos países, existe ainda a necessidade de tradução do código nas respectivas línguas nativas.
6. Revisão, aprovação e atualização: recomenda-se que o Código de Ética e de Conduta seja revisto por áreas da empresa que contribuem diretamente com o programa de integridade, tais como jurídico, controles internos, governança corporativa, sustentabilidade, auditoria interna e recursos humanos. Conforme melhores práticas, o texto final deve ser aprovado pelo órgão máximo da empresa, no caso de companhias de capital aberto, por exemplo, pelo Conselho de Administração. Essa é uma demonstração expressa do compromisso da alta administração com a ética e a integridade na empresa, além de conferir relevância e perenidade ao documento. O Código deve ser atualizado periodicamente, porém a frequência dependerá do dinamismo de cada segmento da economia.

Com a aprovação e publicação do Código de Ética e de Conduta, recomenda-se a divulgação frequente, para os administradores, colaboradores e terceiros. O Código deve ser mencionado e

reafirmado nos diversos documentos da empresa, tais como contratos e políticas. Por fim, deve ser objeto de treinamentos específicos periódicos, no mínimo anualmente, o que ajuda na divulgação de temas e situações relacionadas ao dia a dia da empresa.

2.2. Políticas e Procedimentos do Programa de Integridade

O artigo 41, parágrafo único, do Decreto Anticorrupção determina que "o programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade".[130]

As políticas e procedimentos do programa de integridade são uma série de medidas cujo objetivo é definir os padrões éticos da empresa e garantir a aderências as leis vigentes. A importância crescente das exigências legais e regulatórias e o diferencial competitivo de mercado são fatores que levam as empresas a implementarem programas de integridade robustos e efetivos, que incorporam não somente um canal de denúncias e um código de ética e de conduta, mas também políticas e procedimentos de *Compliance*.

Como dito anteriormente o Código de Ética e de Conduta é a *política mãe* que define os valores e princípios da empresa, e todas as demais políticas e procedimentos do programa de integridade devem estar mencionadas neste documento. Uma vez que afirmado que o Código é uma resposta aos riscos da empresa, as políticas e procedimentos da mesma forma devem estar relacionadas a estes riscos. Ao elaborar as políticas e procedimentos do programa de integridade, alguns pontos devem ser observados, tais como:

- a cultura organizacional da empresa e dos funcionários;
- o ambiente regulatório do mercado em que a empresa atua;
- o padrão e formato de normas e políticas internas existentes nas demais áreas da companhia;
- o público interno que será alvo desta política;
- a personificação das políticas deve ser evitada, pois não são exigências da área de *Compliance*, mas da alta administração.

Com base nas melhores práticas de mercado, recomenda-se que as políticas e procedimentos do programa de integridade contenham, ao menos, os seguintes tópicos: objetivo do documento, papeis e responsabilidades das áreas relacionadas, diretrizes sobre o objetivo da política esclarecendo os procedimentos a serem adotados e o que não é permitido fazer, gestão de consequências em caso de descumprimento, referências do documento (Código de Ética e de Conduta e outras políticas e procedimentos), aprovadores, data da publicação e validade.

Após a elaboração das políticas e procedimentos do programa de integridade, necessita-se garantir que será efetiva. Para tanto, recomenda-se:

- Aprovação pelas instâncias responsáveis, o que eleva a credibilidade da política e estabelece o apoio da alta administração às regras ali definidas. Por exemplo, comitê de ética ou similar, comitê de auditoria, conselho de administração, conforme o caso;
- Divulgação, mantendo as políticas e procedimentos acessíveis a todos os públicos necessários, inclusive clientes e parceiros comerciais, se for o caso;
- Treinamentos periódicos sobre as políticas e procedimentos;
- Mecanismos de controle e monitoramento sobre o cumprimento das políticas e procedimentos;
- Gestão de consequências para eventuais descumprimentos das regras estabelecidas nas políticas e procedimentos;
- Atualização e revisão periódica.

A tabela abaixo visa demonstrar de forma prática as principais políticas e procedimentos do programa de integridade existentes em uma organização, e quais são as principais áreas que devem participar da elaboração de tais documentos, bem como um breve sumário de seu conteúdo. Trata-se de uma lista exemplificativa das principais políticas e procedimentos comumente observados nas

empresas. Não necessariamente serão adotadas todas elas e poderá ser necessário alguma outra que não esteja contemplada nesta relação:

POLÍTICA	ESCOPO	ÁREAS ENVOLVIDAS
Anticorrupção	*Conformidade com leis antissuborno e anticorrupção e estabelecer padrões de conduta apropriada em relação a negociações com agentes públicos, clientes, fornecedores, intermediários e outros parceiros comerciais, incluindo controles internos e contábeis.*	*Jurídico, Compliance e Relações Institucionais*
Relacionamento com agentes públicos e atendimento à fiscalização	*Identifica, nomeia e regula as interações da empresa com agentes públicos. Esta política é um dos parâmetros do programa de integridade (art. 42, inciso VIII, do Decreto Anticorrupção).*	*Jurídico, Compliance e áreas que possuem relacionamento direto com órgãos públicos*
Trade Compliance	*Embargos e Sanções, Aspectos Tributários, KYC – Know your Customer, Processos de Due Diligence, etc.*	*Jurídico, Compliance, Comex e Supply Chain*
Conflitos de Interesse	*Definir os tipos de "potenciais" conflitos de interesses envolvendo funcionários, definir processo de reporte tempestivo de conflitos.*	*Jurídico, Compliance e RH*
Gestão de Terceiros	*Avaliação de riscos na contratação de prestadores de serviços. Definição dos terceiros em escopo e do processo de background check e due diligence*	*Jurídico, Compliance, Financeiro e Suprimentos.*
Presentes, Refeições, Entretenimento e Hospitalidade / Doações e Patrocínios / Eventos	*Definir parâmetros como custo, frequência, razoabilidade cultural/social, relação com o negócio da empresa, temporalidade em relação a decisões relacionadas a ganhos para a empresa. Processos de aprovação. Contabilização transparente e completa*	*Jurídico, Compliance, Financeiro e RH*
Canal de Denúncia	*Definir as formas de comunicação de denúncias e expressar claramente que a empresa proíbe qualquer tipo de retaliação a denunciantes de boa-fé. Descrever os tratamentos conferidos às denúncias.*	*Jurídico, Compliance e RH*
Assédio e Discriminação	*Proíbe e define as sanções para qualquer ato de assédio e discriminação no ambiente de trabalho.*	*Jurídico, Compliance e RH*

Tabela 1 – Sugestões de políticas a serem adotadas por uma organização.

Além das políticas listadas na tabela acima, outras podem ser necessárias, dependendo do ambiente regulatório do mercado em que empresa atua ou de acordo com necessidades internas especificas do negócio, como por exemplo:

- "*Insider Trading*" – Uso de Informações Privilegiadas
- "*Fair Competition*" – Política de Competição Leal
- Segurança da Informação
- Compliance tributário
- Controles Financeiros e Registros Contábeis ("*books and records*")
- Saúde, Segurança e Ambiente
- Compliance ambiental

Conclusão

O Código de Ética e de Conduta, complementado pelas políticas e procedimentos, constituem-se em pilar fundamental do programa de integridade, exigido na legislação nacional e diversas leis estrangeiras como o *FCPA* e o *UK Bribery Act*.

São instrumentos que tem como objetivo padronizar as condutas esperadas de funcionários e demais *stakeholders*, diante de situações que possam violar os princípios éticos e trazer riscos a empresa.

Não há na legislação aplicável um modelo único de formatos e temas a serem considerados em tais documentos, tampouco textos prontos que poderiam ser aproveitados, de forma que cada empresa deve construir seu próprio conjunto de normas fundamentado na cultura organizacional, valores e princípios da empresa e riscos identificados no setor em que a empresa atua.

Referências bibliográficas

BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Programa de integridade: diretrizes para empresas privadas*. Brasília, set. 2015. Disponível em <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf>. Acesso em 02 nov. 2018.

_____. Decreto Federal nº. 8.420, de 18 de março de 2015.

_____. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. *Manual prático de avaliação de programa de integridade em PAR.* Brasília, set. 2018. Disponível em <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/manual-pratico-integridade-

par.pdf>. Acesso em 24 fev. 2019.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission. *A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act*. Disponível em <https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance>. Acesso em 02 nov. 2018.

KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME; BANCO MUNDIAL. *Anti-Corruption ethics and compliance handbook for business*. 2013. Disponível em <https://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthics ComplianceHandbook.pdf>. Acesso em 02 nov. 2018.

REINO UNIDO. Ministry of Justice. *The Bribery Act 2010 Guidance: about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing*. 2011. Disponível em <https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf>. Acesso em 02 nov. 2018.

Capítulo 8

Pilar 4 – Controles Internos no Programa de Compliance
Mitigando os Riscos de Integridade

Daniela Leme[131]

Introdução

Em linhas gerais, é possível definir Controles internos como sendo: um processo, implementado pela alta administração da empresa, envolvendo diretores, gerentes e funcionários, com a finalidade de prover razoável garantia quanto à realização dos objetivos específicos da empresa, nas seguintes categorias: (i) observar o alinhamento das ações ao direcionamento estratégico; (ii) conceder efetividade e eficiência às operações; (iii) obter confiabilidade no processo de comunicação, especialmente por meio das demonstrações contábeis, regulatórias e legais; e (iv) assegurar a conformidade com as leis e os regulamentos.

Para entendermos essas definições acima de Controles Internos, necessária a compreensão os seguintes conceitos de forma individualizada:

(i) **Políticas:** São documentos que exteriorizam a maneira de como uma empresa é conduzida internamente e externamente, através de regras de conduta, normas e procedimentos estabelecidos pela Administração e Departamento de Compliance, em alinhamento ao Código de Conduta;

(ii) **Procedimentos:** São mapeamentos da exteriorização de processos e políticas de um Programa de Compliance;

(iii) **Plano de Ação:** é a forma de estabelecer e organizar o sistema de uma companhia e suas áreas e processos e/ou políticas ou procedimentos, em que se faz necessário à atribuição de funções de autoridades e responsabilidades e verificar quem faz o que e quem tem autoridade sobre quem, para atingir um objetivo ou meta;

(iv) **Métodos:** Nada mais são do que as diretrizes ou metodologias a serem seguidas para atingir a um certo resultado;

(v) **Métricas:** São dados comparativos de resultados que possibilitam vislumbrar o melhor método a ser seguido ou a performance atingida face a avaliação de dados mediante a utilização de um determinado método;

(vi) **Proteção do Patrimônio:** é a forma de salvaguardar os bens e direitos da organização; sejam estes tangíveis ou intangíveis; e

(vii) **Exatidão e Fidedignidade dos dados:** É a averiguação da veracidade das informações, através de planos de contas e conciliação contábil dos sistemas e documentos, no caso de informações contábeis, além de e outras formas de checagem de controles, que não financeiros, mas essenciais a sustentabilidade da organização.

Os controles internos podem ainda serem divididos em dois grupos: os controles administrativos (computando os regulatórios e de qualidade) e contábeis. Assim, considerando que cada empresa possui uma natureza negócio "sui generis" e específica, cujos riscos estão definidos em matriz própria e individualizada. Neste capítulo, faremos a análise dos controles de forma a excluir especificidades regulatórias peculiares de cada negócio.

Nessa trilha, cabe a administração, observada a estrutura societária da empresa e respectivas áreas, o delineamento das diretrizes e estratégias, as quais deverão sempre estarem ligadas a otimização de processos sob as ações diretas necessárias para o seu cumprimento.

1. Um Breve Histórico: Evolução de Práticas de Controles Financeiros e Contábeis X Sistema de Governança Corporativa

Antes de adentrar nas particularidades e características dos institutos utilizados como ferramentas de controle internos no contexto dos Programas de Compliance, é necessário um entendimento "holístico" acerca da concepção e o histórico do desenvolvimento dos Controles Internos, eis que são ferramentas essenciais para a Governança Corporativa.

Conforme definição trazida pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) em sua Cartilha entende-se como Governança Corporativa "o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre Acionistas e ou Cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria independente e Conselho fiscal, apontando que as boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade".[132]

Em um contexto histórico, as regras de Governança Corporativa foram criadas com a finalidade de proteger os acionistas minoritários de empresas com capital aberto em bolsas de valores, em especial a principal bolsa de valores de Inglaterra e Reino Unido LSE *London Stock Exchange* e a americana NYSE – *New York Stock Exchange*, de forma coibir a conduta abusiva de executivos enquanto administradores de companhias. Para tanto, ao longo do tempo e com lições aprendidas, foram sendo criados mecanismos de controle e proteção das empresas, seu capital e acionistas.[133] Segundo a doutrina, o Sistema de Governança Corporativa deve pautar-se nos seguintes princípios:

1) **Transparência:** É o objetivo aliado a obrigação de disponibilizar às partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência em um ambiente corporativo resulta em um clima de confiança tanto internamente nas relações com os colaboradores da empresa, bem como junto aos seus acionistas e terceiros. A transparência não é restritiva ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também outros fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação de valor a uma companhia.
2) **Equidade:** Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis.
3) **Prestação de Contas: (Accountability)**: Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões.
4) **Responsabilidade Corporativa:** Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, incorporando considerações e práticas de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.[134]

Em síntese, a utilização do termo "boas práticas de Governança Corporativa", pode ser interpretada como sendo o sinônimo de um ambiente de negócio sustentável economicamente e seguro do aspectos de vista legal e regulatório, pautado por processos de mitigação de riscos e controles internos bem definidos, que possibilitam uma definição estratégica na condução de negócios e nas tomadas de decisões de uma companhia por seus administradores.

Em continuidade a evolução do quadro das regras e práticas de Governança Corporativa, foi criada em 30 de julho de 2002 por iniciativa do senador Paul Sarbanes (Democrata) e do deputado Michael Oxley (Republicano) e aprovada pelo Presidente George W. Bush, neste mesmo ano, a Lei Sarbanes-Oxley (*Sarbanes-Oxley Act*), normalmente abreviada em SOX ou também conhecida como Sarbox).

Para a maioria dos especialistas em Finanças, a edição dessa lei representou a maior reforma do mercado de capitais americano desde a introdução de sua regulamentação logo após a crise financeira de 1929, acarretando globalmente uma mudança radical nas práticas financeiras e contábeis. A referida legislação foi elaborada em resposta a fraudes e escândalos contábeis que a época, atingiram grandes corporações nos Estados Unidos.

Os escândalos da Enron em 2001, sétima maior empresa dos EUA, e da Arthur Andersen, firma de auditoria que prestava serviços à Enron, ocasionou, como numa reação em cadeia, a divulgação de outras fraudes contábeis envolvendo: WorldCom, Adelphia, Tyco International, Peregrine Systems. Em tais empresas, restaram configuradas deliberadamente a fraude financeira através da sonegação de impostos, bem como o reconhecimento de receitas de forma antecipada, além de outras práticas contábeis não aceitáveis.

Nesse cenário, a edição da SOX teve como objetivo maior tentar evitar a fuga dos investidores causada pela insegurança e perda de confiança em relação as escriturações contábeis e aos princípios de governança nas empresas, posto que com todos esses escândalos os preços das ações caíram assustadoramente, impactando de sobremaneira o mercado de ações americano além de outros.

2. Aplicação da Sarbanes (SOX) e do COSO X Relação com o Compliance

Não raro pairam dúvidas e questionamentos por parte de profissionais que atuam com Compliance, mas não possuem uma formação de finanças, com relação ao tema de SOX, haja vista que este tema é abordado de maneira mais ampla e aprofundada junto a área de finanças em detrimento da área jurídica dentre outras. Vejamos então, uma síntese acerca da aplicabilidade de tal legislação de natureza financeira-contábil.

A SOX é aplicável a todas as empresas americanas ou estrangeiras, que tenham ações registradas na SEC (*Securities and Exchange Comission*), o equivalente americano da CVM brasileira), os também denominados "*issuers*". Essa aplicabilidade inclui as empresas estrangeiras que possuem programas de *ADRs* (*American Depositary Receipts*)[135], do nível 2 ou 3, nas bolsas de valores dos EUA.[136]

Composta de onze títulos (capítulos), com um número variável de seções cada um, totalizando 69 seções (artigos), a SOX impõe diretrizes para as empresas em linhas gerais no sentido de:

a) reestruturarem processos para aumentar os controles internos, a segurança e a transparência na condução dos negócios, na administração financeira, nas escriturações contábeis e na gestão e divulgação das informações;

b) implantação de mecanismos de auditoria (controle externo), definindo regras para os Comitês encarregados de supervisionar as atividades e operações, formados em boa parte por membros independentes, com o intuito de evitar fraudes;

c) impõe a responsabilidade de Diretores Executivos e Diretores Financeiros por estabelecer e monitorar a eficácia dos controles internos em relação aos relatórios financeiros e a divulgação de informações para "*shareholders*" e "*stakeholders*";

d) maior autonomia às empresas de auditoria e os advogados contratados aumentando, todavia, o grau de responsabilidade inclusive de ordem subjetiva sobre seus atos;

e) prevê que devem ser estabelecidas regras para a contratação de serviços de auditoria e legais, bem como limites a fim de evitar o Conflito de Interesses.[137]

Com a missão de estabelecer as normas de auditoria, controle de qualidade, ética e independência em relação aos processos de inspeção e a emissão dos relatórios de auditoria sujeitas a SOX, foi criado o "*Public Company Accounting Oversight Board"* (*PCAOB* é a abreviação em inglês de Conselho de Auditores de Companhias Abertas), uma cuja função precípua é a de supervisionar os processos de auditoria com supervisão da SEC.

De uma forma muito clara e precisa, a SOX faz referências aos GAAP ("*Generally Accepted Accounting Principles"*), na versão US GAAP, para a definição de quais são as normas e práticas contábeis a serem aplicadas por empresas americanas e aquelas que se submetem ao cumprimento das normas de SOX. Outra legislação relevante e explicitamente mencionada na SOX é o "*Securities Exchange Act"* de 1934.[138] Em especial, com relação aos Programas de Compliance, a **Seção 406** da SOX trouxe em seu bojo a exigência de que a empresa adote um Código de Ética e conduta para os gestores financeiros.

A SOX mudou também o esquema de poder nas corporações norte americanas e suas subsidiárias, o qual foi disseminado para outras companhias ao redor do mundo, alterando fundamentalmente as relações entre os executivos e os acionistas minoritários, além de colaboradores tradicionais: os conselheiros, os auditores independentes e os advogados, pois tais colaboradores passaram a ter influência impactante na direção dos negócios. "O clima anterior de cooperação informal com a Diretoria Executiva foi substituído por uma nova atividade de verificar tudo, caracterizada pelo formalismo e legalismo, algumas vezes até antagônico". **[139]**

As recomendações da "*Nacional Commission on Fraudulent Financial Reporting*" (Comissão Nacional sobre Fraudes em Relatórios Financeiros), entidade independente criada em 1975, para estudar as causas da ocorrência de fraudes nos relatórios financeiros e contábeis, são tidas como referência para controles internos, que passaram a ser exigidos pela SEC, e em consequência, dada a robustez do modelo criado, o Sistema de Controles do COSO passou a ser adotado mundialmente por empresas, já que é considerado um dos mais completos e integrados sistemas de gerenciamento para companhias.

O modelo de controles internos do COSO, elaborado no ano de 1992 e batizado com o próprio nome da entidade por quem foi criado, abrange em seu modelo e práticas/procedimentos, o conceito amplo de processo de controles conduzido por todos os entes gerenciais de uma corporação, ou seja;

diretoria, conselheiros, além de outros funcionários, no intuito de prover uma razoável garantia com relação ao cumprimento das metas de organização.

Nada mais é que “um Sistema de Gerenciamento de Riscos Corporativos, o qual prevê uma estrutura integrada, mas ao mesmo tempo interdependente entre áreas”. Embora existam outras estruturas de Controles, o COSO é o modelo dominante entre as empresas, especialmente americanas.

Em linhas gerais, o Sistemática de Controles do **COSO** baseia-se no desmembramento de controles internos em circuitos componentes inter-relacionados, sendo o:

Primeiro: é o ambiente de Controle, que funciona como alicerce de todos os outros elementos de controles internos, incluindo valores éticos e a competência dos funcionários da companhia.

Segundo: é a avaliação de riscos, que identifica e analisa os riscos pertinentes que podem impedir o alcance dos objetivos do negócio.

Terceiro: corresponde as atividades de controle, ou seja, tarefas específicas para identificar cada um dos riscos identificados anteriormente.

Quarto: É a informação e comunicação, isto é, vias de informação que partem da administração para os funcionários e vice-versa.

Quinto: É o monitoramento, processo que cuida da avaliação e apreciação dos controles internos.

Figura 1 - Sistema de Gerenciamento de Riscos modelada pelo COSO 2013.
Uma imagem estruturada e desenhada em circuitos componentes inter-relacionados.

Dessa excessiva tendência de conferências e aprovações interligadas em processos e controles previstos pela *Sarbanes* e pelo COSO com a finalidade de coibir fraudes e riscos, e característica de integração e interdependência de controles internos, a Teoria dos “*Checks and Balances*” ou como chamamos da teoria dos “*Pesos e Contrapesos*” foi reavivada e passou a ser utilizada no ambiente moderno corporativo.

Em sua concepção original, a separação horizontal de poderes é o princípio básico de organização do Estado na maioria dos países do mundo, ou pelo menos naqueles verdadeiramente democráticos. Montesquieu, referência primeira sobre o assunto, procurou em sua clássica obra *"O Espírito das Leis"* [140] evitar o abuso de poder e garantir a liberdade dos indivíduos. Em tese, a tripartição de poderes impediria que um governante aliado ao legislativo expedisse leis tirânicas e da mesma forma as executasse; um judiciário associado ao legislativo seria um superpoder detentor dos meios legais e coativos sobre a vida a liberdade dos indivíduos; e um governante atrelado ao judiciário seria uma força opressora poderosíssima. Assim, a separação era fundamental e indispensável, de tal modo que ninguém seria constrangido a fazer coisas que a lei não obrigasse e a não fazer as que a lei permitisse.

Sob uma perspectiva moderna, a concentração de poderes e atribuições nas tomadas de decisões tende a criar um ambiente empresarial mais propício para a deflagração de fraudes e riscos, daí justificada retomada da utilização do conceito teórico dos “*Checks and Balances*” ou “*Pesos e Contrapesos*” como condição “*sine qua non*” para estruturação de processos, políticas e procedimentos em uma companhia. A adoção dessa Teoria de forma atualizada traduz-se na implantação de controles que possam mitigar riscos e fraudes, sem perder a sua essência originária; que é a de criar e manter mecanismos que garantam harmonia e interdependência em estruturas de governança.

3. Controles Internos

Para as empresas com ações comercializadas em Bolsas de Valores nos Estados Unidos, a implantação de Controles Internos é mandatória. Entretanto, o COSO não é o único sistema de Controles internos, razão pela qual é necessária a análise de outros também considerados como boas práticas.

Desta forma, necessária uma abordagem ainda que genérica sobre os pressupostos mínimos exigíveis de Controles Internos recomendáveis a uma empresa.

Podemos dizer que, no contexto de Governança Corporativa e seus controles internos, devem ser avaliados por uma companhia os seguintes aspectos:

1) **a responsabilidade da alta administração na definição dos limites éticos que norteiam a companhia:** Este tópico, está relacionado ao controle da fraude, com o entendimento do risco operacional como sendo *"risco de erro humano, de fraude ou de que os sistemas irão errar"*[141]. Este conceito é extremamente útil, posto que vincula os riscos mencionados, aos instrumentos de controle. A fim de mitigar ou minimizar as fraudes e o erro humano voluntário, um ambiente de Controle deve basear-se no Código de Ética de uma companhia, dando embasamento a suas políticas e procedimentos elaborados paralelamente com base em sua matriz de riscos, com detalhamentos suficientes para prever sistemas de alçadas de aprovações conforme Contratos Sociais/Estatutos, inclusive atrelados aos Sistemas de Informação e de Tecnologia utilizados. Da mesma forma, a alta administração deve elaborar programas de contingências e planos que possibilitem a continuidade sustentável do negócio. [142]

Os controles internos em uma companhia são considerados ferramentas de governança corporativa utilizadas de forma permanente e contínua, permeando todas as áreas da empresa, com o objetivo de propiciar à redução dos riscos e o aumento da eficácia dos processos. Um ambiente de controle sólido tem por base a integridade e a ética dos funcionários em todos os escalões, portanto, a existência de um clima organizacional permissivo e/ou um contexto operacional corrupto comprometem o atendimento dos objetivos e desenvolvimento da empresa.

Os executivos da alta administração dão, na prática, o tom ético da organização; e o padrão ético vigente na empresa afeta, diretamente, todos os demais componentes e instrumentos de controles internos. Daí a expressão em inglês do "*walk the talk"*, comumente utilizada no sentido de que a ética é consolidada em uma companhia através do exemplo da liderança e da administração.

2) **os papéis do Conselho de administração (Presidência) nas companhias, bem como respectivas Diretorias para manutenção de um ambiente de controle robusto e para a difusão de uma forte cultura de gerenciamento de riscos;** O referido tema, diz respeito à necessidade de disseminação de uma cultura robusta de gerenciamento de riscos no ambiente interno da empresa, acompanhada pela supervisão constante a fim de lhe fortalecer. Vale lembrar que muitos escândalos corporativos como os citados anteriormente neste artigo, ocorreram em decorrência da fragilidade do ambiente de controles, do baixo nível de comprometimento da média gerência com a qualidade dos controles internos contábeis utilizados na gestão de processos e dos riscos.

As atitudes descompromissadas por parte das gestões contribuíram para a existência de uma lacuna informacional entre as unidades de negócios e a alta administração, em outras palavras; tais escândalos financeiros foram corroborados pela ausência de transparência e seguridade de informações em especial financeiras, fornecidas para a administração e consolidadas em seus resultados.

3) **o nível de segregação entre as funções, de modo a possibilitar os "*checks and balances*" na implementação dos controles internos;** a necessidade de segregação entre as funções de governança e de gestão é inquestionável, ficando a cargo da alta administração a atribuição de orientar estrategicamente, bem como supervisionar os atos da Diretoria Executiva, a qual, por seu turno, é responsável pela gestão da empresa.

O Conselho de Administração atua em nome dos acionistas com a obrigação de apresentar a prestação de contas preparada pela Diretoria Executiva, portanto os conselheiros têm que estar bem informados sobre os principais assuntos que envolvem a gestão da empresa. É de responsabilidade da Diretoria Executiva a gestão de riscos, mas cabe ao Conselho supervisionar essa gestão, determinando práticas de governança que incluam a definição de procedimentos relativos à administração dos riscos.

Dentre as atividades de supervisão constante do risco pelo Conselho ou Administração, devem ser incluídos as seguintes agendas: (i) a estruturação de uma política geral de administração dos riscos; (ii) o monitoramento do plano de respostas aos riscos; (iii) a revisão periódica dos controles utilizados para gerenciar os riscos identificados; e, eventualmente, (iv) a contratação de especialistas externos para avaliar e aconselhar a alta administração sobre aspectos específicos da gestão dos riscos.

4) **a verificação do alinhamento da atuação da Diretoria Executiva junto a alta administração, em especial monitoramento do risco e aderências das áreas supervisionadas;** o propósito do *Compliance* ou da conformidade, pode ser desdobrado em duas vertentes: **(i)** o alinhamento a normas internas, tanto no nível operacional quanto no estratégico; e o **(ii)** cumprimento de leis e regulamentos.
5) **a atividade da auditoria interna no ambiente de Controle;** a auditoria, quando existente enquanto área interna de uma empresa, constitui o seu orgão de controle interno, responsável pela verificação da adequação e da efetividade dos controles das mais diversas naturezas.

O gerenciamento do risco operacional envolve a inibição de fraudes, a minimização de erros nos processos utilizados na empresa e a redução de falhas nos sistemas, principalmente os de TI.

4. Sistemas de Controles Internos além do COSO:

4.1. COBIT

O COBIT – Control Objectives For Information And Relates Technology [Objetivos de Controles Relacionados a Tecnologia da Informação] foi desenvolvido pelo "*The Information Systems Audit and Control Foundation- ISACF*", fundação que tem como função precípua prover informações sobre sistemas de auditoria e controle. Tem como característica a incorporação do conceito de controle interno desenvolvido a partir do sistema COSO, aplicando-o na área de Sistemas e Tecnologia da Informação. Atualmente, existem duas categorias bem definidas de modelos de controle: A primeira, voltada para os negócios (tendo como exemplo COSO e CoCo), e a segunda, direcionada para TI (SAC – "*Systems Audit and Control*" (Sistema de Auditoria e Controles). O COBIT procura preencher a lacuna existente entre os dois modelos, visualizando a TI e sua relação com os objetivos de negócios.

O sistema de controle do COBIT possibilita o monitoramento e benchmarking das práticas de controle e segurança nos ambientes de TI, assegurando aos usuários destes ambientes a existência de controles, inclusive tornando-os responsáveis como partes destes controles, além de auxiliar o trabalho dos auditores de sistemas.

A tecnologia é entendida em seu sentido amplo, abrangendo: hardware, sistemas operacionais, redes, dados e as próprias pessoas. Ressalte-se que como Dados são considerados não apenas textos, mas também números e datas, objetos, gráficos e sons. No que tange aos aspectos pessoais é possível afirmar-se que: as habilidades e conhecimentos para planejamento, organização, aquisição, entrega, suporte e monitoramento de sistemas de informações e seus serviços.

O COBIT permite a partir das informações obtidas através de entrevistas, e considerando o conhecimento acumulado em estudos anteriores, o levantamento de um diagnóstico preliminar dos processos de informática agrupados nos 4 domínios (Planejamento e organização, Aquisição e implementação, entrega e operação e Monitoramento), identificar o grau de importância dos riscos nos negócios.

4.2. CoCo

O CoCo – "*Criteria of Control Committee*" [Comitê para desenvolvimento de Critérios de Controle] criado pelo CICA – "*Canadian Institute of Chartered Accountants*" [Instituto Canadense Contadores Certificados] o CoCo visa a auxiliar a Alta Administração das organizações a implementar e avaliar um ambiente de controle, de modo atingir seus objetivos operacionais e estratégicos. Princípios da avaliação do ambiente de controle:

a) É de responsabilidade do Presidente (CEO);
b) É baseada nos critérios de controle do Sistema CoCo;
c) O foco da avaliação são os objetivos da organização e os riscos a eles relacionados;
d) Tem como perspectiva a organização como um todo;

e) A avaliação deve ter a perspectiva das pessoas da organização, sendo uma auto avaliação;
f) É conduzida para pessoas com a capacidade necessária;
g) Fornece relatório dos resultados obtidos para o Conselho de Administração;
h) É um processo contínuo, sendo revisado para conhecer o valor agregado à organização, e como esta mudou em função do mesmo e, também, como a organização pode ser melhorada.

Conforme a visão do CICA ("*Canadian Institute of Chartered Accountants*"), a controle envolve resultados, sistemas, processos, planejamento, aprendizado contínuo, acompanhamento através de indicadores de performance e cultura organizacional, os quais devem atuar de maneira conjunta, possibilitando as pessoas atingir os objetivos da organização. Dessa forma, o foco da avaliação é a empresa como um todo, seus objetivos e riscos que podem dificultar ou impedir sua realização. Ao se enfatizar a participação das pessoas, há uma valorização do elemento humano e dos valores éticos e culturais a ele relacionados. O controle torna-se um conceito mais amplo que apenas o cuidado com as demonstrações financeiras, compliance e segurança de ativos.

O fato de a avaliação do ambiente de controle ter como foco a organização de uma maneira global faz com que:

a) Interações dinâmicas entre os diversos elementos da mesma sejam compreendidas;
b) Sejam avaliados os processos de tomada de decisões da alta administração que afetam o Sistema de Controle (avaliar processos, a forma como ocorre o planejamento e valores éticos e não as decisões em si);
c) Devam ser angariados dados informacionais junto a toda organização, não tão somente da Alta administração;
d) Não sejam duplicados ou substituídos elementos de controle tais como auditoria externa e auditoria interna. Ao contrário, se busque compreender seu impacto sobre a organização, as formas de melhorias que podem ser atingidas e de se obter informações a partir das mesmas.

A avaliação do ambiente de controle deve ser realizada pela própria organização, sem que profissionais externos a empresa consignem opinião independente. O presidente - CEO deve designar um grupo de pessoas com a capacidade técnica e experiência adequadas para realizá-la. O conhecimento da organização, de controle e técnicas para a condução de entrevistas e sessões de auto avaliação (CSA – "*Control Self Assessment*") são fundamentais.

Assim, por tratar-se de um processo de auto avaliação, tem ainda a função e característica de criar um maior compromisso por parte dos colaboradores com os resultados obtidos e as medidas a serem adotadas, pois estes participaram do processo de análise da situação e avaliação do ambiente de controle.

Entretanto, quem decide se o controle é satisfatório, é o presidente da organização, o qual reporta ao conselho de administração, ou aos donos/superiores, suas conclusões a respeito da avaliação do ambiente de controle realizada e indica os planos de ação a serem seguidos para se aperfeiçoar o ambiente de controle.

O processo de avaliação, pode ser utilizado para que as pessoas compreendam conceitos como controle, objetivos da organização e gerenciamento de riscos, de modo a exercer suas funções com maior autonomia, podendo ser útil para se avaliar apenas um processo, um grupo de trabalho ou um departamento. Sistema utilizado: O conceito básico por trás desse sistema é o de que para realizar qualquer tarefa uma pessoa deve compreender seu propósito (o objetivo a ser atingido) e possuir capacidade necessária (informação, recursos e habilidade). Ademais, a pessoa necessitará de um senso de comprometimento para realizar bem a tarefa ao longo do tempo, devendo monitorar sua performance e o ambiente externo para que possa aprender como melhor realizá-la e que mudanças devem ser feitas. Isso vale para um indivíduo ou um grupo de trabalho.

O público-alvo do CoCo é a alta administração da organização, principalmente o executivo máximo (presidente) e os órgãos superiores de controle (conselho de administração e comitê de auditoria). Todavia, o conhecimento desse sistema pode ser utilizado para outros grupos dentro da companhia que pretendem avaliar a eficiência dos controles ou sejam responsáveis por sua execução como gerentes, funcionários, auditores internos, auditores externos e consultores.

O modelo do CoCo, foi desenvolvido tendo como objetivo principal sua aplicação no setor privado, de forma que deverão ser feitas adaptações para adequá-lo a instituições públicas. E, informa que os critérios de controle do CoCo, são formados pelos seguintes grupos:

Propósitos: indicam a direção a ser seguida pela organização.

- Objetivos, Visão, Missão e Estratégia.
- Riscos e Oportunidades.
- Políticas.
- Planejamento.
- Metas e Indicadores de Performance

Comprometimento: fornece a identidade e os valores da organização.

- Valores éticos, incluindo integridade.
- Política de recursos humanos.
- Autoridade e responsabilidade.
- Confiança mútua.

Capacidade: diz respeito a competência da organização.

- Conhecimento, habilidade e ferramentas de gestão.
- Processos de comunicação.
- Informação.
- Coordenação.
- Atividades de Controle.

Monitoramento e aprendizado: fornece quadro evolutivo da organização.

- Monitoramento dos ambientes interno e externo.
- Monitoramento de performance.
- Questões desafiadoras.
- Reavaliação das necessidades e dos sistemas de informação.
- Procedimentos de Follow-up [acompanhamento].
- Avaliação de efetividade do Controle.

4.3. SAC

O SAC é o Sistema Desenvolvido pela "*Internal Auditors Research Foundation – IARF*", fundação de pesquisa dos auditores internos filiada ao IIA, em 1991 e revisado em 1994, tem o propósito de gerar um sistema de controles internos direcionados para a Tecnologia da Informação de forma a auxiliar os auditores internos na realização de suas atribuições.

O sistema SAC define um Sistema de Controles Internos como processos, funções, atividades e pessoas que, em conjunto, devem assegurar o alcance dos objetivos e metas fixados. O material enfatiza a importância dos sistemas de informação em relação ao Sistema de controles internos. Este auxilia na avaliação dos riscos, da relação custo X benefício, além de ressaltar o fato de que os controles internos devem ser inseridos durante as fases de projeto e implementação de sistemas e não quando estes já estejam em operação.

Riscos e Objetivos de Controle: podem ser definidos como riscos erros, as fraudes, as interrupções nos negócios e o uso ineficiente ou ineficaz dos recursos. Para reduzir estes riscos e assegurar a integridade, segurança e situação de compliance das informações existem os Objetivos de Controle, a seguir especificados:

a) A integridade da informação é assegurada através de controles na entrada, processamento, saída e avaliação de qualidade dos softwares.
b) Segurança diz respeito a controle de dados, físico [e lógico], controles para a segurança dos programas.
c) Compliance é assegurado através de controles que propiciem a concordância com regulamentos e legislação, padrões de contabilidade e de auditoria, procedimentos e políticas internas.

Tal modelo atribui como responsabilidade do auditor interno assegurar a adequabilidade do sistema de controles internos, a veracidade dos dados e o uso eficiente dos recursos da organização. Deve ainda prevenir e detectar fraudes, além de coordenar atividades junto a auditores externos.

Ademais, complementa que a integração entre as habilidades de auditoria e de informática e um entendimento dos impactos da tecnologia da informação no processo de auditoria são necessários ao auditor interno. Os profissionais realizarão auditorias financeiras, operacionais e de sistemas de informação.

4.4. SAS 55/78

SAS 55/78 é a designação de dois documentos desenvolvidos pelo AICPA. O primeiro (SAS 55) refere-se a estrutura de controle interno para uma auditoria de demonstrações financeiras e o segundo (SAS 78) refere-se também a este tema, substituindo a definição de controles internos do primeiro relatório pelas definições do sistema COSO. Seu público-alvo é constituído por auditores externos.

O SAS 78 utiliza as definições do COSO, porém realiza uma adaptação, colocando o objetivo de veracidade das demonstrações financeiras em primeiro lugar. O Controle interno é visto como um processo no qual participam o Conselho de Administração, a diretoria, gerentes e demais funcionários, no intuito de assegurar, com um nível considerável de segurança, no alcance dos seguintes objetivos:

a) Veracidade das demonstrações financeiras;
b) Eficiência e eficácia das operações; e
c) Compliance com normas e legislação.

Apesar de conter os objetivos, operacional e de compliance, nas suas definições de controle interno, SAS 78 assim como SAS 55, tem como foco o exame da veracidade das demonstrações financeiras de uma organização. Como o parecer dos auditores externos diz respeito às demonstrações financeiras que cobrem determinado período de tempo, estes devem estar observando os controles que afetam a captura e processamento das informações financeiras ao longo de todo este período. Além disso, devem comunicar as deficiências de controles internos encontradas durante o desenvolvimento dos trabalhos e sempre que possível, buscar oportunidades para melhorar os controles internos contábeis das empresas.

4.5. Quadro Comparativo

	COBIT	SAC	COSO	CoCo	SAS55/78
Público Principal	Administradores, usuários, auditores de sistema	Auditores Internos	Administração	Administração	Auditores Externos
Visão dos Controles Internos	Um conjunto de processos, incluindo políticas, procedimentos, prática e estrutura organizacionais	Um conjunto de processos, subsistemas e pessoas	Processos	Processos	Processos
Objetivos Organizacionais dos Controles Internos	Efetividade e eficiência das operações; confidencialidade; integridade e disponibilidade das informações; confiabilidade dos relatórios financeiros; *compliance* com leis e regulamentos	Efetividade e eficiência das operações; confiabilidade dos relatórios financeiros, *compliance* com leis e regulamento	Efetividade e eficiência das operações; confiabilidade dos relatórios financeiros, *compliance* com leis e regulamento	Efetividade e eficiência das operações; confiabilidade dos relatórios financeiros, *compliance* com leis e regulamento	Efetividade e eficiência das operações; confiabilidade dos relatórios financeiros, *compliance* com leis e regulamento
Componentes ou Setores	Setores: Planejamento e organização; aquisição e implementação; distribuição e suporte; monitoramento	Componentes: Ambiente de controle: procedimentos de sistemas de controle manuais e automatizados	Componentes: Ambiente de controle: risk management; atividades de controle; monitoramento	Componentes: Propósito, Compromisso, capacidade e monitoramento e aprendizado	Componentes: Ambiente
Foco	Tecnologia da informação	Tecnologia da informação	Toda a organização	Objetivos da organização e riscos gerenciais	Declarações Financeira
Avaliação da Efetividade dos Controles	Para um período de tempo	Para um período de tempo	Em um ponto de tempo	Em um ponto de tempo	Para um período de tempo
Responsabilidade pelo Sistema de Controle	Administração	Administração	Administração	Administração	Administração

Fonte: Cocurrullo, 2004

5. O modelo das 03 (três) Linhas de Defesa: Um Controle Integrado entre Diferentes Áreas de Empresas.

Por certo e considerando que toda a sociedade, diga-se empresa ou corporação visa essencialmente o lucro, o controle financeiro é um dos principais, entretanto, os riscos financeiros não são os únicos que devem ser administrados para que uma organização seja protegida da ocorrência de danos, sejam estes reputacionais ou de ordem diversa. Aspectos regulatórios, legais e de qualidade considerando ainda a área do segmento de negócios também devem ser observados, mapeados e gerenciados.

Nesse sentido, surgiu o Modelo das 03 (três) linhas de defesa, a fim de assegurar que diferentes áreas de negócios tenham seus riscos monitorados e geridos. O mero mapeamento de riscos de

diferentes áreas bem como o seu gerenciamento não é suficiente. O grande desafio quanto ao gerenciamento de riscos e controles é determinar funções específicas e monitorar com efetividade todos esses grupos de riscos mapeados, para que não haja "*lacunas*" em controles, nem mesmo sobreposições de controles.

Para que a tarefa acima seja bem-sucedida, responsabilidades claras e delimitadas a cada um desses grupos de controles e riscos devem ser estabelecidas, adequando suas posições de acordo com as respectivas funções e áreas de atuações na organização, já que a existência de "*gaps*" de coordenação e gerenciamento de riscos podem gerar prejuízos de monta inestimável a uma empresa.

Assim, o Modelo das 03 (três) linhas de defesa tem como função principal auxiliar as organizações no gerenciamento de riscos de uma maneira integrada e sistemática, uma vez que o modelo visa melhorar a comunicação do gerenciamento de riscos e controles de diferentes áreas através de atribuições precisas e claras de papéis e responsabilidades essenciais de cada um dos grupos de controles.

Adaptação da *Guidance on the 8th EU Company Law Directive* da ECIIA/FERMA, artigo 41

5.1. Estruturação e Operacionalização do Modelo das Três Linhas de Defesa

No modelo das três linhas de defesa[143], observa-se a seguinte estruturação de parâmetros de controles:

1) Primeira linha de defesa: É a considerada a da gerência de controles no gerenciamento dos riscos de cada área

Na primeira linha de defesa, os gestores operacionais gerenciam os riscos e têm propriedade sobre os mesmos. São eles os responsáveis por implementar ações corretivos a fim de sanar deficiências em processos e controles. Os gestores operacionais ficam encarregados da manutenção de controles, bem como da mitigação de riscos, dando diretrizes para o desenvolvimento e a implementação de políticas e procedimentos internos, de forma a garantir que as atividades de sua atribuição de controles estejam em coadunância com as metas e objetivos traçados. Através da estruturação de responsabilidades bem claras e delimitadas em cascata, a gerência de nível médio é responsável pelo desenvolvimento de procedimentos com detalhes que funcionam como controles, exercendo o a coordenação destes, por parte do monitoramento de seus subordinados.

Em síntese, a gerência de primeira linha de defesa: **(i)** tem propriedade sobre os riscos e atribuições de gerenciá-los; e **(ii)** deve de realizar a avaliação de riscos de forma independente.

2) Segunda linha de defesa: Representa as funções de controle e supervisão de conformidades, os itens de "*Compliance*" estabelecidos pela gerência

Na rotina operacional de uma empresa, seria possível imaginar que somente a primeira linha de defesa e seus controles seriam capazes de mitigar e gerenciar os riscos de uma área. Entretanto, um único enfoque de controle e análise pode revelar-se equivocado, daí a necessidade de mecanismos de "*checks and balances*".

Dentre os segmentos de indústrias, as funções típicas e elementares dessa Segunda linha de Defesa deve conter:

a) Uma área e/ou Comitê responsável pelo gerenciamento de riscos que monitore a implantação de boas práticas eficazes dos riscos atribuídos a cada gerência operacional, auxiliando as gerencias responsáveis pelos riscos a estabelecer parâmetros e metas de exposição do grau

do risco, de forma que seja possível ser reportado a alta administração, bem como a toda a corporação.

b) Uma área de Compliance que monitore diversos riscos específicos, tais como a não conformidade face ao cumprimento de legislações e requisitos regulatórios específicos do negócio. Nesse aspecto, a área de Compliance deve reportar diretamente à alta administração, e em alguns setores de negócios, diretamente ao órgão responsável pela governança. Importante frisar que dependendo do segmento de negócio da organização, há vários tipos de conformidade que devem ser observados, por exemplo: trabalhista, ambiental, de saúde e segurança do trabalho, relativos à cadeia de fornecedores, bem como de natureza regulatória.

c) Uma área de Controladoria responsável por monitorar riscos financeiros, relatórios e reportes financeiros.

Esses três níveis de gerências da Segunda linha de defesa mencionados acima devem atuar garantindo que a Primeira linha de defesa seja direcionada, desenvolvida e que as práticas aconselhadas estão sendo colocadas em prática.

Tanto o Comitê de Riscos, a área de Compliance e a Controladoria exercem funções independentes com relação a Primeira linha de defesa, mas em sua essência, também atuam como gestoras dos riscos do negócio, razão pela qual podem e devem interferir e mesmo modificar os controles internos já delineados de forma a aprimorá-los e corrigi-los para a robustez e evolução dos controles internos.

Nesse sentido, embora essencial para a evolução e progresso dos sistemas de controles internos, a Segunda linha de defesa não pode realizar a tomada das decisões sem que haja a anuência por parte da alta administração.

A Segunda linha de defesa pode ter incluída em suas atribuições as seguintes funções: (i) apoiar as políticas de gestão, definir papéis e responsabilidades, bem como estabelecer prazos e metas para implementação; (ii) atualizar alguns aspectos da matriz de riscos do negócio, adequando-as as práticas já estabelecidas; (iii) franquear estruturas e ferramentas que possibilitem o gerenciamento de riscos; (iv) identificar riscos iminentes bem como futuros; (v) identificar mudanças no apetite do risco implícito da organização; e (vi) prestar suporte à gerência no desenvolvimento de processos e controles para monitorar riscos identificados.

3) Terceira linha de defesa: É tida como da avaliação independente, ou seja; da auditoria interna

A Terceira linha de defesa, representada pela auditoria interna nas organizações, representa o nível de avaliação de riscos e controles mais abrangente, que deve ser realizada de forma independente e reportada à alta administração. Tal aspecto de independência não está presente na Segunda linha de defesa. É função da auditoria interna realizar análises acerca de aspectos de governança, gerenciamento de riscos e dos controles internos, inclusive avaliando como a primeira e segunda linha de defesa alcançam e desempenham o monitoramento de riscos e controles.

Aspectos específicos da atuação da Auditoria Interna será tratada em outro capítulo desta obra, razão pela qual não teceremos aqui comentários mais aprofundados.

Ainda quanto ao modelo das 3 linhas de defesa, importante ressaltar que apesar de que os órgãos de governança e a alta administração não serem contemplados dentre as estruturas delineadas para as 03 (três) linhas de defesa, nenhuma discussão acerca do gerenciamento de riscos poderia ocorrer alheia a participação essenciais dos órgãos da alta administração. (i.e. conselho de administração e órgãos equiparados). Tais entes são os principais interessados em que as responsabilidades e atribuições estabelecidas nas linhas sejam atendidas a fim de possibilitar a segurança e por consequência a sustentabilidade organizacional do negócio, até porque, a alta administração é a área que mais pode assegurar e auxiliar na tomada de decisões. Afinal de contas, o funcionamento satisfatório do modelo das três linhas de defesa de controle em uma organização é um dos fatores que asseguram sua perenidade.

6. Desafios de Controles Internos enfrentados pela área de Compliance

Certo é que os Controles Internos são de extrema importância para as organizações, sendo indiscutível sua necessidade. Entretanto, um dos maiores desafios do Departamento de Compliance é

delinear suas responsabilidades quanto a esses Controles internos em companhias que não possuem áreas auxiliares, que em tese, poderiam suportar pelo menos parcialmente essas tarefas. (Por exemplo: Auditoria Interna, Área de qualidade, Área regulatória e Área de gestão de projetos, Área de Saúde e Segurança do Trabalho etc.).

Esse é o cenário mais comum enfrentado pelos responsáveis pela da Compliance, que em sua rotina em pequenas e médias organizações podem contar na maioria das vezes, de maneira mais efetiva, com o apoio da área financeira, representada pelo seu "*Controller*", bem como a área de RH representada por seu responsável. Assim, como o Compliance Officer e/ou responsável pela área de Compliance deve direcionar suas ações para solucionar problemas decorrentes da ausência de controles específicos, já que muitas vezes sequer poderá contar com membros em sua equipe?

Nesse caso, considerando a escassez de recursos humanos e técnicos, o Compliance Officer e/ou o responsável por tal área deverá contar com o apoio da área financeira, representada por sua Controladoria para auxiliá-lo na estruturação de políticas, procedimentos, bem como implementá-las, além de contar com a colaboração de outras áreas existentes envolvidas no problema ou risco detectado. Para tanto, será necessário examinar os problemas e/ou falhas de processos, devendo logo após fazer um esforço para reestruturá-los, refletindo a solução encontrada de forma clara em políticas e esboços de procedimentos, que devem ser aprovados pela Diretoria (alta administração).[144]

Mas a pergunta é: Como reestruturar um processo de controle interno ou mesmo estruturar um novo controle face a ocorrência de um fato de relevância que traga risco a organização?

Uma ferramenta importante e auxiliar para elaboração de planos corretivos e soluções por parte dos profissionais da área de Compliance na detecção de problemas e de suas correções é o da ferramenta de qualidade 5We 2H.

De forma resumida, tal método consiste em um checklist, cujas perguntas seguem transcritas abaixo, para levantar pontos importantes para resoluções de problemas e /ou falhas detectadas em controles.

1) *When*? - Quando a falha ou problema ocorreu? Em que contexto e tipo de controle? Em que fase do Controle ocorreu?
2) *Why*? – Por que o fato ocorrido é considerado um problema ou divergência? Qual é o embasamento que sustenta que o fato pode ser encarado como um risco ou inconsistência de controles?
3) *Who*? – Quem são as pessoas envolvidas ou qual área levantou o problema ou erro de controle ou risco?
4) *Where?* – Em que local ocorreu o problema (qual processo, departamento, localização geográfica e física, etc....)
5) *What?* – O que houve na prática? (O fato deve ser descrito, contendo inclusive detalhes técnicos se houverem e impactos imediatos se ocorreram ou estão na iminência de se realizarem)
6) *How?* – O como o fato ocorreu? Como isso foi possível?
7) *How much?* – Qual é a porcentagem de falha detectada? Houve amostragem testada? Qual amostragem? Qual foi a perda financeira atrelada ou qualquer outra informação de relevância na análise do problema que dê uma dimensão na divergência ou exceção de controles?

Uma vez aplicada a técnica, é hora de traçar um plano de ação e para tanto, um método de gestão muito utilizado pelas áreas de Compliance, que se enquadra muito bem a situação acima exposta, é o do "PDCA"[145] (do inglês: PLAN - DO - CHECK - ACT ou Adjust), que consiste um método iterativo de gestão de quatro passos, utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos.[146]

Figura 2: Ciclo PDCA
Fonte http://www.sobreadministracao.com/o-ciclo-pdca-deming-e-a-melhoria-continua/

Eventuais falhas e pontos de melhorias objetos de correção, que uma vez observados devem ser mapeados e deve ser elaborado um plano de ação, com prazo, responsáveis, ações e objetivos. Tal plano deve ser testado e medido através de indicadores e amostragens de desempenho para posterior adoção e parametrização em políticas e procedimentos objeto de prática pela área.[147]

Em cumprimento ao objetivo do Programa de Compliance e não havendo área de Auditoria interna, a área de Compliance pode utilizar dessas ferramentas para a melhoria do Programa e correção de eventuais falhas, em prejuízo da realização de Auditoria de Compliance a se realizar pela área de Auditoria interna, se esta existir na estrutura, ou mesmo, por empresa especializada de auditoria de Compliance. Afinal, a área de Compliance deve envidar seus melhores esforços no sentido de cumprir os objetivos do Programa, quais sejam: prevenir – detectar e mitigar ou corrigir riscos.

Caso haja um ponto de atenção crítico que necessite de uma avaliação mais aprofundada, que os recursos internos existentes na empresa não se revelarem capazes de avaliação que possibilite a sua resolução, a área de Compliance deve recomendar a contratação de consultoria e/ou empresa especializada para atuar na área do processo de estruturação de riscos e controles e formalizar tal orientação.

Vale lembrar que a utilização dos recursos financeiros e humanos (facilitadores eleitos para participação no plano de ação) a serem alocados em tais projetos e/ou planos de ações devem ser avaliados e aprovados pela alta administração, devendo igualmente serem monitorados por ela e pela área de Compliance.

Um ponto importante a ser ressaltado nesse contexto, é que uma vez que a Controladoria Financeira e a área de Compliance estão localizadas na 2 linha do modelo de defesa, não compete a tais áreas a realização de procedimentos de auditoria na própria organização, mas sim de monitoramento contínuo. Nessa linha de raciocínio, a recomendação é a de que auditorias de Compliance de Finanças sejam realizadas por empresas externas de tempos em tempos, se a organização não possuir um time de auditoria interna, pois a realização de processos de auditorias confere de forma imparcial e independente, um parecer conclusivo acerca de pontos de atenção, bem como de Controles que devem ser aprimorados no Programa de Compliance.

QUADRO DE RESPONSABILIDADES DE CONTROLES INTERNOS APLICÁVEL PARA EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE	
Alta Administração (Presidência, Diretoria)	**Tem como responsabilidades:** - A alta administração tem a responsabilidade primária organizacional (O Compliance deve vir do direcionamento dado pelo topo da administração, que deve gerir o negócio dando exemplo de elevados padrões éticos) - É responsável pela tomada de decisões finais inerentes a riscos do negócio apontados ou monitorados pela área de Compliance e/ou Auditoria; - É responsável por validar as recomendações da área de Compliance e de Auditoria eventualmente realizadas.
Área de Compliance	**Tem como responsabilidades:**

	- Identificar e avaliar os riscos de Compliance das gerências proprietárias do risco; - Direcionar e treinar os funcionários em assuntos de Compliance; - Monitorar continuamente e relatar novos riscos de Compliance identificados no negócio; - Elaborar junto as gerências responsáveis por cada área de negócio as políticas e procedimentos, as quais devem estar alinhados ao Código de Conduta da organização, mitigando os riscos já mapeados; e - Assessorar a alta administração e as áreas de negócio nas tomadas de decisão que envolvem riscos.
Controladoria Financeira	**Tem como responsabilidades:** - Assegurar controles efetivos e eficientes para mitigar os riscos financeiros, além de verificar as políticas e procedimentos estabelecidos pela empresa/área de Compliance.
Auditoria de Compliance	**Tem como responsabilidades:** - Revisão e adequação dos controles estabelecidos pela área de Compliance para assegurar a conformidade com as políticas, os planos e os procedimentos estabelecidos, verificando se estão alinhados aos objetivos estratégicos da organização, bem como aos riscos inerentes ao negócio e setor de atuação. - Responsável por levantar pontos de atenção e melhorias a serem realizadas no Programa de Compliance e sua área como um todo.

Conclusão

Observado toda a exposição neste Capítulo, sobre controles internos, compara os modelos dos sistemas COBIT, SAC, COSO, CoCo e SAS55/78, bem como apresenta o modelo das três linhas de defesa e ferramentas que podem ser utilizadas pela área de Compliance na resolução de problemas de controles e no seu aperfeiçoamento, é possível notar que conjuntamente, tais sistemas e metodologias podem auxiliar diversas áreas de negócios que necessitem de instrumentos de controles internos, independente da área ou segmento do negócio. Porém, não esgotam os tipos de controles, haja vista que cada empresa possui uma realidade peculiar que deve ser observada para fins de melhoria de seus processos.

Em suma, os Controles internos de uma companhia baseiam-se no conjunto de políticas, normas e procedimentos adotados pela administração da companhia com o intuito de assegurar: (i) o correto cumprimento da legislação interna e externa; (ii) a utilização eficiente e eficaz de todos os recursos; (iii) a redução dos níveis de incerteza e minimização da ocorrência de riscos, sejam eles: financeiros, operacionais, regulatórios, de imagem ou legais. “O Compliance é o mecanismo de observação do cumprimento desses controles”.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. *Auditoria: um curso moderno e completo*. São Paulo: Atlas, 1996.

ARAÚJO, Francisco J. Influência dos controles internos no trabalho do auditor independente. *Revista Brasileira de Contabilidade*, Brasília, n.121, jan-fev. 2000.

BLOK, Marcella; *Compliance e Governança Corporativa*. 2 ed. rev. atual. Freitas Bastos, 2018.

COCURULLO, Antonio. *Os impactos da SOX 301, 302 e 404 nos trabalhos dos auditores internos*. Apostila apresentada na 8ª Conferência de Auditoria Interna, promovida pelo IBC. São Paulo, ago. 2005.

RODRIGUES, José Antonio e MENDES, Gilmar de Melo. *Governança Corporativa: Estratégia para Geração de valor*. Quality Mark, 2005.

MANZI, Vanessa Alessi. *Compliance no Brasil: Consolidação e perspectivas*. Saint Paul, 2008.

NEGRÃO, Celia Lima; PONTELO, Juliana de Fátima. *Compliance, controles internos e riscos: a importância da área de gestão de pessoas*. 2 ed. rev. amp. Senac, 2017.

NEVES, Edmo Colnaghi. *Compliance empresarial: o tom da liderança*. São Paulo: Trevisan, 2018.

Capítulo 9

Pilar 5 – Comunicação e Treinamento de Compliance
Difundindo a Cultura de Integridade

Felipe Faria[148]

Introdução

Primeiramente, esqueça apresentações de Power Point o engajamento estará nas histórias que você irá contar. Talvez você não precise esquecer por completo, mas hoje em dia não se pode mais depender somente de apresentações em *ppt* para conduzir um bom treinamento ou utilizar somente esta ferramenta para passar sua mensagem. Mesmo que essa mensagem seja importante como os temas de um Programa de Compliance.

Consigo recordar nos meus primeiros anos como treinador de Compliance quando fui catapultado na área acostumado com palestras sobre temas em Direito onde mesmo para um advogado era difícil de se concentrar. Nós usualmente colocávamos algumas leis estrangeiras num *ppt*, pesquisávamos o aumento estarrecedor de penalidades impostas por reguladores estrangeiros e acreditávamos que isso seria uma forma eficaz de conscientização sobre a importância do tema, e talvez com uma certa ingenuidade achávamos que somente isso já faria a audiência entender a razão da necessidade de se prestar certa atenção ao conteúdo do treinamento.

Iniciei minha carreira em empresa, e talvez tive um começo mais tranquilo pois teoricamente os empregados que ali estavam tinham uma certa obrigação por parte dos seus líderes para prestar atenção no conteúdo que estava dizendo. Porém passei também alguns anos dando treinamentos como consultor em diversos tipos de contextos pré-operação lava jato e lei anticorrupção brasileira, daí sim você literalmente vê de tudo.

Como todo jovem entusiasmado com um tema novo, falava com certa paixão de leis e dos casos estrangeiros investigados até o momento e via na audiência com certa frequência pessoas me olhando com um certo ponto de interrogação e visão meio atravessada, como se não estivessem mesmo ali.

Por mais que eu tentasse tornar as histórias mais interessantes, para alguns o que eu falava era tão fora de contexto que eu normalmente era confrontado com uma pergunta mais atrevida sobre a impunidade brasileira. E isso rendia algumas discussões acaloradas e ânimos exaltados - o que para mim sempre tinha um lado positivo, ao menos as pessoas acordavam e/ou paravam de roncar (isso aconteceu realmente uma vez). Como treinador, não leve para o lado pessoal, as pessoas devem participar, mesmo que for para criticar, e temos que relevar que talvez para um ou outros eles podem ter tido uma noite mal dormida.

1. Conheça seu Público e Planeje

Como treinamento tem tudo a ver com comunicação é importante notar que estamos hoje vivendo em uma era completamente diferente, comunicadores estão por toda parte e agem de forma rápida. Estamos numa era de *showmans* motivacionais, com conteúdo e empatia, numa era de desconhecidos virando *influencers*, de *youtubers*, que dividem suas experiências e vida ao vivo diariamente, que compartilham informações e geram conteúdo que podem dividir interesse com a mensagem que você está querendo passar. O grande inimigo do treinamento não é o questionador, e sim o *Whatsapp*, o *feed* do *Facebook* e o *Instagram*.

Então as pessoas que você precisa treinar estão cada vez mais interligadas nesse mundo e muito antes do que você imagina você pode vir a ter o desafio de treinar um grupo de *millennials* cada vez mais capacitados e preocupados não só com o conteúdo, porém também com a forma que a mensagem é transmitida. E isso pode ser fator determinante da eficácia do seu treinamento.

Aqui cabe ressaltar que iniciei este Capítulo propositalmente contando uma história pessoal justamente para provar um ponto. A atualidade e a velocidade em que as informações são passadas e adquiridas colocou os *Compliance Officers* em um novo patamar de treinadores. Hoje em dia, ninguém realmente precisa de uma pessoa especifica para aprender um conteúdo novo de qualidade, isso é facilmente encontrável no *Google* e *Youtube*. Apenas digite “treinamento de Compliance” no *Youtube* e

você verá todos os tipos de informações disponíveis - algumas confiáveis e outras não, claro - de forma simples, rápida e sem custo. E pasme, diversas apresentações em *ppt*.

Desta forma como um treinador você deve sim se questionar sobre o que de fato de novo você está passando para aquela audiência específica, e o que você pode agregar de conhecimento em relação àquilo que ele já sabe ou pode facilmente encontrar na web.

Removendo da equação o fato de que o legislador obrigou Programas de Compliance terem planos de treinamentos, o que então podemos concluir que fará o seu treinamento ser um treinamento de sucesso? Minha resposta: empatia.

As pessoas hoje em dia precisam se relacionar com o tema para gerar transformação e reflexão. Nós nos motivamos muito mais pela pessoalidade das histórias e vivencias que o treinador passa no momento do treinamento e a emoção transmitida com essas experiências do que pela razão e os dados empíricos que você poderá apresentar.

Por mais que seja interessante para o *Compliance Officer* transmitir uma informação apurada e fidedigna de que houve um acréscimo de X por cento no valor das penalidades em casos de corrupção no mundo em X anos, provavelmente o que as pessoas mais vão lembrar do seu treinamento será o caso engraçado ou difícil que você contou, o exercício competitivo que você montou entre as equipes, ou a imagem ou o vídeo engraçado de um grupo de comediantes que você mostrou naquele dia.

É inegável. As pessoas vão lembrar melhor do momento que riram, refletiram e se identificaram. Portanto apesar de ser interessante para nós profissionais de Compliance ver e entender os estudos, hoje em dia não adianta mostrar somente dados, tem que tocar no emocional, no coração.

Desta forma nossa premissa neste Capitulo partirá na discussão do dinamismo do treinamento e nas novas formas de comunicação eficazes, especialmente visando um novo grupo de profissionais que estão sendo formados, que já cresceram num ambiente digital, que compartilham informações e experiências de forma ativa, e talvez com um certo desvio de atenção não diagnosticado generalizado - como o que acomete a este autor.

1.1. Público Alvo

O segredo de um treinamento eficaz está num bom planejamento. Portanto vamos começar discutindo qual será seu público alvo pois todo planejamento partirá da informação de para quem o treinamento será direcionado. Há diversos tipos de empresas e diversos perfis de empregados então se torna um pouco lugar comum afirmar que caberá uma avaliação do *Compliance Officer* caso a caso. De qualquer forma as pessoas podem ser diferentes, estarem em diferentes funções e terem background profissional distintos, mas é sempre importante detectar a cultura organizacional que elas estão inseridas. O truque do sucesso neste tema não é buscar fazer os treinamentos pensando nos perfis que se diferem entre si, mas sim na cultura os une dentro daquele microcosmo empresarial que obtém sucesso para atingir suas metas e objetivos.

Achar as similaridades culturais que fazem parte do sucesso da companhia irá lhe auxiliar a passar a informação de forma mais eficaz com uma maior absorção do conteúdo. Mas encontrar isso pode ser desafiador, principalmente se você está iniciando seu Programa e não tem muito conhecimento adquirido sobre a cultura organizacional.

Eis algumas dicas: sua análise deverá passar pelo tipo de funções da maioria dos empregados, ao ambiente em que a empresa foi constituída (por exemplo, empresas que nasceram como uma joint venture tem empregados em uma cultura organizacional especifica e talvez mais difusa, diferentemente de empresas familiares com uma cultura basicamente estabelecida pelos seus donos pessoa física), e poderá passar inclusive pela localização onde a matriz da empresa está constituída em relação às filiais.

Aspectos regionais não devem ser desvalorizados, lembre-se que o treinamento é feito para pessoas, e elas podem estar mais abertas ou menos abertas a certas atividades, formas de expressão ou reações.

Nesta tarefa colaborar com o RH poderá lhe ajudar enormemente. Construir pontes e colaborar com áreas de apoio é muito importante, não só para outras atividades do Programa de Compliance como também para treinamentos. Não há área mais entendedora da cultura organizacional de uma empresa que o RH, portanto, use essa sabedoria fazendo perguntas especificas e claras. Seja honesto e direto, envolva empregados perguntando: “o que você espera de um treinamento interno?”. Com

perguntas diretas você conseguirá respostas claras que você poderá realmente usar para construir seu treinamento.

Outras atividades mais simples que o *Compliance Officer* precisa definir são as posições hierárquicas determinadas que deverão ter necessariamente um treinamento diferencial com maior conteúdo por oferecerem maiores riscos ao Programa, enquanto outras somente uma explicação mais generalizada funcionará como treinamento adequado.

A 'dosimetria' do treinamento é um ponto importante, ao contrário você ganhará alguns líderes desconfortáveis com a quantidade de horas que os funcionários estarão fora de suas atividades normais para participar do seu treinamento mesmo que eles entendam perfeitamente sua importância. Lembre-se que por mais que você ache que seu treinamento é o mais importante da companhia, e até que a alta administração concorde plenamente que seu treinamento é o mais importante, você estará impactando a produção da empresa, e isso não é uma situação completamente tranquila. Todos os profissionais tem valor dentro de uma empresa e são cobrados por sua produtividade (senão nem estariam ali).

Os empregados têm suas agendas, suas prioridades e suas metas para bater, pois obviamente a empresa foi formada para a gerar lucro (com exceção obviamente das ONGs, ou empresas sem fins lucrativos, claro). E o Departamento de Compliance deve considerar esses fatores. Não seja o *Compliance Officer* general militar querendo impor suas vontades em treinamentos, seja um mediador que sabe como influenciar para que seu treinamento atinja o máximo de sua capacidade e exerça influência na tomada de decisões do dia a dia.

Outro ponto interessante seria alinhar as expectativas em relação à meta do público alvo do treinamento que o Departamento de Compliance tem que atingir com a própria Administração. Treinamentos podem ser uma forma interessante de medir a aderência da empresa ao Programa de Compliance e se está sendo dada a devida relevância ao tema de implementação do Programa. A empresa poderá ter uma meta de 80% da força total de empregados treinados durante o período de um ano, ou até uma meta mais arrojada como 100% dependendo da situação em que a companhia se encontra de resposta a stakeholders externos.

É esperado que empresas envolvidas em escândalos externos tenham metas arrojadas de treinamento de forma a capacitar seus empregados a detectar propriamente red flags e situações que ponham a companhia em risco. A beleza desse tema de metas é que treinamentos são formas mensuráveis e auditáveis e como KPIs do Departamento de Compliance funcionam perfeitamente. Num mundo ideal você pode até pensar em atrelar essas metas às metas pessoais dos empregados para recebimento de bônus ou participações nos lucros. Desta forma você consegue garantir a presença no seu treinamento de forma mais confortável sem enveredar por muitas discussões (*that's the dream!*).

Planeje suas atividades de treinamento de acordo com essas informações de maneira a causar menos impacto aos negócios e de quebra ainda criar maior parceria com áreas de negócios e alguns ganhos de relacionamentos com os gestores encontrando formas de harmonizar seu trabalho, porém sempre colocando em discussão a importância e a inegociabilidade dos treinamentos voltados aos temas de seu Programa de Compliance.

1.2. Conteúdo e Material

Definidos o público alvo e seu perfil, comecemos a pensar na próxima parte do planejamento que é a análise do conteúdo e material que será utilizado durante o treinamento.

Talvez esse seja o momento adequado para discutirmos o uso de ppts, porém gostaria de recomendar a utilização muito restrita desta ferramenta. Como comentei, a ideia é que um treinamento tenha muito conteúdo com muita atenção na forma que será passada e usar algum tipo de recurso em demasia (um slide com texto demais por exemplo) pode tornar a experiência toda um tanto enfadonha.

Ouso recomendar como uma boa métrica que para um treinamento de 4 horas, 50 slides são mais que suficientes. Confie em mim – e na sua própria capacidade oratória – 50 slides em 4 horas é o suficiente para passar a mensagem e não passar a impressão que este recurso na verdade é uma 'muleta' para o treinador. Um slide com muito texto espera-se subconscientemente que o empregado leia o texto inteiro e talvez não tenha tempo. Ou pior, dará uma péssima impressão se o treinador começar a ler o texto. Acredite, o que importará mais é o que você apresenta/fala e a forma que você apresenta, e não o ppt.

Outro ponto que é interessante abordar é sobre a estrutura de uma apresentação que aliada a um bom formato gráfico vão trazer enormes benefícios e interesse da equipe que está sendo treinada. Como o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo segundo a OMS, acredito que inserir um slide no começo explicando os passos e os temas que serão abordados na apresentação em ordem cronológica ajuda as pessoas se situarem no tema e em relação ao tempo. Ansiosos agradecem.

2. Algumas sugestões de estrutura e metodologia

Quanto a estrutura, uma boa estrutura de tópicos de forma cronológica ajuda o empregado a entender e assimilar melhor as informações. Como sugestão, considerando um Programa de Compliance básico de acordo com a Lei Anticorrupção Brasileira, normalmente essencialmente devem ser abordados os seguintes temas:

2.1. Conceitos sobre Integridade, como Agir Corretamente e Decisões Éticas

Pode ser um bom ponto de partida para começar a introduzir os temas de Compliance. Este é o ponto onde você exercita a quebra de paradigma e insere novos conceitos e visões que talvez não sejam tão obvias para os empregados de forma geral. O importante é colocar como a empresa espera que o empregado aja e não o senso do Compliance Officer do que é certo ou errado.

Você pode lidar com esse tema de diversas formas, seja introduzindo um exercício prático, seja fazendo determinadas perguntas para gerar reflexão da audiência, seja contando uma história ou anedota que ilustre dilemas éticos e saídas para determinadas situações ou até contratando um palestrante especial para falar sobre o tema.

É um bom momento para você começar a gerar empatia, quebrar o gelo e principalmente engajar as pessoas para que interajam com você seja no treinamento ou fora dele. Lembre-se: para tornar seu treinamento mais dinâmico e memorável você precisa criar alguns momentos chave dentro de sua apresentação que inspire as pessoas, não só para que os empregados reconheçam a forma mais adequada de agir em determinadas situações, mas também que entendam os riscos de sua tomada de decisões.

Isso pode ser muito claro e óbvio para o *Compliance Officer*, porém pode não ser nem para os mais experientes CEOs se eles não foram expostos a determinados tipos de dilemas éticos.

2.2. Breve Introdução aos Tópicos do Programa de Compliance

Normalmente quando se estabelece um Programa de Compliance do início a maioria dos empregados não sabe nem o que a área faz. Seja se ela é denominada Compliance, Conformidade ou Integridade, para que você se envolva nos processos de maior risco, ou mesmo desenvolva seu trabalho de forma adequada, a organização precisa entender o que a área faz, o que ela desempenha e principalmente quais são suas entregas.

Explicar brevemente os pilares do programa ajuda os empregados a saber quando e em que momentos a área deve ser envolvida e você também pode ser bem-sucedido em criar um ambiente de pertencimento, colocando que somos todos responsáveis pelas atividades de Compliance e pelo objetivo de sua implementação.

2.3. Legislação e Penalidades Impostas Historicamente

É um tema importante e absolutamente necessário. Porém na minha opinião serve mais para cumprir uma exigência legal do que servir como motivador para gerar a mudança e a transformação da empresa. Há diversos estudos que indicam que as pessoas reagem melhor a estímulos positivos (como premiações ou reconhecimento de atitudes pró-ativas positivas) do que negativos (como a imposição de penalidades). De qualquer forma, são informações obrigatórias em seus treinamentos.

2.4. Procedimentos e Políticas

Eis que este é o tema chave do seu treinamento. Por óbvio as pessoas têm que ser informadas de como a empresa espera que elas ajam e reajam em relação aos temas do seu Programa de Compliance e tudo aquilo que foi procedimentado. E dentro dessa área você pode estabelecer diversas atividades para fixação do conteúdo que iremos discorrer mais a seguir.

2.5. Canais de Denúncias e Reporte de Preocupações e Dúvidas

Como ponto chave final, fechando o rol de temas obrigatórios nos treinamentos, os canais de comunicação dos empregados e a empresa devem ser bem comunicados e esclarecidos. Talvez para denúncias, a organização tenha um *hotline* específico e centralizado (um site, e-mail, telefone ou todos eles).

Comunique sobre sua existência, sobre o local em que as possas podem encontrá-lo, que tipo de relatos se espera, sobre a possibilidade (ou não) de denúncias anônimas, sobre a política de proteção ao comunicante de boa-fé, além de outros pontos que parecerem essenciais para a boa funcionalidade do canal e para a formação de uma *speak-up culture*.

Quanto as dúvidas, você pode criar um caminho diferente. Ensine as pessoas a provocar a liderança imediata e, somente em caso de omissão ou permanência da dúvida, escalar ao Compliance. Além de reduzir o volume de relatos a serem tratados pelo Departamento de Compliance, garante o envolvimento e engajamento da média gerência. Fala também sobre a importância de se documentar.

2.6. Atividades

Treinar pessoas é um desafio justamente por envolver pessoas. E justamente por envolver pessoas há aspectos intangíveis que podem definir se a mensagem será absorvida ou não, e de que forma seu treinamento será visto. Normalmente para a maioria dos empregados de uma empresa, o período de treinamento é o único momento ao ano que você coloca “uma cara” para o Departamento de Compliance. A intenção de qualquer treinador ou palestrante é justamente passar a informação da melhor forma uma vez que já estejam definidos o público alvo e o conteúdo.

O trabalho do treinador será incitar essas questões e reflexões na equipe, porém o trabalho todo não deve se limitar a ele. Do outro lado os empregados devem entender que estão ali trabalhando, participando do treinamento como se estivessem executando um trabalho em suas mesas, e tanto quanto em uma reunião de equipe os empregados devem executar ações. Para isso eu acredito muito na execução de atividades dentro do treinamento.

Algumas sugestões:

2.7. Casos práticos

Uma forma muito simples de engajar pessoas em atividades é fazê-las trabalharem em casos práticos. Há milhares de dilemas e casos da vida real que podem ser aproveitados com os empregados para que eles solucionem, deem suas ideias, e criem discussões valiosas entre as equipes.

O treinador pode apresentar casos para que eles discutam e solucionem em times ou pode apresentar documentações para que identifiquem *red flags* de Compliance por exemplo. Cases são valiosíssimos para ajudar a construir o entendimento dos riscos de Compliance.

2.8. Perguntas e Respostas

Sentir o nível de conhecimento do time ou absorção do conteúdo é muito importante para o Departamento de Compliance.

Por vezes o *Compliance Officer* pode ter uma percepção errada sobre o conhecimento da equipe sobre determinado tema e isso pode impactar inclusive na dosimetria dos treinamentos como já mencionei anteriormente.

Talvez a forma mais eficaz de fazer esse teste seja na inclusão de perguntas e respostas dentro da apresentação, fazendo com que a audiência escolha entre um “sim”, “não” ou “talvez”.

Além do ganho com a confirmação ou readequação da percepção do conhecimento da companhia em determinado assunto, o Compliance Officer terá a chance de discutir em tempo real as respostas dos participantes e as razões de determinadas dúvidas.

2.9. Jogos de Tabuleiro

Talvez esse seja uma atividade que precise de algum investimento (ponto para o *Compliance Officer* com influência em um budget de treinamento grande!), mas jogos de tabuleiros sempre são interessantes e um ótimo *wow factor* para qualquer treinamento. E não é nem necessário ser tão criativo assim, há vários jogos que são perfeitamente adequáveis para os conteúdos de Compliance que as regras já são conhecidas por grande parte da população mundial como Detetive ou Jogo da Vida por exemplo.

O único cuidado que se deve ter quando se insere jogos de tabuleiro nos treinamentos é que eles não tomem um tempo muito grande do treinamento.

2.10. Teatro (*Role Playing*)

Essa atividade é talvez uma das que mais geram empatia das equipes e engajamento. Estamos falando de diversão mesmo. A ideia é que em alguma determinada mensagem que queira ser transmitida no treinamento seja transforada em um caso para discussão e as pessoas possam interpretar papéis. Ao final há o teatro onde a ideia é exposta e os outros participantes são convidados a compartilhar soluções e impressões.

Estímulos audiovisuais (pedaços de filmes, séries, curtas, etc.)

Esta forma de atividade é muito bem recebida em Programas de Compliance que já passaram por alguns anos de maturidade. As pessoas por já estarem inteiradas sobre os assuntos relacionados a Compliance só precisam relembrá-los e felizmente há diversos materiais disponíveis em filmes, curtas, pedaços de séries que tocam os temas do Programa que podem ser utilizados para gerar uma discussão e justamente essa recordação.

Só não esqueça de pedir autorização para o uso da imagem antes da utilização no treinamento.

2.11. Testemunhos

Outra atividade que funciona bem quando o Programa está bem maduro é convidar os próprios participantes dividirem seus dilemas de dia a dia com as equipes no próprio treinamento.

Esse tipo de testemunho gera uma sensação ótima para os participantes de “ser ouvido” e “compartilhar desafios”. A ideia é que alguns participantes sejam convidados para dividir seus dilemas e suas experiências de trabalho em parceria com a equipe de Compliance e quais foram os resultados e percepções desta experiência.

As pessoas que estão sendo treinadas conseguem se relacionar melhor com os temas em seu dia a dia de trabalho e de quebra o Departamento de Compliance consegue fazer com que determinadas áreas (como compras por exemplo) sejam ouvidas num fórum maior (sobre o cumprimento da política de compras, por exemplo).

Há infinitas formas de criar atividades para treinamento de Compliance e a intenção não é criar um rol exaustivo e sim de ideias com fácil aplicação. O *Compliance Officer* pode ter muitas ideias por exemplo com um simples passeio numa loja de brinquedos (o resgate de atividades que nos submetemos quando éramos criança cria um vínculo muito interessante com o Programa de Compliance tornando-o quem sabe um tema mais leve para ser tratado).

No final do dia, todo adulto ainda secretamente gostaria que fosse possível entrar numa piscina de bolinhas.

2.12. Contexto e Ambiente

Já que falamos sobre os diferentes estímulos e atividades, é importante que conste no seu planejamento os recursos que serão utilizados e o ambiente que ele será dado para que seja adequado às atividades que você desejar conduzir. Preferencialmente como sugestão escolha espaços onde os participantes se disponham em mesas para a formação de pequenas equipes pois isso permite a maior interação entre empregados e torna o ambiente mais colaborativo e intimista, facilitando a execução de atividade e a troca de experiências. De qualquer forma, se o Departamento de Compliance tiver um público enorme para treinar de uma só vez num espaço de auditório, adapte o seu treinamento e as atividades a esse ambiente.

OUTRAS REGRAS PRÁTICAS DE OURO
Privilegie treinamentos na parte da manhã. Estudos indicam que as pessoas estarão mais atentas e há uma maior participação no treinamento e menor risco de pessoas se ausentarem por emergências de trabalho.
Respeite as paradas. O poder de atenção do ser humano tem diminuído a cada estudo e isso nos leva a crer que as pessoas precisam cada vez mais de paradas para respirar. De nada adianta correr no treinamento se as pessoas não vão assimilar nada. Se possível faça as pessoas se movimentarem (especialmente se o clima na sala estiver baixo).
Não subestime o local onde o treinamento será dado. Locais sem ventilação, sem minimamente uma água e café e desconfortáveis devem não só serem evitados como abolidos.
Engaje o RH no seu treinamento. O profissional de RH da empresa tem uma visão mais ampla da empresa e pode lhe ajudar a planejar melhor o treinamento, além de motivar as equipes a comparecer.
Faça com que a alta administração sente em mesas diferentes e não juntos, para que os empregados participem das discussões com diversos diretores. Não os deixe criar um “clube do bolinha” ou uma “mesa da diretoria”. Espalhe-os. Ajudará no *tone from the top*.
Não tenha medo de se utilizar de recursos audiovisuais e frases de efeito. Por mais piegas que possa parecer, essas atitudes quebram o gelo e se tornam mais memoráveis aos empregados.
Planeje, planeje, planeje! Ensaie a sua fala e as pausas com antecedência ao treinamento. Se prepare! Você se sentirá menos nervoso e as pessoas irão notar seu empenho.

3. A Relação Entre os Treinamentos e os Pilares do Programa de Compliance

3.1. *Tone from the Top* e os Treinamentos de Compliance

Talvez uma das fases mais críticas do seu planejamento seja realmente que a alta administração se engaje. Isso porque infelizmente no Brasil a maioria das culturas empresariais que ainda existem colocam as posições de gestão em um patamar elevado como “intocáveis” que não precisam de treinamentos e o Programa de Compliance vem justamente quebrar esses paradigmas.

Mais do que falar que faz parte do *tone from the top* a disponibilidade da alta administração para estar no Treinamento de Compliance, é importante que eles participem junto das equipes como empregados comuns. E a participação não deve ser somente no primeiro discurso de abertura do evento, e sim no evento inteiro – como um empregado que eles ultimamente são.

Planeje previamente alguns pontos com a alta administração do discurso que será dado no início das atividades. Esse discurso será importante para colocar a importância da atividade do treinamento e acertar o tom – além de servir como momento chave para comprovação do *tone from the top* (caso seja necessário comprova-lo).

Uma pergunta que ocorre frequentemente é se o presidente/dono deve ficar para participar de todo o evento. A resposta sempre deverá ser sim. Devemos relembrar que os empregados estão sempre de olho nas atitudes de seus líderes, e a humildade e disponibilidade de agenda para participação de um evento inteiro sobre o Programa de Compliance será percebida por todos os empregados.

Quem dará a importância ao tema não será o *Compliance Officer*, não serão as possíveis sanções financeiras, e não será o conteúdo, será a alta administração. Sempre bom reforçar novamente: Todos da alta administração devem participar do treinamento junto com suas equipes servindo como exemplo.

Porém situações difíceis podem ocorrer. Já estive dando um treinamento para uma equipe de um país inteiro quando um dos membros da alta administração entendeu que ali era o fórum adequado para tecer críticas ao Programa de Compliance e seus requerimentos.

Veja que críticas são saudáveis e devem ser feitas por todos e processos podem e devem ser adequados sempre que necessários, porém aquele não era o momento de fazê-lo. Converse com a alta administração sobre isso. Os empregados estão de olho no comportamento de seus líderes

perante todos os assuntos, e o Programa de Compliance deve ser da empresa e não do *Compliance Officer*.

Com isso precisamos reconhecer que a alta administração precise sim de um treinamento específico, e que seja adicional ao treinamento dado para toda a empresa. Somente por estarem em posições chaves já seria razão suficiente para conduzir este treinamento especial endereçando os principais riscos que eles estão sujeitos.

3.2. Treinamentos e *Compliance Risk Assessment*

Devemos considerar que o Programa de Compliance é sempre baseado em riscos, portanto o tema treinamentos e análise de riscos andam juntos.

Quando da fase de planejamento onde se determina o público alvo e conteúdo, o Compliance Officer tem que ter uma visão completa dos maiores desafios do negócio de forma a colocar as informações não só na mesma linguagem que a organização, mas também abordando mais fortemente determinados riscos específicos já detectados.

Uma empresa por exemplo que se utiliza de distribuidores, o treinamento deve abordar mais o relacionamento integro entre as partes, ou uma empresa que tem relacionamentos próximos com autoridades, há outros temas que devem ser mais aprofundados no treinamento.

Porém tome cuidado quando da realização do *risk assessment* em não se determinar que todas as ações mitigatórias se resumam a treinamentos. Sim, é correto afirmar que treinamento é chave para mudança de atitude e cultura, porém dependendo do risco em discussão há outros tipos de controles que devem ser aplicados onde o treinamento só virá para fechar esse ciclo de mitigação. O treinamento não deve servir como resposta a todo e qualquer risco de Compliance.

3.3. Comunicação em Compliance

Grande parte do desafio depois de um ciclo de treinamento é manter o tema vivo. Justamente neste momento é que se faz necessária o investimento e o planejamento em comunicação.

E isso pode parecer simples, mas é mais complexo do que apenas alguns cartazes ou um e-mail institucional de vez em quando. Cada vez que o Departamento de Compliance inserir um novo tema, responsabilidade ou procedimento dentro do Programa, o *Compliance Officer* deverá comunica-lo a organização.

Em linhas gerais, a comunicação voltada ao Departamento de Compliance – por se tratar de temas por vezes complexos e difíceis – deverá basicamente ter duas funções principais: passar a mensagem de uma forma simples e chamar atenção para a mensagem que está sendo passada.

O planejamento de comunicação seguirá basicamente os mesmos passos do planejamento do treinamento, sendo necessário definir qual será o público, qual será o conteúdo da mensagem a ser transmitida e qual a forma que ela será passada.

Em relação ao público, ele pode ser interno (empregados) ou externo (comunidades, stakeholders, governo, etc.) e o conteúdo será determinado de acordo com o objetivo a ser atingido e tema.

Assuma por hipótese a implementação do Programa de Compliance do zero, onde a área está estabelecendo as primeiras políticas, o Código de Ética, os canais de denúncias, etc. Basicamente o planejamento de comunicação deverá ter um enfoque maior interno, pois as pessoas precisam ser lembradas desses conceitos mais que uma vez ao ano no treinamento e a mensagem deverá ser passada de forma contínua pois a empresa ainda está em transformação e se acostumando com a ideia de ter um Programa.

Colabore com o Departamento de Comunicação para definir onde a empresa já mantem seus canais de comunicação para que se inicie de uma forma mais orgânica - seja por uma intranet, ou por e-mail, ou visualmente por cartazes, o que já estiver disponível e sendo utilizado.

A maravilha de se ter um Programa de Compliance já maduro é que além dos e-mails e murais já disponíveis, o *Compliance Officer* poderá talvez dispor de mais recursos financeiros para a realização de novas atividades de comunicação. Poderá difundir ainda mais as informações criando campanhas e atingir talvez um público externo ainda maior do que o necessário. Sairá do ótimo para o excelente.

Com os canais disponíveis mapeados, o Departamento de Compliance conseguirá adicionar novas ações de comunicação, seja utilizando esses canais disponíveis, seja criando novas formas de comunicação como por exemplo, utilizar a *page* do *Facebook* e do *Instagram* para divulgar conteúdo (aqui pode atingir tanto público interno quanto externo), criar um *quiz* instantâneo periódico com perguntas de Compliance onde o empregado poderá ganhar algum prêmio, ou até ação com brindes aos empregados com informações relevantes do Programa.

O objetivo é chamar atenção e manter uma periodicidade de informações e conteúdo do Departamento de Compliance para a organização mitigando inclusive riscos talvez já mapeados.

CONCLUSÃO

Seja em treinamentos ou em comunicação, está na hora das empresas alavancarem seu programa de Compliance para dialogar com novos profissionais. Estamos na era do compartilhamento de informações e do diálogo colaborativo e Compliance deverá seguir este caminho cada vez mais dinâmico e viral se comunicando com um público cada vez mais antenado e questionador. Sejam bem-vindos a nova era da informação de Compliance.

Capítulo 10

Pilar 6 – Canais de Comunicação com o Programa de Compliance

Marilia Zulini da Costa Loosli[149]
Massamitsu Alberto Iko[150]
Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha[151]

Introdução e Legislação Aplicável

De acordo com os resultados publicados pela *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) em seu último estudo global sobre fraudes ocupacionais o *2018 Report to the Nations,* 40% de todas as fraudes corporativas identificadas no período da pesquisa tiveram como a principal fonte as denúncias, tanto de empregados como de outros stakeholders da empresa. Auditoria Interna com 15% foi a segunda maior fonte de identificação das fraudes. Outros resultados deste mesmo estudo demonstram que 63% das empresas que foram vítimas de fraudes possuíam um canal de denúncias formalmente estabelecido, e nestas os prejuízos causados pelas fraudes foram 50% menores do que nas empresas que não possuíam um canal de denúncias. Baseado nestes dados fica fácil compreender a importância da existência de uma forma de acolhimento destas denúncias.[152]

O artigo 42 do Decreto Federal nº 8.420/2015 (Decreto Anticorrupção), que regulamentou a Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) estabelece os dezesseis parâmetros de avaliação do programa de integridade e, especificamente, o seu inciso X determina a existência de canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé.

O Manual Prático de Avaliação de Programa de Integridade em Processo Administrativo de Responsabilização (PAR)[153], publicado pela Controladoria Geral da União (CGU) em setembro de 2018, tem como objetivo orientar os membros das comissões do PAR a avaliarem a efetividade do programa de integridade de uma empresa investigada. Um dos itens avaliados é a existência de um canal que permita o recebimento de denúncias e que seja acessível a todos empregados, inclusive aqueles que, eventualmente, não tenham acesso a computadores, bem como a terceiros e ao público em geral. Neste documento, a CGU recomenda a adoção de diferentes meios para recebimento de denúncias, como urnas, telefone ou e-mails e menciona a necessidade de proteção e garantias ao denunciante de boa-fé como, por exemplo, o recebimento de denúncias anônimas, a proibição de retaliação de denunciantes de boa-fé, regras de confidencialidade e a disponibilização de meios para que o denunciante acompanhe o andamento do seu reporte.

Além das questões acima mencionadas, outros documentos também reforçam a importância do canal de denúncias como um pilar fundamental para um programa de integridade efetivo:

- CGU (Controladoria Geral da União) - Diretrizes para Empresas Privadas[154]
- DOJ (Departamento de Justiça dos Estados Unidos) - *Evaluation of Corporate Compliance Programs*[155]

1. Objetivos e Formas de Implementação

O objetivo do canal de denúncia é possibilitar que empregados, fornecedores, prestadores de serviços e demais stakeholders da empresa possam de forma segura e anônima comunicar a empresa sobre qualquer tipo de violação a leis ou políticas internas, fraude ou má conduta dentro da organização. Conforme mencionado, o canal de denúncias é um dos principais meios para identificação e prevenção de novas fraudes dentro das empresas e faz parte dos pilares para implementação de programas de integridade efetivos.

Os *hotlines* ou canais de denúncias podem ser estabelecidos em diversos formatos, sendo os mais comuns as linhas de telefone e caixas de e-mails exclusivas ou formulários na internet. O importante é estabelecer um método que possa ser acessível, de fácil utilização e que permita que o usuário faça o contato de forma anônima.

O primeiro aspecto a se considerar para a implementação do canal de denúncias é o porte da empresa e a existência de empregados que não possuem fácil acesso a computadores. No caso de empresas de grande porte e cuja boa parte dos empregados não trabalhem "conectados" a computadores ou celulares, como por exemplo, empregados que trabalham em fábricas, lojas, dirigindo carros ou caminhões, é necessário pensar em alternativas eficazes para facilitar o acesso ao canal. Uma opção é implementar um canal de denúncias por telefone, com atendentes especializados e treinados, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

A presença da empresa em diversos países é um fator que traz complexidade adicional à implementação de canais de denúncias, pois a indisponibilidade do canal na língua nativa do denunciante pode dificultar ou até inibir a realização de reportes, além de possivelmente dificultar ou gerar atrasos no tratamento da denúncia. Nestes casos, deve-se avaliar a conveniência de implementar o canal localmente, em cada país, disponibilizando atendentes nativos que consigam captar a denúncia, compreender os fatos narrados e direcionar rapidamente a tratativa ou investigação para a filial local.

Caso se opte por implementar um canal de denúncias centralizado na matriz, a contratação de empresas terceirizadas especializadas na captação de reportes deve ser avaliada, para se manter a padronização e disponibilização do canal em diversas línguas. Há empresas no mercado que disponibilizam atendentes poli lingues e/ou tradutores simultâneos que facilitam o recebimento das denúncias e direcionam para a filial ou departamento específico para cuidar das tratativas, conforme definição da política de cada empresa.

Além do atendimento via telefone nas principais localidades onde a empresa atua, uma boa prática para todas as empresas, independente do tamanho e cultura, é criar um formulário eletrônico, tanto na intranet como no site institucional da empresa, disponível a todos os públicos. Em tais formulários, é possível disponibilizar campos para direcionar a denúncia conforme o tema e/ou país onde ocorreu a situação por exemplo, orientar o denunciante, permitir que o denunciante faça o reporte de forma anônima e enviar o texto a uma caixa de e-mails centralizada. Para empresas de pequeno e médio porte, esta pode ser a solução para a criação de um canal de denúncias de simples operação e de baixo custo.

A existência de uma área que centralize o recebimento das denúncias, como a área de Recursos Humanos, Jurídico ou o próprio Compliance, é fundamental para padronizar o direcionamento do reporte, as tratativas, investigações e medidas de consequência aplicáveis, além de possibilitar a criação de indicadores da empresa que balizam a ações preventivas do programa de integridade, tais como comunicações e treinamentos.

A centralização também eleva a garantia de imparcialidade e confidencialidade no tratamento das denúncias recebidas, pois restringe o número de pessoas com acesso às informações contidas no canal. Tais características são essenciais para incentivar o uso, pois gera confiança ao público alvo de que os fatos narrados terão destino adequado. Ao contrário, o menor sinal de vazamento de informações do canal e retaliação a denunciantes de boa-fé, pode minar a confiança no canal e no programa de integridade (tema detalhado adiante).

Por fim, não importa o formato do canal de denúncias de sua empresa, que pode ser por meio de uma linha telefônica, site da internet, endereços de e-mail, caixa de denúncias, etc. Importante mesmo é que este mecanismo seja amplamente divulgado, tanto dentro da empresa como para o público externo. A divulgação nos canais internos da empresa (intranet), e nos sites externos da internet, comunicados e cartazes são essenciais para o efetivo funcionamento de um canal de denúncias.

2. A Importância do Anonimato

A Lei Anticorrupção previu como um dos fatores atenuantes de sanções que a implementação de programas de compliance deve ser baseada na "existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e **incentivo à denúncia de irregularidades** e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica", justamente pelo caráter preventivo, detectivo e de responsabilização daqueles indivíduos que pratiquem os atos lesivos, em nome ou representação da pessoa jurídica.

Como visto, o Decreto Federal que regulamentou a Lei Anticorrupção previu a necessidade de existência de "canais de denúncia de irregularidades". Importante ressaltar que esta sistemática não foi uma inovação do direito brasileiro. Encontra-se amparada em uma lógica e diretrizes estabelecidas pelo direito norte-americano, que promulgou em 1977 o *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* e em 2002 a *Sarbanes-Oxley Act (SOx)*. Em relação à FCPA, no intuito de disciplinar os programas de compliance das empresas sujeitas da legislação americana, os órgãos responsáveis pelo *enforcement* da norma, *U.S. Department of Justice (DOJ)* e *U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)*, editaram o manual denominado *A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act.*

No capítulo 5 do referido manual (*Guiding Principles of Enforcement*), o instrumento apresenta no item *Hallmarks of Effective Compliance Programs* os pilares do programa de compliance efetivo aos olhos dos órgãos de fiscalização e controle americanos, dentre eles os canal de denúncias e as investigações internas de irregularidades (*Confidential Reporting and Internal Investigation*). Consta do referido trecho, *in verbis*:

> *An effective compliance program should include a mechanism for an organization's employees and others to report suspected or actual misconduct or violations of the company's policies on a confidential basis and without fear of retaliation. Companies may employ, for example,* ***anonymous hotlines or ombudsmen****. Moreover, once an allegation is made, companies should have in place an efficient, reliable, and properly funded process for investigating the allegation and documenting the company's response, including any disciplinary or remediation measures taken. Companies will want to consider taking "lessons learned" from any reported violations and the outcome of any resulting investigation to update their internal controls and compliance program and focus future training on such issues, as appropriate.* [156]

Como se observa, uma das preocupações dos órgãos de aplicação do FCPA, especificamente em relação ao Canal de Denúncias ou Ouvidoria, não se restringe apenas à existência da ferramenta, mas também quanto à sua efetividade. Essa efetividade decorre justamente da confiabilidade do instrumento em relação ao público a que é destinado (interno e externo). Para isso, deve se firmar sobre três pilares:

- Confidencialidade
- Anonimato (possibilidade de)
- Proteção ao comunicante

Seguindo a mesma linha de raciocínio, a seção 301 da *Sarbanes-Oxley Act (SOx)*, publicada posteriormente à FCPA, expõe de forma expressa:

> *SEC. 301. PUBLIC COMPANY AUDIT COMMITTEES.*
> *Section 10A of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78f) is amended by adding at the end the following: […]*
> *(4) COMPLAINTS. - Each audit committee shall establish procedures for—*
> *(A) the receipt, retention, and treatment of complaints received by the issuer regarding accounting, internal accounting controls, or auditing matters; and*
> *(B)* ***the confidential, anonymous submission by employees of the issuer of concerns regarding questionable accounting or auditing matters****.* [157]

A agência *Occupational Safety and Health Administration (OSHA),* vinculada ao Departamento do Trabalho do Governo Americano, por meio do seu comitê *Whistleblower Protection Advisory Committee (WPAC*), editou o documento denominado *Best Practices for Protecting Whistleblowers and Preventing and Addressing Retaliation*, em que define:

> *The best way to preclude retaliation is to take a preventive approach, starting with a real program to assure employees can raise issues of concern. The seeds of retaliation are planted when employee issues are unwelcome or go unaddressed. Therefore, employers should foster a "speak up" culture that encourages reporting, provides for fair evaluation, and for just and effective resolution of concerns.* ***[…] To assure issues are not missed, anonymous reporting should be available****. […]*

Retaliation against whistleblowers usually stems from prior management failures to address issues that employees believe are important or that they otherwise believe they have an obligation to report. An effective retaliation response system should include an independent complaint review process and an independent reporting line that can reach the employer's board or oversight body, if necessary. The system must include clearly defined roles, responsibilities, and expectations for top leaders, board members, managers at all levels, employees, compliance and legal staff, and HR and labor relations staffs. The procedures should be known and accessible to all. […] ***Like issue reporting, the retaliation response system should include multiple avenues for reporting, including opportunities outside chain of command and a hotline, including anonymous reporting****.* [158]

Retornando à realidade nacional, a primeira ouvidoria pública brasileira foi criada em 1986, no município de Curitiba. Desde então, e em especial desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, as ouvidorias evoluíram rapidamente, sob o impulso das reinvindicações populares por participação nas deliberações do Estado. Em 1995 foi criada a Ouvidoria-Geral da República, como parte da estrutura do Ministério da Justiça. Em 2003, a Ouvidoria-Geral da República foi transferida para a estrutura da Controladoria-Geral da União (CGU), e posteriormente teve o nome alterado para Ouvidoria-Geral da União (OGU), com competência para exercer a coordenação técnica do segmento de ouvidorias do Poder Executivo federal.

A Instrução Normativa OGU nº 01, de 05 de novembro de 2014[159], promove a atuação integrada e sistêmica das Ouvidorias do Poder Executivo federal, com a finalidade de qualificar a prestação de serviços públicos e o atendimento aos cidadãos. Já na Instrução Normativa Conjunta CRG/OGU nº 01, de 24 de junho de 2014[160], o Governo Federal estabelece normas de recebimento e tratamento de denúncias anônimas e estabelece diretrizes para a reserva de identidade do denunciante.

Nestes instrumentos normativos, consigna-se que é iniciativa do Governo Federal, o recebimento de qualquer tipo de comunicação por meio do seu sistema de ouvidoria, na forma anônima. O e-Ouv é o atualmente sistema que permite a você reclamar, sugerir, denunciar, elogiar e solicitar providências e a simplificação de serviços às ouvidorias públicas, disponível no site http://www.ouvidorias.gov.br/cidadao/acesso-e-ouv e disposto em todos os órgão e entidades do Governo Federal. Ainda, de acordo com o Manual para Ouvidores Federais:

O cidadão pode realizar manifestação anônima ou identificada. Neste último caso, ao final do registro da manifestação, será gerado um número de protocolo, com o qual o cidadão poderá consultar o andamento do pedido posteriormente. Caso seja uma manifestação anônima, não há um número de protocolo, e não será possível realizar o acompanhamento. [161]

Figura 1: Imagem retirada do site http://www.ouvidorias.gov.br/cidadao/acesso-e-ouv

Por fim, no intuito de auxiliar a pessoas jurídicas de direito privado na implementação de Programas de Compliance, especialmente para a prevenção de atos lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013, a Controladoria-Geral da União (CGU) criou o manual Programa de Integridade – Diretrizes para Empresas Privadas. No item 4.4, consta a orientação:

Uma empresa com um Programa de Integridade bem estruturado deve contar com canais que permitam o recebimento de denúncias, aumentando, assim, as possibilidades de ter ciência sobre irregularidades. A empresa deve avaliar a necessidade de adotar diferentes meios para que possa receber denúncias, como urnas, telefone ou internet. Em empresas com funcioná- rios que não tenham acesso a computador com internet, deve-se estar atento à necessidade de oferecimento de alternativas à denúncia online. É importante também que os canais de denúncias sejam acessíveis a terceiros e ao público externo. ***Para garantir a efetividade de seus canais, é necessário que a empresa tenha políticas que garantam a proteção ao denunciante de boa-***

***fé como, por exemplo, o recebimento de denúncias anônimas e a proibição de retaliação de denunciantes**. A empresa pode também prever regras de confidencialidade, para proteger aqueles que, apesar de se identificarem à empresa, não queiram ser conhecidos publicamente. **O bom cumprimento pela empresa das regras de anonimato, confidencialidade e proibição de retaliação é um fator essencial para conquistar a confiança daqueles que tenham algo a reportar**. Além disso, é desejável que a empresa tenha meios para que o denunciante acompanhe o andamento da denúncia, pois a transparência no processo confere maior credibilidade aos procedimentos.* [162]

Dessa forma, a possibilidade de denúncias anônimas por Canais de Denúncias e Ouvidorias é evidentemente reconhecida como uma boa prática nacional e internacional para garantir a confiabilidade do instrumento ao público a que é destinado, junto a outros dois critérios que também devem ser observados, a confidencialidade e proteção ao denunciante.

3. A Importância da Proteção ao Denunciante de Boa-Fé

Outro fator a ser observado na implementação do canal de denúncias é a proteção do denunciante de boa-fé. Neste sentido, uma política clara de não retaliação e a possibilidade de efetuar uma denúncia anônima, bem como a confidencialidade das informações reportadas e o acompanhamento do status da denúncia pelo denunciante, contribuem para a transparência e efetividade da ferramenta.

O Manual Prático de Avaliação de Programas de Integridade em Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) da Controladoria-Geral da União é categórico: “Para garantir a efetividade dos canais, é necessário que existam garantias de proteção ao denunciante de boa-fé como, por exemplo, o recebimento de denúncias anônimas, a proibição de retaliação de denunciantes e regras de confidencialidade”. [163]

Tal política deve ser escrita, aprovada pela alta administração da empresa, publicada nos canais institucionais internos e externos da empresa, amplamente divulgada e objeto de treinamentos específicos, para que seja incentivado o uso do canal de denúncias por todos os públicos alvo. Além deste fator, questões adicionais como a facilidade de acesso e o uso da língua nativa do país devem ser levadas em consideração, conforme já exposto.

4. A Gestão das Comunicações Recebidas

Não menos importante que a existência e implementação de um mecanismo de denúncias, é o tratamento que se dá às denúncias recebidas pelo canal. Ressalta a CGU, que “não basta ter os canais, é preciso que e pessoa jurídica tenha meio para apurar e tratar as denúncias recebidas, bem como sancionar aqueles que violaram os padrões de ética e conduta estabelecidos pela pessoa jurídica”. E ainda continua: “também é desejável a disponibilização de meios para que o denunciante acompanhe o andamento da denúncia, pois a transparência no processo confere maior credibilidade aos procedimentos”.[164]

Deve existir um protocolo para o recebimento, classificação e tratamento destas denúncias, com acesso restrito apenas para aquelas pessoas responsáveis pela investigação. E algumas etapas devem ser observadas:

1. Recebimento, fontes e designação das alegações
2. Categorização das alegações
3. Avaliação da gravidade da alegação
4. Planejamento da investigação
5. Realização da investigação
6. Protocolos de comunicação
7. Comunicação dos resultados
8. Ações corretivas e mitigatórias

O nome do denunciante assim como os fatos narrados devem ser tratados com sigilo e proteção de vazamento de informações, para se elevar a confiança, seriedade e uso do canal. Comprovada a procedência da denúncia, a devida tratativa com a adoção das medidas corretivas aos envolvidos na conduta indevida tem consequências educativas ao restante dos empregados e contribui para a efetividade do programa de integridade da empresa.

A tratativa das denúncias, com a respectiva investigação dos fatos narrados pelo denunciante e aplicação das consequências cabíveis, como medidas disciplinares e desligamentos, é abordada com maior profundidade no Capítulo 11 deste livro.

Conclusão

Neste capítulo, vimos a relevância da implementação de canais de denúncia para a efetividade de programas de integridade em empresas de qualquer porte ou localização. De fato, o canal de denúncias é um dos principais meios de identificação de fraudes e violação a leis e políticas da empresa. Comprovada a procedência da denúncia e com a adoção das ações corretivas e mitigatórias, é possível aprimorar os controles e implementar práticas para prevenir novos desvios, tais como criação de novas regras, comunicação e treinamentos. Uma empresa que conhece as suas próprias vulnerabilidades, adota medidas corretivas e preventivas e almeja a confiança de seus empregados, fornecedores e clientes, é uma empresa que está na direção para a criação de uma cultura organizacional de integridade e transparência em suas relações.

Referências Bibliográficas

ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS. *Report to the Nations 2018: global study on occupational fraud and abuse*. 2018.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Programa de integridade: diretrizes para empresas privadas.* Brasília, set. 2015. Disponível em <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf>. Acesso em 14 abr. 2019.

_____. Controladoria-Geral da União. Ouvidoria-Geral da União. *Instrução Normativa nº 01 de 05 de novembro de 2014*. Disponível em http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/ legislacao/in/in-cgu-04.pdf. Acesso em 14 abr. 2019.

_____. Controladoria-Geral da União. Ouvidoria-Geral da União. *Manual para Ouvidores Federais,* Brasília: 2015 Disponível em http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/legislacao/ instrucao-normativa/manual-instrucao-normativa.pdf. Acesso em 14 abr. 2019.

_____. Controladoria-Geral da União. *Instrução Normativa Conjunta nº 01 CRG/OGU de 04 de julho de 2014.* Disponível em http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/legislacao/in/ instrucao-normativa-conjunta-n-01-2014-ogu0001.pdf. Acesso em 14 abr. 2019.

_____. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. *Manual prático de avaliação de programa de integridade em PAR.* Brasília, set. 2018. Disponível em < http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/manual-pratico-integridade-par.pdf>. Acesso em 24 fev. 2019.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission. *A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act.* Disponível em <https://www.justice.gov/ criminal-fraud/fcpa-guidance>. Acesso em 14 abr. 2019.

_____. Fraud Section of the Criminal Division of the U.S. Department of Justice. *Evaluation of Corporate Compliance Programs.* Disponível em <https://www.justice.gov/ criminal-fraud/page/file/937501/download>. Acesso em 14 abr. 2019.

_____. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Whistleblower Protection Advisory Committee (WPAC). *Best Practices for Protecting Whistleblowers and Preventing and Addressing Retaliation*, April 21, 2015. Disponível em https://www.whistleblowers.gov/ sites/default/files/2016-11/WPAC_BPR_42115.pdf. Acesso em 14 abr. 2019.

_____. Sarbanes-Oxley Act. Public Law 107-204 JULY 30, 2002. Disponível em https://pcaobus.org/About/History/Documents/PDFs/Sarbanes_Oxley_Act_of_2002.pdf. Acesso em 14 abr. 2019.

Capítulo 11

Pilar 7 – Investigações Internas e Medidas Disciplinares

Alessandra Gonsales[165]
Daniel Sibille[166]

Introdução

Um tema de constante desafio para a área de compliance são as investigações internas.

Há uma série de fatores que devem ser considerados durante o processo de investigação, incluindo como e quando iniciar uma investigação interna, gerenciamento do orçamento que será direcionado à investigação, determinação de quem será responsável pela investigação (será necessário, por exemplo, a contratação de advogado externo em razão do privilégio profissional?), elaboração do *planning memo*, contendo o escopo e as etapas que serão executadas. Abaixo abordaremos algumas questões práticas sobre o tema, alguns tópicos controversos, dicas e melhores práticas para tornar as investigações internas mais eficazes.

1. Quando e Como Iniciar uma Investigação Interna

As investigações internas geralmente começam com uma denúncia ou suspeita de violação legal, das políticas internas, fraude ou até mesmo um crime. As investigações internas podem ser iniciadas por diversas fontes: denúncia de um funcionário, acionista, diretor, fornecedor ou qualquer outro *stakeholder*; notícias de mídia; resultado do trabalho da auditoria interna ou externa, resultado da avaliação de riscos ou auditoria do programa de compliance que deve ser efetuada periodicamente, processos administrativos ou judiciais de reguladores ou funcionários, parceiros de negócios, distribuidores, fornecedores ou até mesmo membros do conselho, entre outras.

O primeiro passo a ser adotado pela área de compliance, quando diante de uma denúncia ou suspeita de desconformidade ou ilegalidade, com base em uma das fontes acima, é analisar se a alegação ou denúncia requer investigação e, em caso afirmativo, quem deve conduzir a investigação. Em algumas empresas, a decisão sobre o seguimento ou não da investigação é da área de compliance, ou de outras áreas como auditoria[167], é recomendável que a empresa possua um Comitê de Ética que possua reporte direto a maior instância da empresa e este tenha como uma das atribuições decidir sobre a abertura ou não das investigações.

Seguindo as melhores práticas de governança e transparência, as decisões relevantes relativas ao Programa de Compliance deveriam ser tomadas pela decisão colegiada deste comitê. Nas empresas internacionais, este comitê ou o órgão decisor sobre os temas de compliance estão localizados na matriz para dar ainda mais independência e autonomia à área de compliance no Brasil. De qualquer forma, o(s) profissional(is) que decidirão sobre a abertura ou não de uma investigação interna possuem dever de diligência e responsabilidade fiduciária em relação à sua decisão.

Não podemos deixar de citar que as investigações geralmente são caras e os recursos são limitados. Embora a necessidade de investigar em certos casos seja óbvia, alguns fatores a serem considerados incluem:

1. A gravidade das alegações, incluindo se a falta cometida alegada viola o direito penal ou a política da empresa;
2. Existência de histórico de violações semelhantes;
3. Se a falta cometida envolve a gerência sênior ou membros da diretoria ou conselho;
4. Exposição potencial para a empresa, principalmente reputacional, se as alegações forem verdadeiras;
5. A possibilidade de violações futuras adicionais ou de que as violações continuem;
6. Se a suposta má conduta implica um potencial risco de saúde e segurança para funcionários ou outros;
7. Se existe uma investigação paralela do Poder Público ou se é provável que tal investigação ocorra;

8. Se a suposta má conduta põe em causa qualquer controle interno prévio ou certificações financeiras fornecidas por executivos e se a alegada conduta inadequada impede que tais gestores executem certificações futuras;
9. A provável resposta dos auditores da empresa à suposta má conduta;
10. Se o regulamento do comitê de ética, o código de conduta ou outras políticas determinam ou incentivam que este tipo de situação seja reportada às autoridades;
11. Até que ponto a empresa pode receber crédito por conduzir sua própria investigação;
12. O possível impacto em qualquer litígio civil pendente ou potencial.

2. Gerenciando o Orçamento

Gerenciar o orçamento durante uma investigação interna é um dos grandes desafios para a área de compliance, já que geralmente requer extensas revisões de e-mails e documentos, imagens forenses de dispositivos, auditorias e custos com consultores externos, inclusive escritórios de advocacia e auditorias. Como já mencionado a decisão pela abertura ou não de uma investigação interna não é uma mera opção do comitê de ética ou da área de compliance, mas uma decisão pautada no dever de diligência e na responsabilidade fiduciária e, geralmente, as investigações mais dispendiosas são aquelas que envolvem maiores riscos patrimoniais e reputacionais para a empresas e, e alguns casos, reporte às autoridades.

Neste tipo de investigação, é essencial que a área de compliance possa fornecer toda a documentação produzida para as autoridades, bem como ser capaz de demonstrar que a investigação interna foi conduzida seguindo as melhores práticas, não poupando recursos para obter as informações relevantes e para tomar as medidas de remediação necessárias. Diante desse cenário, como equalizar a credibilidade da investigação com seus custos? Aqui estão algumas dicas sobre como efetivamente conduzir investigações aproveitando ao máximo os recursos internos e tecnológicos.

2.1. Identifique o escopo correto da investigação

Identificar e avaliar com precisão o escopo da investigação ajudará muito a reduzir custos, porque, em vez de profissionais iniciarem uma revisão de documentos, auditorias ou até mesmo a coleta de dispositivos, é necessário primeiro entender se há informações disponíveis para conduzir uma investigação ou meios disponíveis para obter esta informação.

Um bom exemplo disso é quando recebemos denúncias generalizadas, como "O gestor X está envolvido em um caso de corrupção". Mesmo que uma alegação como essa seja bastante alarmante, se não houver mais informações sobre uma data específica, terceiros que teriam interagido com ele, uma empresa específica ou outra informação, a investigação será bastante prejudicada. Se não for possível fazer o acompanhamento com o denunciante para obter informações adicionais, o investimento não será efetivo.

2.2. Desenvolva um Planejamento Inteligente

Estabelecer prioridades, custódias e evidências a serem obtidas pode ser crucial para uma economia orçamentária. Neste contexto, a construção de uma investigação faseada pode ajudar o investigador a ter visibilidade do todo e trabalhar individualmente em cada parte da investigação. Se você puder detalhar as etapas necessárias no “planning memo”, incluindo todos os custodiantes[168] prioritários, revisão de documentos e entrevistas necessárias, será possível minimizar os custos de viagem, de contratação de auditoria e de advogados externos. Há também recursos que podem ser utilizados para redução de custo como videoconferências e aplicativos de comunicação.

A contratação de advogados externos é fundamental em muitas situações para dar credibilidade e independência à investigação, porém, esta contratação deve ser efetuada de forma inteligente, solicitando opiniões e análises jurídicas apenas nas situações mapeadas previamente, evitando solicitações genéricas e sem cronograma definido. Também é bastante comum ter o desejo de realizar auditorias em muitos dos casos a serem analisados, especialmente os que envolvem as áreas comercial e de suprimentos, no entanto, se não houver data de corte ou informações um pouco mais objetivas, as auditorias a serem realizadas raramente serão eficazes.

2.3. Use Recursos Internos

Recursos internos podem ser de grande valor na redução dos custos de uma investigação. Algumas empresas têm recursos de inteligência artificial para buscar transações e processos de auditoria, e isso pode ser mais eficaz do que contratar uma empresa externa. Realizar a revisão de e-mails e documentos internamente também é importante, pois além de profissionais internos já serem especialistas na maioria das questões comerciais, não haveria custos adicionais. Para revisões contratuais e até memorandos legais, o uso do departamento jurídico pode ser também eficaz.

2.4. Solicite Relatórios Regulares e Propostas Anteriores

Uma das maneiras mais eficazes de controlar os custos de uma investigação é solicitar uma estimativa dos honorários com antecedência e também receber reportes regulares, se possível semanalmente. Nestes relatórios você será capaz de entender o momento atual da investigação, os passos que serão dados, alguns detalhes operacionais e, o mais importante, os valores gastos em cada fase.

2.5. Considere Relatos Verbais e Apresentações em *Power Point*

Usar relatórios verbais ou resumidos por e-mail pode ser uma ferramenta importante para economizar tempo e dinheiro. Em casos menos complexos, como violação de políticas sem grande impacto e risco legal, seu uso pode ser efetivo, desde que o caso seja atualizado nos registros internos da empresa.

A substituição de relatórios grandes por modelos em *power point*, por exemplo, também permite economias substanciais, mesmo para investigações complexas, pois pode ajudar o comitê de ética, o conselho e até as autoridades a entender a complexidade dos achados e o resultado da investigação.

3. Pontos Relevantes a Serem Levados em Consideração

Quem deve conduzir uma investigação interna?

Após a avaliação inicial de que uma investigação deve ser conduzida, surgem questões importantes sobre quem deve conduzi-la. Normalmente, o departamento legal, de compliance, de auditoria ou de recursos humanos será designado para conduzir a revisão[169], no entanto, se os membros do conselho ou executivos seniores da organização estiverem envolvidos, recomenda-se que a investigação seja atribuída a equipe independente para garantir a independência e autonomia necessárias do processo. Outra questão a ser considerada nesse caso é a interação entre os executivos seniores e a área de compliance. Embora haja respeito mútuo entre os departamentos, o gestor de compliance geralmente procura a gerência sênior para obter suporte para a implementação do programa, especialmente em sua fase inicial, e no caso de uma investigação em andamento conduzida por conformidade em que tal gestor está sendo investigado, a decisão de dar suporte efetivo pode ser comprometida.

Outro fator a considerar é a equação entre o tempo esperado para a conclusão do caso e os recursos disponíveis. Nesse caso, deve-se considerar se a designação do caso para uma equipe interna com habilidades e conhecimento de investigações ou para aconselhamento externo seria a solução mais eficaz. Os recursos são limitados, portanto, entender como usá-los efetivamente fará a diferença.

Uma dica importante para os executivos de compliance serem capazes de equilibrar restrições orçamentárias com um tempo menor de investigação é desenvolver um plano interno de investigação para investigações potencialmente menos prejudiciais, onde um terceiro analisa documentos e e-mails e o departamento jurídico ou de compliance (ou até de auditoria ou recursos humanos, dependendo do tema) conduz as entrevistas e prepara o relatório. Será certamente mais rentável.

3.2. Planejamento, Definição de Escopo e Execução

A área de compliance deve avaliar e reavaliar constantemente o escopo de uma investigação. Uma armadilha comum é atacar demais, muitas vezes com base em informações difusas ou múltiplas violações e falta de foco. Por exemplo, se você tem uma suposta violação no departamento de vendas,

não seria necessário ou eficaz revisar toda a estrutura de preços ou toda a cadeia de distribuição. No caso de uma denúncia recebida através do canal de denúncias, por exemplo, uma entrevista preliminar e uma breve reunião do comitê de ética podem ajudar a definir o escopo com mais precisão. Observe que as denúncias realizadas através do canal geralmente são feitas com uma alta carga emocional, e ser capaz de discernir o que precisa ser usado no plano de investigação é crítico.

Quanto aos custodiantes, para manter o foco no escopo da investigação, é importante identificar os principais participantes e torná-los prioridades. Quando surgem novos fatos ou custodiantes, o escopo pode ser revisto. Isso não significa descartar os outros, mas sim prestar atenção especial aqueles que podem contribuir mais efetivamente para a investigação.

Quanto à evidência, os documentos (incluindo e-mails e mensagens de aplicativos e de texto) são muitas vezes a melhor forma de evidência. Atualmente, um número impressionante de casos é suportado por evidências de aplicativos de mensagens. Para tornar essas evidências válidas para uso em juízo, em muitas jurisdições, é fundamental que a empresa tenha uma política clara de investigação e uso de dispositivos comunicada a seus funcionários.

Também é aconselhável enviar um aviso de retenção aos custodiantes para preservar todas as evidências em potencial e evitar a destruição de documentos. Certifique-se de ter procedimentos para vincular documentos a seus autores e destinatários e arquivar provas adequadamente.

Com relação à revisão de documentos, é muito importante que a equipe dedicada à investigação tenha tempo suficiente para concluir uma análise significativa, familiarizem-se com os principais documentos relacionados a cada testemunha e decidam como confrontar cada testemunha com esses documentos durante a entrevista.

Depois de definir o escopo, o planejamento e a revisão de documentos, é hora de realizar entrevistas. Investigadores devem ser guiados pelos documentos e alegações para identificar os custodiantes. Ao entrevistar, fique atento aos direitos e obrigações dos funcionários e da empresa e aja com gentileza e foco.

Os custodiantes muitas vezes tentam evitar que a entrevista corra bem, mentirá ou até mesmo tentará desqualificar o investigador. É fundamental que um investigador, seja ou não da área de compliance, aja de maneira natural e firme para concluir o processo. Os profissionais das áreas que assessorem compliance em relação às investigações internas devem ser experientes e treinadas.

Vale destacar que, tanto o eventual confronto de informações com os custodiantes, assim como a tentativa de obtenção de qualquer outra informação dos custodiantes deve observar as normas brasileiras, principalmente a legislação trabalhista e penal.

A realização de entrevistas mal conduzidas pode gerar um grande risco para as organizações e, principalmente, para a área de compliance. Imagine o impacto para a área de compliance se a organização recebe, como já aconteceu com algumas empresas, uma ação trabalhista em razão da má condução de uma investigação? Todo o tempo e dedicação para convencer a alta administração, os colaboradores e stakeholders da seriedade e importância do programa de compliance para a organização terão sido perdidos.

Em suma, uma boa entrevista é fundamentalmente aquela que possibilita: (i) a descoberta de tantos fatos relevantes (ou fontes de tais fatos) do custodiante quanto possível; e (ii) uma avaliação precisa da credibilidade da testemunha.

Preparar o relatório depois de seguir todas as etapas acima é uma consequência natural de um processo de investigação para averiguação de fatos. O relatório final deve conter o escopo da investigação, um resumo das medidas tomadas durante a revisão (incluindo uma descrição dos custodiantes), uma descrição de todos os fatos encontrados, os pontos mais relevantes e uma conclusão factual sobre as alegações.

O próximo passo e, como resultado do relatório, é implementar as melhorias e ação disciplinar, conforme necessário. A ação de correção, se houver, deve ser adaptada à situação. A ação apropriada pode incluir: treinamento de funcionários, parceiros de negócios e terceiros; criação e revisão de políticas; e aplicação de medida disciplinar, como carta de advertência, suspensão ou até demissão de funcionários. Uma dica importante é se concentrar na implementação oportuna de itens de ação, pois o atraso na tomada de tais ações pode tornar a investigação interna ineficaz.

3.3. Dados Privados

Durante as investigações internas e especialmente a coleta de dispositivos dos funcionários, é crucial que a área de compliance verifique as leis locais aplicáveis. Em vários países da América Latina, por exemplo, é recomendável obter o consentimento formal do funcionário para evitar a exposição legal e a suposta violação de dados pessoais. Em caso de dúvida, é sempre recomendável procurar parecer externo.

Outras situações específicas devem ser consideradas, como a existência de uma política de investigação que é comunicada aos funcionários, a existência de uma política de BYOD e restrições locais, com base na legislação ou jurisprudência.

Outro ponto muito relevante é a promulgação do GDPR e da Lei Brasileira de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/18) que gerou uma mudança significativa nos processos internos, uma vez que as empresas que planejam conduzir investigações internas sobre a conduta de seus funcionários ou agentes provavelmente precisarão primeiro realizar avaliações de impacto de proteção de dados (DPIAs); As DPIAs agora são obrigatórias em alguns casos no âmbito do GDPR.

Em termos práticos, o processo de DPIA exigirá que as empresas considerem e documentem a natureza e o escopo das investigações propostas, as razões pelas quais elas são procuradas e sua avaliação da necessidade e proporcionalidade das medidas e do impacto na privacidade dos indivíduos. Além disso, exige que as empresas descrevam as etapas que planejam adotar para lidar com os riscos à privacidade.

3.4. Privilégio Advogado-Cliente

Embora o contexto de proteção advogado-cliente possa variar dependendo do país onde a revisão é conduzida, o conceito de privilégio advogado-cliente é uma ferramenta essencial para a condução de investigações internas envolvendo questões relevantes e exposição importante.

Certificar-se de que as investigações são privilegiadas é importante porque permite que os clientes e seus advogados discutam problemas, cheguem a conclusões ou outras descobertas, discutam soluções alternativas e tomem decisões com base nos resultados sem medo de divulgação a terceiros. Isso ajuda a proteger a precisão e a integridade da revisão.

Essa proteção é especialmente importante no contexto das investigações do FCPA, Lei Brasileira Anticorrupção ou qualquer outra lei anticorrupção internacional, dado o potencial de que terceiros, incluindo o Poder Públicos, acionistas da empresa ou outras partes interessadas, possam buscar acesso a informações altamente confidenciais produzidas em uma revisão.

Se um escritório de advocacia for contratado para conduzir a investigação interna, deve ficar especificado, desde o início, a investigação específica está sendo conduzida sob a proteção do privilégio.

Depois disso, e em cada etapa, o advogado e os investigadores devem declarar inequivocamente, antes de qualquer entrevista, que a investigação está sendo conduzida sob o privilégio e que é privilégio da empresa, de modo que a renúncia ou qualquer reivindicação pertença à empresa, não a qualquer indivíduo. A empresa deve documentar cuidadosamente a base legal da investigação, a afirmação específica do privilégio e fornecer orientações básicas sobre como o privilégio deve ser preservado.

Mesmo se as leis locais se aplicarem, quando se trata de uma investigação envolvendo o FCPA sob o privilégio de advogado-cliente, há muitos detalhes relevantes sobre a aplicação do conceito e, como um guia geral, é recomendável a contratação de um advogado americano, estará familiarizado com seus detalhes e aplicação.

Conclusão

Com o crescimento exponencial das investigações internas, especialmente na América Latina, é fundamental que a área de compliance receba a legitimidade e a independência necessárias para conduzir as investigações necessárias. O custo, como mencionado acima, pode impactar, mas não ser uma barreira para a realização da investigação. Algumas formas inteligentes de maximizar esforços e reduzir os custos que podem ser aplicados à maioria das investigações existentes, independentemente do tamanho da empresa, foram mencionadas neste artigo.

A realização de investigações internas requer uma série de decisões que variam de acordo com a gravidade da investigação, bem como a resposta esperada do Poder Público. Infelizmente, essas

respostas nem sempre são previsíveis, por isso, será sempre melhor realizar uma investigação com base nas melhores práticas de compliance.

Capítulo 12

Pilar 8 - *Due Diligence* de Integridade
Uma Estratégia para a Gestão de Riscos de Terceiros

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha[170]

Introdução

A estruturação de um programa ou sistema de *compliance* ou integridade[171] em uma organização passa naturalmente pela elaboração dos mecanismos ou pilares destinados ao público interno, primeiramente, para na sequência atingir terceiros que com ela se relacionam. Embora não seja uma regra, obviamente, faz mais sentido primeiro *estar compliant*, para depois exigir que alguém *seja compliant*.

No entanto, em determinado momento, inevitavelmente, os terceiros que se relacionam com uma organização serão atingidos pelas ações (normas, controles internos, treinamentos, comunicações, etc.) de seu programa de *compliance*, caso ele seja efetivamente levado a sério (e não um programa de *faz de conta*). Isso se deve ao fato de que o relacionamento com terceiros naturalmente traz uma série de riscos para a organização, ao passo que são essencialmente necessários. Assim, como são essenciais, mas trazem riscos, dificilmente a melhor decisão poderá ser tomada sem uma estratégia de gestão de riscos.

Fica fácil compreender que o melhor caminho seja justamente a imposição de medidas mitigadoras para a probabilidade de materialização desses riscos e/ou do impacto que tal materialização possa causar à organização, como um elemento da tomada de decisão da organização. Mas para se chegar à melhor decisão é preciso mapear, avaliar e gerir os terceiros, naquilo que chamaremos de Processo de Gerenciamento de Riscos de Compliance para Terceiros ou *Third-Party Compliance Risk Management*.

Uma medida fundamental deste processo são as “diligências apropriadas” ou *due diligence,* para conhecimento e avaliação dos terceiros. Dessa forma, o objetivo deste texto é, ao apresentar os conceitos e melhores práticas nacionais e internacionais, diferenciar os institutos gestão de riscos de terceiros e *due diligence*, embora sejam comumente confundidos, demonstrando que mutuamente se completam, mas não de forma exclusiva.

1. Por que Terceiros, ao Mesmo Tempo, são Essenciais e Sinônimo de Riscos?

Terceiros são todos aqueles que se relacionam com uma organização, que não se classifiquem como prepostos ou *stakeholders* internos (colaboradores, administradores, gestores, conselheiros, etc.), mas que se colocam como intermediários na relação entre duas pessoas, físicas ou jurídicas, como por exemplo, fornecedores, clientes, vendedores, distribuidores, revendedores, representantes comerciais, parceiros de negócios, corretores e agentes. Ainda, haverá relacionamento com outras espécies de terceiros, sem fins comerciais, (*v.g.,* órgãos de fiscalização e controle, entes estatais, sindicatos, etc.). Carlos Ayres define terceiros como “toda e qualquer pessoa física ou jurídica, independente de sua nomenclatura, que aja em nome de outrem”.[172] Dessa forma, constata-se que é absolutamente impossível a existência e manutenção de uma organização sem a relação com terceiros.

Alguns números, segundo a pesquisa *CEB 2015 Third-Party Risk Diagnostic*, demonstram que: (i) a maioria das empresas avaliadas possuem mais de 5.000 terceiros a elas relacionados; (ii) 92% das empresas analisadas aumentarão o uso de terceiros ou permanecerão estáveis nos próximos doze meses; (iii) 75% estão atualmente terceirizando a função corporativa principal ou planejam fazê-lo no futuro; (iv) 5,5% é a taxa de crescimento esperada no mercado de terceirização de negócios no ano da pesquisa; (v) as principais razões para o uso de terceiros são: redução de custos, acesso ao mercado, maior velocidade de comercialização e experiência local.[173]

Assim como os *stakeholders* internos são a porta de entrada dos mais diversos riscos para uma organização (*v.g.,* art. 932, inciso III, do Código Civil[174]) a relação com terceiros pode trazer riscos financeiros, jurídicos, estratégicos, operacionais, de *compliance* (dado o objeto do presente texto, serão

levados em consideração os riscos de *compliance*) etc., que podem impor consequências negativas em caso de materialização, como a responsabilidade civil, multas, sanções comerciais, exposição reputacional, entre outras.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou em 2014 um estudo chamado *OECD Foreign Bribery Report: an analysis of the crime of bribery of foreign public officials* em que analisa e descreve a corrupção transnacional baseada em dados de 427 casos que foram concluídos desde a entrada em vigor da Convenção Antissuborno da OCDE, em 1999. Dentre as constatações, o relatório apresenta informações relevantes como: (i) suborno é pago em todos os setores da economia; (ii) acontece em todos os níveis de desenvolvimento econômico; (iii) a liderança corporativa está envolvida, ou pelo menos ciente, da prática de suborno estrangeiro na maioria dos casos; (iv) a maioria dos pagamentos são para obter contratos públicos; (v) o valor do suborno corresponde, em média, a 10,9% do valor total da transação. No entanto, o dado mais alarmante do relatório aponta que em 75% dos casos terceiros intermediários foram utilizados na oferta, promessa ou pagamento da corrupção. Ou seja, três em quatro casos de suborno envolveram pagamentos através de intermediários:

> *Em 304 casos intermediários foram usados. Um "agente" foi usado em 41% dos casos; essa categoria inclui agentes de vendas e marketing, distribuidores e corretores baseados localmente no país em que os subornos foram pagos ou em outro lugar. O trabalho futuro poderia considerar a gama de "taxas" cobradas por esses agentes, e quanto mais isso aumenta o custo do suborno em si. A segunda maior categoria de intermediários, utilizada em 35% dos casos, é a do "veículo corporativo". Esta categoria inclui empresas subsidiárias, empresas de consultoria locais, empresas localizadas em centros financeiros offshore ou paraísos fiscais ou empresas estabelecidas sob a propriedade efetiva do funcionário público que recebeu os subornos ou do indivíduo ou entidade que paga os subornos. Os advogados foram usados como intermediários em 6% dos casos. Os familiares do funcionário público foram utilizados como intermediários em 3% dos casos. Contadores e associados (incluindo assessores) do funcionário público foram utilizados em 1% e 2% dos casos, respectivamente. A natureza do intermediário não foi especificada em 12% dos casos.*[175]

O conceito de terceiro utilizado pela OCDE está expresso no reporte *Typologies on the Role of Intermediaries in International Business Transactions*, e considera um intermediário como uma pessoa física ou jurídica (como empresas de consultoria, *joint venture*, etc.) que é colocada em contato com ou entre dois ou mais parceiros comerciais, como um canal para bens ou serviços oferecidos por um fornecedor para um consumidor, que pode atuar para atividades econômicas legítimas, pagamentos de suborno ou em uma combinação de ambos.[176]

Em relação à legislação anticorrupção disseminada pelo mundo (*FCPA*, *UKBA*, Lei Anticorrupção, etc.), terceiros são considerados fator elementar de responsabilização de pessoas jurídicas por atos de corrupção, simplesmente porque eram (e ainda são) engrenagem fundamental para o suborno. Mas existem outras normas que dedicam parte de sua preocupação aos terceiros, como é o caso das legislações de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Em 03 de setembro de 1998, o *Office of the Comptroller of the Currency*[177] divulgou a *Advisory Letter 1998-14*, que determinava aos bancos regulados a avaliação e gerenciamento do risco de todos os seus relacionamentos com terceiros sobre os "problemas dos anos 2000".[178]

A primeira norma a prever a proibição de suborno de agentes públicos estrangeiros (*FCPA*) foi categórica ao estabelecer a vedação: […] "any person, while knowing that all or a portion of such money or thing of value will be offered, given, or promised, directly or **indirectly**, to any foreign official, to any foreign political party or official thereof, or to any candidate for foreign political office, for purposes of" […].[179] O mesmo é previsto nas legislações anticorrupção já disseminadas pelo mundo, como *United Kingdom Bribery Act* 2010 (*directly or **through a third party***), Código Penal Francês (*directement ou **indirectement***) ou Alemão (*Mitglied oder einen **Dritten***) e Lei nº. 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção ou da Empresa Limpa ("prometer, oferecer ou dar, direta ou **indiretamente**, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada").

Todas estas normas preveem a responsabilização de pessoas jurídicas pelo suborno de agentes públicos (algumas delas estabelecem também outras condutas ilícitas, *v.g.,* fraude a licitação, na lei brasileira, e corrupção privada nas leis britânica e francesa), sem qualquer distinção se a conduta é

praticada por um colaborador da empresa ou um terceiro que a ela representava. Dessa forma, se os profissionais de *compliance*, e as organização como um todo, têm como grande desafio a conscientização dos colaboradores e administradores sobre a relevância dos riscos de *compliance* e a necessidade de mitigá-los, imagine em relação aos terceiros, que agem por conta própria, de acordo com a sua cultura organizacional específica e fora dos limites de controle e atuação do seu programa de *compliance*.

2. Todos os Terceiros Têm a Mesma Relevância?

A tentativa de padronização ou tamanho único (*one-size-fits-all*) de programas de *compliance* pode e deve levar à sua ineficiência, por dezenas de motivos, como: (i) ausência de relação como as especificidades de cada organização (atividade, riscos, estrutura, operação, recursos, etc.); (ii) baixo engajamento de lideranças com o projeto de implementação e sua gestão; (iii) falta de aderência e engajamento de *stakeholders* internos e externos por falta de conscientização, sentimento de pertencimento, senso de responsabilidade; etc.

Preocupados com essa possibilidade de padronização, órgãos de controles e aplicação da legislação americana antissuborno (DOJ/SEC) estabeleceram dois princípios fundamentais na avaliação da existência e de efetividade de programas de *compliance*, especialmente em relação àquelas organizações investigadas e processadas naquela jurisdição: (i) *no one-size-fits-all*; (ii) *risk-based approach*.

Em relação ao primeiro princípio, DOJ e SEC esclarecem: "individual companies may have different compliance needs depending on their size and the particular risks associated with their businesses, among other factors. When it comes to compliance, there is no one-size-fits-all program". [180] Já em relação ao segundo princípio: "DOJ and SEC will give meaningful credit to a company that implements in good faith a comprehensive, risk-based compliance program, even if that program does not prevent an infraction in a low risk area because greater attention and resources had been devoted to a higher risk area". [181]

Dessa forma, trazendo para realidade do processo interno de Gerenciamento de Riscos de *Compliance* para Terceiros (*Third-Party Compliance Risk Management*), cada companhia deverá empenhar-se no estabelecimento de suas diretrizes internas para identificação, avaliação e gestão dos terceiros que realmente sejam relevantes, ou seja, que a exponham de forma considerável a situação que possa gerar a materialização dos riscos de *compliance*, previamente estabelecidos. Uma análise exemplificativa pode facilitar a compreensão.

Para uma companhia multinacional americana que realiza vendas de forma indireta a governos, ou seja, com o auxílio de distribuidores e revendas locais (*know your partner*), estes intermediários se enquadram em um grupo de terceiros com alto grau de exposição ao risco de corrupção a agentes públicos para, em tese, concluir as vendas e gerar contratos e faturamento. Embora os intermediários vendam em nome próprio, indiretamente representam elevação de receita da empresa americana, que facilmente poderia ser investigada e processada por violação ao *FCPA* (impacto). Ainda, quanto maior a quantidade de concorrências, vendas e intermediários, e quanto mais elevada a percepção de corrupção no país em que os negócios são realizados (vide *Corruption Perception Index - Transparency International*), maior a possibilidade de materialização do risco de corrupção (probabilidade). No entanto, clientes e fornecedores da mesma empresa, que também se enquadram como terceiros, possivelmente não tenham a mesma relevância do ponto de vista deste risco e, talvez, sequer precisem ser avaliados e monitorados.

Empresas que atuam com importação e exportação de bens, talvez devam dedicar suas atenções iniciais aos prestadores de serviço relacionados ao desembaraço aduaneiro (*know your supplier*), vez que áreas alfandegadas possuem diversas autoridades públicas, o processo é bastante burocrático, por regra, e as cargas embaraçadas são valiosas, fatores que elevam a probabilidade do risco de corrupção. Da mesma forma, as grandes organizações de varejo de roupas e acessórios, devem se preocupar com toda a cadeia de produção (*know your supplier*) pelo risco de trabalho escravo (vide casos públicos, como Zara, M.Officer, etc.).

Já para instituições financeiras e demais setores obrigados a se reportarem ao COAF, são os clientes que geram a probabilidade de materialização do risco de lavagem de ativos (*know your client/ know your customer*). Em processos de fusão e aquisição (*Merger and Acquisition - M&A*) as empresas

a serem adquiridas ou incorporadas são relevantes, especialmente pela responsabilidade solidária imposta na legislação anticorrupção (*v.g.,* art. 4º, caput e §1º, da Lei nº. 12.846/2013).[182]

Cada organização deve previamente estabelecer e formalizar seu processo interno de Gerenciamento de Riscos de *Compliance* para Terceiros, em que deve prever quais são os seus riscos de *compliance* prioritários e quais os grupos de terceiros que estão em alta exposição, para que posteriormente sejam analisados e monitorados. É preciso governança ao programa de *compliance*, com regras claras e aplicáveis de forma objetiva para todos os terceiros que de fato tenham alta exposição ao risco.

3. Como Desenvolver um Processo Interno de Gerenciamento de Riscos de *Compliance* para Terceiros?

Este é um campo ainda pouco explorado academicamente, e portanto, não se propõe aqui um modelo exaustivo, pronto ou acabado. Longe de querer estabelecer um padrão a ser seguido (*no one-size-fits-all*), talvez uma sugestão metodológica possa contribuir com os profissionais de *compliance* para a elaboração do processo interno de gestão de terceiros. Ainda, importante registrar que o nome utilizado (*v.g.,* política, processo, procedimento, etc.), pouco importa. Como ressalta Hui Chen do prefácio desta obra, o relevante é o resultado.

3.1. Pensar e Planejar o Projeto: Conheça a Organização e seu Modelo de Negócio, Envolva Donos de Processos e Riscos e Defina o Escopo de Atuação

Como toda a implementação dos mecanismos ou pilares que compõe um programa de *compliance* efetivo, a elaboração do um Processo de Gerenciamento de Riscos de *Compliance* para Terceiro deve ser tratada como um projeto, vez que envolverá pessoas, impactará áreas internas da organização (e pessoas que as compõem) e, possivelmente, gerará custos. Este pode ser um trabalho nada fácil de se concluir, portanto, é sempre melhor despender algumas horas de trabalho com planejamento, que resolvendo problemas futuros que podem surgir justamente pela falta dele. Assim, planejar é fundamental!

Por isso, se na organização existir um “escritório de projetos”, seguir as diretrizes vai contribuir bastante. Se não existir, é fundamental buscar uma das dezenas de metodologias de planejamento e gestão de projetos existes e já consagradas (*v.g., Prince 2, PMBOK, Scrum, Canvas, Six Sigma, Waterfall*, etc.) e adaptar o projeto a uma delas, inclusive para apreciação e validação do *board* da organização.

Conhecer a realidade da organização é o próximo passo fundamental. Um diagnóstico detalhado vai apontar quais são os riscos de *compliance* mais relevantes (maior impacto x probabilidade) ou que já priorizados (vide o *Compliance Risk Assessment*), além de quais os processos e áreas internas devam ser afetados. Ainda que inicialmente sejam apenas algumas áreas e riscos, pois “começar pequeno” facilita bastante, no futuro o projeto deve evoluir, pois o programa de *compliance* efetivo está amparado na expansão e na melhoria contínua.

O envolvimento das áreas relacionadas (*business sponsor*) é fundamental por vários motivos, sendo o principal deles, a importância de engajamento das partes que são proprietárias dos processos e riscos afetados (*process and risk ownership*), em especial para fortalecimento da primeira linha de defesa e concreta mitigação dos riscos.

Ademais, criar controles internos sem envolvimento dos donos dos riscos e sem uma efetiva estratégia de comunicação pautada na conscientização, pode gerar relutância na utilização de tais controles, que passam a ser encarados como mera burocracia. Por fim, ninguém melhor que o próprio dono do processo e dos riscos para levantar informações relevantes para o diagnóstico inicial.

Assim, neste momento, em cooperação, a área de *compliance* e as áreas afetadas pelo projeto devem se dedicar em entender quais os riscos e terceiros são relevantes, dentre um universo enorme.

Definir critérios para a classificação (níveis de alto, médio e baixo risco, por exemplo) como *key risk indicators* ou indicadores-chave de riscos (*v.g.,* risco geográfico[183], risco de seguimento de atuação[184], risco do valor do contrato, risco da dependência econômica do terceiro, risco das áreas contratantes, etc.) pode ser uma excelente iniciativa para os *cortes* necessário nas bases de dados, que dependendo do tamanho da organização podem ter milhares de linhas de *excel*.

Estes critérios, inclusive, são relevantes para um plano de priorização das análises do “legado” ou “passivo” de terceiros que já foram contratados, não foram avaliados e não são monitorados, embora seus níveis de exposição aos riscos de *compliance* sejam elevados, simplesmente pelo fato de que o processo não exista à época da contratação.

Ainda, conhecer a possível existência de processos de *screening* de terceiros possibilita a integração dos riscos de *compliance*, reduzindo o impacto burocrático. Por exemplo, em algumas empresas faz-se uma análise cadastral no momento de inclusão dos terceiros no *Enterprise Resource Planning* (ERP) ou Sistema Integrado de Gestão Empresarial, que avalia alguns critérios (*v.g.,* registro e situação cadastral na Receito Federal e Junta Comercial, certidões de regularidade fiscal, etc.). Impor esta análise, também, ao processo de gestão de terceiros seria gerar retrabalho.

Por fim, definir níveis distintos de análise em razão dos níveis de exposição aos riscos, assim como quais informações relevantes e quais as bases de dados são importantes para uma diligência devida em cada um destes níveis, é importante.

Como destacam os órgãos aplicadores do *FCPA*, “risk-based due diligence is particularly important with third parties and will also be considered by DOJ and SEC in assessing the effectiveness of a company’s compliance program. Although the degree of appropriate due diligence may vary based on industry, country, size and nature of the transaction, and historical relationship with the third-party, some guiding principles always apply”.[185]

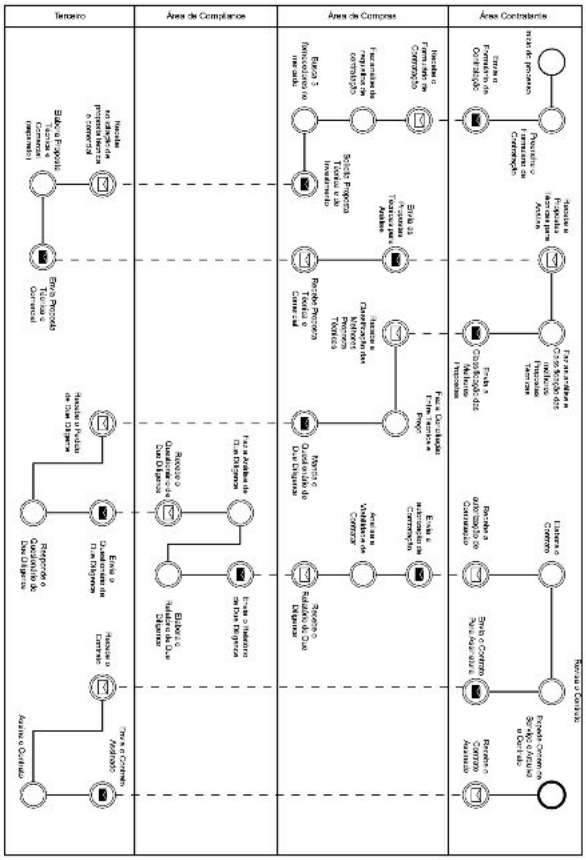
3.2. Mapear o Fluxo e Formalizar o Processo

Uma excelente forma de iniciar a redação de um processo é pelo mapeamento de seu fluxo. Isso implica em identificar as partes relacionadas e suas competências, as fases do processo (passo-a-passo), as relações de cada parte relacionada com as fases do processo, eventuais controles que possam ser implementados, etc.

Estão à disposição no mercado uma série de ferramentas que podem ajudar nesse mapeamento, conhecidas como ferramentas de Gerenciamento de Processos de Negócio ou *Business Process Management* (BPM). Algumas são, inclusive, gratuitas e estão disponíveis *on-line* com mapas, modelos e diagramas de processos, que vão auxiliar na modelagem, revisão e validação. Algumas são intuitivas e fáceis de usar.

Mas há também ferramentas pagas, que disponibilizam recursos diferenciados, além da possibilidade de se utilizar vários usuários, os quais podem contribuir com o mapeamento e aprovação do fluxo.

Vejamos um exemplo:


Áreas Contratantes
Área de Compras
Área de Compliance
Terceiro
Início do processo
Necessidade Formalizada para Aprovação
Fornecedores Cadastrados e Homologados
Classificação dos Melhores Fornecedores
Fornecedores Classificados
Fase Consolidada Para Prego
Classificação dos Melhores Fornecedores Técnicos

	High risk country	Low risk country
High risk industry	High	High
Low risk industry	High/Low	Low
High value contract	High	High/Low
Low value contract	High/Low	Low
Any contract involving public officials (or connected – for definition of public official see section 1)	High	High

Figura 2 - Exemplo de Matriz de Risco de Terceiros em pequenas e médias empresas sugerida pela ICC

Deve ser estabelecido qual é a área responsável pela implementação e gerenciamento do processo. Este documento, após concluído, deve ser apresentado e validado pela alta administração da organização, a fim de que haja o seu envolvimento (*tone from the top*), bem como publicado para cumprimento de todas as partes relacionadas. Importante que sejam utilizadas também estratégias de treinamento e comunicação, mecanismos ou pilares fundamentais do próprio programa de *compliance*.

Por fim, um plano de trabalho pode ser desenvolvido em relação ao "legado" de terceiros que foram contratados antes da vigência do processo. Estes também precisam se enquadrar, pois são hipóteses de risco. A priorização daqueles com alto grau de exposição aos riscos de *compliance*, o condicionamento de *due diligence* para renovação ou prorrogação contratual e/ou uma força-tarefa, podem ser medidas interessantes.

3.3. Critérios Para as Diligências Apropriadas de Terceiros

Conforma consta do art. 42 do Decreto Federal nº, 8.420/2015, inciso XIII, para que o programa de *compliance* seja efetivo, caberá à organização realizar "diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados". A questão aqui é, o que de fato seriam consideradas "diligências apropriadas", aos olhos dos órgãos que podem realizar auditorias no programa de *compliance.*

Pode-se concluir, talvez, que: (i) para terceiros com baixíssimo grau de exposição ao risco, nenhuma análise seja necessária; (ii) para terceiros com baixo grau de risco, uma análise simplificada é suficiente (*background check*); (iii) para terceiros com um médio risco, uma análise mais avança seja importante; e (iv) para terceiros com alto grau de exposição aos riscos de *compliance*, uma análise robusta, complementada com atividades *in loco*, entrevistas e outros mecanismos de apuração, sejam de fato aquilo que o legislador entende por "diligências apropriadas".

Para o DOJ e SEC devem ser observados três princípios orientadores:

> *First, as part of risk-based due diligence, companies should understand the qualifications and associations of its third-party partners, including its business reputation, and relationship, if any, with foreign officials. The degree of scrutiny should increase as red flags surface. Second, companies should have an understanding of the business rationale for including the third party in the transaction. Among other things, the company should understand the role of and need for the third party and ensure that the contract terms specifically describe the services to be performed. Additional considerations include payment terms and how those payment terms compare to typical terms in that industry and country, as well as the timing of the third party's introduction to the business. Moreover, companies may want to confirm and document that the third party is actually performing the work for which it is being paid and that its compensation is commensurate with the work being provided.*
>
> *Third, companies should undertake some form of ongoing monitoring of third-party relationships. Where appropriate, this may include updating due diligence periodically, exercising*

audit rights, providing periodic training, and requesting annual compliance certifications by the third party.[187]

Seguindo essa mesma linha dos órgãos de controle americanos, a Controladoria-Geral da União publicou em 2018 um Manual Prático de Avaliação de Programas de Integridade em Processos Administrativos de Responsabilização (PAR), em que sugerem alguns requisitos de análise para verificar se os mecanismos ou pilares do programa de *compliance* sejam de fato existentes e efetivos. Em relação ao tema em questão, consta do manual:

> *Para diminuir as chances de que a pessoa jurídica se envolva em casos de corrupção ou fraude em licitações e contratos, em função da atuação de terceiros, é importante que adote verificações apropriadas para contratação e supervisão de fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados, entre outros, principalmente em situações de elevado risco à integridade. Ainda que a contratação de terceiros não tenha como objetivo imediato intermediar o relacionamento com a administração pública, tal fato pode acontecer durante a execução do contrato, gerando riscos para a contratante. A contratação de serviço de transporte internacional de mercadorias, por exemplo, exige o pagamento de tributos na fronteira e, nesse sentido, a prestadora de serviço pode praticar atos ilícitos em benefício da contratante, podendo acarretar sua responsabilização perante a Lei Anticorrupção. Antes de realizar a contratação de terceiros, é recomendável averiguar se a pessoa física ou jurídica possui histórico de envolvimento em atos lesivos contra a administração pública. Caso seja pessoa jurídica, é aconselhável ainda verificar se possui Programa de Integridade que diminua o risco de ocorrência de irregularidades e que esteja de acordo com os princípios éticos da contratante. É recomendável, ainda, seja verificado periodicamente se o terceiro está atuando de forma condizente com o acordado em contrato e se não adota comporta- mentos contrários aos seus valores ou às leis.*[188]

Com objetivo de nortear o auditor responsável pela análise, a CGU fornece alguns questionamentos para se levantar evidências, o que também pode auxiliar no estabelecimento dos critérios necessários para que as diligências implementadas no processo de gestão de terceiros sejam de fato, apropriadas:

- *As diligências prévias realizadas pela PJ para contratação de terceiros incluem: a) verificação do envolvimento de terceiros em casos de corrupção e práticas de fraude contra a administração pública? b) verificação da existência de programas de integridade implementados nos terceiros avaliados, para mitigar os riscos de corrupção e fraude contra a administração pública? c) realização de diligências aprofundadas em relação aos terceiros para celebração de parcerias, como consórcios, associações, join ventures e sociedades de propósito específico?*
- *As regras sobre a realização de diligências prévias à contratação de terceiros: a) favorecem a contratação de terceiros que apresentam baixo risco de integridade? b) estabelecem a necessidade de adoção de medidas para minimizar o risco da contratação de terceiro, caso o resultado das diligências realizadas indique alto risco de integridade na contratação? c) podem impossibilitar a contratação ou a formação da parceria, caso seja verificado alto risco de integridade do terceiro?*
- *Há segregação de função entre aqueles que realizam as diligências e os responsáveis por realizar a contratação?*
- *Há participação da área responsável pelo Programa de Integridade na realização das diligências?*
- *Foram apresentados documentos demonstrando que as diligências de terceiros são aplicadas pela PJ, como formulários preenchidos por terceiros, e-mails solicitando informações a terceiros e avaliações do perfil de risco dos terceiros?* [189]

Algumas formas de comprovação são apresentadas, como “políticas disciplinando a realização de diligências; formulários; telas de consulta de fornecedores em bancos de dados governamentais

relacionados ao tema (CEIS, CNEP e CEPIM); fluxogramas; relatórios sobre terceiros; telas de sistemas utilizados para realização de verificações de terceiros".[190]

Para a coleta de informações, algumas fontes de pesquisa são públicas e, portanto, podem ser acessadas por qualquer pessoa. Dessa maneira, uma preocupação para o profissional responsável pela realização das diligências é mapear quais fontes disponíveis existem para levantar informações sobre os terceiros com quem sua organização se relaciona e que possam informar questões relevantes (*red flags*) do ponto de vista de integridade e do risco de *compliance* a ele atribuído. São centenas de fontes já mapeadas por empresas especializadas: Receita Federal do Brasil, juntas comerciais dos estados, portais transparência dos órgãos governamentais, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); Cadastro de Penalidade a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM); sites dos tribunais superiores (STF, STJ, TST, TSE e STM), dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça dos estados; site dos tribunais de contas da União, dos estados e dos municípios (aqueles que possuem), site do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE); listas de sanções internacionais (Conselho de Segurança das Nações Unidas - UNSC, *U.S. Office of Foreign Assets Control* – OFAC, Política Externa e de Segurança Comum da União Europeia – CFSP, *UK HM Treasury*, etc.); buscadores de internet (Google, Yahoo, Bing, etc.); dentre outras.

Uma ferramenta bastante utilizada e muito rica para o processo de análise, são os questionários de *due diligence*. Primeiro, porque é uma oportunidade de o próprio terceiro fornecer informações relevantes que a diligência eventualmente não tenha encontrado (*v.g.,* alguns processos estão em segredo de justiça e as informações não são públicas). Segundo que, é importante um *cross-check* de informações e, caso se identifique questões divergentes ou omissas, isso pode representar que o terceiro não está agindo de boa-fé. Por fim, é uma oportunidade do terceiro já esclarecer questões que pela diligência seriam *red flags*, mas que de fato estão superadas ou não são relevantes para os riscos de *compliance*.

Existem também as ferramentas de mineração de dados que são serviços pagos, mas que facilitam a busca de informações, pois possuem uma relação de fontes e critérios de busca pré-definidos, e ainda, centralizam em relatórios as evidências e pontos relevantes. A questão aqui é que o relatório por si só não gera o resultado, assim, alguém deverá ser designado pela organização para que promova a leitura minuciosa do relatório, exclua os falso-positivos e reporte as informações que de fato são pertinentes. É importante alertar que para alguns terceiros, dado o grau de risco a que estão expostos, esta análise, unicamente, pode não ser suficiente para convencer ao auditor que a diligência foi apropriada ou para evitar a materialização do risco, o que é mais relevante do ponto de vista da prevenção.

Por fim, prestadores de serviço especializados, capacitados em investigações corporativas, gestão do conhecimento (inteligência) e outros *skills*, podem ser uma alternativa, especialmente para níveis de análises mais aprofundados ou simplesmente quando "faltam braços" para a equipe interna responsável. Neste caso, recomenda-se a busca por profissionais sérios e capacitados, que conheçam e se responsabilizem por sua atuação, pois uma série de consequências negativas podem ser causadas à organização, principalmente em casos de violação de questões sensíveis, como a intimidade e a honra.

Um relatório final de *due diligence* é muito importante para subsidiar a tomada de decisão, especialmente no caso de *red flags* levantados. Suspender a contratação e buscar medidas alternativas (outros terceiros); prosseguir com a contratação, mas implementar medidas de mitigação dos riscos; simplesmente aceitar o risco, pois está em consonância com o apetite de risco do *board* da organização e/ou em caso de materialização dos riscos, o impacto acaba sendo mais baixo que o custos da implementação de controles. Todas são alternativas a se analisar com base no relatório de *due diligence*.

3.4. *Red Flags* em *Due Diligence* de Integridade para Terceiros

A partir do momento em que as informações relevantes em relação ao terceiro (*target*) são coletadas e catalogadas, precisam ser avaliadas por pessoas capacitadas, que realmente entendam sobre os riscos de *compliance* da organização, sobre como eles podem se materializar pela atuação dos terceiros e que tenham "olho clínico" para ler nas entrelinhas e resgatar questões relevantes, às

vezes ocultas. Para auxiliar o julgamento, pode ser relevante que o profissional responsável tenha em mãos uma lista de *red flags* pré-definidos.

Red flags referem-se a circunstâncias que sugerem um forte risco de corrupção que devem ser identificados e mitigados adequadamente por meio de medidas de mitigação, conforme estabelecido pelo Banco Econômico Mundial. A identificação de uma bandeira vermelha não significa, por si só, que uma organização não pode prosseguir com o relacionamento comercial com o terceiro. No entanto, nenhum *red flag* deve ser deixado sem solução ou não resolvido e as organizações devem implementar medidas de mitigação que reflitam o nível de gravidade de cada um deles.[191]

Com base nos termos que foram expostos na primeira parte desta análise, para se definir quais são as informações relevantes a ponto de simbolizarem um *red flag*, certamente dependerá dos riscos que foram definidos pela organização como riscos de *compliance* (*risk-based approach*). Por outro lado, é importante considerar que um ou alguns sinais de alerta encontrados, não necessariamente correspondem à materialização do risco. Talvez, sejam capazes de elevar a probabilidade de sua materialização. Portanto, precisam ser melhor avaliados e geridos, especialmente com a implementação de medidas de mitigação, que têm o condão de reduzir tal probabilidade. Assim, ao considerar o risco de corrupção, amplamente explorado neste estudo, exemplos de alguns sinais de alerta podem ser relevantes. Seguindo as diretrizes do Fórum Econômico Mundial, seriam *red flags* anticorrupção:

- Relacionado ao seguimento de atuação e a localização do terceiro: a) O nível de percepção de corrupção no país em que o terceiro atuará é relativamente alto com base no Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional? b) A transação envolve um seguimento que tem histórico de violações antissuborno?
- Específicas da organização: a) O colaborador(es) responsável(eis) é(são) recém contratados no terceiro? b) O terceiro parece não ter capacidade suficiente ou qualificações profissionais para fornecer os serviços ou bens para os quais está sendo contratado (com base em anos de atividade, tipos de serviço prestados, níveis de pessoal, etc.)? c) O terceiro reluta em fornecer referências comerciais ou a resposta de qualquer uma das referências comerciais? d) O terceiro é advogado, contador, despachante ou outro que normalmente não está diretamente envolvido no tipo de projeto ou atividade comercial para o qual está sendo retido? e) Foi-nos perguntado ou indicado por alguém para utilizar este terceiro específico? Se sim, por quem e por quê? f) O terceiro deseja trabalhar sem contrato ou com um contrato vago? g) O terceiro está hesitante em assinar cláusula anticorrupção em um contrato? h) O terceiro tem laços familiares ou comerciais com funcionários do governo? i) Fomos solicitados por qualquer pessoa associada à transação a fazer contribuições políticas ou de caridade de qualquer tipo? O terceiro ou seus sócios são ou foram investigados, processados ou condenados por condutas corruptivas?
- Específicas da transação: a) O montante total a ser pago por bens e serviços parece ser excessivamente alto ou acima do valor costumeiro ou normal? b) São adiantados pagamentos excessivos ou incomuns (comissões elevadas, bônus substanciais, etc.), ou a compensação é baseada no desempenho (taxas de sucesso ou êxito)? c) Há solicitação de pagamentos indiretos ou incomuns aos procedimentos de faturamento, como: por meio de contas bancárias em um país estrangeiro, fora daquele em que os serviços estão sendo prestados; para contas bancárias anônimas (numeradas); para contas bancárias contendo fundos corporativos, mas mantidos em nomes de indivíduos; a estranhos por bens ou serviços prestados pelo terceiro; por meio de empresas fantasmas criadas para receber receitas e facilitar transações; ou em dinheiro ou cheques ao portador?
- Outros: a) O terceiro será exposto e/ou terá interações com funcionários públicos em nome de nossa organização? b) O terceiro estará lidando com clientes, fornecedores e agentes de nossa organização em nome de nossa organização?[192]

Com objetivo de exemplificar alguns *red flags* sobre o risco de violação do FCPA, DOJ e SEC expõe sinais comuns: comissões excessivas para agentes ou consultores; descontos excessivamente grandes para distribuidores; “acordos de consultoria” que incluem apenas serviços vagamente descritos; consultor está em uma linha de negócios diferente daquela para a qual foi contratado; o terceiro está relacionado ou intimamente associado ao funcionário estrangeiro; o terceiro tornou-se

parte da transação por solicitação expressa ou insistência do funcionário público; o terceiro é apenas uma empresa-fantasma incorporada em uma jurisdição *offshore*; e o terceiro solicita pagamento a contas bancárias *offshore*.[193]

Alguns renomados autores apresentam outras relevantes situações que potencialmente possam representar *red flags* e que contribuem com a exemplificação acima exposta, como Matteson Ellis[194] e Marjorie W. Doyle.[195]

3.5. *Estratégias de Gerenciamento do Risco de Terceiros*

Como mencionado, nenhum *red flag* deve ser deixado sem solução ou não resolvido e, assim, devem as organizações implementar medidas de mitigação que reflitam o nível de gravidade. DOJ e SEC ressaltam que, além de considerar a realização de diligências apropriadas em relação a terceiro, também deve-se avaliar se a empresa os informou sobre o seu programa de *compliance* e o compromisso com práticas comerciais éticas e legais e, quando apropriado, se buscou garantias de terceiros por meio de certificações e outros meios de compromissos recíprocos.[196]

Portanto, realizada a *due diligence*, havendo *red flags* no relatório sobre um terceiro, medidas devem ser tomadas, especialmente pela área responsável pelo contato direto com o mesmo. Havendo informações relevantes, que elevam os riscos de *compliance* a uma alta probabilidade de materialização, talvez seja causa de se estabelecer com o *business sponsor* um plano de substituição do terceiro, ainda que no médio prazo.

Por outro lado, se o relatório não trouxer *red flags*, a contratação pode ser mantida sem maiores medidas a serem implementadas, a não ser a realização de diligências futuras de renovação da análise. No entanto, em determinadas hipóteses, ainda que os riscos do terceiro estejam em nível elevado, ainda que em seu relatório constem *red flags* relevantes, por uma decisão estratégica ou financeira, por exemplo, a organização opte por continuar a contratação. O importante é que, qualquer que seja a sua decisão, a organização documente claramente seus esforços de diligência, para que sejam considerados apropriados, além de explicar as justificativas para sua tomada de decisão e os mecanismos de mitigação adotados.

Assim, caso a organização opte pela contratação, contrariando um relatório de *due diligence* com *red flags*, é extremamente importante que medidas sejam tomadas, com o objetivo de demonstrar que de fato se entende a questão como relevante, mas que optando pela manutenção do terceiro, a organização envidou os esforços possíveis e necessários para evitar que o risco se materializasse, ao menos dentro de sua esfera de decisão e atuação.

No entanto, quais seriam as medidas mitigatórias necessárias para demonstrar a preocupação real da organização com os riscos de *compliance* para terceiros, especialmente havendo *red flags* em seus relatórios de *due diligence*, bem como efetivas ao ponto de evitar a materialização? Ainda que os princípios *no one-size-fits-all* e *risk-based approach* precisem ser observados, uma classificação destes controles mitigatórios auxilia a compreensão. Assim, podemos dividir em quatro grupos de medidas: (i) de aprovação; (ii) contratuais; (iii) de conscientização; (iv) de monitoramento.

Por **medidas de aprovação**, entende-se o procedimento interno necessário para o julgamento específico e subjetivo que devem ser submetidos os terceiros que possuam classificação elevada de nível de exposição ao risco, com *red flags* em seus relatórios de *due diligence*, mas que por decisão baseada em outros critérios (estratégicos, financeiros, comercial, etc.) serão mantidas as contratações. Recomenda-se, de forma veemente, que este fluxo de aprovação seja formalizado no processo de gestão de risco de terceiros.

Neste caso, recomenda-se que a decisão final não deve ser atribuída à área que demanda a contratação do terceiro, para evitar conflitos de interesses. Também não deve ser incumbência da área de *compliance*, mas sim ao *board* ou executivos, como instância de alçada de aprovação para as transações mais relevantes da organização. Dessa forma, o processo de aprovação e pós-aprovação exige uma forte parceria entre a unidade de negócios que deseja contratar com o terceiro e a área responsável pela aprovação (*board* ou executivos), que deve ter o apoio intermediário da área de *compliance*. Como recomendação de boa prática, o Fórum Econômico Mundial sugere:

> *The responsibility of the risk assessment and due diligence processes should be with those within the company who are looking to enter into a third-party relationship – typically a business unit – in consultation with key subject-matter experts in the organization (e.g. compliance and legal*

departments). The persons responsible for the risk assessment should document the rating process in reasonable detail and renew the assessment periodically (e.g. once every three years).

Once the risk assessment and due diligence processes are complete, the organization should apply a clear system of approval for determining whether or not to move forward with the third party:

- For low-risk third parties, it is appropriate for the management of the business unit to be responsible for approving the business relationship.

- For medium- to high-risk third parties, there should be a minimum of two business units involved in the approval process: - the management of the business unit, and - another level of management which has nothing to gain from the selection of the third party (e.g. the compliance or legal department).

All documentation relating to the risk assessment and due diligence processes, and to the evaluation of red flags, should be signed by the parties responsible and retained by the organization.[197]

O Manual Prático de Avaliação do Programa de Integridade, elaborado pela CGU, recomenda que nos contratos celebrados com terceiros haja cláusula estabelecendo a obrigatoriedade do cumprimento de "normas éticas" e vedação a práticas de fraude e corrupção (cláusula anticorrupção), previsão de aplicação de penalidades e/ou de rescisão contratual em caso de descumprimento, além de pagamento de indenização em caso de responsabilização da empresa contratante por ato do contratado.[198] Estas são algumas **medidas contratuais** para mitigação dos riscos de terceiros, ou seja, aquelas que estarão dispostas no instrumento jurídico que estabelece as obrigações firmadas entre as partes.

Sabe-se que em alguns casos, seja por displicência ou para redução de burocracia, algumas contratações com terceiros não são devidamente formalizadas. No caso de terceiros com alto grau de exposição ao risco, não se recomenda que isso aconteça. Porém, caso a organização opte por uma relação sem contrato, que ao menos formalize obrigações anticorrupção de outra maneira (*v.g.,* e-mail, pedido, ata de reunião, etc.).

Como sugestão, o Fórum Econômico Mundial recomenda que as organizações solicitem a inclusão das seguintes disposições, representações e garantias em seus acordos contratuais com terceiros: (i) acordo por escrito pelos terceiros para cumprir as políticas e programas anticorrupção da organização (ou outras políticas e programas materialmente equivalentes) e/ou com as leis e regulamentações aplicáveis; (ii) confirmação por escrito de que o terceiro leu o Código de Conduta do Fornecedor da organização e concorda em satisfazer seus requisitos; (iii) cláusula de "direito de auditar", impondo ao terceiro o dever de fornecer acesso a todos os registros relevantes; (iv) provisão obrigando o terceiro a manter livros e registros contábeis precisos e fiéis, além de um sistema efetivo e rigoroso de controles internos contábeis; (v) direito contratual de rescisão em caso de violação das leis anticorrupção; (vi) disposições que limitem a capacidade do terceiro de agir em nome da organização e/ou de ter interações com funcionários do governo; e (vii) obrigação contratual por parte do terceiro de reportar os serviços prestados.[199]

Pode não ser nada fácil este tipo de negociação e aprovação com o terceiro, especialmente para as cláusulas mais genéricas e sem contextualização. Assim, "uma boa opção é *clusterizar*, ou seja, dividir por lotes, grupos de ramo de atividade e dar à cláusula uma redação que seja condizente com a atividade relacionada".[200]

Já as **medidas de conscientização** são aquelas adotadas para o fortalecimento da "Cultura Organizacional de Integridade" (COI). Aqui podem ser utilizadas as estratégias de comunicação e treinamento, pilares fundamentais do programa de *compliance* no aculturamento sobre a conduta ética e integridade, especialmente no ambiente corporativo. Assim, capacitações específicas sobre o Código de Conduta de Terceiros ou sobre as políticas anticorrupção e de relacionamento com agentes públicos, podem ser estendidas a terceiros, ou feitas de forma exclusiva aos mesmos. Comunicados frequentes, por meios distintos, que gerem os "lembretes" sobre a existência destes instrumentos normativos ou, até mesmo, contratuais, também são relevantes.

Por fim, **medidas de monitoramento** são aquelas que garantirão a periodicidade das análises dos terceiros. Um relatório de *due diligence*, elaboração de uma matriz de risco ou até mesmo uma apuração mais aprofundada, são como fotografias de momento. Ou seja, a partir de sua conclusão, instantaneamente já refletem a análise de situação, fatores, condutas, etc. que ficaram no passado. Daí a importância do monitoramento contínuo, a necessidade de atualização desse *status*.

É recomendado que as organizações considerarem as seguintes atividades de monitoramento contínuo para supervisionar a conduta de terceiros: (i) renovação periódica ou atualização dos processos de avaliação de risco e *due diligence*; (ii) implementação de um programa pós-aprovação, incluindo atividades de treinamento e auditorias periódicas e/ou baseadas em riscos; (iii) solicitação para emissão de uma declaração anual de conformidade com as normas e cláusulas anticorrupção aplicáveis; (iv) revisão periódica de pedidos e pagamentos feitos pelo terceiro ou para o terceiro; (v) acompanhamento de despesas incomuns ou excessivas pelo terceiro ou para o terceiro.[201]

Importante que tais medidas sejam formalizadas no processo de gestão de terceiros, inclusive com descrição de periodicidade (*v.g.,* para terceiros com alto grau de exposição ao risco de corrupção a renovação da *due diligence* será anual).

Ainda, pode ser uma estratégia saudável, a utilização de uma matriz de monitoramento para todo o Processo de Gerenciamento do Risco de *Compliance* para Terceiros, em que o(s) profissional(is) responsável(is) pela gestão dos terceiros pode(m) relacionar: (i) os terceiros que devam ser envolvidos no processo, (ii) data da inclusão no processo; (iii) estágio atual de avaliação; (iv) data de atualização do estágio; (v) responsável pela gestão; (vi) realização de *due diligence* e nível; (vii) grau de risco; (viii) data para renovação da análise; (ix) estratégia adotada pela empresa quanto ao terceiro; (x) pessoal responsável pela deliberação sobre o terceiro e sua área; (xi) medidas de mitigação a serem adotadas; (xii) prazo para a adoção das medidas; (xiii) nome da pessoa responsável pela implantação das medidas, etc.

ID	Terceiro	Data da inclusão	Status	Data da atualiz.	Resp.	DDI	Risco	Estra
1	João Despachante Ltda.	02/03/19	Em monitoramento	15/04/19	Maria (Compliance)	Sim	Alto	Man terceiro
2	Tício e Mélvio Advogados S/C	18/04/19	Avaliação de Risco	21/04/19	Pedro (Compliance)	Não	N/A	N

Figura 3 - Exemplo de Matriz de Monitoramento do Processo de Gerenciamento de Riscos de *Compliance* para Terceiros

Assim, o importante é estabelecer metodologicamente qual processo será desempenhado pela organização na gestão dos terceiros com o engajamento das áreas responsáveis e, além de formalizá-lo, envolver a alta administração, estabelecer os papéis de trabalho e os critérios de avaliação e gestão, realizar o processo no caso concreto, documentar todas as evidência relevantes, monitorar de forma contínua a aplicação do processo e, por fim, propor todas as recomendações de melhorias necessárias para a evolução.

Conclusão

Assim como os colaboradores podem ser causa de materialização dos riscos de *compliance*, com a imposição de consequências negativas à organização (*v.g.,* multas, sanções, indenizações, impacto reputacional, etc.), tais condutas podem ser praticadas também por terceiros. Esta é a previsão da maioria das normas anticorrupção vigentes em todo o mundo. Inegavelmente, os terceiros são relevantes para qualquer organização, mas representam riscos diretos, que devem ser mitigados.

Ter um processo interno de gestão dos riscos de terceiros, sob as lentes do *compliance*, além de análises estratégicas de contratação e gerenciamento da relação com os mesmos, é fundamental para a proteção da corporação. Estas análises devem ser subsidiadas por informações coletadas em diligências apropriadas (*due diligence*) de acordo com o grau de risco que o terceiro expõe a organização. E assim, tal análise estratégica deve subsidiar a tomada de decisão, de acordo com os achados.

Caso a organização persista na contratação do terceiro, ainda que encontre informações relevantes, deve propor controles internos para a mitigação dos riscos de *compliance*, que se dividem em medidas de aprovação, contratuais, de conscientização e monitoramento.

Adotar e documentar a avaliação de riscos, diligências realizadas e medidas adotadas caso a caso, além de garantir conformidade legal com aquilo que os órgãos de controle entendem por um programa de *compliance* existente e efetivo, também pode evitar, de fato, que os riscos se materializem.

Importante que todo este processo esteja formalizado, aplicado e alinhado com a formação da cultura organizacional de integridade, engajando a primeira linha de defesa, ou seja, os donos dos processos afetados e, por consequência, os donos dos riscos, além do *board* da organização, amparados pela instância interna responsável pelo programa de *compliance*, e os terceiros relacionados que de fato representem exposição aos riscos de *compliance*.

Referência Bibliográfica

AYRES, Carlos Henrique da Silva. *Utilização de terceiros e operações de fusões e aquisições no âmbito do Foreign Corrupt Practices Act: riscos e necessidade da due diligence anticorrupção. In:* DEBBIO, Alessandra Del; MAEDA, Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da Silva (Org). Temas de anticorrupção & compliance. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013

BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Manual Prática de Avaliação de Programas de Integridade em Processos Administrativos de Responsabilização (PAR)*. Brasília, 2018.

CEB COMPLIANCE & ETHICS LEADERSHIP COUNCIL. *CEB 2015 Third-Party Risk Diagnostic*. 2015.

DOYLE, Marjorie W. *Third-Party Essentials: A Reputation/Liability Checkup When Using Third Parties Globally*. Minneapolis: Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE), 2011. Disponível em https://assets.corporatecompliance.org/Portals/1/PDF/Resources/ThirdPartyEssentials-Doyle.pdf.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Office of the Comptroller of the Currency. *Advisory Letter 1998-14: Fiduciary Services and Year 2000 Readiness*. Washington D.C., 03 set. 1998.

_____. Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission. *A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act.* Disponível em <https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance>. Acesso em 02 nov. 2018,

ELLIS, Matteson. *The Master List of Third Party Corruption Red Flags*. FCPAméricas, 02 abr. 2014. Disponível em http://fcpamericas.com/english/anti-corruption-compliance/master-list-party-corruption-red-flags.

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL. Partnering Against Corruption Initiative (PACI). *Good Practice Guidelines on Conducting Third-Party Due Diligence*. Genebra: WEF, 2013.

FREIRE, Rodrigo. *Compliance e uso de terceiro intermediário. In:* CARVALHO, André Castro *et. al.* (Coord.). Manual de Compliance. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 135-151.

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. *ICC anti-Corruption third party due diligence: a guide for small and medium size enterprises*. Paris: ICC Policy and Business Practices, 2015.

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. *OECD Foreign Bribery Report: an analysis of the crime of bribery of foreign public officials*. Paris: OCDE, 2014.

_____. *Typologies on the Role of Intermediaries in International Business Transactions*. Final Report. Paris: OCDE, 2009.

Capítulo 13

Pilar 9 - Monitoramento e Auditoria de Compliance
Melhoria Contínua e Sustentação do Programa de Integridade

Daniele Leme[202]

Introdução

Sem sombra de dúvidas, o tema da avaliação de um Programa de Compliance e sua sustentabilidade após o seu período de implantação é um dos temas mais polêmicos e intrigantes enfrentados por profissionais da área e empresas que já possuem um Programa de Integridade, ou para aquelas que estão prestes a criá-los.

É possível atribuir tais desafios aos seguintes fatores: (i) a pluralidade de órgãos competentes para iniciar investigações sobre os atos de corrupção previstos na Lei 12.846/2013[203]; (ii) ausência de jurisprudência consolidada sobre o tema, uma vez que a Lei 12.846/2013 e o Decreto 8.420/2015 são relativamente recentes; (iii) a efetividade e o sucesso de um programa de Compliance depende de atividades e ações constantes, dinâmicas e focadas em pessoas; (iv) a estruturação de cada Programa de Compliance baseia-se em matriz de risco específica de cada empresa. Assim, a estruturação de um Programa de Compliance e a sua efetividade ainda é considerada um *green field* para as empresas e para os profissionais que atuam na área, eis que não existe a fórmula *one size fits all* – cada Programa de Compliance é único. É preciso profundo conhecimento sobre o negócio e criatividade para a estruturação e manutenção de um Programa, para que ele atinja a efetividade esperada pela empresa, bem como a exigida em decorrência de lei.

As peculiaridades e legislações financeiras-contábeis, legais e regulatórias de cada região ou *geos*, igualmente, são fatores determinantes que devem ser levados em consideração na customização dos Programas de Integridade, eis somente sob uma condução estratégica bem orientada atingirão a efetividade.

Nesse sentido, é essencial o suporte da alta administração ao Programa de Compliance, bem como da implementação das ferramentas de treinamento e comunicação apropriadas. Por isto, os temas de auditoria e monitoramento têm sido cada vez mais debatidos pelos profissionais da área, uma vez que são tidos como métodos eficazes e essenciais, capazes de garantir a continuidade e a implementação de melhorias nos Programas de Integridade. Façamos então um estudo dos tópicos inter-relacionados a auditoria e ao monitoramento inseridos no contexto da área de Compliance.

1. A Fraude: Conceito e Principais Teorias que a Explicam

Segundo o *Institute of Internal Auditors* (IIA) pode definir-se a fraude como: “quaisquer atos ilegais caracterizados por desonestidade, dissimulação ou quebra de confiança. Estes atos não implicam no uso de ameaça de violência ou de força física. As fraudes são perpetradas por partes e organizações: a fim de ser obtido dinheiro, propriedade ou serviços; para evitar pagamento ou perda de serviços; ou ainda, para garantir vantagem pessoal ou em negócios”.[204]

Tal conceito é o que mais se aproxima ao utilizado pela *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), considerada como a principal associação responsável pela organização e treinamento de profissionais no combate aos atos fraudulentos, que entende que “a fraude ocupacional pode ser definida como sendo o uso de um cargo ou função para obtenção de vantagem e enriquecimento pessoal, através da má utilização ou má aplicação dos recursos e bens de uma organização”.[205]

2. Teorias que Explicam o Fenômeno da Fraude

a) Teoria do Triângulo da Fraude: De acordo com o sociólogo e criminologista americano Donald Cressey (1953), a ocorrência de fraudes é condicionada pela existência conjunta das três dimensões: pressão, oportunidade e racionalização. Vejamos o entendimento de cada fator em específico.[206]

(i) Pressão: corresponde a problemas financeiros não compartilhados pelo indivíduo, como por exemplo: medo de perder a ocupação atual, o alcance ou manutenção de um dado padrão de vida e

problemas pessoais etc.

(ii) Oportunidade: significa a existência de conhecimento necessário e a posse de informações sobre os falhos de governança corporativa e a oportunidade de resolver o problema não compartilhado.

(iii) Racionalização: é o processo de racionalizar o ato como justificável e/ou aceitável e "*correto*". Ainda nesse sentido, Cressey (1950), idealizador de tal teoria, observou que em todos os casos de violação da confiança analisados, o violador considerou que um problema financeiro enfrentado por ele, não poderia ser compartilhado com outras pessoas que, de um ponto de vista mais objetivo, provavelmente poderiam ter contribuído para a solução do problema.

Muitas situações diferentes são consideradas por um indivíduo na produção de problemas financeiros não compartilhados. As pressões, derivadas desses problemas, criam na pessoa de confiança o desejo por um resultado específico para solucionar o problema, que pode ser por intermédio da violação criminal da confiança financeira. Sob a ótica de Cressey (1953), todos os problemas financeiros não compartilhados estão relacionados à manutenção ou à procura de um "*status"* de comportamento dos violadores.

Ao seguir o triângulo de fraudes, as normas de auditoria, Resolução CFC nº 1.207 de 2009 e SAS nº 99, esclarecem que pode existir um incentivo ou pressão para produzir uma informação financeira fraudulenta quando a administração sofre pressão, de fontes externas ou internas, para alcançar metas de ganhos ou resultados financeiros previstos.

Da mesma forma, também, podem existir incentivos para se apropriarem de ativos porque, por exemplo, esses indivíduos estão vivendo além de suas possibilidades. Esse "*status"* poderá ser de ordem pessoal ou profissional como problemas resultantes de fracassos pessoais, alto nível de padrão de vida, este incompatível com a remuneração recebida, a relação entre empregado e empregador, pressões sobre o desempenho da empresa.

Figura 1 – Triângulo da Fraude – Donald Cressey (1950)

b) Teoria da Agência: Segundo a teoria criada por Jensen e Meckling (1976), o evento da fraude ocorre a partir do conflito de interesses entre duas entidades: o principal e o agente.[207] O principal é caracterizado pelo proprietário e acionistas de uma empresa, os quais não possuem todas as informações. Os agentes, por sua vez, possuem poder de decisão e conduzem a empresa. As partes da relação (principal e agente) procuram maximizar seus interesses pessoais, assim, fica latente a probabilidade de o agente não atuar sempre em conformidade com os interesses do principal, uma vez que poderá tomar decisões com o intuito de obter vantagens pessoais. Para mitigar a existência de conflitos de interesses, o principal poderá estabelecer medidas de incentivos (bônus, participação nos lucros, "*stock options*", etc.) e também atividades de monitoramento (controles, auditorias interna e externa, compliance, canal de denúncia, dentre outros).

A execução dessas atividades resultará nos chamados *custos de agência*, ou seja; manifestando-se ou não o conflito, os custos existirão para a empresa. No contexto da fraude corporativa, a existência da lacuna informacional é a principal responsável pelo surgimento da oportunidade de o fraudador perpetrar seu ato em benefício próprio, causando danos a terceiros. Considerando o problema pelo ponto de vista dos profissionais auditores, talvez o processo mais notável, pelo lado psicológico, seja a condição de que o conflito de interesses pode levar o auditor a ser indulgente de forma inconsciente.

Segundo a figura utilizada no estudo da fraude - Diamante da Fraude - os elementos apresentados na Teoria do Triângulo da Fraude, de Cressey (1953), quais sejam: pressão, oportunidade e racionalização, estão reforçados por uma mente criminosa e atitude arrogante. Nessa mesma linha, a *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) apontou que o processo de execução da fraude pode seguir os seguintes passos: i) pressão, vontade ou necessidade de cometer a fraude; ii) oportunidade, identificação de uma falha nos controles que possibilita a realização do ato; iii)

racionalização, autoconvencimento, após analisar os riscos envolvidos, de que vale a pena correr o risco; e, iv) capacidade de intuir que possui as características e habilidades necessárias para realizar o ato fraudulento. Note-se que a capacidade está associada à oportunidade, e torna-se mais grave quando o autor é extremamente capacitado, não apenas com habilidades pessoais, mas com conhecimento dos processos internos, associados ao poder de decisão dentro da empresa, fator que denota uma mente criminosa e de atitude arrogante.

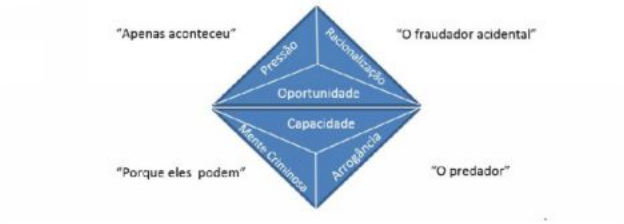


Figura 2 – Diamante da Fraude de Jensen e Meckling (1976) - Fonte: Dorminey et al. (2011)

Entretanto, no estudo do fenômeno da fraude uma das contribuições mais relevantes para o tratamento das formas de fraudes corporativas foi desenvolvida pela *Association of Certified Fraud Examiners*, mediante a divulgação da Árvore da Fraude em seus relatórios anuais sobre a fraude em âmbito global. Com o objetivo de apresentar de forma sucinta as formas conhecidas de fraudes corporativas, a ACFE desenvolveu de forma esquemática a figura da *Árvore da Fraude*, a qual reproduzimos abaixo:

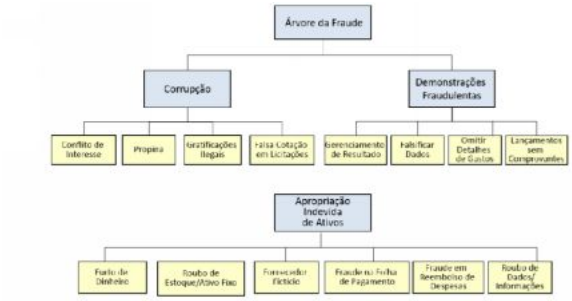


Figura 3 – Árvore da Fraude - Fonte da imagem: Research gate

3. Aspectos e Considerações sobre de um Efetivo Programa Antifraude.

Todas as instituições elas sejam públicas ou privadas, estão expostas às ocorrências de fraudes em suas operações, o que lhes gera expressivos prejuízos financeiros. Assim, faz-se necessário o combate da fraude pelos Programas de Compliance. É possível minimizar ou reduzir o risco de fraude no ambiente corporativo, através da adoção de um programa antifraude orientado estrategicamente e que promova: (i) a conscientização dos colaboradores; (ii) a identificação; e por fim (iii) prevenção de atos de fraude.

Para o sucesso de um programa antifraude, as empresas através de seus gestores devem ter consciência de que o risco existe. Parece inacreditável, mas alguns níveis de gestão em empresas não acreditam que possam ser alvo de um evento de fraude. Quando tal tema vem à tona nas corporações, é comum ouvir que um fato como esse nunca ocorreu, e/ou que as pessoas são de confiança, em outras palavras; que não existe este risco, até o dia em que o evento da fraude realmente é concretizado.

Em uma empresa, é possível afirmar-se que todos dentro da organização são responsáveis pelo processo de prevenção da fraude, entretanto, a alta gestão é a responsável principal, pois cabe a ela promover um ambiente organizacional propício para a conscientização da importância do combate à fraude juntos aos seus colaboradores, fortalecendo sua cultura de gestão de riscos em especial, quando a empresa tem ações negociadas em bolsa, como forma de respeito aos *shareholders* e *stakeholders*. A falta de comprometimento com os valores éticos e com as melhores práticas de gestão, pela alta administração e seus executivos, é o principal fato gerador de atividades ilícitas dentro de uma

organização, aliada também a falta de fundamentos de governança efetivos e controles internos confiáveis da empresa.

É necessário que a organização tenha um programa robusto de prevenção e combate à fraude, que sensibilize todos os seus colaboradores, prestadores de serviços e/ou fornecedores, além de outras partes relacionadas no tocante a: **(i)** visão da empresa; **(ii)** processo de detecção e tratamento dos eventos relacionados às fraudes.

Nessa linha, os mecanismos antifraude devem ter como pilares os seguintes norteamentos:

1) Conscientização: Tal diretriz baseia-se na disseminação das políticas e programas de integridade através de reuniões periódicas, palestras, oficinas de trabalho e processo contínuo de *e-learning* juntos a colaboradores e terceiros como um todo. É de extrema importância que a alta administração e gestores promovam um comportamento exemplar; o *walk by the talk*, que igualmente é esperado de todos os funcionários e partes relacionadas;

2) Detecção: Este tópico diz respeito ao cotidiano operacional de uma empresa que abrange o processo de avaliação da exposição e identificação das vulnerabilidades nos diversos fluxos de transação e negócios, gerenciamento do risco à fraude e monitoramento dos controles internos existentes como resposta ao risco de fraude;

3) Tratamento: Referido tópico está relacionado a importância de se fazer claro para todos os colaboradores de uma empresa, do mais baixo até o mais alto escalão como será o tratamento adotado pela companhia ao identificar uma fraude, incluindo as penalidades das quais o fraudador estará suscetível. Para o sucesso do programa de prevenção, é inadmissível qualquer flexibilidade para os atos de fraude, lembrando que não existe fraude que deva ser deixada de lado por ser pequena ou imaterial. Todas devem ser punidas, de forma que a empresa deixe claro que não admite, em nenhuma hipótese, atos desta natureza. É nesse sentido que um processo robusto de prevenção à fraude faz a diferença, reduzindo as oportunidades existentes para que o fraudador não se sinta motivado a perpetrar a fraude. Segundo reiteradas pesquisas[208], na maioria das vezes o fraudador está dentro de instituição[209], mas com o advento dos sistemas de processamento eletrônico e a convergência dos negócios globais via internet, o fraudador pode estar também fora da empresa; ou seja; do outro lado da conexão. Atualmente, tem sido muito comum a fraude realizada através de *cyber atacks* conduzida por *rackers*, daí a necessidade de serem adotadas tecnologias capazes de combater a fraude[210], bem como a adoção de políticas e procedimentos alinhados com a *GDPR (General Data Privacy Regulation)*, bem como a recente legislação brasileira acerca da proteção de dados - Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Em suma, é possível afirmar-se que a perpetração da fraude no ambiente corporativo traz as seguintes consequência negativas: (i) potencial risco de minar o alicerce reputacional e financeiro de uma empresa, a depender do tamanho e repercussão do evento da fraude, uma vez que, se não for sanada de forma imediata após sua descoberta, pode franquear a incidência de outras fraudes aumentando os prejuízos já causados; (ii) geração de reclamações e denúncias configuradas como atos de corrupção em países com previsão para a tipificação de tal delito no âmbito privado, haja vista que podem comprometer os interesses de proprietários e *shareholders* de uma organização; e (iii) geração de um ambiente nocivo de trabalho, considerando que um ambiente fraudulento traz aos colaboradores que são fiéis aos princípios da organização e ao Programa de Compliance, a falta de crença em sua eficácia, bem como a desmotivação profissional.

Nesse cenário, conclui-se que um programa antifraudes em uma empresa para ser bem-sucedido deve contar com especialistas em controles internos para apoiar os gestores com suas responsabilidades de gerenciamento dos riscos[211], bem como com uma auditoria interna proativa avaliando, de forma independente, o desempenho e conformidade dos diversos processos e fluxo das transações e negócios.

4. Auditoria: Definição Genérica, Princípios e Forma de Atuação

A palavra auditoria teve origem no latim *audire,* que significa ouvir sendo que posteriormente foram os ingleses que ampliaram seu conceito para *auditing,* voltando o seu significado para o sentido de revisão ou verificação. De forma genérica, é possível afirmar que "*a essência do trabalho de auditoria consiste na audição de informações sobre fatos sujeitos a auditoria para que o auditor possa formar opinião a respeito de sua adequação em relação a determinadas normas ou temas refletidos em*

processos".[212] Como processo, possui vários tipos de subprocessos e segmentos em que tal ferramenta pode ser utilizada. Vejamos então seus princípios e pressupostos genéricos de elaboração.

4.1. Princípios Aplicáveis aos Processos de Auditoria

Os princípios gerais que devem pautar um processo de auditoria encontram-se dispostos abaixo:

a) Conduta Ética: Este tópico está relacionado ao profissionalismo do Auditor. Confiança, integridade, confidencialidade e discrição. Na condução de um processo de auditoria, um auditor deve ser integro e ético, não deve aceitar presentes e não se deve influenciar por elogios e subornos em uma auditoria.

b) Apresentação Justa: Tal princípio está relacionado a obrigação de reportar com exatidão e verdade os fatos constatados em um processo de auditoria. Relatórios de auditoria devem ser precisos e verdadeiros. Quesitos, opiniões divergentes não resolvidas entre a equipe de auditoria e o auditado devem ser relatados, ou seja; o auditor deve reportar tudo o que observa com retidão em seu relatório final.

c) Devido Cuidado Profissional: Referido princípio está ligado a utilização da devida diligência e o julgamento na auditoria. Os auditores devem ter o cuidado necessário no processo de auditoria, considerando a importância da tarefa que executam e a confiança que lhe é depositada pelos clientes e partes interessadas. Ter a competência necessária é um fator importante. Em outras palavras, a auditoria deve ser feita com muito *zelo*. Os critérios de auditoria devem ser examinados e não se pode *relaxar* na análise e verificação dos requisitos avaliados. Ser competente com base em habilidade, experiência, educação e treinamento previamente definidos e comprovados é fundamental.

d) Independência: O princípio da independência é a base para a imparcialidade e conclusões objetivas a serem atingidas em um processo de auditoria. Auditores são independentes da atividade a ser auditada e livres de tendências e conflitos de interesse. Os auditores devem manter um estado de mente aberta ao longo do processo de auditoria para assegurar que as constatações e conclusões de auditoria serão baseadas somente nas evidências constatadas. Por exemplo: Se a pessoa trabalha no setor de compras não deveria auditar este mesmo setor em uma auditoria interna. Se você é um auditor de certificadora não é recomendável auditar a empresa que é dirigida por seu irmão ou parente. Se você é um organismo que audita e pode certificar sistemas de gestão seria desejável que não realizasse consultorias.

e) Abordagem baseada em evidências: Mediante tal princípio, a auditoria deve ser realizada com base em um método racional para alcançar conclusões de auditorias confiáveis a serem reproduzidas em um processo sistemático. Evidências são baseadas em amostras das informações disponíveis, uma vez que uma auditoria é realizada durante um determinado período e com recurso limitados. O uso apropriado da amostragem está intimamente relacionado com a confiança que pode ser colocada nas conclusões de auditoria. Em um processo de auditoria, não deve existir o "*achismo*", ou existem evidências ou não se pode concluir com veracidade acerca de um processo auditado.

4.2. Processo de Auditoria e Passo a Passo para Elaboração

Conforme já mencionado, o processo de Auditoria é um processo que pode ser realizado em diferentes segmentos ou áreas, não sendo um processo exclusivo da área financeira. Assim, necessário entender a forma de como conduzi-lo, razão pela deve ser seguido no mínimo, o passo a passo reproduzido abaixo:

1) Definição de objetivos e resultados: Em todos os processos e tipos de auditorias a se realizarem, é necessário existir um objetivo, bem como resultado a ser alcançado. Por exemplo: Pesquisa de satisfação de clientes. Objetivo: medir a satisfação de clientes. Resultado a ser alcançado: coletar informações para melhoria contínua dos nossos produtos e processos.

2) Elaboração de um cronograma e plano: O atingimento do objetivo e resultado previsto em um processo de auditoria requer a organização de um cronograma e um plano. Portanto, é preciso definir: (i) Que processos específicos e subprocessos serão auditados; (ii) Quando eles serão auditados; (iii) Quais serão as ações adotadas para auditar os processos específicos e subprocessos; e por fim; (iv) com base em que requisitos serão auditados.

3) Necessário a garantia de que seja um processo válido: Na execução de um processo de auditoria, o auditor precisa garantir que o processo seja realmente válido, ou seja; que o trabalho está sendo conduzido para o atingir o resultado proposto. Tal fator está relacionado com o que fazer a partir dos resultados e informações obtidas em um processo de auditoria, em outras palavras; com as *não conformidades* e *planos de ações*, pois o delineamento deles tem que ser claros para toda a equipe envolvida, daí a importância da definição de prazos, bem como da designação de responsáveis pelas ações.

4) Elaboração de relatórios de Auditorias: Após a realização do processo de auditoria é necessário a elaboração de um relatório final. Nesse sentido, vale a aplicação da máxima de auditoria de que *bons relatórios respondem perguntas*, utilizada como uma técnica eficaz para a geração do relatório a ser apresentado à área e/ou as pessoas responsáveis pelo setor auditado. Por exemplo: Quantos itens da auditoria foram cumpridos? Quais ações devem ser tomadas em decorrências das não conformidades e ações de melhoria apontadas na auditoria? Devo submeter o resultado do relatório à alta diretoria e quais perguntas por eles seriam feitas? Qual é a área de foco de melhoria? Quanto deve ser investido?

5) Gerenciamento dos planos de ações e não conformidades: Depois de estabelecidos os responsáveis e os planos de ação, o auditor em um processo de auditoria deve dentro de uma periodicidade determinada verificar o andamento das ações traçadas no plano e das não conformidades. Também será necessário a certificação de que todas as pessoas envolvidas no processo entendam quais ações devem tomar e quando devem fazê-las. Isto significa que devem ser instruídas pelo auditor de maneira clara e didática, pois não raro as pessoas responsáveis pelos planos de ações não o entendem corretamente, e a ausência da correta diretriz e entendimento tende a impactar na execução dos planos de ações.

4.3. Tipos de Auditoria relacionados a área de Compliance

a) Auditoria Financeira ou Externa - Conforme já exposto no Capítulo desta obra dedicado a Controles Internos, nos termos da SOX [213], em específico das Seções a seguir reproduzidas, as empresas com ações listadas em bolsas de valores americanas com base nas Seções abaixo reproduzidas, devem obrigatoriamente passarem por uma auditoria financeira ou externa e a possuírem uma área de auditoria interna, segundo os moldes apresentados abaixo:

A **Seção 404** exige que o CEO e CFO se responsabilizem pelo estabelecimento e manutenção de um adequado sistema de controles internos e que façam periodicamente uma avaliação sobre a eficácia desses controles. A referida Seção exige também que a Auditoria Independente emita dois pareceres dentro dos padrões definidos pela PCAOB, sendo um sobre a avaliação realizada pela administração e o outro sobre a efetividade desses controles internos.

A **Seção 407** exige que faça parte do Comitê de Auditoria um perito em finanças com formação e experiência como contador, auditor, principal administrador financeiro, *controller* ou função similar, incluindo experiência em controles internos contábeis e entendimento das funções do Comitê de auditoria. A SOX admite que, não tendo a sociedade listada no mercado norte-americano um Comitê de Auditoria, todos os integrantes do Conselho de Administração possam exercer as funções que são atribuídas ao aludido Comitê, porém, deve-se levar em conta alguns princípios exigidos pela SEC.

A **Seção 802** refere-se à fraude na contabilidade corporativa, prevendo penalidades criminais pela modificação de documentos. Estabelece multa e/ou prisão por alteração intencional, destruição, mutilação, ocultação, dissimulação, disfarce, falsificação ou falsa entrada de dados em que qualquer relatório ou documento. A referida seção prevê a guarda por cinco anos de relatórios de auditoria, papéis de trabalho, comunicados, memorandos, correspondências e outros, incluindo os eletrônicos, emitidos e recebidos em conexão com as atividades da auditoria. As empresas que não estiverem em conformidade com a SEC poderão receber sanções pecuniárias de US$ 1 milhão a US$ 5 milhões e/ou penais de dez a vinte anos de reclusão.

No Brasil, a legislação obriga algumas empresas a passarem periodicamente pela avaliação de uma auditoria externa.

Nesse sentido, todas as empresas classificadas como de grande porte (com faturamento maio que 300 milhões de reais por ano ou que tenham ativos totais superiores a 240 milhões de reais) devem ser auditadas uma vez por ano, enquanto as instituições financeiras (bancos, fundos de investimento, etc.) e seguradoras devem ser submetidas a auditorias a cada seis meses.

Adicionalmente, as empresas de capital aberto (aquelas com ações negociadas em bolsa de valores) também são auditadas uma vez ao ano. A auditoria, nesse caso, serve como uma garantia aos acionistas de que os números apresentados pela companhia fazem sentido **-** as firmas de auditoria possuem expertise em avaliar a saúde financeira de uma empresa. Por isso mesmo, também é comum que empresas sejam auditadas na iminência de serem compradas, ou durante procedimentos de fusão e aquisição

Por todo o exposto, embora o processo de Auditoria Financeira ou Externa seja recomendável para todas as empresas em território nacional, tal processo é facultativo para as empresas brasileiras que não se enquadrem nas hipóteses acima elencadas, bem como as expostas no quadro comparativo reproduzido a diante.

b) Auditoria Interna - Dentre outras definições, a de auditoria Interna com maior aceitação é a dada pela organização com sede nos Estados Unidos da América, o IIA (*The Institute of Internal Auditors*) segundo a qual "*Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes*". [214]

A área de auditoria interna é tida como facultativa nas estruturas que não devem possuir a referida área em decorrência de exigência legal (vide quadro comparativo com legislações atinentes, listando as hipóteses de obrigatoriedade). Tem a função de apoiar a gestão e objetiva verificar se o controle interno está em efetivo funcionamento, proferindo o auditor, quando cabível, apontamentos de melhorias e não conformidades encontradas.

Assim, referida área está geralmente subordinada ao maior nível hierárquico da empresa, qual seja; ao Conselho da Administração ou a presidência, para que os profissionais que integrem tal órgão possam usufruir de maior independência dentro da corporação.

O trabalho da auditoria interna deve ser desenvolvido com um planejamento anual de auditoria, a ser submetido previamente a alta administração para conhecimento e aprovação. Nele devem constar as principais atividades da entidade a ser auditada a partir do maior grau de risco operacional apresentado.

A recomendação para a composição de uma área de auditoria interna é a de que seja composta por profissionais com formação e experiências diversas (corpo multidisciplinar) para que, após o trabalho de campo, que inclui discussão com os responsáveis pelas áreas auditadas, sejam produzidos relatórios os quais devem ser encaminhados a alta administração para conhecimento e decisões. A área é tida também como uma das ferramentas de governança corporativa.

Os relatórios deverão conter as constatações de fatos que a auditoria interna entende como incorretos ou com oportunidades de aperfeiçoamento, bem como as correspondentes recomendações e sugestões.

Por fim, a auditoria interna para fins de controle, deverá manter um banco de dados com as constatações e recomendações contidas nos seus relatórios, catalogados por área (diretoria, departamento, divisão, gerência, assuntos objeto de auditoria, etc.) para que os membros da área de auditoria e mesmo da alta administração possam monitorar os planos de ações traçados.

c) Auditoria de Compliance - Conforme já mencionado neste artigo e somente para fins de fixação do conceito, o processo de auditoria é um gênero, do qual a auditoria financeira ou externa, auditoria interna e a auditoria de compliance são apenas consideradas espécies, além das demais existentes.

A Auditoria de Compliance visa averiguar se os pilares do Programa de Compliance ou se parte dele estão sendo cumpridos, utilizando as técnicas e princípios previstos dentro da realização de um processo de auditoria tradicional. Em decorrência disso, faremos menção de alguns itens comum a todos os Programas de Compliance, que devem ser verificados em um processo de auditoria:

1) Conformidade de registros financeiros: Os registros contábeis devem refletir de forma completa as transações da pessoa jurídica (art. 42, inciso V, do Decreto 8.420/2015, e na SOX, Seção 802 do Capítulo *Books & Records*);

2) Cumprimento de Políticas, Procedimentos e Código de Ética: Deve ser objeto de auditoria a empresa e também os fornecedores e/ou terceiros a fim de averiguar se estão cumprindo em sua prática, as políticas e procedimentos contidos no Programa, merecendo especial atenção a prestação

ou fornecimento de serviços, haja vista que podem esconder ou dissimular práticas em desacordo com as regras estabelecidas pela empresa;

3) Relacionamento de fornecedores e terceiros junto a entes governamentais: Os trabalhos de despachantes em específico, se não tiverem um efetivo monitoramento, podem trazer sérias consequências para a empresa tomadora de serviços no contexto do Compliance, em decorrência do fenômeno da representação. Merece atenção também, as empresas representantes ou franqueadas que atuam em nome das empresas representadas ou franqueadas junto a entes estatais, eis que elas respondem objetivamente perante o poder público, daí a necessidade da estruturação de um robusto Programa de Compliance, aliado ao monitoramento de terceiros para empresas que possuam capilaridade expressiva de representação em seu ecossistema de negócios;[215]

4) Riscos regulatórios identificados na matriz de riscos: Geralmente em programas que envolvam terceiros, além da própria empresa a depender do segmento do negócio, será necessário a checagem de documentos regulatórios. Por exemplo: Licenças, alvarás, bem como autorizações e suas validades emitidas por entes reguladores, que de alguma forma tragam riscos ou impactem o negócio);

5) Situação financeira de terceiros e fornecedores: devem ser avaliados junto a terceiros e fornecedores em geral as certidões negativas além de outros documentos regulatórios a depender do ramo de atuação da empresa que está realizando uma auditoria de Compliance;

6) Riscos com concorrentes: determinadas informações são extremamente sensíveis, sendo assim, a confidencialidade é essencial para o bom andamento dos negócios de uma companhia. Por isso, algumas empresas possuem já estabelecidas regras que balizam tais relacionamentos; (Por exemplo: verificação obrigatória de procedimentos de que sempre em reuniões com concorrentes deve haver mais de uma pessoa presente, elaboração obrigatória de ata de registro de encontros, gravações, etc.)

7) Conflitos de interesses: Para que não haja em uma situação o conflito de interesses, tal risco deve ser checado periodicamente, em especial, junto a relacionamentos com entes governamentais e parentes consanguíneos, sendo certo que a transparência das informações nesses tipos de relacionamentos pode efetivamente reduzir ou mitigar o risco. Dessa forma, perguntas geralmente elaboradas em questionários de *on boarding* de terceiros devem ser feitas novamente. Por exemplo: (i) se o terceiro possui familiares que trabalha na empresa junto a área de compras; (ii) se o terceiro tem parentes ou cônjuge que trabalha em multinacionais concorrentes; (iii) se o terceiro está informando corretamente todos os seus relacionamentos com entes estatais para fins de monitoramento, dentre outras perguntas.

8) Viagens, entretenimentos e concessão de presentes e cortesias: É importante que todos os procedimentos e políticas envolvendo viagens e entretenimentos tenham o seu cumprimento verificado.

9) Matriz de riscos: A averiguação da atualização da matriz de risco é essencial durante um processo de auditoria, por tratar-se de um dos pilares que compõe um Programa de Compliance.

10) Doações & patrocínios: A fim de coibir atos de corrupção, é necessário a verificação do cumprimento das políticas e do oferecimento de cortesias, realização e doações e patrocínios, em especial envolvendo entes de governos e as peculiaridades das legislações incidentes nas *geos* objeto de auditoria.

11) A adequação de práticas e Procedimentos da área de Compliance: A aferição de práticas adotadas pela empresa em consonância com as diretrizes contidas no Manual de Avaliação de Programas de Compliance editado pela CGU.

Na prática, a auditoria de Compliance na própria área não é muito realizada em virtude das seguintes razões: (i) limitação de orçamento para contratação de empresas externas especializadas na realização de auditoria de Compliance; ou (ii) falta de experiência do time de auditoria interna (quando existente na estrutura da empresa) no exercício da prática de auditoria junto a área de Compliance. O que se observa é que na área de Compliance, a prática de auditoria é muito aplicada junto a terceiros e fornecedores, incluindo relacionamentos de representantes comerciais e franqueados, eis que a empresa em um relacionamento de representação, responde nos termos da legislação pátria, de forma objetiva.[216]

d) Quadros Comparativos

AUDITORIA EXTERNA OU FINANCEIRA X AUDITORIA DE COMPLIANCE

	AUDIT. FINANCEIRA/ EXTERNA	AUDITORIA DE COMPLIANCE
Quanto ao alcance de atuação:	É específica. Investiga somente aspectos relacionados aos registros financeiros e contábeis e políticas e procedimentos ao tema relacionados.	É abrangente. Tem como base o Programa de Compliance, bem como as Políticas e Procedimentos criados com base na matriz de risco da empresa. Observa o cumprimento de requisitos extremamente relevante para o negócio tais como: regulatórios, ambientais, de padrões de qualidade, de segurança do trabalho além de legais dentre outros.
Quanto ao atendimento normas regulatórias e contábeis:	Atende as normas determinadas pela SOX do Capítulo "*Book & Records*", além das previstas para empresas brasileiras que possuem ações negociadas em Bolsas de valores americanas. Conforme legislação contábil brasileira, as empresas que devem submeter suas demonstrações contábeis ao exame de auditores externos são: - As sociedades por ações de capital aberto nos termos da Lei 6.404/76, Art. 177 § 3º, além dessas: (i) instituições financeiras (bancos, financeiras, distribuidoras e corretoras entre outras); (ii) companhias de seguros; (iii) fundações públicas ou privadas consideradas de interesse público; e (iv) empresas subordinadas a agências reguladoras. Por exemplo: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência nacional de Telecomunicações (Anatel) etc. - Sociedades por ações de capital fechado e sociedade por quotas de responsabilidade limitada de grande porte nos termos da Lei 11.638/07, Art.3º—consideradas aquelas com ativo total superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$ 300.000,00 (trezentos milhões de reais).	A Auditoria financeira é obrigatória dentro do contexto do Compliance somente um dos itens a serem analisados e para as empresas brasileiras que possuem ações negociadas em Bolsas de valores americanas, bem como nas hipóteses eventualmente estabelecidas em legislações estaduais anticorrupção. Embora a análise dos dados financeiros seja mencionada no Art. 42, inciso VI (registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica) do Decreto 8.420/2015, em decorrência de tal legislação ela não é obrigatória, embora recomendável. Contudo, nas hipóteses de enquadramento legal conforme legislação brasileira ao lado expostas, a sua realização da auditoria financeira é mandatória.
Quanto a finalidade do parecer final ou relatório	A conclusão ou "*Financial Statement*" ou Balanço permite a valoração oficial da organização perante o mercado e/ou acionistas da empresa. Serve como base para a tributação de IR da empresa. Identifica os controles financeiros e de sistemas que devem ser aperfeiçoados como formas de coibir fraudes e atos de corrupção.	A conclusão ou relatório final quando firmada por consultoria externa especializada, deve ser utilizada para nortear pontos de melhoria e não conformidades em Programas de Compliance. Quando realizada junto a terceiros e fornecedores, autorizam a sua permanência e continuidade dentro do ecossistema da empresa auditada. Nesse contexto visam coibir e mitigar riscos de deflagração de atos de corrupção previstos pelo FCPA e Lei brasileira anticorrupção.
Quanto ao atendimento de ISO:	A Auditoria Financeira ou Externa atende aos requisitos previstos na ISO 31000:2009.	A Auditoria de Compliance submete-se além dos preceitos para auditorias financeiras obrigatórias, conforme as regras da ISSO 31000:2009. Além desta, dentre outras, a auditoria deve submeter-se ao cumprimento além de outras: ISO 37001:2017 - Sistemas de Gestão Antissuborno; ISO 19600:2014 - Sistemas de Gestão de Gestão dos Programas de Compliance; ISO 9000:2001 - Que abrange 4 normas internacionais para Sistema de Gestão da Qualidade e Sistema de Garantia da Qualidade. Ela não é destinada a um "produto" nem para alguma indústria específica. Tem como objetivo orientar a implantação de sistemas de qualidade nas organizações.
Quanto a validação	Deve ser assinada por contador.	Deve ser assinada pelo responsável pela condução do processo, entendido como sendo pessoa de reputado conhecimento e autoridade na área de Compliance.
Quanto ao reporte	A auditoria financeira deve reportar-se ao Comitê de Auditoria quando existente na estrutura da empresa e quando não houver à alta administração.	A Auditoria de terceiros deve ser reportada a área de Compliance e alternativamente a outras áreas da companhia (Auditoria interna/Alta administração). A Auditoria do Programa de Compliance deve ser reportada a alta administração ou Área de Auditoria interna se a houver na estrutura da corporação.

AUDITORIA INTERNA X AUDITORIA DE COMPLIANCE

	AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA DE COMPLIANCE
Quanto ao objetivo	A auditoria interna efetua seus trabalhos através de amostragens periódicas no sentido de verificar o cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos pela alta administração, inclusive no que tange a aspectos da área de finanças.	A área de compliance faz um monitoramento contínuo e permanente para assegurar que o Programa de Compliance, bem como suas políticas e procedimentos estejam respeitando as regras aplicáveis ao negócio, o Programa, bem como o mapa de riscos traçado. A Auditoria de Compliance junto a terceiros, executa suas atividades de forma rotineira junto a cadeia de fornecedores e terceiros de uma empresa, haja vista que a responsabilidade objetiva decorrente, pode representar no Programa de Compliance a maior área de riscos
Quanto a amostragem	Realiza trabalhos por amostragens.	Pode realizar por amostragens ou não.

Quanto a especificidade	Visa investigar em processos e sub-processos de auditoria temas específicos para o relato de "*pontos de melhoria*" e "*não conformidades*", de acordo com as regras e metas estabelecidas pela alta administração, não necessariamente relacionados a área de Compliance.	Quanto realizada por consultoria externa especializada, seu resultado é capaz de determinar "*pontos de melhoria*" e "*não conformidades*" relacionados ao Programa de Compliance analisado. A área de Compliance é considerada um braço dos órgãos reguladores junto a alta administração no que se refere a preservação da boa imagem e reputação. Vela também pelos controles das normas em busca da conformidade.

5. Monitoramento do Programa de Compliance

De forma simplificada, é possível afirmar-se que o monitoramento de um Programa de Compliance é o seu acompanhamento, a constatação de seu funcionamento, em outras palavras; a materialização de sua existência e desenvolvimento.

Para que a efetividade de um Programa de Compliance seja aferida é preciso que ele seja monitorado, a fim de constatar que os seus pilares estão funcionando conforme o esperado, bem como se os efeitos esperados com relação a conscientização dos funcionários estão sendo atingidos. Igualmente, é necessária a análise no tocante aos riscos identificados, a fim de constatar se eventuais riscos estão sendo gerenciados e se novos riscos surgiram no decorrer da operação monitorada pelo Programa.

Dessa forma, para que os objetivos de um Programa de Compliance sejam alcançados, ou seja; para que comportamentos éticos sejam estabelecidos na prática e não somente *no papel*, em alinhamento com as exigências legais, o comprometimento da alta administração de uma companhia é essencial.

Assim, a alta administração da empresa deve conduzir o Programa de Compliance, através da prática do *tone from the top*; participando de forma direta e indireta, promovendo o programa de integridade e viabilizando recursos para o seu gerenciamento e para a realização de ações de melhorias. Nesse ponto, os indicadores de gestão da área assumem um papel de extrema relevância, sendo determinante para o seu sucesso.

Nunca é demais lembrar que os membros da alta administração de uma companhia normalmente possuem restrições de agenda e até mesmo física de estarem próximos da rotina da área e do Programa de Compliance. Portanto, a existência de indicadores de tal área, viabiliza a participação ativa da administração da empresa em seu monitoramento.

Sob a ótica da gestão, é possível sustentar a afirmação de que: "*não se gerencia aquilo que não se mede, e da mesma forma, não se mede o que não se define*". Se a definição e o entendimento do objeto de análise não são possíveis, não há que se falar em seu gerenciamento. Justamente por isso, é de responsabilidade da alta administração da empresa a análise de indicadores a fim de propor ações concretas de gerenciamento de seu Programa de Compliance.

Os KPIs (*Key Performance Indicators*) da área de Compliance ou como também conhecidos indicadores de gestão devem variar conforme a realidade de cada empresa e a sua exposição ao risco. Uma vez entendido o grau de exposição ao risco, é possível então definir as políticas esperadas de todos os colaboradores da empresa. Ao ter a definição do escopo das políticas do Programa de Compliance, é possível estabelecer o monitoramento periódico e a partir de então, gerenciar a sua efetividade, bem como fomentar sua existência e continuidade.

A visão do todo por parte da alta administração da empresa, possibilita o entendimento dos riscos envolvidos para adoção das medidas com a finalidade de mitigar riscos; avaliar medidas corretivas tomadas em determinados períodos propostas através de mudanças; e até mesmo, o atingimento de metas e resultados. Os indicadores de gestão são apenas um meio para concretizar o engajamento da alta administração com o Programa de Compliance.

Diversas iniciativas da mesma forma, podem demonstram comprometimento da alta administração da empresa para com o Compliance, tais como: como mensagens escritas para os funcionários, participação presencial em treinamentos de compliance, etc. É claro que tais medidas são importantes e também denotam o comprometimento por parte da alta administração, todavia, nada substitui a visão objetiva da área.

Também, é necessário frisar a importância dos KPIs das áreas de Compliance para fins de eventual defesa do próprio Programa, uma vez que sua demonstração de forma viva e concreta é capaz de comprovar ou não o funcionamento dos pilares do programa na hipótese uma eventual investigação.

Vejamos então alguns exemplos que podem ser utilizados como parâmetros adicionais[217] que podem ser utilizados na avaliação e efetividade de um Programa de Integridade:

1) Demonstrativo de listas de presença e controles de colaboradores da empresa em treinamentos de Compliance;
2) Pesquisas realizadas junto aos colabores para avaliarem o Programa de Compliance, pontos a serem trabalhados, bem como aferição da efetividade de Treinamentos;
3) Envio de e/ou e-mails corporativos com conteúdo de campanhas de boas práticas de compliance;
4) Documentação acerca de casos de Compliance analisados, tratativas e investigações;
5) E-mails direcionados a alta administração contendo assuntos da área de Compliance;
6) Apresentação de Slides com informações e KPI's da área de Compliance apresentados ao *Board* ou alta administração;
7) Formalização em atas societárias de decisões tomadas acerca de casos apresentados ao *Board*;
8) Comprovação de aprovação e utilização de budget da área, com as respectivas destinações (por exemplo: material de divulgação do Programa, palestra de ministrantes convidados etc.);
9) Documentação de cursos de aperfeiçoamento realizados pelos membros da área de Compliance, refletindo o intuito de melhoria contínua dos recursos da área;
10) Comprovação de procedimentos e parâmetros para a inserção de terceiros (incluindo representante comerciais e franqueados), bem como fornecedores junto ao ecossistema de empresa;
11) Estatísticas de rejeição de terceiros e fornecedores em aplicação da prática *Know Your Client, Know Your Supplier,* etc.;
12) Estatísticas de reclamações e tipos de reclamações e casos de Compliance recebidos e tratados com uma resolução final;
13) Com relação ao Compliance trabalhista, indicativos demonstrando a capacidade de preencher rapidamente vagas com candidatos de alta qualidade. Número e velocidade de candidatos a partir de quando a posição foi anunciada e/ou postada em sites. Número e qualidade do *pool* de candidatos concorrentes a vaga, bem como porcentagem de candidatos serem entrevistados, medindo a percepção de marca e reputação da empresa;
14) Estatísticas acerca de negócios de riscos avaliados pela área de Compliance, envolvendo propinas, presentes, descontos não aprovados, relações pessoais etc.;
15) Indicativos em porcentagem de situações que podem ser consideradas como sendo situações de *retaliação silenciosa*;
16) Demonstrativos acerca do tempo levado para a conclusão de casos (o fechamento oportuno reduz o risco de a investigação ser comprometida e demonstra a justiça organizacional.);
17) Comparativos estatísticos contendo porcentagem de relatórios de prestação de contas X reembolso, contendo dados de conformidades e não conformidades para o direcionamento de ações antifraude;
18) Com relação ao reconhecimento de receitas, indicadores acerca de vendas e transações suportadas por documentos fiscais X relação ao desempenho de vendas;
19) Em relação ao risco de segmentação de um negócio, informativos de *grey markets* explorados, falhas de segurança/quase acidentes, reduções em atuações específicas em setores de atuação da empresa; e
20) Com relação a M&A's, um relatório final ou documentação equivalente, cujo conteúdo foi apresentado a alta administração conclusões finais acerca de processo de *due diligence* realizado a fim de para identificar condutas impróprias ou o risco de má conduta na empresa examinada;
21) Relatórios finais de auditorias de Compliance contendo pontos de melhorias e planos de ações a serem implantados na área, bem como o seu monitoramento apresentados a alta administração.
22) Documentos que reflitam que os requisitos que avaliam positivamente um Programa de Compliance previstos no Manual de Avaliação do Programa de Compliance editado pela CGU, estão sendo cumpridos.

Na avaliação de um Programa de Compliance, nunca é demais lembrar que as iniciativas se complementam, mas o engajamento por parte da alta administração e funcionamento do Programa deve ser demonstrado na prática e não de forma fictícia.

Por oportuno, é importante lembrar que dever do gestor do departamento de Compliance, comprovar a independência da área, gerar *KPIs* (*Key Performance Indicators*) a fim de possibilitar a

participação e monitoramento da área e do Programa pela alta administração, que certamente trarão maiores chances de sucesso e efetividade do Programa, de forma a sedimentar a sua continuidade.

Essencial também, que o monitoramento de um Programa de Compliance seja feito de forma customizada, levando-se em conta os aspectos locais quais sejam; cultura, legislação e matriz de risco traçada especificamente para a "*geo*" etc... caso contrário, apesar dos esforços, a tarefa do monitoramento do Programa estará fadada ao insucesso.

5.1. Avaliação do Programa de Compliance sob a ótica da Legislação Brasileira

Acerca do tema da avaliação do Programa de Compliance, vale lembrar que a Lei 12.846/2013 deixou em aberto para legislação posterior fixar os parâmetros, e diretrizes para a avalição de um programa de Compliance.

Nesse sentido, o Decreto 8.420/2015, trouxe em seu texto, no Art. 42 § 4º,[218] a previsão de que seria de responsabilidade do ao Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União (atual Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União) expedir orientações, normas e procedimentos complementares referentes à avaliação do programa de integridade de que trata este Capítulo, embora no mesmo artigo tenha fixado alguns dos parâmetros a serem analisados.

Posteriormente, a Portaria CGU nº 909/15,[219] fixou alguns critérios de avaliação dos Programas de Integridade das pessoas jurídicas para redução da multa aplicável em razão da prática de atos ilícitos contra a Administração Pública.

Segundo a referida portaria, para fins de redução de penalidade, em função da existência de um programa de Compliance, as empresas têm de demonstrar que o programa implementado é eficaz, ou seja; é capaz de mitigar o risco advindo da prática de atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Relatório de Perfil: Documento que consolida informações sobre a pessoa jurídica investigada, indicando sua posição no mercado, estrutura organizacional, quantitativo de prepostos, relacionamento com a administração e a descrição do grupo empresarial e consórcios que integra; e

b) Relatório de Conformidade: Documento que versa acerca do atendimento as previsões contidas Art. 42, do Decreto nº 8.420/15 e a implementação das regras do Programa de Integridade na rotina da empresa, dentre outras informações.

Em data recente (14 de setembro de 2018), o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União editou de forma complementar para a avaliação dos Programas de avaliação dos Programas de Compliance o *Manual Prático de avaliação de Programa de Integridade em PAR*[220] (Processo Administrativo de Responsabilização).

Tal Manual traz orientações para os servidores públicos federais responsáveis por avaliarem Programas de Compliance, bem como perguntas que devem ser respondidas pelas empresas durante o processo de avaliação. Adicionalmente, a obra traz exemplos de como as empresas podem apresentar provas de que seu Programa cumpre com os 15 dos 16 parâmetros mencionados no Art. 42 do Decreto nº 8.420/15.

Para a avaliação do Programa de Compliance, a CPAR (Comissão que analisa o Processo Administrativo de Responsabilização) solicitará formalmente que as empresas apresentem informações sobre o seu Programa de Integridade no momento de sua defesa escrita.

O processo de avaliação nos termos do Manual é dividido em 03 (três) partes a serem examinadas pela CPAR (Comissão que analisa o Processo Administrativo de Responsabilização), a saber:

1) Cultura Organizacional de Integridade (COI): Em tal parte as perguntas objetivam avaliar se a empresa tem condições de promover e manter uma cultura de integridade;

2) Mecanismos, Políticas e Procedimentos de Integridade: Nesse bloco as perguntas têm como objetivo avaliar se a empresa tem mecanismos apropriados para prevenir, detectar e remediar violações a lei brasileira anticorrupção; e

3) Atuação da empresa em relação ao ato lesivo: Nessa parte as perguntas têm como objetivo: **(i)** avaliar a atuação do Programa de Compliance na prevenção, detecção ou remediação da violação objeto do PAR; e **(ii)** aferir se a empresa estabeleceu medidas para evitar que atos semelhantes ocorram novamente.

Reproduzimos em notas de rodapé, as perguntas que a empresa investigada deverá responder conforme orientação do referido guia.[221]

Quanto ao tema da atuação da empresa em relação ao ato lesivo exposto acima, oportuno esclarecer que o item (i) é exclusivo para companhias que já tenham um Programa de Compliance antes da violação investigada; e o item (ii) é aplicável a empresas que implementaram um Programa de Compliance, após a ocorrência da violação à lei brasileira anticorrupção.

Nessa linha, a matéria da avaliação de um Programa de Compliance, deve ser iniciada quando a CPAR (Comissão que analisa o Processo Administrativo de Responsabilização) já tiver formada a convicção sobre a responsabilidade da pessoa jurídica, devendo a referida comissão propor uma sanção, sendo a principal sanção administrativa a prevista no Art.6º, da Lei 12.846/2013[222], reproduzida abaixo, a qual poderá ser reduzida nos termos do art. 7º, inciso VIII do mesmo texto legal. [223]

Com base no exposto, a avaliação e o monitoramento de um Programa de Compliance, passam a ser temas suscetíveis de exploração, posto que já existe legislação nacional específica. Entretanto, remanesce ainda como um desafio, a consolidação de jurisprudência pátria atinente a matéria.

5.2. Avaliação do Programa de Compliance sob a ótica do FCPA.

O tema da avaliação de Programas de Compliance também ainda representava um desafio à luz do FCPA. Sob a ótica da referida legislação, a aferição da efetividade de um Programa de Compliance, face a análise de um ato ou "*wrong doing*" deveria atender a duas avaliações:

1) ***Principles of Federal Prossecution of Business Organizations***[224]: Diretrizes que guiam as decisões dos procuradores americanos acerca da propositura ou não de uma ação penal contra uma empresa investigada;

2) ***The United States Sentencing Guidelines – Chapter 8***[225]: Uma vez proposta a ação penal, o Judiciário Americano irá seguir as diretrizes do documento no momento de avaliar a culpabilidade da pessoa jurídica e calcular a pena, ressaltando que a existência de um Programa de Compliance efetivo, é um dos dois fatores capazes de mitigar a pena.[226]

Apesar da existência dos documentos acima mencionados contendo parâmetros sobre a avaliação do Programa de Compliance em processos já em análise perante os membros do Judiciário, pairava uma lacuna no FCPA acerca dos critérios de investigações conduzidas pelo DOJ, fornecendo diretrizes para emissão de um parecer final acerca da efetividade dos Programas de Compliance a ser apresentado aos promotores americanos para fins da propositura ou não de uma ação.[227]

Todavia, no dia 08 de fevereiro de 2018, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, através do Setor de Fraude, que também afere a efetividade ou não de Programas de Compliance, publicou o documento denominado de Avaliação dos Programas de Compliance Corporativos.[228]

O *Evaluation of Corporate Compliance Program* é um documento dividido em 11 tópicos diferentes e cada tópico possui uma série de perguntas – somando ao todo 46. Embora os tópicos e as perguntas não sejam novos, a diretriz para os Programas de Compliance reforça a mensagem de que o foco do DOJ está nas ações concretas que a alta administração de uma empresa adota para promover a cultura de Compliance corporativa.

Uma vez que a maioria dos Programas de Compliance em empresas multinacionais ou aquelas que têm ações negociadas em bolsas de valores americanas tem como base o FCPA, conclui-se que juntamente com o *Manual Prático de avaliação de Programa de Integridade em PAR*, os Programas de Compliance serão avaliados com base em tais documentos. Vejamos então 11 tópicos que serão explorados nas perguntas contidas no *Evaluation of Corporate Compliance Program*:

1. Análise e Remediação de Má Conduta Subjacente: Durante o curso de uma investigação, o DOJ examinará, por meio de relatórios de auditoria, denúncias e investigações prévias de *wrong doing* semelhantes as já ocorridas, que possam de alguma forma indicar que anteriormente já ocorreu uma falha na detecção do *wrong doing*. Nesse sentido, as empresas devem garantir que não exista vulnerabilidades no Programa de Compliance ou lapsos de responsabilização na detecção de problemas. Da mesma forma, as empresas devem ter um sistema para expor vulnerabilidades e implementar medidas corretivas para reduzir o risco da incidência da conduta inadequada novamente.

2. Alta administração e Gerência: A Diretriz de Compliance editada reitera que a cultura de Compliance deve ser implementada pautada na prática do *tone from the top* e o DOJ analisará se a alta

administração dissemina adequadamente a mensagem da Cultura de Compliance na empresa. Tal ônus é de incumbência da alta administração, através de discursos ou ações, para fomentar e incentivar o ambiente organizacional de uma cultura ética. Não somente a alta administração deve tomar ações concretas nos esforços de sedimentar a cultura de Compliance, mas as gerências em todos os níveis devem dar diretrizes, atuando como exemplo de comportamento para os funcionários. Além disso, a alta administração tem a responsabilidade de garantir que as informações apropriadas sejam compartilhadas entre os diferentes entes da empresa - incluindo o conselho de administração. A diretoria e a alta administração precisarão examinar as informações pertinentes na posição de supervisores do Programa, tendo um acesso especial a área de Compliance. Da mesma forma, a Diretoria e os auditores externos devem realizar sessões regulares cumprindo suas atribuições de Compliance e controle.

3. Autonomia e Recursos: Ainda que o Programa de Compliance de uma empresa tenha o seu monitoramento realizado por empresa externa especializada, os investigadores do DOJ inspecionarão o Programa de Compliance objeto de investigação, no sentido de aferir se área é autônoma. O Programa de Compliance em empresas deve garantir que os profissionais atuando na área de Compliance sejam independentes, tenham a experiência e as qualificações adequadas para suas funções e responsabilidades, mantenham um nível de comparabilidade com outros departamentos da empresa e tenha acesso a tomadores de decisão importantes, como o conselho administrativo de diretores e/ou a presidência, bem como se estes são avaliados de forma adequada pela gerência, tendo uma rotatividade baixa e atuando nas decisões estratégicas operacionais. A equipe de Compliance deve ter autonomia e ser empoderada para identificar, encaminhar e resolver casos da área.

4. Políticas e Procedimentos: Apenas ter políticas e procedimentos de Compliance em vigor não é suficiente para comprovar a efetividade de um Programa de Compliance. O DOJ analisará: **(i)** o processo de uma empresa de criação e implementação das políticas e procedimentos; **(ii)** a capacidade da empresa de avaliar a utilidade de políticas e procedimentos; e **(iii)** se os departamentos ou gestores tidos como responsáveis estão realizando a adequada supervisão. Ainda nesse sentido, ao examinar as políticas e procedimentos de Compliance, o DOJ examinará se houve orientação e treinamento claros para os principais responsáveis (por exemplo, as pessoas que emitem pagamentos ou revisam aprovações) nos processos de controle. Os *gatekeepers* devem estar cientes do processo, a fim de apontar as situações de risco ou *noncompliance*. Ademais, as políticas e procedimentos devem ser divulgados e acessíveis a todos os funcionários.

A área de Compliance deverá ser responsável pela integração operacional das políticas e procedimentos, consultando os executivos ou segmentos de negócios para fins de implementação, de forma a garantir que os funcionários possuam total compreensão. Para evitar futuros desvios de conduta, a empresa deve ter controles para detectar e prevenir toda conduta imprópria, restringir e controlar rigidamente todas as operações financeiras para evitar abusos e ter um processo para gerenciar fornecedores externos. Os funcionários de cada departamento com autoridade de aprovação ou responsabilidades de certificação precisarão saber o que procurar e quando, bem como a quem endereçar possíveis eventos de fraude ou *noncompliance*.

5. Avaliação de Risco: É preciso haver a adoção de uma metodologia para identificar, analisar e abordar os riscos de má conduta dentro da empresa investigada. O DOJ examinará o tipo de informações ou métricas coletadas pela empresa objeto de investigação para detectar condutas indevidas e como essas informações ou métricas estão sendo usadas para informar o Programa de Compliance da empresa quanto a possíveis riscos e eventuais situações de *noncompliance*.

6. Treinamento e Comunicações: O DOJ se concentrará no tipo de treinamento ministrado aos funcionários que trabalham em posições de alto risco e controle. As empresas devem garantir que: (i) os funcionários em funções de controle relevantes recebam treinamento adequado e eficaz; (ii) os funcionários de alto risco e controle estão recebendo treinamento adequado no sentido de serem alertados quanto aos riscos nas áreas onde pode ocorrer em maior probabilidade uma *wrong doing*; e (iii) é realizada uma análise apropriada de quais funcionários devem ser treinados e sobre quais assuntos.

Além de identificar os funcionários que devem receber treinamento adequado, as empresas deverão garantir que o treinamento seja efetivamente comunicado. O DOJ analisará se o formato do treinamento (ou seja; seminário presencial, interativo, etc.) e também aferirá o idioma em que o treinamento foi realizado, a fim de concluir ou não se o treinamento é apropriado para o público-alvo. Além disso, o DOJ examinará se a empresa mediu a sua eficácia.

A liderança precisará comunicar aos funcionários acerca do posicionamento da empresa sobre qualquer má conduta que tenha ocorrido, inclusive quando um funcionário for demitido por não cumprir as políticas e os procedimentos da empresa. Além disso, as empresas devem garantir que os funcionários tenham acesso adequado a recursos que forneçam orientações sobre políticas e procedimentos de conformidade.

7. Relatório Confidencial e Investigação: O DOJ analisará se a empresa implementou um mecanismo de denúncias eficaz e confidencial, incluindo a capacidade de avaliar o nível de risco ou a gravidade dos relatos recebidos. Uma vez que o relato de Compliance chega, a empresa deve responder à reclamação em tempo hábil, analisar adequadamente e identificar a conduta imprópria, de forma a determinar as pessoas envolvidas. Se uma investigação for garantida, ela deve permanecer independente, devidamente delimitada e documentada e, se apropriado, envolver todos os níveis de alta administração, além da área de Compliance. Em resposta à investigação, a remediação deve ser apropriada à luz dos resultados da investigação.

8. Incentivos e medidas disciplinares: É imperativo que uma empresa implemente medidas disciplinares apropriadas ao identificar uma má conduta. Todos os indivíduos envolvidos na má conduta devem assumir a responsabilidade por seu papel, especialmente os funcionários que têm um papel de gerenciamento na empresa. Ações disciplinares devem ser justas e consistentes para todos os níveis de emprego. Além de disciplinar a má conduta, uma empresa deve ter um processo para incentivar o bom comportamento. O DOJ procurará exemplos concretos de incentivos para conformidade e comportamento ético, como promoções e recompensas.[229]

9. Melhoria Contínua, Testes Periódicos e Revisão: Um programa de Compliance abrangente precisará passar por revisões e auditorias periódicas para testar controles e identificar vulnerabilidades. Os investigadores examinarão os tipos de auditorias ou testes de controle que uma empresa realiza em seus programas de conformidade, resultados de auditorias, se o progresso da correção é relatado à gerência e ao conselho regularmente, e como estes entes analisam esses relatórios. Muitas vezes, as auditorias internas são realizadas em áreas de alto risco. Ademais, as políticas, procedimentos e práticas de conformidade precisarão ser revisadas periodicamente e as avaliações de risco precisarão ser continuamente atualizadas.

10. Gerenciamento de Terceiros: Ao confiar em terceiros fora do controle de uma empresa, a empresa deve implementar um processo baseado em risco para gerenciar esses terceiros. A lógica de negócios para usar um terceiro precisará ser adequadamente documentada, incluindo condições de pagamento e o trabalho a ser executado. A devida diligência em terceiros deve ser conduzida para identificar *red flags* e a empresa precisará de um processo para identificar e monitorar questões de Compliance, incluindo métodos de remediação, como suspensão ou término do relacionamento de terceiros.

11. Fusões e Aquisições: Fusões e aquisições devem passar por um processo de "*due diligence*" para identificar condutas impróprias ou o risco de má conduta. A empresa deve ter de um processo para rastrear e corrigir os riscos de má conduta ou má conduta identificados durante o processo de "*due diligence*". Além disso, a empresa precisará de um processo para implementar suas políticas e procedimentos de conformidade na nova entidade.

O *Evaluation of Corporate Compliance Program* deve ser utilizado como um passo a passo de como testar e aferir Programas de Compliance já implementados, bem como para definir estratégias a serem tomadas quando *wrong doing* são descobertos a fim de demonstrar o comprometimento da empresa com o Programa.

As perguntas contidas no referido documento atreladas aos tópicos acima expostos são específicas. Elas estão relacionadas com as operações corporativas e uma vez configurada a situação de que os

gestores das áreas de Compliance não consigam dar respostas plausíveis às perguntas, isto significará que seu Programa de Compliance não funciona, ou seja; é o um Programa *no papel*.

Através da publicação do *Evaluation of Corporate Compliance Program*, o DOJ reiterou a importância de que os Programas de Compliance sejam efetivos, consolidando as tendências já estabelecidas no Memorando de Yates [230] e Projeto Piloto [231].

Conclui-se assim, que o monitoramento e a avaliação de um Programa de Compliance à luz da nova regulamentação editada pelo DOJ, assume fundamental importância para as empresas, a fim de coibir ilícitos punidos nos termos da legislação americana, posto que uma avalição positiva, conclusiva no sentido de que um Programa de Compliance é efetivo pelo DOJ, revela-se capaz de afastar de forma concreta a culpa da empresa no caso da concessão de uma *Declination* na investigação do caso ou mesmo; mitigar o risco a aplicação de penalidades mediante a adoção de meios alternativos, quais sejam: (i) Os *Non-prosecution Agreements (NPAs)*; e (ii) os *Deffered Prosecution Agreements (DPAs)*, que funcionam como um equilíbrio paliativo entre a opção de deixar de processar a empresa e a de proferir uma condenação criminal, tudo isso após a aferição da efetividade do Programa de Compliance pelo DOJ.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. São Paulo: Atlas, 1996.

ARAÚJO, Francisco J. “Influência dos controles internos no trabalho do auditor independente”. Revista Brasileira de Contabilidade, Brasília, n.121, jan-fev. 2000.

ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS. *Report to the Nations 2018: global study on occupational fraud and abuse*, 2018.

BLOK, Marcella; Compliance e Governança Corporativa, 2ª Edição revisada e ampliada, Editora Freitas Bastos, 2018.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução nº 1.207 de 27 de novembro de 2009. Aprova a NBC TA 240 – Responsabilidade do Auditor em Relação a Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis. Disponível em:< http://www.cfc.org.br>. Acesso em: 25 de outubro de 2018.

CRESSEY, Donald R. The criminal violation of financial trust. American Sociological Review, 15 (6), p.738-743, December, pp.1-15, 1950.

RODRIGUES, José Antonio e MENDES, Gilmar de Melo: Governança Corporativa – Estratégia para Geração de valor: Editora Quality Mark, 2005.

MANZI, Vanessa Alessi, in Compliance no Brasil – Consolidação e perspectivas, 1ª Edição, Editora Saint Paul, 2008.

NEGRÃO, Celia Lima; PONTELO, Juliana de Fátima, in Compliance, controles internos e riscos: a importância da área de gestão de pessoas, 2ª edição revisada e ampliada, Editora Senac, 2017.

NEVES, Edmo Colnaghi, in Compliance Empresarial – O tom da liderança, São Paulo, 1ª Edição, Editora Trevisan, 2018.

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. *Normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna*. Florida, 2017, p. 21-22.

VERÍSSIMO, Carla, in Compliance incentivo à adoção de medidas anticorrupção, 1ª Edição, Editora Saraiva, 2018.

Capítulo 14

Tomada de Decisão [Ética]

Alexandre da Cunha Serpa[232]

Introdução

No domínio do *compliance* os temas ética e integridade têm tomado um lugar de destaque nas discussões entre os profissionais da área e também dentro da sociedade como um todo e, apesar de serem temas extremamente complexos, têm sido tratados com uma simplicidade muito grande, o que pode vir a causar tanto um enfraquecimento da relevância que têm, como também algumas abordagens bastante simplórias e negativas para o campo de *compliance* como um todo. Um dos motivos para essas abordagens vagas e simplistas é a popularidade do tema nos meios de comunicação e, talvez, o apelo populista da palavra *ética* no momento do país. Quem irá ter coragem de discutir, e discordar, de alguém que diz que *sempre há uma decisão certa*, que *a ética é uma só*, ou ainda *ou você tem ética ou não*? Poucos teriam essa coragem, por mais certos que estivessem ao dizer que *não, não é tão simples assim*.

Eu mesmo já resumi que *compliance* é 'fazer o certo porque é o certo a se fazer', ou algumas variações desta afirmação. Mas, depois de estudar, viver e discutir um pouco mais o tema, entendi que há muito mais nuances no tema do que gostaríamos, ou do que nos deixaria confortáveis. Talvez seja essa a palavra mais importante a pensarmos enquanto discutimos o tema: *confortável*, ou na verdade, seu oposto *desconfortável*. Desconfortáveis é como nos sentimos ao entendermos e aceitarmos que o mundo, os seres que nele habitam e suas ações, são bastante menos simples, puros, éticos, altruístas ou bondosos do que gostaríamos que fossem. Não adianta, apenas por desconforto, fecharmos nossos olhos às realidades e verdades. Temos que aceitar a realidade e tomar as ações necessárias para melhorarmos os seus aspectos que podem ser melhorados.

Um outro ponto relevante quanto a tomadas de decisão [éticas] é a ilusão de que sempre há uma decisão certa e uma errada e o processo decisório seria apenas escolher entre uma das duas opções. Apesar de, por raras vezes, nos deparamos com este cenário simples de certo contra errado, a nossa realidade rotineira é bastante mais complicada e cenários em que mais de uma opção certa existem são bastante comuns. Como também são comuns os cenários em que não há nenhuma decisão certa, ou, em resumo, cenários em que temos um dilema, para os quais a opção de não se tomar nenhuma decisão não existe. Adicionemos ao acima que a própria definição de CERTO [ou ÉTICO] não são nem óbvias, nem simples, nem democráticas - e tampouco universais - e teremos que qualquer forma de simplificar o tema estaria incorreta.

Decisões de negócios são sempre tomadas utilizando-se algum método, ou ferramenta, que suporta o processo de decisão, tanto organizando as informações quanto calculando-se qual seria a melhor decisão em relação a outras. Ou seja, as decisões não são tomadas apenas com base em crenças -- ao menos é assim que os processos decisórios deveriam ser -- mas sim com base em obtenção de informações acerca da decisão e dos cenários em que a decisão é implementada [ou não], organização dessas informações, algum tipo de ranqueamento ou ponderação e, somente então, toma-se uma decisão. Como apenas um exemplo temos os métodos de cálculo de Valor Presente (*NPV - Net Present Value*) de projetos ou investimentos.

Mesmo métodos *matemáticos*, como o cálculo de valor presente de investimento, têm suas limitações e não são puramente quantitativos, levando em conta também fatores qualitativos e sempre com assunções e estimativas sobre o futuro (*assumptions and estimates*), estimativas em relação a variáveis e algum tipo de *probabilização* dos diversos cenários possíveis. Penso que o mesmo deveria ser feito em relação à dimensão "ética" das decisões. Assim, a ideia básica deste material é propor um método para que os tomadores de decisão possam reconhecer os pontos relevantes envolvidos em uma decisão a ser tomada, para que possam organizar as informações e que, ao final, tenham uma visão abrangente dos diversos aspectos que compõem o processo decisório. O foco estará em tentar direcionar a pessoa que tomará a decisão para que ela possa ir elaborando um racional que leve em conta os potenciais diversos interessados (*stakeholders)* na sua decisão e também os impactos da decisão em cada um destes interessados. Passaremos pela introdução, bastante sucinta, de alguns temas mais filosóficos e, ao final, tentarei definir o processo de tomada de decisão [ética].

Devemos ter em mente que o método proposto não é em si uma novidade, mas apenas uma consolidação de alguns temas de uma forma [espero] didática e organizada. Também, não devemos entender que toda e qualquer decisão é de tal forma complexa que precise passar pelo método e, tampouco, que ao passar por ele uma decisão seja magicamente transformada em simples, fácil ou correta. Tampouco devemos assumir que este método seria utilizado isoladamente de outros, posto que a dimensão *ética* da tomada de decisão é apenas mais uma dentro de diversas outras (como a financeira, por exemplo).

1. O que é certo?

Comentei anteriormente que existe uma ilusão coletiva de que sempre há uma decisão certa e uma errada e que, para sermos éticos, nos basta escolher a certa – mas acredito que todos nós que já vivemos um pouco sabemos que isso não reflete a realidade. Complementei dizendo que a própria definição de CERTO [ou ÉTICO] não são nem óbvias, nem simples, nem democráticas e tampouco universais, dificultando ainda mais definirmos o que seria uma decisão certa, ou ética.

Pois bem, definir o que é uma decisão ética, certa, correta ou moral não é algo que tentarei fazer, uma vez que pessoas muito mais capacitadas que eu já o fizeram, ou, ao menos, criaram conceitos que nos ajudam a enquadrar as decisões em alguns parâmetros que *podem indicar* a moralidade, ética ou correção da decisão, ou do(s) ato(s) dela resultante(s). Assim, utilizaremos duas das abordagens mais conhecidas para a discussão da moralidade de um ato, a *universalidade* (ou a moral Kantiana) e o *utilitarismo*.

Sem a intenção de passar no crivo de um filósofo ou outro estudioso dedicado ao tema, resumo as duas abordagens, pensando no propósito de utilizá-las futuramente nas etapas do método de tomada de decisão como sendo:

- *UNIVERSALIDADE* – uma ação é boa, moral, ou ética, se puder ser transformada numa regra aplicável a todos os agentes do ambiente (ou seja, quase que a regra de ouro – *não fazer a outrem o que não gostarias que fizessem a ti*);
- *UTILITARISMO* – uma ação é boa, moral, ou ética, se trouxer mais benefícios a um número maior de entes, ou se, ao contrário, reduzir os malefícios (em intensidade ou que sejam a um número menor de entes).

De uma forma geral o que temos acima é uma redução da análise da ação à análise de seus resultados reais e/ ou percebidos por todos os entes e agentes de um sistema, ou seja, uma ação seria boa, moral ou ética se assim fossem os seus resultados. Deixamos, assim, de lado a discussão de se uma ação é boa, moral ou ética em si, posto que, num contexto prático como aquele a que as nossas empresas estão expostas, a mera [boa] virtude da ação, ou da intenção da ação, não são garantias de que os resultados práticos, reais e tangíveis da ação sejam, também, virtuosos, bons, morais ou éticos.

Apenas como um exemplo ilustrativo rápido do motivo de o exposto acima ser importante: matar um outro ser humano é uma ação, em si, reprovável, ruim, imoral e antiética. Mas se a discussão passar a ser sobre matar alguém que está assassinando outras pessoas (um atirador dentro de uma escola, por exemplo) e, assim, salvar um número maior de vidas, a ação passa a ser vista como correta ou, ao menos, aceitável.

Uma boa forma de ilustrar a real complexidade em relação à discussão sobre o que é certo, bom, moral, ou ético, é investirmos cinco minutos e respondermos aos cenários de decisão em relação a carros autônomos do projeto *Moral Machine* do MIT[233] - por favor vá para http://moralmachine.mit.edu selecione o menu *judge*, responda aos 13 cenários apresentados (com calma, reflita bastante sobre o que seria o certo, ou ético, a se fazer em cada cenário) e ao terminar de responder aos casos analise os resultados com atenção e responda a você mesma se/ que:

- ainda acredita que há sempre apenas uma escolha certa, ou ética?
- há sempre uma forma de se levar todas as informações em conta ao tomar uma decisão (ou se houve algum parâmetro que você nem percebeu que poderia ser considerado)?
- se você conseguiu eliminar todos os potenciais vieses de sua decisão ou se suas decisões tiveram consequências não intencionais?

Uma outra forma simples de ilustrar a diferença entre *utilitarismo* e *universalidade* seria utilizando o cenário do *trolley problem*[234] em que um trem em movimento atropelaria quatro pessoas amarradas nos trilhos, mas você poderia desviar o trem para matar apenas uma pessoa que está amarrado no outro ramal dos trilhos.

Do ponto de vista do *utilitarismo* a resposta seria simples: desvie o trem e salve a vida de um total de três pessoas. Mas, se pensarmos na *universalidade* se poderia colocar a pergunta: você tomaria essa decisão – de matar a pessoa que estava *segura* no outro ramal dos trilhos – utilitária mesmo que a pessoa a morrer fosse um familiar seu?

Ainda como exercício de aquecimento imagine qual seria a resposta *certa*, ou *ética*, para as quatro situações a seguir:

- De forma geral, você acredita que a doação de órgãos é algo que deveria sempre ocorrer?
- Você doaria os órgãos de um familiar próximo para salvar uma vida?
- Você doaria os órgãos de um familiar próximo para salvar a vida de um assassino?
- Você doaria os órgãos de um familiar próximo para salvar a vida do assassino deste mesmo familiar?

O que esses exemplos ilustram é apenas o fato de que nossas decisões levam em conta muito mais do que fatos isolados, que nosso processo decisório é influenciado por emoções, que somos também [muito] influenciados por nossos valores (sejam familiares, religiosos ou outros) e que simplificar a tomada de decisões como algo universal é, além de errado, perigoso.

2. Quero? Posso? Devo?

Uma maneira comum de resumirmos o que uma tomada de decisão ética significa é usar o padrão do “Quero? Posso? Devo?” e esse padrão será o ponto de partida para elaborarmos o método deste livro.

2.1. Quero?

Ao pensarmos em uma decisão a primeira pergunta que precisamos responder é se queremos mesmo fazer algo (ou deixar de fazer algo) e podemos pensar que se uma decisão precisa ser tomada a resposta ao questionamento *quero?* é simples e óbvia. Mas podemos destrinchar um pouco mais a realidade da tomada de decisão e lembrar que nem sempre *querer* existe no sentido de *tenho vontade de,* pois podemos, também, nos deparar com situações em que a tomada de decisão é sobre uma **necessidade** e não simplesmente sobre uma **vontade**. Ainda, a tomada de decisão pode ser resultado de uma **obrigação**.

Assim, temos três cenários possíveis em cena: a vontade, a necessidade e a obrigação.

O impacto disto para o processo de tomada de decisão é que, para uma simples vontade a inação é uma opção clara e factível, enquanto que o mesmo não é verdade para o caso de uma obrigação e, para o terceiro cenário, o da necessidade, temos a possibilidade de uma abordagem mista. Ou seja, se durante o processo de análise e composição da decisão nos deparamos com um resultado negativo com o qual não nos sentimos confortáveis essa primeira variável do *quero* poderá nos ajudar a decidir o que [não] fazer em alguns casos; como os da pura vontade, ou o da necessidade menos premente; mas não será tão relevante no caso da obrigação, uma vez que em sendo *obrigado* a realizar uma certa ação, nos resultaria não real o cenário de não realizá-la.

2.2. Posso?

A segunda pergunta se refere à nossa possibilidade de fazer algo. Em outras palavras se temos a permissão de fazer algo ou, ao menos, se não há uma proibição para aquela ação. Uma pergunta que tem um foco puramente formal, ou legal, e que, felizmente, quase sempre tem uma resposta bastante clara e direta. O lado complexo desta pergunta se refere ao fato de haver níveis distintos a serem considerados.

Inicialmente, devemos considerar o nível legal externo, ou seja, as leis e regulamentações do local – ou locais - em que a decisão precisa ser tomada e implementada. Nesta etapa o suporte necessário ao processo de tomada de decisão vem dos departamentos jurídicos e regulatórios (em sendo aplicável) de nossas instituições.

Posteriormente, consideraremos o nível da autorregulação, ou seja, todo e qualquer instrumento regulador ou código de atuação, ética ou conduta de entidades de autorregulação, associações de classe ou indústria e similares que são, por vezes, de adoção voluntária por parte das instituições - mas lembremos que ao adotar um compromisso, mesmo que voluntário, devemos, enquanto instituição, passar uma mensagem clara de integridade e não ficar escolhendo partes ou situações de tais documentos que cumpriremos ou não. Nesta etapa o suporte ao processo de tomada de decisão pode vir de distintos departamentos de nossa instituição, a depender do escopo ou tópico da autorregulação.

Finalmente, chegamos ao nível das políticas internas de nossa instituição, que englobam todos os documentos internos que regulam o assunto, ou processo, ou objeto da decisão que está sendo avaliado. Como há uma variedade enorme dos tópicos das decisões há o potencial de precisarmos do suporte de diversas outras áreas da instituição para conhecer, entender e aplicar as regras internas na análise da decisão em questão.

Pensando puramente no processo de tomada de decisão em relação ao *Posso* nos depararemos então com as seguintes respostas (ou composições das mesmas) possíveis:

- Uma clara proibição legal ou regulatória;
- Uma clara proibição de autorregulação;
- Uma clara proibição nas políticas internas;
- Uma clara permissão, ou nenhuma proibição, em cada um dos níveis;
- Possíveis casos de falta de clareza, ou de interpretações conflitantes em algum nível de regulação.

Para o primeiro caso o caminho a tomar em relação à decisão em pauta deveria ser óbvio e nenhum debate, nesta etapa, deveria ser necessário posto que uma clara proibição legal ou regulatória deveria ser motivo suficiente para que a decisão fosse imediatamente descartada (não é objeto deste material focar na discussão do *tom do topo* na organização e assumirei que estamos discutindo os cenários dentro da realidade de uma empresa que tenha o compromisso mínimo com o cumprimento de instrumentos legais e regulatórios).

Já para o segundo caso existem possibilidades alternativas, posto que pode haver a opção de uma instituição deixar de participar de alguma autorregulação, ou do grupo a que se aplica tal documento. Neste caso, muitos pensarão, de forma maniqueísta, que uma vez tendo firmado compromisso com uma autorregulação uma instituição não estaria sendo ética, ou correta, em se retirar de tal compromisso apenas por interesses próprios ou pontuais - anteriormente eu citei que uma instituição não deve ficar escolhendo partes da autorregulação que a interessam ou o quando ela segue ou não a autorregulação, e isso está mantido. Mas pode a instituição decidir deixar de ser signatária de uma autorregulação de forma clara e definitiva. Acontece que uma instituição é livre para, face a novas realidades ou informações ou necessidades, reavaliar suas decisões passadas e, em havendo essa possibilidade, alterar o rumo de sua decisão anterior. Claro que uma decisão deste tipo poderá trazer impactos negativos em relação a imagem e reputação da instituição, e estes impactos deverão ser integrados ao processo decisório (em uma das etapas seguintes, quando avaliamos os impactos positivos e negativos da decisão em diversos níveis). Mas não devemos ser simplistas a ponto de crer que uma organização não possa voltar atrás em uma decisão anterior apenas pelo fato de que essa decisão, enquanto uma opção lícita e existente dentro das regras, esteja criando perdas para a organização.

Uma situação semelhante se apresenta em relação ao próximo caso, ou seja, a proibição por políticas internas. Posto que sendo as políticas internas frutos de decisões anteriores da própria instituição estas podem ser revistas e adaptadas a novas realidades ou necessidades. Por óbvio, temos que alterações de políticas internas não devem ser realizadas de forma promíscua e com objetivos escusos, mas se a situação assim o requerer e sendo o benefício futuro para a instituição maior que potenciais malefícios, não há proibição de se alterar estes documentos. Desnecessário dizer que devemos sempre ter em mente a legalidade da alteração, seu alinhamento com políticas das casas matriz quando estamos no nível da filial ou controladas de grupos maiores e o impacto que essa

alteração possa causar na percepção dos próprios funcionários da organização em relação a sua conduta e seus valores.

O cenário de clara permissão, ou nenhuma proibição, em cada um dos níveis é o mais simples, posto que não cria óbice para que passemos diretamente para as próximas etapas do processo decisório.

Já o cenário de falta de clareza, ou de interpretações conflitantes em algum nível de regulação traz um nível adicional de iteração ao processo (e potencial demora) pois cria a necessidade de uma avaliação adicional ou de obtenção de opiniões de especialistas, internos ou externos, caso se tenha optado por manter a decisão em discussão. Quando há falta de clareza, ou potenciais interpretações conflitantes, é importante não se deixar levar pelo lugar comum de deixar que leigos no tema, ou que pessoas com potenciais conflitos de interesses, tomem as decisões sozinhas, uma vez que tenderão a ignorar, ou a subavaliar, os reais riscos envolvidos (quantos de nós já não passamos pelo *eu assumo o risco* dito pela pessoa que mais interesse tem em que a decisão seja aprovada?!). O envolvimento de especialistas nestas situações é muito importante para que o processo de decisão seja *informado* e o mais profissionalmente conduzido possível e qual o especialista a ser envolvido depende da dimensão, complexidade e riscos potenciais da decisão em pauta, podendo significar desde uma simples consulta a uma gerência técnica da instituição até a obtenção de opiniões legais de dois escritórios de advogados distintos. Nestes casos também é importante ter em conta que ao deixarmos *para a última hora* certas discussões, estaremos limitando a capacidade da organização de avaliar os diferentes cenários e isso tenderá a aumentar a possibilidade de que a tomada de decisão seja influenciada por aqueles que gritam mais alto, ou que colocam argumentos mais apocalípticos (*se perdermos essa conta a empresa pode quebrar*).

2.3. Devo?

A terceira, e, sem qualquer sombra de dúvida, a mais difícil de todas as perguntas se refere àqueles aspectos menos técnicos, por vezes menos tangíveis, e menos calculáveis que aqueles relacionados às duas perguntas anteriores. O *Devo* é o passo durante o qual podemos discutir os *valores* (morais e não morais, se é que tal divisão possa ser pensada) relacionados tanto à ação e seus efeitos, quanto aos indivíduos envolvidas na ação e na tomada de decisão, e quanto aos entes menos tangíveis envolvidos, que são as instituições e a sociedade que serão influenciados, e influenciarão, pela decisão (em resumo, para facilitar a discussão e o processo da escrita, podemos nos referir aos entes de uma forma geral como *stakeholders,* ou partes interessadas). Também, é o momento no qual pensamos em cultura, pensamos no *zeitgeist,* pensamos no ambiente, pensamos no *todo* envolvido tanto na decisão quanto nos potenciais resultados da ação [ou da inação, que é, por si, uma decisão possível no processo e não deixa de ser uma ação]. Neste momento, também, vem à tona um dos problemas inerentes a esta etapa da tomada de decisão: a definição da dimensão *todo* – que é, por sua vez, consequência da definição do que são a *sociedade,* as *instituições,* ou, coletivamente, as ***partes interessadas*** – uma vez que é impossível considerar, realmente, TODOS os interesses de TODAS as partes interessadas em uma decisão, temos que, naturalmente, limitar essa análise àquilo que é, simultaneamente, possível do ponto de vista das restrições de tempo, conhecimento e recursos, e minimamente abrangente para que não deixemos de fora os agentes e partes interessadas que são *obviamente* (coloco a palavra entre aspas por saber de sua inerente limitação, me refiro ao óbvio como aquilo que uma pessoa medianamente capaz e informada consideraria como tal), relevantes, envolvidas na ou impactadas pela decisão (ou seja, uma questão de balanço, ou *trade-off*, entre factibilidade, relevância, suficiência e agilidade).

Discutir o *devo* é, resumidamente, tentar identificar os efeitos e os resultados de curto e de longo prazo que a tomada da decisão terá em relação a cada uma das partes interessadas, incluindo-se, naturalmente, a própria instituição em seus distintos níveis – funcionário, departamento, empresa como um todo (ou a pessoa física, caso estejamos discutindo uma decisão pessoal e não uma decisão corporativa, pois esse método pode ser aplicada a ambos, mas manterei o foco no corporativo), levando-se em conta diversas dimensões de mensuração – financeira, reputação, longevidade, *market share*, posicionamento etc., sob diferentes óticas para que a decisão não seja tomada com uma limitação que pode ser chamada de *Narrow Framing*[235], ou, em tradução livre “Perspectiva Limitada”.

Para evitarmos que a tomada de decisão seja vítima da armadilha da perspectiva limitada, que é natural a todos nós, pois muitos dos nossos processos cognitivos – pessoais e profissionais –

acontecem de forma automática (o que inclui o *Sistema Um*[236] como citado no livro *Thinking, fast and slow*[237] do Prof Daniel Kahneman) e, também, dentro de alguns modelos simplificados da realidade: os *schemas* (ou *cognitive frames*[238]) que nos ajudam a interpretar a realidade e que fazem o que vemos, lemos ou experimentamos fazer sentido. Essa realidade do nosso processo de tomada de decisão serve para tornar nossa vida possível, alocando recursos [mentais] de maneira em que sejam necessários e economizando os mesmos sempre que uma decisão puder ser tomada de forma simples e/ ou automatizada.

Fazemos isso o tempo todo em todas as dimensões de nossas vidas, seja ao avaliar uma decisão financeira, seja em relação a entender o que estamos assistindo à nossa frente, seja para avaliar se devemos confiar em uma pessoa ou não. Por outro lado essa simplificação e esse automatismo trazem os malefícios de que nem sempre estamos tomando decisões completamente racionais ou lógicas, mas apenas agindo conforme padrões – conscientes ou inconscientes/ formais ou informais, ou hábitos criados no decorrer de nossas interações com o meio.

Apesar da perspectiva limitada ser natural e parte da vida, ela pode cercear de forma perigosa o que vemos, ou o que levamos em conta, ao tomar uma decisão e isso pode ser crítico se combinado com um contexto que nos leva a ignorar estas limitações por conta de uma outra variável extremamente importante que é o nível de pressão a que os atores da tomada de decisão estão submetidos. Não à toa a pressão é um dos lados do *triângulo de fraude*[239]. Uma pessoa pode ter toda a capacidade de tomar uma *boa* decisão e saber que tem uma perspectiva limitada da realidade relevante, mas se estiver sendo pressionada seja para tomar a decisão em um tempo insuficiente, ou sem o mínimo de informação ou ponderação necessários a decisão será 'não-ótima' ou, potencialmente, negativa.

3. Dimensões a serem analisadas para a pergunta do "Devo"

É claro que, por vezes, uma situação real requer a tomada de decisão rápida e sem informações suficientes. Mas são poucas as vezes em que nos encontramos com algo absolutamente inadiável. Assim, devemos reconhecer que a simples pressa de outrem não é razão suficiente para se tomar decisões emergenciais, mas, infelizmente, no mundo corporativo atual, com seus jargões, simplificações, falácias e maus hábitos temos nos deparado cada vez mais frequentemente com pares ou superiores que acreditam que tudo é uma emergência, que todos devem sempre concordar e/ ou que tudo precisa sempre ser resolvido o mais rapidamente possível (ao custo de se você for aquela que busca – quando cabível - chamar a atenção de todos para que a cada caso cabe um ferramental distinto, um tempo próprio e uma ponderação proporcionais, acabará sendo acusada de *não jogar no time*, de *criar dificuldades em tudo*, de ser *a chata* ou *o chato*).

Apenas como um acordo entre nós para a leitura do trecho seguinte assumamos que estamos falando das situações importantes mas não emergenciais (apesar de que, todo o modelo poderá sim ser aplicado em situações emergenciais, desde que tenhamos já criado o hábito e que não tentemos tornar a ferramenta mais importante que o trabalho a ser realizado).

Para evitar as [algumas das] armadilhas acima temos que nos **habituar** a tomar decisões de forma estruturada, com tempo e informação suficientes dentro de uma modelo estruturado que nos ajude a identificar, ou relembrar, as dimensões que sejam relevantes no processo. A seguir, listo algumas dessas dimensões:

- **Tempo** – todas as decisões que tomamos terão resultados de curto e longo prazo.
- **Entidades** – as decisões produzirão efeitos em diversos níveis *físicos*, iniciando-se pela profissional que toma a decisão, passando pelo departamento ou área da instituição, chegando na própria instituição e também nas instituições externas (como a sociedade de forma geral, fornecedores, clientes, concorrentes, governos, reguladores etc.).
- **Métricas de Interesse** – uma decisão tomada traz mudanças em um ou mais resultados ou métricas das entidades, sejam elas financeiras (como lucro, fluxo de caixa, bônus), de performance (como *market-share*, ticket médio), de reputação (como rejeição da marca/ instituição, número de menções negativas na mídia), de bem-estar (como grau de satisfação com o trabalho, diversidade/ inclusão) ou outras que se fizerem relevantes para a instituição ou decisão em questão.

De forma geral o que tentaremos com a inclusão destas dimensões no processo de tomada de decisão é buscar tornar a decisão o mais abrangente possível no que tange aos efeitos de colocar a decisão em prática e *todas* as possíveis esferas que serão impactadas com os resultados da ação, tanto no curto quanto no longo prazo, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do reputacional, tanto para a empresa como quanto para a sociedade. Algo próximo do que nossos contemporâneos professores e filósofos como Cortella, Karnal e Clóvis de Barros definem como **ética**, que é algo como *a convivência harmoniosa* ou *a busca pelo bem comum* – então uma decisão ética é uma decisão que traz o melhor resultado para a maior quantidade possível de partes interessadas.

4. Documentando e Julgando os Efeitos Potenciais da Decisão nas Dimensões

As três dimensões acima deverão ser utilizadas para organizar todos os resultados potenciais da tomada da decisão (ou até da não tomada da decisão) e cada um destes resultados precisará ser julgado em relação a ser *positivo* ou *negativo* (dentro daquela métrica, para aquela entidade no curto e no longo prazo). Após se avaliar cada uma das dimensões fazemos uma *soma* dos resultados e tomamos uma decisão *ética*.

Como não existe uma decisão ética para podermos analisar a decisão (após termos avaliado todas os componentes da decisão) levando em conta o apetite de risco da organização e o conjunto de seus Valores, Missão e Visão, que serão, ao final, os reais direcionadores da decisão, servindo como a métrica mais importante e como os *tie-breakers* de cenários em que há a possibilidade de tomarmos decisões distintas e que não são semelhantes em termos de resultados externos ou a terceiros.

Conclusão

O método não nos dirá quais são as dimensões de métrica/ resultados são necessárias, nem como ponderar os pesos de cada uma das dimensões (temporal, métricas de interesses, partes interessadas), muito menos de como avaliar se um resultado é positivo ou negativo, pois a intenção por trás deste método é nos ajudar a **organizar o processo**, a **lembrar das dimensõ**es, a **buscar pensar não somente na decisão e seus resultado**s, mas, também, nas **motivações**, nas **possibilidades**, nas **limitações**, nos efeitos e nos **aspectos menos tangíveis** do processo e não tomar a decisão em nosso lugar. O método tenta nos ajudar a *ver* a decisão e seus efeitos, mas a decisão em si continuará a ser tomada por nós, seres humanos, ainda com todas limitações potencialmente relevantes e, talvez o mais importante, podendo ser questionada no futuro por qualquer outro profissional, ou ainda, por reguladores ou pela justiça (como diz o ditado americano *hindsight is always 20/20*).

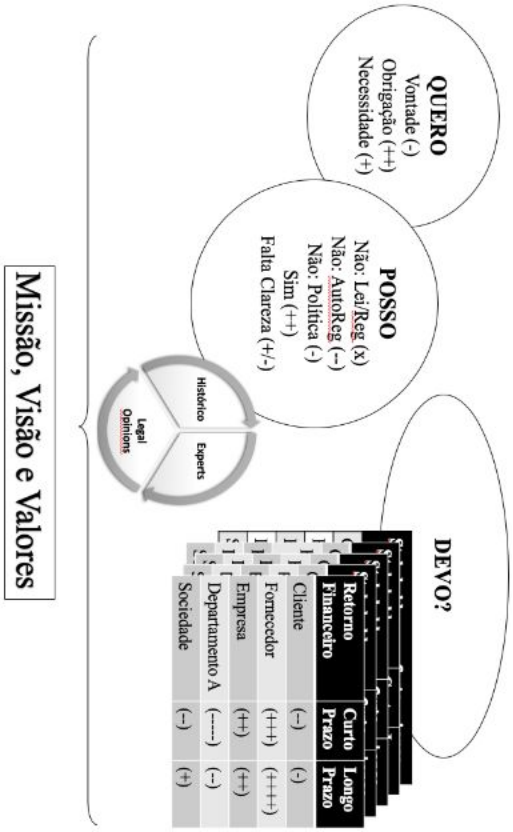


Figura 1 – Representação gráfica do processo de tomada de decisão [ética].

Referências bibliográficas

KAHNEMAN, Daniel; EGAN, Patrick. *Thinking, fast and slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. *Moral Machine.* Disponível em <http://moralmachine.mit.edu>. Acesso em 15 out. 2018.

PALAZZO, Guido; KRINGS, Franciska; HOFFRAGE, Ulrich. Ethical blindness. *Journal of Business Ethics*, v. 109, n. 3, (2012), p. 323-338. Disponível em <https://www.researchgate.net/publication/256046104_Ethical_ Blindness>. Acesso em 15 out. 2018.

WIKIPÉDIA. *Dual process theory*. Disponível em < https://en.wikipedia.org/wiki/Dual_process_theory>. Acesso em 15 out. 2018.

_____. *Framing (social sciences).* Disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/Framing_(social_ sciences)>. Acesso em 15 out. 2018.

_____. *Fraud Triangle.* Disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/Fraud_deterrence#Fraud_Triangle>. Acesso em 15 out. 2018.

_____. *Dilema do Bonde*. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_bonde>. Acesso em 15 out. 2018.

Capítulo 15

a importância dos Sistemas de Integridade
na Prevenção ao Assédio Moral

Marcelo Zenkner[240]
Patrícia Punder[241]

Introdução

A luta de classes, em sociedades capitalistas, historicamente consubstanciou-se na reivindicação por melhores salários e condições de trabalho. O mundo, entretanto, vem passando por rápidas transformações e os impactos produzidos na sociedade pela velocidade da informação e pelos meios de comunicação altamente sofisticados têm provocado uma profunda modificação no estilo de vida, na conduta, nas atitudes, nos costumes e nos valores que permeiam o tecido social.

Tudo isso produz reflexos imediatos nas relações de trabalho, pois, quando as pessoas se tornam mais conscientes e se mostram mais bem preparadas, elas passam a buscar no ambiente profissional valores capazes de lhes proporcionar felicidade que não necessariamente estão vinculados à questão salarial. Por tudo isso é possível dizer que, atualmente, a remuneração não é mais a principal fonte de insatisfação dos funcionários dentro das empresas.

Mais do que uma remuneração condizente com o que seria justo pelo seu trabalho, os profissionais mais competentes, mais dedicados e mais compromissados desejam ser reconhecidos e valorizados dentro das organizações. Esperam, assim, a retribuição pelo esforço que dispendem em favor da corporação ou instituição a partir de um sistema meritocrático, uma das tônicas de qualquer sistema de integridade empresarial ou governamental.

A ambição pelo reconhecimento é absolutamente natural e deve ser, inclusive, incentivada em qualquer ambiente profissional. É exatamente a motivação decorrente dessa ambição que funciona como combustível para que qualquer funcionário busque o aperfeiçoamento técnico e passe a trabalhar cada vez melhor, aprimorando os resultados da corporação ou instituição à qual se encontra vinculado. Assim, seja na iniciativa privada ou na administração pública, os funcionários ambiciosos devem ser sempre valorizados e protegidos em razão do alto valor agregado que a eles é ínsito.

Os problemas dos funcionários ambiciosos começam quando eles se deparam com colegas gananciosos. A ganância é um vício de caráter própria dos incompetentes e desidiosos, mas que, ainda assim, buscam dar musculatura a suas carreiras às custas do trabalho alheio ou da aniquilação dos concorrentes, normalmente os ambiciosos. A desordem decorrente desse choque, tão comum no dia-a-dia, pode representar a destruição de carreiras e até mesmo da vida de muitas pessoas.

É nesse contexto que se estabelece o cenário perfeito para o assédio moral, que não é um fenômeno novo, mas que vem se repetindo cada vez com mais intensidade, com um potencial cada vez mais devastador e com severos prejuízos para as organizações, que vão desde a queda de sua produtividade até a perda de um funcionário altamente qualificado.

O elefante cor-de-rosa está no meio da sala e são poucos aqueles que têm coragem de enfrentar o assunto.

O presente artigo, assim, tem por objetivo discutir de forma franca essa questão para, ao final, demonstrar como um sistema de integridade não só pode como também deve ser efetivo inclusive para coibir e prevenir esse malefício que atinge instituições e organizações de um modo geral.

1. Caracterização do Assédio Moral e sua Regulação na Legislação Pátria

É fundamental, preliminarmente, caracterizar o assédio moral no local do trabalho, indicando seu conceito, características, causas, formas de desenvolvimento e consequências.

A doutrina conceitua o assédio moral como:

> *[...] a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou*

mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-a a desistir do emprego.[242]

Trata-se de um abuso de poder que pode se manifestar por quaisquer comportamentos capazes de gerar prejuízos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa e, ao mesmo tempo, ainda colocar em risco seu emprego. Como o assédio moral ocorre quando o trabalhador ou funcionário público é submetido a repetidas situações de humilhação, de degradação ou de hostilidade, ele ainda traz como consequência a degradação do ambiente de profissional.

A origem do assédio moral normalmente está no medo ou na inveja de um superior, normalmente menos competente ou capaz que seu subordinado, que acredita que está diante um competidor que precisa ser eliminado a fim de que sua posição seja mantida. Entretanto, as vítimas de assédio moral podem ser também funcionários íntegros que precisam ser extirpados de um determinado setor da empresa exatamente para que atos ilícitos possam ali ser praticados com mais facilidade. Fica fácil perceber, assim, que pode existir uma vinculação direta entre o assédio moral e o controle que deve se estabelecer dentro das organizações.

O fato é que o assédio moral é uma violência totalmente invisível, pois, na maior parte das vezes, apresenta-se de uma forma que, apesar de rotineira, não é ostensiva. Assim, pode-se concretizar por meras insinuações, críticas difusas, não ditos, posturas rudes dentre outros comportamentos sutis e inadequados. O assediador age de forma absolutamente dolosa, mas procura sempre dar uma roupagem de normalidade a sua conduta, buscando fazer com que as providências que adota representem a rotina normal dentro de um ambiente profissional.

Já a vítima não consegue manter o seu potencial máximo, pois fica temerosa, desatenta, menos eficiente e de flanco aberto às agressões persistentes recaem sobre si própria e sobre a qualidade do seu trabalho. O assédio moral é um mal que acompanha a vítima não só no ambiente de trabalho, mas a cada minuto de seu dia, inclusive nos fins-de-semana e horários de descanso, eliminando os momentos de lazer e de prazer que qualquer ser humano tem direito e gerando uma profunda intranquilidade para sua vida pessoal e até para sua família. Como isso, aquele funcionário que antes era competente e compromissado, torna-se inseguro e profundamente vulnerável ao afastamento por doença, por incompetência profissional ou até mesmo por um inevitável erro que acaba cometendo.

Como o assédio moral causa sérios danos à saúde física e mental e prejudica as pessoas em seu desempenho profissional, social e familiar, a Constituição Federal, em seus artigos 5° e 7°, inciso XXX, e a CLT, em seu artigo 483, buscam proteger a integridade do trabalhador no seu direito à intimidade, dignidade, igualdade, honra e vida privada.

2. Sujeitos do Assédio Moral em um Regime de "Mediocracia"

O assédio moral acontece em todo os mercados, independentemente da idade dos envolvidos, do nível educacional, etc. Simplesmente acontece porque existem algumas pessoas preferem a ganância à ambição, outras porque são psicopatas e outras porque são verdadeiramente desonestas.

O sujeito ativo do assédio moral é aquele que, se valendo de todos os meios ilícitos e antiéticos, age com o objetivo de reduzir o seu alvo a uma posição de impotência a fim de que possa, em seguida, destruí-lo com total impunidade. Normalmente é uma pessoa de extrema arrogância, pois dela precisa para esconder sua total incompetência e incapacidade de se aprimorar profissionalmente. Fala-se, em ambientes contaminados por profissionais dessa espécie, em uma "mediocracia":

> *Quando o ignorante se julga igualado ao estudioso, o velhaco ao apóstolo, o falador ao eloquente e o estúpido ao digno, a escala do mérito desaparece num vergonhoso nivelamento de vilania. Isso é a mediocracia: os que nada sabem creem dizer o que pensam, embora cada um deles consiga apenas repetir dogmas ou auspiciar voracidades. Esse achatamento moral é mais grave que a aclimatação à tirania; ninguém pode voar onde todos se arrastam. Convenciona-se chamar de urbanidade a hipocrisia, de distinção a efeminação, de cultura a timidez, de tolerância a cumplicidade; a mentira dá margem a denominações equívocas. E os que assim mentem são inimigos de si mesmos e da pátria, desonrando nela seus pais e seus filhos, corroendo a dignidade comum.*[243]

A conduta do assediador é sempre dolosa e, devido sua posição na empresa, tem ele a expectativa de que não sofra nenhuma consequência em razão de seu comportamento ilícito. O sujeito ativo do assédio moral é um profissional ganancioso que sabe que, no ambiente laboral, sempre haverá um grupo de pessoas interessado na manutenção das posições, dos benefícios e das comodidades e que, por isso, jamais aceitará a ocorrência de um assédio moral.

Já a vítima do assédio moral (servidor público, empregado de empresa estatal ou privada, terceirizado ou estagiário) é, normalmente, um profissional responsável, qualificado ou que busca qualificar-se, profundamente eficiente e incansável em suas atividades laborais. Acredita na empresa ou na instituição à qual encontra-se vinculado e, por isso, crê que sua ascensão profissional depende única e exclusivamente do seu esforço pessoal e ocorrerá naturalmente.

Não vê problemas em dividir os resultados do trabalho que realiza com seus colegas e, principalmente com sua chefia, deixando, inclusive, de registrar sua produtividade pessoal em prol da equipe. Se torna, assim, um incômodo para os colegas de trabalho menos capazes que não conseguem acompanhá-lo, os quais ficam expostos em termos comparativos, e também para a chefia imediata, que se sente ameaçada diante do alto grau de excelência do trabalho de um pretenso assediado.

A inveja e o temor associados e canalizados em desfavor da vítima do assédio moral acabam fazendo com que se forme um complô com objetivos comuns, o qual buscará incessantemente transformá-la em um profissional desqualificado ou causador de problemas. Nesse sentido, factoides são criados e jargões corporativos são utilizados com o objetivo de frear a escalada profissional do assediado.

É interessante notar que a vítima de assédio moral, dada sua crença e responsabilidade para com o trabalho, demora a perceber que foi posicionada como alvo a ser eliminado no ambiente de trabalho, dada a sutiliza com que se inicia o processo de assédio moral, como se demonstrará a seguir. Isso a coloca em posição de imensa desvantagem, pois somente inicia uma reação depois que um longo tempo de deflagração da violência contra si própria.

O *Chief Compliance Officer* pode aparecer como sujeito ativo do assédio moral?

É claro que existe muita pressão para que o negócio dê lucro rapidamente. Por isso, muitos CEO's entram em uma empresa já preocupados em dar resultado em, no máximo, dezoito meses. Por isso, infelizmente ainda não é comum entre a grande maioria dos executivos um apoio real aos sistemas de integridade e seus times. Se a meta não for batida, os acionistas reclamarão por não terem recebido os dividendos prometidos e, muitas vezes, a culpa acaba recaindo nos departamentos de compliance (*Preventing Sales Department* ou *Comitê Anti-Vendas*, como debochadamente são apelidados).

Nessa linha, é natural que um CEO passe a buscar profissionais pensam como ele – estudos de psicologia demonstram que as pessoas tendem a contratar funcionários que normalmente pensam parecido e que têm comportamentos sinérgicos aos do contratante. A consequência disso é que o Chief Compliance Officer fará parte do time do CEO e tenderá a pensar ou, pelo menos, disfarçará que concorda e que pensa como o CEO, se quiser sobreviver e se manter em seu emprego por mais tempo.

Sendo assim, se um determinado *compliance officer* começa a atuar em uma empresa e verifica que a empresa não possui uma cultura de integridade ou não tem interesse de fato em implementar essa cultura, este profissional estará realmente em uma situação delicada. Imaginemos que o *compliance officer*, ao realizar o check in the box dos pilares de compliance, descobre uma situação de fraude ou corrupção. Quando tal fato for levado ao conhecimento Chief Compliance Officer, a primeira resposta será que nada ocorreu e que o *compliance officer* deverá checar tudo novamente, pois, com certeza, cometeu algum um erro. Posteriormente, realizadas as novas checagens, virá o bom e velho discurso no sentido de que "aquilo sempre foi feito daquele jeito" e que já ocorreram inovações, mas elas não deram certo ainda.

Neste momento, o *Chief Compliance Officer* já considera o colega local como um "causador de problemas" e que, por essa razão, deverá ser afastado daquela função para não prejudicar os "negócios da empresa".

Se o eficiente *compliance officer* descobrir novas irregularidades e resolver fazer sugestões ao negócio para melhorar os controles, aí então o Chief Compliance Officer precisará tomar providências mais enérgicas, deflagrando o processo de assédio moral contra seu subordinado: ofensas sutis, perda de funções, afastamento de reuniões, avaliação ruim e, finalmente, a demissão. Isso se o próprio

profissional não tiver pedido antes sua própria demissão, dada a pressão, a sobrecarga emocional e stress corporativo.

Pode o *compliance officer* oferecer uma denúncia contra o Chief Compliance Officer ao CEO ou ao *Board* (dependendo de que entidade o Departamento de Compliance responde hierarquicamente)? Sim, isso pode acontecer. Se a empresa estiver permeada pela cultura da integridade, ambos serão afastados e uma investigação independente será realizada por um escritório externo). Por outro lado, se a empresa não for íntegra, ocorrerá apenas uma investigação de faz de conta e, ao final, o *compliance officer*, vítima do assédio moral, será demitido.

Importante ressaltar que também não existem parâmetros técnicos para avaliar se o assédio contra os *compliance officers* vem aumentando ou diminuindo. Esse tema ainda é muito pouco discutido no mundo corporativo e, no fim do dia, é mais conveniente para todos alegar que o profissional simplesmente decidiu mudar de emprego. Diante da possibilidade do profissional ficar alijado do mercado de trabalho, há ainda um grande temor em se denunciar essa espécie gravíssima (e rotineira) de assédio moral.

3. Fases do Assédio Moral

Quando o assédio moral é praticado pelo empregador, por chefes e por superiores hierárquicos, ele é denominado de "vertical", mas também pode ser praticado por colegas do mesmo nível hierárquico ("assédio moral horizontal"). Seja de que maneira for, o assédio moral é um processo dinâmico que evolui ao longo tempo em que a vítima é exposta a comportamentos ilícitos e ostensivos, cuja intensidade vai aumentando até atingir o seu objetivo.

Nesse sentido, o processo evolutivo do assédio moral costuma ser subdividido em quatro fases: 1ª) Fase do incidente crítico; 2ª) Fase de assédio ou estigmatização; 3ª) Fase de intervenção por parte da organização; 4ª) Fase de marginalização ou de exclusão.

É normal que nas empresas surjam conflitos interpessoais devido à diferença de interesses. Devido a isto surgem problemas que podem solucionar-se de forma positiva através do diálogo ou que, pelo contrário, podem constituir o início de um problema mais profundo. Esses conflitos – chamados de "incidentes críticos" –, que poderiam ter sido resolvidos de uma forma simples e imediata, mas que acabam se mantendo diante da ausência de uma adequada gestão por parte da chefia, representam exatamente a primeira fase do processo evolutivo do assédio moral.

Na segunda fase, chamada de assédio ou estigmatização, o assediador, percebendo que não há qualquer controle sobre sua conduta, passa a colocar em prática toda a sua estratégia de humilhação da vítima, utilizando uma série de comportamentos inadequados cuja finalidade é rotular e isolar socialmente a vítima. Nesta fase, os comportamentos de assédio, que antes se estabeleciam por um *modus operandi* indireto e sútil, assumem um caráter muito mais agressivo e explícito. "Da honestidade convencional se passa à infâmia, gradualmente, por leves nuances e concessões sutis", diria José Ingenieros[244].

É a partir desse momento que o trabalhador ou o funcionário público passa a ser adjetivado e repelido pelo assediador, que faz questão de que sua postura seja, inclusive, de pleno conhecimento dos colegas de trabalho da vítima, não apenas para que estes se afastem do assediado, mas também para que os mesmos se acomodem em suas posições para evitar que o mesmo tipo de represálias recaia sobre si próprios.

Isso faz com que a vítima do assédio moral passe a sofrer da "síndrome do leproso", pois seus colegas de trabalho preferem manter absoluta distância por temerem ser vistos conversando ou simplesmente na companhia do alvo do assediador. A crueldade dessa fase está exatamente em seu lapso temporal prolongado, que vai minando as resistências do assediado e vai tornando sua vida absolutamente insuportável.

Na terceira fase, o conflito que, até então, era conhecido e tratando apenas em um setor específico da organização, chega ao conhecimento da alta direção da empresa ou da instituição. O correto, neste momento, seria a realização de uma investigação séria, imparcial, ética e exaustiva dentro do setor de integridade governamental ou empresarial, adotando-se providências para sanar o conflito e, se for o caso, para punir o assediador.

O problema se agrava quando a alta direção decide proteger o assediador e passa a vítima do assédio como um problema a ser eliminado, tornando-se cúmplice do conflito, ou quando a origem do assédio está exatamente nos mais altos postos do poder da empresa ou da administração pública. Quando isso acontece, o assediado começa a sentir imensa dificuldade em lidar com os efeitos que o assédio traz para sua saúde.

Não sou poucos os casos de vítimas como sintomas de estresse, depressão, irritabilidade, ansiedade, esgotamento profissional, fadiga crônica, alcoolismo, insônia, dores musculares, pressão alta, aumento de peso ou emagrecimento exagerado, redução da libido e, alguns casos mais graves, até mesmo tendências suicidas, o que, por óbvio, leva à deterioração do desempenho profissional e à aniquilação da capacidade para realizar o seu trabalho.

A fase de marginalização ou exclusão profissional – última fase do processo evolutivo – conduz, com frequência, ao abandono do trabalho por absoluta incapacidade fisiológica da vítima em continuar naquele ambiente em razão dos danos psicológicos e/ou físicos causados pelo assédio moral, à incapacidade laboral permanente ou até mesmo à morte.

A empresa ou o Poder Público perde, assim, definitivamente, um empregado ou funcionário de grande valor que, pelo resto de sua vida, pode ser obrigado a suportar os prejuízos decorrentes do assédio moral. Por outro lado, ainda mantêm em seus quadros o assediador investido de poder, pronto para atacar sua próxima vítima, gerando imensa instabilidade no ambiente laboral tomado pelo terror.

4. Consequências Jurídicas do Assédio Moral

Abalar psicologicamente um colega de trabalho para manter sua posição profissional, afastar um pretenso concorrente, demonstrar seu poder para os demais e conseguir uma boa autoestima parece algo legítimo aos olhos do agressor.

Entretanto, quem pratica assédio moral incide numa série de ilicitudes e pode até cometer alguns crimes, como calúnia, difamação, injúria e, no âmbito da administração pública, até mesmo abuso de autoridade por atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional (artigo 3º, alínea “j”, c/c artigo 4º, alínea “h”, ambos da Lei nº 4.898/65).[245]

Muitas vezes esse abuso de autoridade vem travestido de aparência de regularidade, como ocorre na prática de atos de ofício carregados de subjetivismo e imputações de pseudo irregularidades que teriam sido praticadas pela vítima em sua atividade profissional, ou até mesmo votos públicos contrários à promoção do assediado por estar ele respondendo a sindicâncias e processos administrativos disciplinares forjados, dados com o intuito único e exclusivo de humilhar a vítima e rotulá-la negativamente.

Constatada a prática de assédio moral, o responsável pode ser demitido por justa causa ou, se o fato ocorrer no âmbito da administração pública, restará caracterizado ato de improbidade administrativa, a luz do disposto no *caput* e no inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429/92[246], inclusive por violação aos princípios da impessoalidade e da eficiência, eis que toda sociedade acaba sendo afetada pela prestação de um serviço público de má qualidade.

Além disso, como o assédio moral acarreta prejuízos materiais e emocionais para qualquer trabalhador, eis que a humilhação repetitiva e o sofrimento de longa duração não apenas compromete sua identidade, sua dignidade e suas relações afetivas e sociais, mas também causa graves danos à sua saúde física e psicológica, não fica excluída a responsabilidade civil do assediador e da própria pessoa jurídica envolvida, pública ou privada, por danos morais e materiais, os quais deverão ser pleiteados pelas vias próprias.

5. Sistemas de Integridade Efetivos X Assédio Moral

Se a ambição é necessária, a ganância precisa que ser colocada fora do circuito. É exatamente nesse ponto que os sistemas de integridade devem demonstrar a sua real efetividade, indo além de meros processos e políticas.

Antes de mais nada, um canal de comunicação confiável deve estar à disposição dos funcionários, até porque dar queixa ou trazer o problema à tona é o único meio de que a vítima dispõe para encerrar o seu ciclo de psicoterror. Para tanto, é preciso ter segurança de que o assunto será

investigado com seriedade e que medidas serão adotadas, pois, se assim não for, uma denúncia poderá significar uma ruptura definitiva com a empresa.

Deve-se tomar muito cuidado, entretanto, para que o canal de denúncias não seja utilizado como instrumento para o assédio moral contra profissionais éticos. Há muitos relatos de compliance officers no sentido de que foram injustamente denunciados no canal de denúncias de suas respectivas empresas por gerentes/diretores/CEOs exatamente por estarem realizado o trabalho com correção e eficiência. O intuito seria apenas retirar do caminho o profissional de compliance que está seguindo as regras definidas pela própria empresa. Infelizmente, os altos percentuais de denúncias de má-fé não geram consequências para aqueles que as realizaram.

Além disso, como os sistemas de integridade têm como foco atingir comportamentos e moldar a cultura das empresas e das instituições, treinamentos e orientações devem ser constantemente fornecidos a fim de que o tema assédio moral seja tratado de forma aberta no âmbito profissional, sem qualquer tipo de preconceito, inclusive envolvendo o comprometimento da alta direção na disseminação do assunto.

Se a empresa for condescendente ou agir com corporativismo, a perversão decorrente do assédio moral gerará a emulação entre indivíduos que não são propriamente perversos, mas que perderão seus referenciais e se deixarão persuadir. Aliás, a omissão da organização diante de um caso explícito de assédio moral será suficiente para demonstrar que o sistema de integridade ali implementado não existe de fato ou não é efetivo ("Sham Compliance Programs") por ausência de um de seus pilares mais importantes – o "tone at the top". Se a empresa ou instituição, por seu alto comando, não concretiza seu discurso ("walk the talk"), o indicativo será a existência apenas de um sistema no papel ("compliance on paper").

Como os impactos decorrentes do assédio moral não são apenas financeiros, mas também reputacionais, todos os casos devem ser levados muito a sério pelos envolvidos, principalmente pelos departamentos de compliance (ou de integridade), de RH e jurídico. Nesse sentido, é essencial possuir um departamento de compliance independente, com canal direto que garanta o sigilo das informações providas pelas potenciais vítimas e também com profissionais devidamente capacitados para conduzir uma investigação dessa envergadura.

Por outro lado, se uma empresa delegar a investigação de assédio moral ao RH e ao departamento jurídico sem ao menos ministrar um treinamento específico que os capacite para conduzir a necessária investigação, certamente ela terá sérios problemas no futuro, eis que o resultado dessa investigação poderá ser questionado por ambas as partes (assediador e vítima) e até mesmo ser anulado em caso de uma ação judicial.

Cabe também ressaltar que o resultado de uma investigação por assédio moral é capaz de definir a real cultura da empresa: aqui estará representada a dicotomia entre a cultura da integridade *versus* a cultura do corporativismo. O resultado, via de consequência, trará um impacto muito grande no clima organizacional da empresa da instituição, principalmente no tocante a credibilidade interna do sistema de integridade. Se os funcionários passarem a não mais acreditar que o sistema existe de fato, simplesmente deixarão de relatar o que ocorre e, caso sejam perguntados, passarão a dar de ombros para as ilicitudes ocorrentes.

Outro reflexo que põe frente a frente o assédio moral com os sistemas de integridade envolve a retenção de talentos. É claro que, em momentos de forte recessão econômica, os funcionários permanecem na empresa, ainda que profundamente insatisfeitos, pois precisam do emprego para pagar as contas. Entretanto, com a economia voltando aos eixos, as organizações que são coniventes com o assédio moral não terão capacidade para reter os talentos e sofrerão com a crise de imagem decorrente do abalo reputacional derivado do conceito externado por ex-funcionários: "não trabalhe nessa empresa, ela não é ética e somente protege quem é amigo do rei".

Vale lembrar que, hoje em dia, existem até websites que permitem as pessoas comentar publicamente sobre o trabalho realizado em determinada empresa, sendo que muitas delas, reconhecidas como sendo "as melhores empresas para se trabalhar", estão pessimamente cotadas por funcionários e ex-funcionários. Um bom trabalho de marketing pode até ajudar durante determinado momento, mas sem conteúdo, transparência, integridade e compliance, a verdade um dia aparecerá.

Por fim, um sólido sistema de meritocracia também deve estar consolidado no âmbito da governança da empresa e da administração público. Isso é absolutamente fundamental para o alcance da integridade governamental empresarial, pois os funcionários íntegros são totalmente avessos à troca de favores e, por isso, sem a necessária meritocracia, grandes valores podem ser perdidos, ficar

obscurecidos diante da ocupação de cargos estratégicos por servidores medíocres que pouco ou nada acrescentarão em favor da organização. A meritocracia, aliás, representa um eficiente antídoto contra o assédio moral, pois, como explica José Ingenieros,

> *A fraqueza e a ignorância favorecem a domesticação dos caracteres medíocres, adaptando-os a uma vida confortável; a coragem e a cultura exaltam a personalidade dos excelentes, prosperando-os na dignidade. O lacaio pede, o digno merece. Aquele implora por favor o que este espera por mérito. Ser digno significa não pedir aquilo que se merece, tampouco aceitar o imerecido. Enquanto os servis progridem valendo-se da rede de favores, os íntegros se valem das escadas de suas virtudes. Ou não sobem por nenhuma. [...] O pão ensopado na adulação, que engorda o servil, envenena o digno. Este prefere perder um direito a obter um favor; mil anos lhe serão mais leves que prosperar de maneira indigna.*[247]

Fica fácil perceber, por todas essas razões, que um sistema de integridade não pode se descurar das hipóteses de assédio moral, sob pena de padecer de absoluta falta de efetividade e, via de consequência, funcionar como um simples castelo de areia.

6. Conclusão

É inegável que existe uma correlação direta entre os casos de assédio moral e a falta de maturidade dos programas de integridade nas empresas e no Poder Público. Ainda estamos, no Brasil, há anos luz da efetividade garantida em, pelo menos, 50% das 500 grandes maiores empresas listadas na bolsa de valores de Nova Iorque.

A conclusão final, por isso, deve gravitar em torno da fundamental importância dos sistemas de integridade na prevenção do assédio moral, não só como forma de aprimoramento funcional e melhoria da produtividade da empresa, mas também como forma de coibir a prática de outros ilícitos mais graves.

As corporações precisam entender que necessitam criar movimentos de estímulo profissional, promover formação continuada, dar reconhecimento, pois isso faz com que os funcionários ganhem energia e receba combustível; o assédio moral, ao contrário, paralisa os funcionários. Um funcionário se encontrará mais motivado se ele for estimulado nesse sentido e se souber que estará protegido do assédio.

As empresas inteligentes agem assim – promovem, por sua alta cúpula e a partir de critérios objetivos, momentos de reconhecimento em favor dos funcionários dedicados e comprometidos com os propósitos empresariais, nos quais as pessoas entendam que as empresas se interessam por elas e não somente as usam. Os funcionários devem entender que são um bem e não apenas uma propriedade no sentido maquinário do termo, pois quem é cuidado por uma organização também vai querer cuidar dela.

Referências bibliográficas

BARRETO, Margarida M. S. *Violência, Saúde, Trabalho - Uma jornada de humilhações*. 1.ed. São Paulo: EDUC – Editora da PUC-SP, 2003.

Cortella, Mario Sergio. *Por que fazemos o que fazemos?* 27ª ed. São Paulo: Planeta, 2016.

Hirigoyen, Marie-France. *Assédio moral: a violência perversa no cotidiano*. 15ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014;

Hirigoyen, Marie-France. *Mal-Estar no Trabalho – redefinindo o assédio moral*. 6ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.

INGENIEROS, *O Homem Medíocre* [Trad. Douglas Dias Ferreira]. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

Autores

Alessandra Gonsales

Sócia do WFaria Advogados e da LEC. Graduada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial e mestre em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), também tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Suas pesquisas foram conduzidas na Universidade de Harvard (EUA). Professora e coordenadora de cursos da LEC, palestrante, conferencista e escritora de artigos para imprensa local e internacional, é ainda autora e coordenadora do livro "Compliance - A Nova Regra do Jogo" (LEC, 2016), além de ter participado dos livros "Compliance na Saúde: presente e futuro de um mercado em busca da auto-regulamentação" (Criarmed, 2016) e "Lei Anticorrupção e Temas de Compliance" (Juspodivm, 2017).

Alexandre da Cunha Serpa

Há 10 anos atuando em Compliance, é um profissional com mais de 20 anos de experiência nacional e internacional nas áreas de governança corporativa (Compliance, Auditoria, Gestão de Riscos e Controles Internos) em empresas de Consultoria, Indústria Farmacêutica (Brasil, Suíça, América Latina e Canadá) e Varejo Farmacêutico. Graduado em Ciências da Computação pela UNESP e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. Certificado em Investigação de Fraudes (CFE – Certified Fraud Examiner) e em Compliance e Ética (CCEP – Certified Compliance and Ethics Professional) e em Compliance Anticorrupção (CPC-A). Criador do "COMPLIANCE PROGRAM – THE BOARD GAME".

Carolina Gazoni

Carolina Gazoni é advogada (PUC-SP, 2003), especialista em Gestão de Sustentabilidade (FGV – SP, 2008) e sócia fundadora da 360 Compliance, empresa de consultoria e treinamentos focada na implantação e disseminação de conceitos de compliance em organizações. Foi responsável pela área de Compliance de Mattos Engelberg Sociedade de Advogados durante os anos de 2016 e 2017, e do escritório Barreto Ferreira e Brancher Sociedade de Advogados entre 2011 e 2016. Desenvolveu, em conjunto com a o Instituto Euvaldo Lodi e CNI, metodologia para certificação de programas de compliance tendo como base as normas 19600 e 37001. É profissional certificada em Compliance e Ética pelo CCEP-I ("Certified Compliance & Ethics Professional") desde 2014. Durante 2017 e 2018, realizou 16 Cursos sobre Ética, Compliance e Eficiência Empresarial em todo o Brasil, tendo treinado mais de 300 de alunos no tema. É reconhecida pelo LACCA - Latin American Corporate Counsel Association (2014, 2015, 2016, 2017), membro da SCCE – Society of Corporate Compliance and Ethics, da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP - Instituto dos Advogados de São Paulo e do Comitê Anticorrupção e Compliance da OAB e integra o grupo Master Mind da LEC - Legal and Ethics Institute.

Daniela Leme

Diretora de Compliance da PTC "Parametric Technology Brasil" na região da América Latina & Caribe desde 2017, estando baseada em São Paulo. É graduada pela Universidade Estadual de Londrina – UEL, com cursos de especialização e extensão na área de Intelectal Property Law and Policy pela Penn State e em Data Science Ethics pela Michigan University. Anteriormente, militou como advogada em renomadas bancas de advocacia na área internacional e de Compliance atuando com FCPA, legislação brasileira além de outras esparsas, tendo atuado também em multinacionais (Credicard, Grupo Abril, PwC e Solazyme Bunge). Na área de Compliance implementou diversos Programas, estruturou políticas de Controles, conduziu investigações internas, due diligence de M&A e terceiros, sendo responsável também pela elaboração de treinamentos para a alta administração e gestão.

Daniel Sibille

Co-autor dos livros "Compliance, a nova regra do jogo", "The guide to corporate crisismangement" e do e-book "Os pilares do programa de compliance". Em 2018 eleito o segundo advogado mais admirado do ano, de acordo com a LACCA (Latin America Corporate Counsel Association), sendo também premiado pelos pares como um dos 20 profissionais mais admirados de Compliance no Brasil, no anuário Compliance On Top 2018.

Felipe Faria

Há mais de 10 anos trabalha na implementação e gestão de programas de Compliance em empresas que passaram por escândalos governamentais e institucionais e processos de transformação de uma cultura mais integra e ética. Atuou em escritórios de advocacia e em empresas multinacionais e brasileiras em momentos de crise, ocasionados seja pela assinatura de um Deferred Prosecution Agreement (DPA) com o Departamento de Justiça dos EUA ou por acordos de leniência com o Banco Mundial e outros bancos de desenvolvimento. Também atuou em empresas envolvidas em escândalos nacionais como a Lava Jato. Atua como compliance officer não só no Brasil como por toda América Latina em especial Chile e Peru. Autor de artigos e conferencista em eventos de compliance nacionais e internacionais. Atualmente é responsável pela área de Compliance de uma grande empresa no setor elétrico no Brasil.

Gustavo Lucena

Há 24 anos atuando em consultoria de compliance, gestão de riscos e de Governança Corporativa para os segmentos de LifeSciences & HealthCare e para o Mercado de Capitais. Membro de Comitês de Compliance de associações do segmento financeiro e da área da saúde. Escritor de 2 livros (tesouraria e câmbio) junto a Febraban, além da Cartilha de Compliance junto a ABBI e Febraban e do Manual de Compliance - Preservando a boa Governança e a Integridade Corporativa vendido pela Editora Atlas. Membro efetivo da Comissão de Governança Corporativa para Instituições Financeiras do IBGC. Atuou como professor da pós-graduação da FIA do curso "Análise, Prevenção, Detecção e Riscos de Fraudes Empresarias" pelo período de 3 anos e atual professor do MBA de Governança de Compliance da UFSCAR. Contador e Economista, com MBA em Banking e em Administração de Marketing.

Hui Chen

Doutora em Direito (J.D.) pela UCLA - Universidade da Califórnia, Los Angeles. Bacharel em Ciências Sociais (B.A.) pela Universidade da California, Berkeley. Foi a primeira especialista em Compliance do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), consultora de promotores federais especializados em crimes de colarinho branco, analisando programas de ética corporativa e compliance de empresas, como foco em antifraude, antissuborno, saúde, controle de qualidade, manipulação de mercados financeiros, segurança de processos e proteção ambiental. Atuou em casos de repercussão como Petrobras, Tenet Healthcare, VW e monitoria da Deepwater Horizon (BP). Autora da reconhecida metodologia de avaliação de programas de integridade "Evaluation of Corporate

Compliance Programs" aplicada pela Seção de Fraude do DOJ, que tem sido amplamente elogiada por profissionais de compliance e reconhecida por órgãos reguladores em todo o mundo. Antes de ser contratada pelo DOJ, atuou como líder sênior de compliance em setores como tecnologia (Microsoft), farmacêutico (Pfizer) e serviços financeiros (Standard Chartered Bank). Atualmente é consultora na Hui Chen Ethics LLC, responsável por auxiliar e assessorar empresas e órgãos de governo em todo o mundo sobre ética corporativa e Programas de Compliance. Advogada membro do District of Columbia Bar.

Marília Zulini da Costa Loosli

Formada em Ciências Econômicas na FEA-USP e em Direito na PUC-SP, com especialização em Compliance pela FGV-SP e em Comércio Internacional pelo World Trade Institute. Atualmente, é Gerente Executiva de Compliance da BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, sendo responsável pela disseminação da cultura da ética e implementação do Sistema de Integridade nas unidades da empresa, no Brasil e demais países onde a BRF opera. Antes, foi Gerente de Compliance no Grupo Pão de Açúcar, e atuou na criação da área e desenvolvimento do programa de integridade na companhia e suas subsidiárias. Trabalhou por mais de 10 anos no Pinheiro Neto Advogados, na condução de processos administrativos e judiciais relacionados a Defesa da Concorrência e Direito do Comércio Internacional.

Marcelo Zenkner

Advogado especializado em Direito Público. Membro do Comitê de Medidas Disciplinares e consultor da presidência da Petrobras. Ex-Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo. Ex-Secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, o primeiro estado do Brasil a criar uma estrutura administrativa e a aplicar sanções administrativas com base na Lei Anticorrupção Empresarial e premiado pela Controladoria-Geral da União com o primeiro lugar no cumprimento das regras da Lei de Acesso à Informação (2015) e pelo Ministério Público Federal com o primeiro lugar no ranking dos melhores portais de transparência no Brasil (2015). Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV - Faculdade de Direito de Vitória e Doutor em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa (Portugal). É Professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV) nos cursos de graduação e pós-graduação.

Massamitsu Alberto Iko

Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e post-MBA pela Kellogg School of Management da Northwestern University em Chicago. Há 21 anos atuando nas áreas de Auditoria Interna, Controladoria e Ética & Compliance, conduziu centenas de projetos de auditoria interna e investigações de Compliance e fraudes corporativas na América do Sul, Estados Unidos, Singapura e China. Atualmente é o responsável pela área de Ética e Compliance para a América do Sul da Bunge. Professor convidado nos cursos de Compliance Anticorrupção da Legal, Ethics and Compliance – LEC, Certified Expert em Compliance do Instituto ARC e na Pós-Graduação em Controles Internos e Compliance Officer da Daryus Escola de Negócios. Co-autor do livro Manual de Compliance (Instituto ARC 2017). Possui os certificados CFE (Certified Fraud Examiner) e CCEP-I (Certified Compliance and Ethics Professional – International).

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha

Sócio e consultor líder na T4 Compliance. Advogado com experiência em compliance e jurídico contencioso em empresas nacionais e multinacionais. Foi Secretário Adjunto de Transparência e Combate à Corrupção no Governo de Mato Grosso, responsável pela criação e implementação do Programa de Integridade, um projeto pioneiro de mecanismos de Compliance no Setor Público. Foi membro da comissão responsável pela regulamentação da Lei Anticorrupção em Mato Grosso. Professor nos cursos de Compliance Anticorrupção da LEC - Legal, Ethics and Compliance e em cursos de pós-graduação na UFMT (MT), Grupo Atame (MT), Faculdade Baiana de Direito (BA), Faculdade Pólis Civitas (PR) e Faculdade de Direito de Vitória (ES). Mestrando em Direito pela UFMT, com linha de pesquisa sobre "Corrupção, Compliance e Direitos Humanos e Fundamentais". Autor de artigos sobre compliance, gestão de riscos, governança pública e corporativa.

Patrícia Punder

Advogada com vinte anos de prática, incluindo dez anos com foco exclusivo em Compliance. Profissional certificada internacionalmente pela ECOA - Ethics & Compliance Office Association e Fordham University e nacionalmente, pela CPC-A – LEC Certification Board. Sólida experiência na implementação de programa de Compliance em empresas nacionais e internacionais, inclusive atuou em empresas que foram foco de investigação pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). Responsável por lidar com autoridades como FBI, INTERPOL e Política Federal do Brasil durante operação de combate ao cartel junto ao CADE. Professora do curso de pós-graduação em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance na FIA/USP e na LEC. Constantemente convidada para palestrar sobre diversos temas de Compliance, inclusive em Washington em 2016. Recebeu premiação como uma das 20 profissionais mais admiradas e destacadas em Compliance no Brasil pela LEC Compliance on Top/2018.

Rodrigo Pironti Aguirre de Castro

Sócio da Pironti Advogados. Pós-Doutor em Direito pela Universidad Complutense de Madrid. Doutor e Mestre em Direito Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. Especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Vencedor do Prêmio Iberoamericano de Direito Administrativo/Contratual. Professor da Universidade de La Plata – ARGENTINA, da Universidade de San Nicolas de Hidalgo e da Universidade Tecnológica de Monterrey – MÉXICO, da Escola de Gestão Pública Gallega e da Universidade Complutense de Madrid – ESPANHA, do "Centro Studi Giuridici Latinoamericani" – ITÁLIA. Professor da Escola Superior de Advocacia. Autor e coordenador de 11 obras jurídicas, dentre elas: - Compliance e Gestão de Riscos nas empresas Estatais. CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; GONÇALVES, Francine Silva Pacheco. Fórum, 2018; Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção: Integridade para o desenvolvimento. CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; PAULA, Marco Aurélio Borges de Paula. Fórum, 2018. Autor de vários artigos em periódicos legais nacionais e internacionais. Conferencista em eventos nacionais e internacionais (ARGENTINA, MÉXICO, ESPANHA, ITÁLIA dentre outros).

[1]. *Doutora em Direito (J.D.) pela UCLA - Universidade da Califórnia, Los Angeles. Bacharel em Ciências Sociais (B.A.) pela Universidade da California, Berkeley. Foi a primeira especialista em Compliance do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), consultora de promotores federais especializados em crimes de colarinho branco, analisando programas de ética corporativa e compliance de empresas, como foco em antifraude, antissuborno, saúde, controle de qualidade, manipulação de mercados financeiros, segurança de processos e proteção ambiental. Atuou em casos de repercussão como Petrobras, Tenet Healthcare, VW e monitoria da Deepwater Horizon (BP). Autora da reconhecida metodologia de avaliação de programas de integridade "Evaluation of Corporate Compliance Programs" aplicada pela Seção de Fraude do DOJ, que tem sido amplamente elogiada por profissionais de compliance e reconhecida por órgãos reguladores em todo o mundo. Antes de ser contratada pelo DOJ, atuou como líder sênior de compliance em setores como tecnologia (Microsoft), farmacêutico (Pfizer) e serviços financeiros (Standard Chartered Bank). Atualmente é consultora na Hui Chen Ethics LLC, responsável por auxiliar e assessorar empresas e órgãos de governo em todo o mundo sobre ética corporativa e Programas de Compliance. Advogada membro do District of Columbia Bar.*

[2] *Advogada com vinte anos de prática, incluindo dez anos com foco exclusivo em Compliance. Profissional certificada internacionalmente pela ECOA - Ethics & Compliance Office Association e Fordham University e nacionalmente, pela CPC-A – LEC Certification Board. Sólida experiência na implementação de programa de Compliance em empresas nacionais e internacionais, inclusive atuou em empresas que foram foco de investigação pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). Responsável por lidar com autoridades como FBI, INTERPOL e Política Federal do Brasil durante operação de combate ao cartel junto ao CADE. Professora do curso de pós-graduação em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance na FIA/USP e na LEC. Constantemente convidada para palestrar sobre diversos temas de Compliance, inclusive em Washington em 2016. Recebeu premiação como uma das 20 profissionais mais admiradas e destacadas em Compliance no Brasil pela LEC Compliance on Top/2018.*

[3] WIKIPIDIA. *Erie War.* Disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/Erie_War>. Acesso em 20 nov. 2018.

[4] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Securities and Exchange Commission. *What we do. Creation of the SEC*. Disponível em < https://www.sec.gov/Article/whatwedo.html#create>. Acesso em 20 nov. 2018.

[5] HISTORY.COM. Watergate Scandal. Disponível em <https://www.history.com/topics/1970s/watergate>. Acesso em 20 nov. 2018.

[6] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Securities and Exchange Commission. *Report of the Securities and Exchange Commission on questionable and illegal corporate payments and practices.* Submitted to the Committee on Banking, Housing and Urban Affairs of United States Senate, mai. 1976. Disponível em <https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/sec-report-questionable-illegal-corporate-payments-practices-1976.pdf>. Acesso em 20 nov. 2018.

[7] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Senate. *Domestic and Foreign Investment Improved Disclosure Acts of 1977*. Report of the Committee on Banking, Housing and Urban Affairs of United States Senate, 2 may 1977. Disponível em <https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2010/04/11/senaterpt-95-114.pdf>. Acesso em 20 nov. 2018.

[8] SEITZINGER, Michael V. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA): *Congressional Interest and Executive Enforcement, In Brief*. Disponível em <https://fas.org/sgp/crs/misc/ R41466.pdf>. Acesso em 20 nov. 2018.

[9] ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*. Disponível em <http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.html>. Acesso em 20 nov. 2018.

[10] REINO UNIDO. *Bribery Act 2010*. Disponível em <https://www.legislation.gov.uk/ ukpga/2010/23/contents>. Acesso em 20 nov. 2018.

[11] Sobre a aplicabilidade da jurisdição extraterritorial do DoJ e da SEC *v.* item 4, a seguir.

[12] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission. *A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act.* Disponível em <https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance>. Acesso em 20 nov. 2018.

[13] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Department of Justice. *Deputy Attorney General Sally Quillian Yates Delivers Remarks at New York University School of Law Announcing New Policy on Individual Liability in Matters of Corporate Wrongdoing*. Disponível em <https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-sally-quillian-yates-delivers-remarks-new-york-university-school>. Acesso em 20 nov. 2018.

[14] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Department of Justice. Individual Accountability for Corporate Wrongdoing. Memorandum Yates. Disponível em <https://www.justice.gov/ archives/dag/individual-accountability>. Acesso em 20 nov. 2018.

[15] *Idem.*

[16] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Department of Justice. *The Fraud Section's Foreign Corrupt Practices Act Enforcement Plan and Guidance*. Disponível em <https://www.justice.gov/ archives/opa/blog-entry/file/838386/download>. Acesso em 20 nov. 2018.

[17] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Department of Justice. *United States v. Siemens court docket number: 08-cr-367-rjl.* Disponível em <https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-siemens-aktiengesellschaft-court-docket-number-08-cr-367-rjl>. Acesso em 20 nov. 2018.

[18] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Department of Justice. Criminal Division. Fraud Section. *Evaluation of Corporate Compliance Programs*. Disponível em <https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download>. Acesso em 20 nov. 2018.

[19] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Department of Justice. *Principles of Federal Prosecution of Business Organizations*. Disponível em <https://www.justice.gov/jm/jm-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations>. Acesso em 20 nov. 2018.

[20] JARRETT, Laura. *Justice Department anti-fraud expert resigns, disturbed by Trump's 'stunning' conduct.* CNN Politics, 4 jul. 2017. Disponível em <https://edition.cnn.com/2017/07/04/politics/justice-hui-chen-resignation/index.html>. Acesso em 20 nov. 2018.

[21] GRAHAM, Victoria. *Anti-Bribery Enforcement Remains Steady Under Trump*. Bloomberg BNA. The Bureau of National Affairs, 20 jun. 2018. Disponível em <https://www.bna.com/antibribery-enforcement-remains-n73014476694/>. Acesso em 20 nov. 2018.

[22] KARP, Brad S. The DOJ's New "Piling On". *Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation Policy*, 23 fev. 2019. Disponível em <https://corpgov.law.harvard.edu/ 2018/05/24/the-dojs-new-piling-on-policy/>. Acesso em 24 fev. 2019.

[23] *Idem*.

[24] *Ibidem*.

[25] *Sócio e consultor líder na T4 Compliance. Advogado com experiência em compliance e jurídico contencioso em empresas nacionais e multinacionais. Foi Secretário Adjunto de Transparência e Combate à Corrupção no Governo de Mato Grosso, responsável pela criação e implementação do Programa de Integridade, um projeto pioneiro de mecanismos de Compliance no Setor Público. Foi membro da comissão responsável pela regulamentação da Lei Anticorrupção em Mato Grosso. Professor nos cursos de Compliance Anticorrupção da LEC - Legal, Ethics and Compliance e em cursos de pós-graduação na UFMT (Cuiabá/MT), Grupo Atame (Cuiabá/MT), Faculdade Baiana de Direito (Salvador/BA), Faculdade Pólis Civitas (Curitiba/PR) e Faculdade de Direito de Vitória (Vitória/ES). Mestrando em Direito pela UFMT, com linha de pesquisa sobre "Corrupção, Compliance e Direitos Humanos e Fundamentais". Autor de artigos sobre compliance, gestão de riscos, governança pública e corporativa. [matheus.cdlr@terra.com.br].*

[26] Sobre o tema recomenda-se a leitura de KAHNEMAN, Daniel; EGAN, Patrick. *Thinking, fast and slow.* New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

[27] CRESSEY, Donald R. The criminal violation of financial trust. American Sociological Review, 15 (6), p.738-743, December, pp.1-15, 1950.

[28] FURTADO, Lucas Rocha. *As raízes da corrupção no Brasil*. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 387.

[29] Report of the SEC on questionable and illegal corporate payments and practices. Submitted to Committee on Banking, Housing and Urban Affairs of the United States Senate.

[30] CASSIN, Richard L. *The 2015 FCPA Enforcement Index*. Disponível em <www.fcpablog.com/blog/ 2016/1/4/the-2015-fcpa-enforcement-index.html#sthash.gRRmyVeb.dpuf> Acesso em 14 de julho de 2016.

[31] GONSALES, Alessandra. *Compliance. A nova regra do jogo.* São Paulo: LEC, 2016, p. 9.

[32] GONSALES, Alessandra. *Op. cit.*, p. 9.

[33] FURTADO, Lucas Rocha. *Op. cit.*, p. 382.

[34] FURTADO, Lucas Rocha. *Op. cit.*, p. 396.

[35] FURTADO, Lucas Rocha. *Op. cit.*, p. 410.

[36] *Países membros da OEA: Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, São Cristóvão e Nevis, Suriname, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.*

[37] ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Carta da OEA. Bogotá, 1948.

[38] *Idem*.

[39] ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. *Convenção Interamericana Contra a Corrupção*. Caracas, 1996, p. 1.

[40] *Idem*, p. 2.

[41] BRASIL. *Op. cit.*, p. 19.

[42] BRASIL. Controladoria Geral da União. *Cartilha sobre a Convenção da OCDE contra o suborno transnacional.* 2016, p. 5.

[43] FURTADO, Lucas Rocha. *Op. Cit.*, p. 206.

[44] BRASIL. *Op. cit.*, p. 6.

[45] ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. *Convenção da OCDE sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais*. 1997, p. 2.

[46] BRASIL. Controladoria Geral da União. *Cartilha sobre a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção.* 2016, p. 5.

[47] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção das Nações Unidas contra Corrupção, 2000.

[48] BRASIL. *Op. cit.*, p. 6.

[49] *Idem.*

[50] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Op. cit.*, 2000.

[51]. *Advogado especializado em Direito Público. Membro do Comitê de Medidas Disciplinares e consultor da presidência da Petrobras. Ex-Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo. Ex-Secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, o primeiro estado do Brasil a criar uma estrutura administrativa e a aplicar sanções administrativas com base na Lei Anticorrupção Empresarial e premiado pela Controladoria-Geral da União com o primeiro lugar no cumprimento das regras da Lei de Acesso à Informação (2015) e pelo Ministério Público Federal com o primeiro lugar no ranking dos melhores portais de transparência no Brasil (2015). Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV - Faculdade de Direito de Vitória e Doutor em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa (Portugal). É Professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV) nos cursos de graduação e pós-graduação.*

[52] Johnson, “Corrupt (adjective)”, in *A Dictionary of the English Language: A Digital Edition of the 1755 Classic by Samuel Johnson*, ed. B. BESALKE, last modified November 7, 2013. Disponível em <http://johnsonsdictionaryonline.com/?p=16538>. Acesso em 28 out. 2018.

[53] BOLT, “Public Corruption for Profit”, in *Character and Cops – Ethics in Policing*, 4ª ed., E. J. DELATTRE (coord.). Washington, The AEI Press, 2002, p. 63. Tradução livre: *O bom caráter inclui uma concepção do que é digno de si próprio. Pessoas que realmente não têm preço possuem valores que estão acima de ceder a tentações para a gratificação ilícita ou lucro. Pressão dos colegas, fraqueza dos outros, impulso, oportunidade e racionalização pessoal ou consolo não desculpam os lapsos de caráter. [...] Incorruptibilidade é uma forma de liberdade pessoal que consiste no controle da própria vida de acordo com padrões de excelência e autoestima, os quais são mais importantes do que qualquer outra coisa, incluindo a própria vida. Nenhuma outra disposição torna a nossa própria vida verdadeiramente nossa, e nenhuma outra disposição pode fazer alguém ser confiável até o fim. Embora poucos de nós sejam capazes de alcançar a incorruptibilidade completa, todos nós devemos manter a sua natureza claramente diante de nós*.

[54] HUBERTS, L., *The integrity of governance – What it is, what we know, what is done, and where to go*, Cambridge, Palgrave Macmillan, 2014, p. 5.

[55] VERISSIMO, “Etimológicas”, in *O Estado de São Paulo*, Caderno 2, edição de 30 de abril de 2015, p. C10.

[56] Clóvis de Barros Filho e Sérgio Praça estabelecem uma interligação entre ética e corrupção ao constarem que esta “[...] atenta contra a saúde do tecido social e agride princípios básicos de convivência”. Para os citados autores, na relação de corrupção, “[...] o que

se rompe é um elemento terceiro, que não se confunde nem com corruptores nem com corruptos. Tampouco se confunde com a relação entre eles, porque toda relação de corrupção deteriora as relações entre os agentes que dela participam com o resto da sociedade. Por isso, a responsabilidade moral e jurídica dos que tomam parte de uma relação de corrupção transcende a situação concreta que protagonizaram" (BARROS FILHO, C.,/PRAÇA, S., *Corrupção: Parceria degenerativa*, Campinas, Papirus 7 Mares, 2014, pp. 20; 24-25).

[57] BUCHAN/HILL, *An Intellectual History of Political Corruption*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014.

[58] AMUNDSEN, *Political corruption: An introduction to the issues*. Bergen, Chr. Michelsen Institute, 1999, p. 1.

[59] BANCO MUNDIAL, Discurso de abertura de James D. Wolfensohn na reunião anual, 1º de outubro de 1996. Disponível em <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ ORGANIZATION/EXTPRESIDENT/EXTPASTPRESIDENTS/PRESIDENTEXTERNAL/0,,contentMDK:20025269~menuPK:232083~pagePK: Acesso em 20 jul. 2016.

[60] BROOKS, "The Nature of Political Corruption", in *Political Corruption: Readings in Comparative Analysis*, Londres, Holt, Rinehart and Winston, 1910, pp. 56-64.

[61] ADEODATO, *Corrupção sistêmica, democracia e 'natureza humana' – Uma velha tese*, Diário de Pernambuco, edição de 8 de novembro de 2015. Disponível em <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/ noticia/opiniao/46,97,43,74/2015/11/08/interna_opiniao,130469/corrupcao-sistemica-democracia-e-natureza-humana-uma-velha-tese.shtml>. Acesso em 20 jul. 2016.

[62] PHILP, "Corruption Definition and Measurement", in *Measuring Corruption*, Londres, Ashgate, 2006, p. 45. Tradução livre: "*Há algum consenso na literatura de que temos um caso de corrupção quando: um funcionário público (A), agindo para seu ganho pessoal, viola as normas que regem os cargos públicos e prejudica o interesse público (B) para beneficiar terceiros (C), que premia (A) para ter acesso a bens ou serviços que (C) de outra forma não poderia obter". Norberto Bobbio, Nicola Matteuci e Gianfranco Pasquino têm a mesma impressão sobre corrupção: "Assim se designa o fenômeno pelo qual um funcionário público é levado a agir de modo diverso dos padrões normativos do sistema, favorecendo interesses particulares em troca de recompensa. Corrupto é, portanto, o comportamento ilegal de quem desempenha um papel na estrutura estatal"* (BOBBIO/MATTEUCCI/PASQUINO, Dicionário de Política [Trad. Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto Cacais e Renzo Dini, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1998], p. 291).

[63] "Corruption is the abuse of an entrustred power for private gain" (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, *Faqs on Corruption – How do you define corruption?*, 2015. Disponível em: <http://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption>. Acesso em 12 set. 2016).

[64] O ex-presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln é até hoje historicamente louvado por ter sido o responsável pela abolição da escravatura naquele país. Para colocar em votação a décima terceira emenda constitucional, agiu corajosamente contra seu próprio partido, seus ministros, seus assessores e, assim, conseguiu dar a liberdade a milhões de negros americanos. Entretanto, para obter êxito em seu intento, contratou emissários para trocar votos no congresso americano por cargos no governo. Pode-se dizer, assim, que foi a corrupção que garantiu a liberdade de milhares de americanos e que a moralidade foi sacrificada em prol da justiça. Diante de um parlamento corrupto, como deve agir um estadista? Deve jogar o jogo da política e comprar congressistas para alcançar a justiça social e a igualdade, ou deve manter a postura impoluta do início até o final e se conformar com o *status quo*? A hipótese é interessante porque Abraham Lincoln muito provavelmente fez essa escolha convicto de que a história jamais o recriminaria e muito menos colocaria em dúvida sua integridade.

[65] "Não obstante a população rejeite de um modo abstrato a corrupção, pactua com toda uma série de comportamentos e práticas venais por parte do patrono, desde que sejam beneficiários da sua protecção ou ajuda. A corrupção estilo 'Robin Hood' tem grande aceitação na sociedade portuguesa e é sintomática de uma cultura cívica ainda muito assente na satisfação de necessidades básicas. No inquérito *Corrupção e Ética em Democracia: o Caso de Portugal*, realizado em 2006 a uma amostra representativa da população, verificou-se que 63,6% dos portugueses toleram a corrupção desde que essa produza efeitos benéficos para a população em geral" (SOUSA, L., *Corrupção*, Lisboa, Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2011, p. 46).

[66] "Grand corruption consists of acts committed at a high level of government that distort policies or the central functioning of the state, enabling leaders to benefit at the expense of the public good. Petty corruption refers to everyday abuse of entrusted power by low- and mid-level public officials in their interactions with ordinary citizens, who often are trying to access basic goods or services in places like hospitals, schools, police departments and other agencies. Political corruption is a manipulation of policies, institutions and rules of procedure in the allocation of resources and financing by political decision makers, who abuse their position to sustain their power, status and wealth" (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, *Faqs on Corruption – How do you define corruption?*, *op. cit.*

[67] ROSE-ACKERMAN, S.,/PALIFKA, B. J., *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*, 2nd ed., New York: Cambridge University Press, 2016, p. 9.

[68] Ação Comum n.º 98/742/JAI. [...] Artigo 2º. Corrupção passiva no sector privado. 1. Para efeitos da presente acção comum, constitui corrupção passiva no sector privado o acto deliberado de qualquer pessoa que, no exercício da sua actividade profissional, solicite ou receba, directamente ou por interposta pessoa, vantagens indevidas de qualquer natureza, ou aceite a promessa de tais vantagens, para si próprio ou para terceiros, a fim de, em violação dos seus deveres, praticar ou se abster de praticar determinados actos. 2. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 4º, os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para que as condutas referidas no n.º 1 constituam crimes. Tais medidas deverão visar, no mínimo, qualquer conduta que implique ou possa implicar distorções de concorrência, pelo menos no mercado comum, e da qual resultem ou possam vir a resultar prejuízos económicos para terceiros em virtude da indevida celebração ou da indevida execucão de um contrato. Artigo 3º. Corrupção activa no sector privado. 1. Para efeitos da presente acção comum, constitui corrupção activa no sector privado a acção deliberada de alguém que prometa, ofereça ou dê, directamente ou por interposta pessoa, uma vantagem indevida, de qualquer natureza, a uma pessoa, para esta ou para terceiros, no exercício das actividades profissionais dessa pessoa, a fim de, em violação dos seus deveres, pratique ou se abstenha de praticar determinados actos. 2. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 4º, os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para que as condutas referidas no n.º 1 constituam crimes. Tais medidas deverão visar no mínimo qualquer conduta que implique ou possa implicar distorções de concorrência, pelo menos no mercado comum, e da qual resultem ou possam vir a resultar prejuízos económicos para terceiros em virtude da indevida celebração ou da indevida execucão de um contrato.

[69] Decisão-Quadro 2003/568/JAI. [...]. Artigo 2º. Corrupção activa e passiva no sector privado. 1. Os Estados-membros devem tomar as medidas necessárias para garantir que sejam consideradas infracção penal as seguintes condutas voluntárias, praticadas no exercício de actividades profissionais: a) Prometer, oferecer ou dar, directamente ou por interposta pessoa, vantagens indevidas de qualquer natureza a uma pessoa que, a qualquer título, dirija uma entidade do sector privado ou nela trabalhe, em benefício dessa pessoa ou de terceiros, a fim de essa pessoa, em violação dos seus deveres, praticar ou se abster de praticar determinados actos; b) Solicitar ou

receber, directamente ou por interposta pessoa, vantagens indevidas de qualquer natureza, ou aceitar a promessa de tais vantagens, em benefício do próprio ou de terceiros, quando, a qualquer título, essa pessoa dirija uma entidade do sector privado ou nela trabalhe, a fim de, em violação dos seus deveres, praticar ou se abster de praticar determinados actos. 2. O n.º 1 aplica-se às actividades profissionais no âmbito de entidades com ou sem fins lucrativos.

[70] Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, arts. 8º e 9º, que serão tratados com mais detalhes no Item 2.2.3 do Capítulo II. No Brasil, conduta assemelhada ainda não está tipificada, mas o projeto de Código Penal, em trâmite no Senado Federal (PLS n.º 236/12), já traz a previsão da corrupção privada como crime, assunto que será abordado no Item 4.3 do Capítulo II.

[71] Nos Estados Unidos, apesar de alguns Estados tratarem a corrupção privada como delito em seus respectivos códigos estaduais, mesmo assim não há um crime federal expressamente previsto para a hipótese, razão pela qual o Departamento de Justiça normalmente combina delitos estaduais com previsões federais de fraude por meios de comunicação ("*wire fraud*") para avocar fatos afetos à sua competência.

[72] SOUSA, *op. cit.*, p. 18.

[73] NIETO, "Desmitificando la corrupción en América Latina", in *Revista Nueva Sociedad*, n.º 194, Caracas, Fundación Friedrich Ebert, 2004, pp. 54-68.

[74] Ary Ferreira da Cunha observa que, nesses ambientes, uma das características mais interessantes da corrupção é a *histerese*: assim como uma mola, que possui a tendência de conservar a sua forma na ausência do estímulo que a gerou, também a corrupção, uma vez enraizada no sistema, tem a tendência de nele permanecer (CUNHA, *Combate à corrupção – Da teoria à prática*, Lisboa, Quid Juris, 2015, p. 109).

[75] HANNS, Luiz. *Corrupção sistêmica, endêmica e sindrômica: é possível vencer*! Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=EGjVH06nUOw>. Acesso em 28 out. 2018.

[76] Heidenheimmer, *Readings in comparative analysis on political corruption*, New York, Holt, Rinegart and Winston, 1970, pp. 03-06.

[77] "O enfrentamento das chamadas 'remunerações ilícitas' é necessário, sobretudo se levarmos em conta que, debaixo desse manto de suposta legalidade ou juridicidade, podem encaixar-se atos abusivos, não raro caracterizadores da denominada 'corrupção branca', fenômeno tão invisível quanto nocivo aos interesses sociais, eis que se cuida de transgressão mascarada pela fachada de legalidade" (OSÓRIO, *Teoria da improbidade administrativa – má gestão pública – corrupção – ineficiência*, *op. cit.*, p. 311).

[78] "Inasmuch as parochial corruption reflects narrow, traditional loyalty patterns while market corruption offers access to all who can pay, one might expect that long-run trends would favor the more modern market form" (SCOTT, *Comparative Political Corruption*, New Jersey, Prentice-Hall, 1972, p. 89). Tradução livre: Como a corrupção paroquial reflete padrões estreitos e tradicionais de fidelidade, enquanto que a corrupção mercado oferece acesso a todos os que podem pagar, se poderia esperar que a tendência de longo prazo se estabelecesse a favor da forma de mercado mais moderna.

[79] OSÓRIO, *Teoria da improbidade administrativa – má gestão pública – corrupção – ineficiência*, *op. cit.*, pp. 194-195.

[80] Art. 73 da LC n.º 101/2000. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei n.º 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação pertinente.

[81] Art. 52 da Lei n.º 10.257/2001. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: I – (VETADO); II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4º do art. 8º desta Lei; III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no art. 26 desta Lei; IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei; V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no § 1º do art. 33 desta Lei; VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4º do art. 40 desta Lei; VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3º do art. 40 e no art. 50 desta Lei; VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado.

[82] CANARIS, *Pensamento sistemático e o conceito de sistema na ciência do direito*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 22.

[83] Em sentido contrário: "Portanto, se 'por vontade expressa do Constituinte, existe prerrogativa de foro para infrações penais que acarretam simples pena de multa pecuniária, não teria sentido negar tal garantia em relação às ações de improbidade, que importam, além da multa pecuniária, também a perda da própria função pública e a suspensão dos direitos políticos'. [...] Em outras palavras, se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por crime comum ou de responsabilidade, perante o Supremo Tribunal Federal, entender que tais agentes devem responder a processo assemelhado, ou de consequência assemelhada, perante o juiz de primeiro grau, não pode ser admitido" (MENDES, "A improbidade administrativa no Supremo Tribunal Federal", in *Improbidade administrativa: temas atuais e controvertidos*, coord. M. C. MARQUES, et al., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pp. 139-140).

[84] DIDIER Jr./ZANETI Jr., *Curso de Direito Processual Civil – Processo Coletivo*, 10ª ed., Salvador, Editora JusPodivm, 2016, p. 49.

[85] Guilherme de Souza Nucci, por exemplo, discorre sobre a expressão "vantagem indevida" nos seguintes termos: "pode ser qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes. Entendíamos que o conteúdo da vantagem indevida deveria possuir algum conteúdo econômico, mesmo que indireto. Ampliamos nosso pensamento, pois há casos concretos em que o funcionário deseja obter somente um elogio, uma vingança ou mesmo um favor sexual, enfim, algo imponderável no campo econômico e, ainda assim, corrompe-se para prejudicar ato de ofício. Por vezes, já que a natureza humana é complexa para abarcar essas situações, uma vantagem não econômica pode surtir mais efeito do que se tivesse algum conteúdo patrimonial" (NUCCI, G. S., *Corrupção e Anticorrupção*, Rio de Janeiro, Forense, 2015, p. 1149). Essa discussão assume um relevo ainda maior diante da disposição constante do *caput* do art. 9º da Lei n.º 8.429/92, que deixa expressamente consignado que "constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida" – grifo nosso.

[86] Art. 125 da Lei n.º 8.112/1990. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si; Art. 935 do Código Civil. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal; Art. 66 do Código de Processo Penal. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato; Art. 67 do Código de Processo Penal. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: I – o despacho

de arquivamento do inquérito ou das peças de informação; II – a decisão que julgar extinta a punibilidade; III – a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime; Art. 12 da Lei n.º 8.429/92. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: […]; Art. 18 da Lei n.º 12.846/2013. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial; Art. 30 da Lei n.º 12.846/2013. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: I – ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e II – atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011; Art. 82 da Lei n.º 8.666/1993. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.

[87] Fábio Medina Osório ainda descreve outras hipóteses de aplicação, apesar de não usar explicitamente essa expressão *microssistema*: "Somente o Código Penal e a legislação de mesma natureza enfocam a matéria das excludentes da ilicitude, da culpabilidade ou da imputação, mas, tratando-se de direito punitivo, principalmente de direito administrativo sancionador, é possível invocar, de modo análogo, o direito penal e o direito processual penal. Estamos diante de ilícitos administrativos e sanções de direito administrativo, e o regime jurídico imperante terá que ser chamado a intervir, dentro da perspectiva de equilíbrio entre os direitos fundamentais potencialmente em conflito" (OSÓRIO, *Teoria da improbidade administrativa – má gestão pública – corrupção – ineficiência*, *op. cit.*, p. 203).

[88] Nas palavras de Medina Osório: "Reconhece a doutrina, destarte, que existem 'sanções administrativas jurisdicionais', como ocorre, por exemplo, com algumas infrações cuja repressão compete diretamente aos Tribunais Administrativos franceses. Essas sanções administrativas jurisdicionalizadas encontram respaldo no Direito Administrativo francês, berço da jurisdição dúplice, onde se assentam as raízes mais profundas do tradicional conceito de sanção associada às funções administrativas. Daí a importância de se perceber, numa linha história e de direito comparado, aberturas eloquentes às sanções de Direito Administrativo, com seus consectários lógicos e sistêmicos. Não há dúvidas de que o Direito francês repercute influências no Direito brasileiro, senão de modo uniforme, ao menos como referência teórica e histórica. Por tal razão, não é de se estranhar que o sistema jurídico nacional comporte alternativas idôneas. No Direito brasileiro está consagrada a ideia de que juízes podem impor sanções administrativas, ainda que no desempenho de atividades jurisdicionais, desde que habilitados pelo legislador. Não configura, portanto, elemento indissociável da sanção administrativa a figura da autoridade administrativa, visto que podem as autoridades judiciárias, de igual modo, aplicar essas medidas punitivas, desde que outorgada, por lei, a respectiva competência repressiva, na tutela de valores protegidos pelo Direito Administrativo" (OSÓRIO, *Direito Administrativo Sancionador*, *op. cit.*, p. 97).

[89] Carolina Gazoni é advogada (PUC-SP, 2003), especialista em Gestão de Sustentabilidade (FGV – SP, 2008) e sócia fundadora da 360 Compliance, empresa de consultoria e treinamentos focada na implantação e disseminação de conceitos de compliance em organizações. Foi responsável pela área de Compliance de Mattos Engelberg Sociedade de Advogados durante os anos de 2016 e 2017, e do escritório Barreto Ferreira e Brancher Sociedade de Advogados entre 2011 e 2016. Desenvolveu, em conjunto com a o Instituto Euvaldo Lodi e CNI, metodologia para certificação de programas de compliance tendo como base as normas 19600 e 37001. É profissional certificada em Compliance e Ética pelo CCEP-I ("Certified Compliance & Ethics Professional") desde 2014. Durante 2017 e 2018, realizou 16 Cursos sobre Ética, Compliance e Eficiência Empresarial em todo o Brasil, tendo treinado mais de 300 de alunos no tema. É reconhecida pelo LACCA - Latin American Corporate Counsel Association (2014, 2015, 2016, 2017), membro da SCCE – Society of Corporate Compliance and Ethics, da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do IASP - Instituto dos Advogados de São Paulo e do Comitê Anticorrupção e Compliance da OAB e integra o grupo Master Mind da LEC - Legal and Ethics Institute.

[90] BRASIL. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas, Brasília, 2015, p. 9. Disponível em: <http://cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf>.

[91] BRASIL. CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. *Op. cit.*, p. 8.

[92] DELOITTE. Sarbanes-Oxley: Guia para Melhorar a Governança Corporativa através de Controles Internos. 2003, p. 6.

[93] INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código Brasileiro de Governança Corporativa, 5 ed, 2018, p. 16. Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/Publicacoes/Publicacao-IBGCCodigo-CodigodasMelhoresPraticasdeGC-5aEdicao.pdf>.

[94] INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. *Op. cit.*, p. 39.

[95] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICA. NBR ISO 19600. Sistema de Gestão de Compliance, 2016.

[96] *Idem*.

[97] ESTADOS UNIDOS. *US Department OF Justice and Enforcement Division of the US Securities and Exchange Comission*. FCPA - A *Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practises Act.* Disponível em: <https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act>.

[98] BRASIL. Decreto Federal nº. 8.240 de 18 de março de 2015.

[99] Vide Artigo 1009 do Código Civil.

[100] Há 24 anos atuando em consultoria de compliance, gestão de riscos e de Governança Corporativa para os segmentos de LifeSciences & HealthCare e para o Mercado de Capitais. Membro de Comitês de Compliance de associações do segmento financeiro e da área da saúde. Escritor de 2 livros (tesouraria e câmbio) junto a Febraban, além da Cartilha de Compliance junto a ABBI e Febraban e do Manual de Compliance - Preservando a boa Governança e a Integridade Corporativa vendido pela Editora Atlas. Membro efetivo da Comissão de Governança Corporativa para Instituições Financeiras do IBGC. Atuou como professor da pós-graduação da FIA do curso "Análise, Prevenção, Detecção e Riscos de Fraudes Empresarias" pelo período de 3 anos e atual professor do MBA de Governança de Compliance da UFSCAR. Contador e Economista, com MBA em Banking e em Administração de Marketing.

[101] Sócio e consultor líder na T4 Compliance. Advogado com experiência em compliance e jurídico contencioso em empresas nacionais e multinacionais. Foi Secretário Adjunto de Transparência e Combate à Corrupção no Governo de Mato Grosso, responsável pela criação e implementação do Programa de Integridade, um projeto pioneiro de mecanismos de Compliance no Setor Público. Foi membro da comissão responsável pela regulamentação da Lei Anticorrupção em Mato Grosso. Professor nos cursos de Compliance Anticorrupção da LEC - Legal, Ethics and Compliance e em cursos de pós-graduação na UFMT (Cuiabá/MT), Grupo Atame (Cuiabá/MT), Faculdade Baiana de Direito (Salvador/BA), Faculdade Pólis Civitas (Curitiba/PR) e Faculdade de Direito de Vitória (Vitória/ES).

Mestrando em Direito pela UFMT, com linha de pesquisa sobre "Corrupção, Compliance e Direitos Humanos e Fundamentais". Autor de artigos sobre compliance, gestão de riscos, governança pública e corporativa. [matheus.cdlr@terra.com.br].

[102] *Sócio da Pironti Advogados. Pós-Doutor em Direito pela Universidad Complutense de Madrid (Espanha). Doutor e Mestre em Direito Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. Especialista em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Vencedor do Prêmio Iberoamericano de Direito Administrativo/Contratual. Professor convidado da Universidade de La Plata – ARGENTINA, da Universidade de San Nicolas de Hidalgo e da Universidade Tecnológica de Monterrey – MÉXICO, da Escola de Gestão Pública Gallega e da Universidade Complutense de Madrid – ESPANHA, do "Centro Studi Giuridici Latinoamericani" – ITÁLIA. Professor da Escola Superior de Advocacia. Autor e coordenador de 11 obras jurídicas, dentre elas: - Compliance e Gestão de Riscos nas empresas Estatais. CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; GONÇALVES, Francine Silva Pacheco. Editora Fórum, 2018; Compliance, Gestão de Riscos e Combate à Corrupção: Integridade para o desenvolvimento. CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; PAULA, Marco Aurélio Borges de Paula. Editora Fórum, 2018. Autor de vários artigos em periódicos legais nacionais e internacionais. Conferencista em eventos nacionais e internacionais (ARGENTINA, MÉXICO, ESPANHA, ITÁLIA dentre outros).*

[103] BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 37, inciso XXI.

[104] BRASIL. Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. "Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos.
§ 1º - O Título I desta Lei, exceto o disposto nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27, não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista que tiver, em conjunto com suas respectivas subsidiárias, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior a R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais).
Art. 6º - O estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes desta Lei".

[105] Art. 69. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta Lei:
(...)
X - matriz de riscos.

[106] O tema é abordado em: NESTER, Alexandre Wagner. O risco do empreendimento nas parcerias público-privadas. *In:* TALAMINI, Eduardo; JUSTEN, Monica Spezia (coord.). Parcerias Público-Privadas: um enfoque multidisciplinar. São Paulo: RT, 2005, p. 174-192.

[107] Sobre o tema, conferir: PEREZ, Marcos Augusto. *O risco no contrato de concessão de serviço público.* Belo Horizonte: Fórum, 2006.

[108] BRASIL. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. "Art. 5º - Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; (...)
IV - no tocante a licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública".

[109] BRASIL. Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015.

[110] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Global. *Guia de avaliação de riscos de corrupção*. Nova York, 2013, p. 48.

[111] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Global. *Op. cit.*, p. 30.

[112] CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; GONÇALVES, Francine Silva Pacheco. *Compliance e gestão de riscos nas empresas estatais*. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 82-83.

[113] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR ISO 31000*, 2018, p. 5.

[114] BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. *Matriz de riscos: gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão*. Brasília, 2016, p. 7.

[115] BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. *Metodologia de gestão de riscos*. Brasília, 2018, p. 20.

[116] De acordo com a Norma ABNT NBR ISO 31000:2018 utiliza-se a nomenclatura "proprietário dos riscos". No entanto, entendemos que essa nomenclatura não é adequada, certo que, pelo modelo de gestão das "Três Linhas de Defesa" o proprietário do risco é o próprio gestor responsável pelo processo em que o risco poderá se materializar. Assim, entendemos mais adequado a nomenclatura "gestor dos riscos", que em se tratando de Riscos de Integridade poderá ser o *Compliance-Officer* da companhia.

[117] BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. *Op. cit*., p. 8.

[118] A conjugação dos fatores, portanto, não é impossível, mas dependerá do nível de maturidade de cada Entidade.

[119] Veja que a sintaxe do risco, com o objetivo de sua descrição, como regra adotará o seguinte formato: "Devido a <CAUSA>, poderá acontecer <DESCRIÇÃO DA INCERTEZA>, o que levaria <DESCRIÇÃO DO IMPACTO, CONSEQUÊNCIA, EFEITO> impactando no/na <DIMENSÃO DE OBJETIVO IMPACTADA>".

[120] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Global. *Op. cit.*, p. 30.

[121] *Formada em Ciências Econômicas na FEA-USP e em Direito na PUC-SP, com especialização em Compliance pela FGV-SP e em Comércio Internacional pelo World Trade Institute. Atualmente, é Gerente Executiva de Compliance da BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, sendo responsável pela disseminação da cultura da ética e implementação do Sistema de Integridade nas unidades da empresa, no Brasil e demais países onde a BRF opera. Antes, foi Gerente de Compliance no Grupo Pão de Açúcar, e atuou na criação da área e desenvolvimento do programa de integridade na companhia e suas subsidiárias. Trabalhou por mais de 10 anos no Pinheiro Neto Advogados, na condução de processos administrativos e judiciais relacionados a Defesa da Concorrência e Direito do Comércio Internacional.*

[122] *Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e post-MBA pela Kellogg School of Management da Northwestern University em Chicago. Há 21 anos atuando nas áreas de Auditoria Interna, Controladoria e Ética & Compliance, conduziu centenas de projetos de auditoria interna e investigações de Compliance e fraudes corporativas na América do Sul, Estados Unidos, Singapura e China. Atualmente é o responsável pela área de Ética e Compliance para a América do Sul da Bunge. Professor convidado nos cursos de Compliance Anticorrupção da Legal, Ethics and Compliance – LEC, Certified Expert em Compliance do Instituto ARC e na Pós-Graduação em Controles Internos e Compliance Officer da Daryus Escola de Negócios. Co-autor do livro Manual de Compliance (Instituto ARC 2017). Possui os certificados CFE (Certified Fraud Examiner) e CCEP-I (Certified Compliance and Ethics Professional – International).*

[123] BRASIL. Decreto Federal nº. 8.420, de 18 de março de 2015, *que regulamenta a Lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências*.

[124] BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Programa de integridade: diretrizes para empresas privadas.* Brasília, set. 2015. Disponível em <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf>. Acesso em 02 nov. 2018.

[125] BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. *Manual prático de avaliação de programa de integridade em PAR.* Brasília, set. 2018. Disponível em < http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/manual-pratico-integridade-par.pdf>. Acesso em 24 fev. 2019.

[126] ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME; BANCO MUNDIAL. *Anti-Corruption ethics and compliance handbook for business,* 2013. Disponível em <https://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthics ComplianceHandbook.pdf>. Acesso em 02 nov. 2018.

[127] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission. *A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act.* Disponível em <https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance>. Acesso em 02 nov. 2018.

[128] REINO UNIDO. Ministry of Justice. *The Bribery Act 2010 Guidance: about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing*, 2011. Disponível em <https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf>. Acesso em 02 nov. 2018.

[129] KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

[130] *Idem*.

[131] *Diretora de Compliance da PTC "Parametric Technology Brasil" na região da America Latina & Caribe desde 2017, estando baseada em São Paulo. É graduada pela Universidade Estadual de Londrina – UEL, com cursos de especialização e extensão na área de Intelectal Property Law and Policy pela Penn State e em Data Science Ethics pela Michigan University. Anteriormente, militou como advogada em renomadas bancas de advocacia na área internacional e de Compliance atuando com FCPA, legislação brasileira além de outras esparsas, tendo atuado também em multinacionais (Credicard, Grupo Abril, PwC e Solazyme Bunge). Na área de Compliance implementou diversos Programas, estruturou políticas de Controles, conduziu investigações internas, due diligence de M&A e terceiros, sendo responsável também pela elaboração de treinamentos para a alta administração e gestão.*

[132] INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Cartilha de Governança Corporativa. Disponível em: <https://www.ibgc.org.br/index.php/biblioteca/20113/Cartilha-de-governanca-corporativa>.

[133] A maioria da literatura acerca do tema Governança Corporativa teve desenvolvimento inicial na Inglaterra e Estados Unidos, haja vista que em tais países, grande parte das companhias apresentam uma estrutura de propriedade "pulverizada", ou seja; com a maior parte dos acionistas possuindo ações minoritárias negociadas em bolsas de valores.

[134] INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. *Op. cit.*

[135] De acordo com o site da SEC: "As ações da maioria das empresas estrangeiras que negociam no mercado americano são negociadas como *American Depositary Receipt* (*ADRs*). Bancos Depositários norte-americanos emitem essas ações. Cada *ADR* representa uma ou mais ações estrangeiras ou a fração de uma ação. Se você é dono de uma *ADR*, você possui o direito de obter a ação estrangeira que o representa, porém, a maioria dos investidores norte-americanos costumam achar conveniente manter a propriedade do próprio *ADR*" (SEC, 2013).

[136] Nas últimas décadas, houve um aumento vertiginoso nas *issuers* estrangeiras na Bolsa de Valores de Nova Iorque (New York Stock Exchange). Em 1975, apenas 2,12 % das companhias listadas eram estrangeiras. Em 2005, este percentual já era de 37%.

[137]As seções da SOX que interessam a análise dos temas aqui abordados versam sobre a responsabilidade corporativa, a divulgação das informações financeiras e sobre os controles internos. Seguem relacionadas resumidamente as principais Seções da referida Lei:

A Seção 301 exige que a empresa listada tenha um Comitê de Auditoria. As companhias brasileiras listadas na NYSE foram autorizadas pela SEC a incorporar ao Conselho Fiscal, que passa a ser chamado de Conselho Fiscal Turbinado, as atribuições do Comitê de Auditoria, conforme definidas pela Lei, visando adotar os atributos mínimos exigidos.

A Seção 302 exige que o CEO e CFO assinem cada relatório, que sejam responsáveis pelos controles internos e informem ao Comitê de Auditoria todas as deficiências, fraude material ou alterações significativas nos controles internos. A SEC recomenda formar um Comitê de Divulgação (com regulamento interno, cronograma de reuniões, participantes definidos, atas, etc...) que se encarregará de revisar todos os materiais legalmente exigidos para divulgação e também deverá se reunir regularmente para conferir todos os dados que serão publicados.

A Seção 401 exige que seja divulgada em relatórios periódicos financeiros, todas as transações ocorridas que não constem no balanço e também demonstre que o relatório está em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (*Generally Accepted Accounting Principles* – GAAP).

A Seção 402 proíbe a qualquer empresa fazer empréstimos pessoais quer direta, quer indiretamente, a um administrador ou gestor Executivo dessa empresa.

A Seção 404 exige que o CEO e CFO se responsabilizem pelo estabelecimento e manutenção de um adequado sistema de controles internos e que façam periodicamente uma avaliação sobre a eficácia desses controles. A Seção exige também que a Auditoria Independente emita dois pareceres dentro dos padrões definidos pela PCAOB, sendo um sobre a avaliação realizada pela administração e o outro sobre a efetividade desses controles internos.

A Seção 406 exige que a empresa adote um código de ética e conduta para os gestores, trazendo consigo um canal de denúncias.

A Seção 407 exige que faça parte do Comitê de Auditoria um perito em finanças com formação e experiência como contador, auditor, principal administrador financeiro, controller ou função similar, incluindo experiência em controles internos contábeis e entendimento das funções do Comitê de auditoria. A SOX admite que, não tendo a sociedade listada no mercado norte-americano um Comitê de Auditoria, todos os integrantes do Conselho de Administração possam exercer as funções que são atribuídas ao aludido Comitê, porém, deve-se levar em conta alguns princípios exigidos pela SEC.

A Seção 802 refere-se à fraude na contabilidade corporativa, prevendo penalidades criminais pela modificação de documentos. Estabelece multa e/ou prisão por alteração intencional, destruição, mutilação, ocultação, dissimulação, disfarce, falsificação ou falsa entrada de dados em que qualquer relatório ou documento. A referida seção prevê a guarda por cinco anos de relatórios de auditoria, papéis de trabalho, comunicados, memorandos, correspondências e outros, incluindo os eletrônicos, emitidos e recebidos em conexão com as atividades da auditoria. As empresas que não estiverem em conformidade com a SEC poderão receber sanções pecuniárias de US$ 1 milhão a US$ 5 milhões e/ou penais de dez a vinte anos de reclusão.

No mercado brasileiro, os resultados da seção 404 somente foram vislumbrados no ano de 2007, quando as companhias passaram a entregar para a SEC os resultados anuais de 2006 no relatório chamado de 20-F.

[138] ESTADO UNIDOS DA AMÉRICA. Texto original do *Securities Exchange Act* de 1934, disponível em: <http://legcounsel.house.gov/Comps/Securities%20Exchange%20Act%20Of%201934.pdf>.

[139]. BUSINESS WEEK. 2005.

[140]. "*O Espírito das Leis*": (em francês: "*De 'Esprit des lois*"), Obra Clássica escrita por Montesquieu, publicada em 1748, que elabora conceitos sobre formas de governo e exercícios da autoridade política que se tornaram pontos doutrinários básicos da ciência política. Suas teorias exerceram profunda influência no pensamento político moderno. Elas inspiraram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborada em 1789, durante a Revolução Francesa, além de preceitos modernos mundiais de governabilidade e democracia.

[141] Definição proposta pelo "The Board of Governors of the Federal Reserve System Trading Activities Manual".

[142] A gestão de riscos e a continuidade dos negócios, faz atualmente com que muitas empresas tenham instituídos de forma permanente ou esporádica Comitês de Gestão de Crises e Riscos. Referidos Comitês gerem danos já ocasionados em virtude da ocorrência de um risco ou ameaças concretas dele advindas.

[143] As três linhas de defesa foi uma metodologia criada pelo IIA ("*Institute of Internal Audits*).

[144] Para estruturação de controles e compliance em pequenas e médias empresa, recomendamos a leitura da obra da CGU – "Integridade para pequenos negócios". Disponível em <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/integridade-para-pequenos-negocios.pdf>.

[145] O método PDSA é também conhecido como o círculo/ciclo/roda de Deming, ciclo de Shewhart, círculo/ciclo de controle, ou PDSA (plan-do-study-act).

[146] Importante ressaltar que as metodologias de melhorias apontadas acima (5We 2H e PDSA) podem também ser utilizadas na fase de detecção e elaboração de riscos e na realização de auditorias.

[147] Para fins de comprovação do monitoramento de Controles Internos e melhoria contínua do Programa de Compliance, toda documentação referente a aplicação das metodologias 5We 2H e PDCA devem compor os arquivos da área, ainda que não sejam especificamente mandatórios em decorrência de lei.

[148] Há mais de 10 anos trabalha na implementação e gestão de programas de Compliance em empresas que passaram por escândalos governamentais e institucionais e processos de transformação de uma cultura mais integra e ética. Atuou em escritórios de advocacia e em empresas multinacionais e brasileiras em momentos de crise, ocasionados seja pela assinatura de um Deferred Prosecution Agreement (DPA) com o Departamento de Justiça dos EUA ou por acordos de leniência com o Banco Mundial e outros bancos de desenvolvimento. Também atuou em empresas envolvidas em escândalos nacionais como a Lava Jato. Atua como compliance officer não só no Brasil como por toda América Latina em especial Chile e Peru. Autor de artigos e conferencista em eventos de compliance nacionais e internacionais. Atualmente é responsável pela área de Compliance de uma grande empresa no setor elétrico no Brasil.

[149] Formada em Ciências Econômicas na FEA-USP e em Direito na PUC-SP, com especialização em Compliance pela FGV-SP e em Comércio Internacional pelo World Trade Institute. Atualmente, é Gerente Executiva de Compliance da BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, sendo responsável pela disseminação da cultura da ética e implementação do Sistema de Integridade nas unidades da empresa, no Brasil e demais países onde a BRF opera. Antes, foi Gerente de Compliance no Grupo Pão de Açúcar, e atuou na criação da área e desenvolvimento do programa de integridade na companhia e suas subsidiárias. Trabalhou por mais de 10 anos no Pinheiro Neto Advogados, na condução de processos administrativos e judiciais relacionados a Defesa da Concorrência e Direito do Comércio Internacional.

[150] Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e post-MBA pela Kellogg School of Management da Northwestern University em Chicago. Há 21

anos atuando nas áreas de Auditoria Interna, Controladoria e Ética & Compliance, conduziu centenas de projetos de auditoria interna e investigações de Compliance e fraudes corporativas na América do Sul, Estados Unidos, Singapura e China. Atualmente é responsável pela área de Ética e Compliance para a América do Sul da Bunge. Professor convidado nos cursos de Compliance Anticorrupção da LEC, Certified Expert em Compliance do Instituto ARC e na Pós-Graduação em Controles Internos e Compliance Officer da Daryus Escola de Negócios. Co-autor do livro Manual de Compliance (Instituto ARC 2017). Possui os certificados CFE (Certified Fraud Examiner) e CCEP-I (Certified Compliance and Ethics Professional – International).

[151] *Sócio e consultor líder na T4 Compliance. Advogado com experiência em compliance e jurídico contencioso em empresas nacionais e multinacionais. Foi Secretário Adjunto de Transparência e Combate à Corrupção no Governo de Mato Grosso, responsável pela criação e implementação do Programa de Integridade, um projeto pioneiro de mecanismos de Compliance no Setor Público. Foi membro da comissão responsável pela regulamentação da Lei Anticorrupção em Mato Grosso. Professor nos cursos de Compliance Anticorrupção da LEC - Legal, Ethics and Compliance e em cursos de pós-graduação na UFMT (Cuiabá/MT), Grupo Atame (Cuiabá/MT), Faculdade Baiana de Direito (Salvador/BA), Faculdade Pólis Civitas (Curitiba/PR) e Faculdade de Direito de Vitória (Vitória/ES). Mestrando em Direito pela UFMT, com linha de pesquisa sobre "Corrupção, Compliance e Direitos Humanos e Fundamentais". Autor de artigos sobre compliance, riscos, governança pública e corporativa. [matheus.cdlr@terra.com.br].*

[152] ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS. *Report to the Nations 2018: global study on occupational fraud and abuse*. 2018.

[153] BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. *Manual prático de avaliação de programa de integridade em PAR.* Brasília, set. 2018. Disponível em <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/ etica-e-integridade/arquivos/manual-pratico-integridade-par.pdf>. Acesso em 24 fev. 2019.

[154] BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Programa de integridade: diretrizes para empresas privadas.* Brasília, set. 2015. Disponível em <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/ programa- de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf>. Acesso em 14 abr. 2019.

[155] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Fraud Section of the Criminal Division of the U.S. Department of Justice. *Evaluation of Corporate Compliance Programs.* Disponível em <https://www.justice.gov/ criminal-fraud/page/file/937501/download>. Acesso em 14 abr. 2019.

[156] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission. *A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act.* Disponível em <https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance>. Acesso em 20 nov. 2018, p. 61: *Um programa de compliance efetivo deve incluir um mecanismo para os funcionários de uma organização relatarem más condutas ou violações suspeitas ou reais das políticas da empresa, com confidencialidade e sem medo de retaliação. As empresas podem empregar, por exemplo, linhas telefônicas anônimas ou ombudsmen. Além disso, uma vez que uma alegação é feita, as empresas devem ter em vigor um processo eficiente, confiável e adequadamente financiado para investigar a alegação e documentar a resposta da empresa, incluindo quaisquer medidas disciplinares ou corretivas tomadas. As empresas devem tirar "lições aprendidas" de quaisquer violações relatadas e o resultado de qualquer investigação adicional para atualizar seus controles internos e programa de compliance, além de focar em treinamento futuro sobre tais questões, conforme apropriado.* (Tradução Livre).

[157] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Sarbanes-Oxley Act, 2002. Public Law 107-204 JULY 30, 2002. Disponível em https://pcaobus.org/About/History/Documents/PDFs/Sarbanes_Oxley_Act_of_2002.pdf: SEC. 301. COMITÊS DE AUDITORIA DAS EMPRESAS PÚBLICAS. *A Seção 10A do Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78f) é emendada adicionando ao final, pelo seguinte:[…] (4) RECLAMAÇÕES. - Cada comitê de auditoria deve estabelecer procedimentos para: (A) o recebimento, retenção e tratamento de reclamações recebidas pelo emissor em relação a questões contábeis, controles contábeis internos ou questões de auditoria; e (B) a apresentação confidencial e anônima, pelos funcionários do emissor, de preocupações relativas a questões contábeis ou de auditoria questionáveis.* (Tradução Livre).

[158] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Whistleblower Protection Advisory Committee (WPAC). *Best Practices for Protecting Whistleblowers and Preventing and Addressing Retaliation*, April 21, 2015. Disponível em https://www.whistleblowers.gov/sites/default/files/2016-11/WPAC_BPR_42115.pdf, p. 5-6: *A melhor maneira de impedir a retaliação é adotar uma abordagem preventiva, começando com um programa real para garantir que os funcionários possam suscitar preocupações. As sementes de retaliação são plantadas quando os problemas dos funcionários não são bem-vindos ou não são atendidos. Portanto, os empregadores devem fomentar uma cultura de "manifestar-se" que incentive a comunicação, forneça uma avaliação justa e uma resolução justa e efetiva das preocupações. […] Para garantir que os problemas não sejam perdidos, a denúncia anônima deve estar disponível. [...] A retaliação contra denunciantes geralmente decorre de falhas anteriores da administração para tratar de questões que os funcionários acreditam ser importantes ou que, de outra forma, acreditam ter a obrigação de denunciar. Um sistema efetivo de resposta a retaliações deve incluir um processo independente de revisão de reclamações e uma linha de reporte independente que pode alcançar o conselho ou o órgão de supervisão do empregador, se necessário. O sistema deve incluir funções, responsabilidades e expectativas claramente definidas para os principais líderes, membros do conselho, gerentes de todos os níveis, funcionários, conformidade e equipe jurídica, bem como equipes de RH e de relações trabalhistas. Os procedimentos devem ser conhecidos e acessíveis a todos. […] Assim como o relatório de problemas, o sistema de resposta de retaliação deve incluir vários caminhos para relatórios, incluindo oportunidades fora da cadeia de comando e uma linha direta, incluindo relatórios anônimos.* (Tradução Livre).

[159] BRASIL. Controladoria-Geral da União. Ouvidoria-Geral da União. *Instrução Normativa nº 01 de 05 de novembro de 2014*. Disponível em http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/legislacao/in/in-cgu-04.pdf

[160] BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Instrução Normativa Conjunta nº 01 CRG/OGU de 04 de julho de 2014.* Disponível em http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/legislacao/in/instrucao-normativa-conjunta-n-01-2014-ogu0001.pdf

[161] BRASIL. Controladoria-Geral da União. Ouvidoria-Geral da União. *Manual para Ouvidores Federais,* Brasília: 2015 Disponível em http://www.ouvidorias.gov.br/ouvidorias/legislacao/instrucao-normativa/manual-instrucao-normativa.pdf

[162] BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Op. cit.,* p. 21.

[163] BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. *Op. cit.*, p. 54.

[164] BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. *Op. cit.*, p. 54.

[165]. *Sócia do WFaria Advogados e da LEC. Graduada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial e mestre em Direito Comercial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), também tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Suas pesquisas foram conduzidas na Universidade de Harvard (EUA). Professora e coordenadora de cursos da LEC, palestrante, conferencista e escritora de artigos para imprensa local e internacional, é ainda autora e coordenadora do livro "Compliance - A Nova*

Regra do Jogo" (LEC, 2016), além de ter participado dos livros "Compliance na Saúde: presente e futuro de um mercado em busca da auto-regulamentação" (Criarmed, 2016) e "Lei Anticorrupção e Temas de Compliance" (Juspodivm, 2017).

[166] *Advogado especialista em Compliance com 10 anos de experiência em empresa europeia e norte-americana. Atualmente é Diretor Sênior de Compliance para a América Latina. E também coordenador do Curso de Compliance Anticorrupção da LEC e autor de diversas publicações relacionadas a área de compliance e combate à corrupção.*

[167] É recomendável que a gestão relativa às investigações internas seja atribuída a área de compliance ou comitê de ética. As demais áreas da empresa, como auditoria, recursos humanos e jurídico (quando não integrado à compliance, o que seria o ideal), deveriam ser apoiadoras da área de compliance em relação a este e outros temas de compliance, mas, como as investigações internas correspondem a um dos pilares de um programa efetivo de compliance, este deveria estar sob a responsabilidade da área de compliance ou do comitê para o qual se reporta.

[168] Este é um termo utilizado nas investigações internas e se refere aqueles profissionais que custodiam informações relevantes e cujos dados disponíveis em equipamentos eletrônicos da empresa serão coletados e analisados e/ou que serão entrevistados.

[169] Como já destacamos, é essencial que a área de compliance seja responsável pela gestão das investigações internas, podendo, dependendo do tema da investigação, solicitar a condução por outras áreas, mas devendo sempre acompanhar os procedimentos que estão sendo adotados e se os prazos previamente definidos estão sendo respeitados.

[170]. *Sócio e consultor líder na T4 Compliance. Advogado com experiência em compliance e jurídico contencioso em empresas nacionais e multinacionais. Foi Secretário Adjunto de Transparência e Combate à Corrupção no Governo de Mato Grosso, responsável pela criação e implementação do Programa de Integridade, um projeto pioneiro de mecanismos de Compliance no Setor Público. Foi membro da comissão responsável pela regulamentação da Lei Anticorrupção em Mato Grosso. Professor nos cursos de Compliance Anticorrupção da LEC - Legal, Ethics and Compliance e em cursos de pós-graduação na UFMT (Cuiabá/MT), Grupo Atame (Cuiabá/MT), Faculdade Baiana de Direito (Salvador/BA), Faculdade Pólis Civitas (Curitiba/PR) e Faculdade de Direito de Vitória (Vitória/ES). Mestrando em Direito pela UFMT, com linha de pesquisa sobre "Corrupção, Compliance e Direitos Humanos e Fundamentais". Autor de artigos sobre compliance, gestão de riscos, governança pública e corporativa. [matheus.cdlr@terra.com.br].*

[171] Na prática diária os termos *programa*, *sistema*, *mecanismo* etc. são tratados sem qualquer diferenciação, assim como *compliance*, *conformidade*, *integridade* etc. Não há grandes consequências práticas. No entanto, academicamente, a semântica provoca uma sensível alteração dos significados, propósitos e requisitos dos institutos. Como o objetivo deste texto não é o aprofundamento acadêmico sobre este tema em específico (que poderia facilmente ser objetivo de uma tese) serão tratados como sinônimos, mas registra-se que na concepção do autor o melhor termo a se empregar seria *Sistema de Integridade*.

[172] AYRES, Carlos Henrique da Silva. *Utilização de terceiros e operações de fusões e aquisições no âmbito do Foreign Corrupt Practices Act: riscos e necessidade da due diligence anticorrupção. In:* DEBBIO, Alessandra Del; MAEDA, Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da Silva (Org). Temas de anticorrupção & compliance. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, p. 204.

[173] CEB COMPLIANCE & ETHICS LEADERSHIP COUNCIL. *CEB 2015 Third-Party Risk Diagnostic*. 2015.

[174] Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...)

II - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

[175] ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. *OECD Foreign Bribery Report: an analysis of the crime of bribery of foreign public officials*. Paris: OCDE, 2014, p. 28.

[176] ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. *Typologies on the Role of Intermediaries in International Business Transactions*. Final Report. Paris: OCDE, 2009, p. 5.

[177] *Office of the Comptroller of the Currency* (OCC) é uma agência independente do Departamento do Tesouro americano que organiza, regula e supervisiona todos os bancos e associações federais de poupança, agências federais e de bancos estrangeiros nos EUA.

[178] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Office of the Comptroller of the Currency. *Advisory Letter 1998-14: Fiduciary Services and Year 2000 Readiness*. Washington D.C., 03 set. 1998.

[179] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *The Foreign Corrupt Practices Act*. §78dd-1(a)(3); §78dd-2(a)(3); §78dd-3(a)(3): [...] *qualquer pessoa, sabendo que toda ou parte de tal dinheiro ou coisa de valor será oferecida, dada ou prometida, direta ou indiretamente, a qualquer autoridade estrangeira, a qualquer partido político estrangeiro ou seu oficial, ou a qualquer candidato a estrangeiro cargo político, para fins de* [...]. (Tradução livre).

[180] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission. *A Resource Guide to the FCPA U.S. Foreign Corrupt Practices Act.* Disponível em <https://www.justice.gov/criminal-fraud/fcpa-guidance>. Acesso em 02 nov. 2018, p. 57: *Empresas individuais podem ter diferentes necessidades de compliance, dependendo de seu tamanho e dos riscos específicos associados a seus negócios, entre outros fatores. Quando se trata de compliance, não existe um programa de tamanho único para todos*. (Tradução livre).

[181] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Op. cit.,* p. 59: *O DOJ e a SEC darão crédito significativo a uma empresa que implemente de boa-fé um programa abrangente de compliance baseado em risco, mesmo que esse programa não impeça uma infração em uma área de baixo risco, porque maior atenção e mais recursos devem ser dedicados a uma área de risco mais alto*. (Tradução livre).

[182] Art. 4º da Lei nº. 12.846/2013. *Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária*.

§ 1º - *Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovados*.

[183] Para o risco geográfico global de corrupção pode ser utilizado como critério o *Corruption Perception Index* (CPI) ou Índice de Percepção da Corrupção (IPC) da Transparência Internacional, que está disponível em https://www.transparency.org/research/cpi/overview.

[184] O Transparência Internacional classificou no ranking *Bribe Payers Index* (BPI) ou Índice de Pagadores de Suborno os 19 setores da economia que estão mais propensos ao suborno de agentes públicos, que está disponível em https://www.transparency.org/whatwedo/publication/bpi_2011.

[185] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Op. cit.,* p. 61: *A due diligence baseada em riscos é particularmente importante com terceiros e também será considerada pelo DOJ e pela SEC na avaliação da eficácia do programa de compliance de uma empresa. Embora o grau de devida diligência apropriada possa variar com base na indústria, país, tamanho e natureza da transação, e relacionamento histórico com o terceiro, alguns princípios orientadores sempre se aplicam.* (Tradução Livre).

[186] INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE. *ICC anti-Corruption third party due diligence: a guide for small and medium size enterprises*. Paris: ICC Policy and Business Practices, 2015.

[187] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Op. cit.,* p. 61: *Primeiro, como parte da due diligence baseada em risco, as empresas devem entender as qualificações e associações de seus parceiros terceirizados, incluindo sua reputação comercial e relacionamento, se houver, com autoridades estrangeiras. O grau de precisão deve aumentar à medida que as bandeiras vermelhas aparecerem. Em segundo lugar, as empresas devem ter uma compreensão da lógica de negócio para incluir o terceiro na transação. Entre outras coisas, a empresa deve entender o papel e a necessidade do terceiro e garantir que os termos do contrato descrevam especificamente os serviços a serem executados. Considerações adicionais incluem termos de pagamento e como esses termos de pagamento se comparam aos padrões nesse setor e país, bem como o momento da introdução do terceiro à empresa. Além disso, as empresas podem querer confirmar e documentar que o terceiro está realmente realizando o trabalho para o qual está sendo pago e que sua remuneração é compatível com o trabalho que está sendo realizado. Em terceiro lugar, as empresas devem realizar alguma forma de monitoramento contínuo de relacionamentos com terceiros. Quando apropriado, isso pode incluir a atualização da due diligence periodicamente, o exercício de direitos de auditoria, o treinamento periódico e a solicitação de certificações anuais de conformidade pelo terceiro.* (Tradução livre).

[188] BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Manual Prática de Avaliação de Programas de Integridade em Processos Administrativos de Responsabilização (PAR)*. Brasília, 2018, p. 49.

[189] BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Op. cit.*, p. 50.

[190] BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Op. cit.*, p. 50.

[191] FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL. Partnering Against Corruption Initiative (PACI). *Good Practice Guidelines on Conducting Third-Party Due Diligence*. Genebra: WEF, 2013, p. 13.

[192] FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL. *Op. cit.,* p. 45.

[193] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Op. cit.,* p. 22-23.

[194] ELLIS, Matteson. *The Master List of Third Party Corruption Red Flags*. FCPAméricas, 02 abr. 2014. Disponível em http://fcpamericas.com/english/anti-corruption-compliance/master-list-party-corruption-red-flags.

[195] DOYLE, Marjorie W. *Third-Party Essentials: A Reputation/Liability Checkup When Using Third Parties Globally*. Minneapolis: Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE), 2011. Disponível em https://assets.corporatecompliance.org/Portals/1/PDF/Resources/ThirdPartyEssentials-Doyle.pdf.

[196] ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *Op. cit.,* p. 61.

[197] FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL. *Op. cit.,* p. 13: *A responsabilidade dos processos de avaliação de risco e due diligence deve ser daqueles que desejam se relacionar com terceiros - normalmente uma unidade de negócios - em consulta aos principais especialistas na organização (por exemplo, área de compliance e jurídico). As pessoas responsáveis pela avaliação de risco devem documentar o processo de classificação com detalhes razoáveis e renovar a avaliação periodicamente (por exemplo, uma vez a cada três anos). Uma vez concluídos os processos de avaliação de riscos e due diligence, a organização deve aplicar um sistema claro de aprovação para determinar se deve ou não avançar com o terceiro: - Para terceiros de baixo risco, é apropriado que a gestão do negócio seja da unidade responsável pela aprovação do relacionamento comercial. -* ***Para terceiros de médio a alto risco, deve haver no mínimo duas unidades de negócios envolvidas no processo de aprovação: a administração da unidade de negócios, e outro nível de gerenciamento que não tem nada a ganhar com a seleção do terceiro (por exemplo, jurídico ou compliance).*** *Toda a documentação relacionada aos processos de avaliação de risco, due diligence e da avaliação de red flags deve ser assinada pelas partes responsáveis e retida pela organização.*

[198] BRASIL. Controladoria-Geral da União. *Op. cit.*, p. 51.

[199] FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL. *Op. cit.,* p. 14.

[200] FREIRE, Rodrigo. *Compliance e uso de terceiro intermediário. In:* CARVALHO, André Castro *et. al.* (Coord.). Manual de Compliance. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 139.

[201] FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL. *Op. cit.,* p. 14.

[202]. Diretora de Compliance da PTC "Parametric Technology Brasil" na região da America Latina & Caribe desde 2017, estando baseada em São Paulo. É graduada pela Universidade Estadual de Londrina – UEL, com cursos de especialização e extensão na área de Intelectal Property Law and Policy pela Penn State e em Data Science Ethics pela Michigan University. Anteriormente, militou como advogada em renomadas bancas de advocacia na área internacional e de Compliance atuando com FCPA, legislação brasileira além de outras esparsas, tendo atuado também em multinacionais (Credicard, Grupo Abril, PwC e Solazyme Bunge). Na área de Compliance implementou diversos Programas, estruturou políticas de Controles, conduziu investigações internas, due diligence de M&A e terceiros, sendo responsável também pela elaboração de treinamentos para a alta administração e gestão.

[203] Os seguintes órgãos podem iniciar a investigação de atos de corrupção decorrentes da Lei 12.846/2013 e o Decreto 8420/2015: Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, Vítima, SEC, DOJ, CADE, TCU e Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União.

[204] THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. *Normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna. Florida*, 2017, p. 21-22.

[205] ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS. *Report to the Nations 2018: global study on occupational fraud and abuse*. 2018, p. 6.

[206] CRESSEY, Donald R. The criminal violation of financial trust. American Sociological Review, 15 (6), p.738-743, December, pp.1-15, 1950.

[207] JENSEN M. e MECKLING, W. Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure. *Journal os Financial Economics*, p. 305-360, 1976.

[208] Com base na pesquisa global editada pela KPMG no ano de 2016 – "*The profile of the fraudster*" – muito utilizada em estudos de fraudes, que investigou 750 fraudadores, concluiu que o perpetrador de fraude tende a ser do sexo masculino entre as idades de 36 e 55 anos, trabalhando com a organização vítima por mais de seis anos e ocupando uma posição executiva em operações, finanças ou

administração geral. Além disso, a referida pesquisa verificou que: (i) 79% por cento dos fraudadores são homens; (ii) 68% por cento dos perpetradores de fraudes (homens e mulheres) têm idade entre 36 e 55 anos; (iii) e 14% por cento dos fraudadores estão na faixa etária de 26 a 35 anos.

[209]Segundo a Pesquisa do Perfil do Fraudador também referidas acima, reiterando estatísticas anteriormente obtidas, a maioria das denúncias relativas a fraudes são feitas de forma anônima por colaboradores utilizando o canal do *hotline* do Programa de Compliance.

[210] Hoje já estão disponíveis no mercado dezenas de ferramentas que monitoram em tempo real *fulltime* os movimentos globais de *cyber attacks* (Cyber Security Services).

[211] A tratativa da fraude originariamente era atribuição da área de auditoria interna. Entretanto, recentemente passou a ser atribuição da área de Compliance ou da Ouvidoria interna.

[212] MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco Javier *et al.* La importancia relativa en auditoría: Las nuevas normas internacionales en comparación con la normativa vigente en Iberoamérica. *Contaduría y administración*, n. 230, p. 77-103, 2010.

[213] A Seção 301 exige que as empresas com ações listadas em bolsas de valores americanas tenham tenha um Comitê de Auditoria. As companhias brasileiras listadas na NYSE foram autorizadas pela SEC a incorporar ao Conselho Fiscal, que passa a ser chamado de Conselho Fiscal Turbinado, as atribuições do Comitê de Auditoria, conforme definidas pela Lei, visando adotar os atributos mínimos exigidos.

A Seção 302 exige que o CEO e CFO assinem cada relatório, que sejam responsáveis pelos controles internos e informem ao Comitê de Auditoria todas as deficiências, fraude material ou alterações significativas nos controles internos. A SEC recomenda formar um Comitê de Divulgação (com regulamento interno, cronograma de reuniões, participantes definidos, atas, etc...) que se encarregará de revisar todos os materiais legalmente exigidos para divulgação e também deverá se reunir regularmente para conferir todos os dados que serão publicados.

A Seção 401 exige que seja divulgada em relatórios periódicos financeiros, todas as transações ocorridas que não constem no balanço e também demonstre que o relatório está em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (*Generally Accepted Accounting Principles* – GAAP).

A Seção 402 proíbe a qualquer empresa fazer empréstimos pessoais quer direta, quer indiretamente, a um administrador ou gestor Executivo dessa empresa.

A Seção 404 exige que o CEO e CFO se responsabilizem pelo estabelecimento e manutenção de um adequado sistema de controles internos e que façam periodicamente uma avaliação sobre a eficácia desses controles. A Seção exige também que a Auditoria Independente emita dois pareceres dentro dos padrões definidos pela PCAOB, sendo um sobre a avaliação realizada pela administração e o outro sobre a efetividade desses controles internos.

A Seção 406 exige que a empresa adote um código de ética e conduta para os gestores, trazendo consigo um canal de denúncias.

A Seção 407 exige que faça parte do Comitê de Auditoria um perito em finanças com formação e experiência como contador, auditor, principal administrador financeiro, controller ou função similar, incluindo experiência em controles internos contábeis e entendimento das funções do Comitê de auditoria. A SOX admite que, não tendo a sociedade listada no mercado norte-americano um Comitê de Auditoria, todos os integrantes do Conselho de Administração possam exercer as funções que são atribuídas ao aludido Comitê, porém, deve-se levar em conta alguns princípios exigidos pela SEC.

A Seção 802 refere-se à fraude na contabilidade corporativa, prevendo penalidades criminais pela modificação de documentos. Estabelece multa e/ou prisão por alteração intencional, destruição, mutilação, ocultação, dissimulação, disfarce, falsificação ou falsa entrada de dados em que qualquer relatório ou documento. A referida seção prevê a guarda por cinco anos de relatórios de auditoria, papéis de trabalho, comunicados, memorandos, correspondências e outros, incluindo os eletrônicos, emitidos e recebidos em conexão com as atividades da auditoria. As empresas que não estiverem em conformidade com a SEC poderão receber sanções pecuniárias de US$ 1 milhão a US$ 5 milhões e/ou penais de dez a vinte anos de reclusão.

No mercado brasileiro, os resultados da seção 404 somente foram vislumbrados no ano de 2007, quando as companhias passaram a entregar para a SEC os resultados anuais de 2006 no relatório chamado de 20-F.

[214] THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. *Definition of Internal Auditing*. 2019.

[215] A legislação brasileira não fez menção aos consorciados, clientes e relacionamentos de joint-ventures, cumprindo a jurisprudência futura fixar diretrizes de responsabilidade para tais tipos de relacionamento.

[216] No setor fabril de empresas que possuem Programa de Compliance implantado, um procedimento muito comum junto a terceiros e fornecedores é a denominada "*Certificação de Terceiros*", que nada mais é, do que uma auditoria junto a terceiros e/ou fornecedores em que se inspeciona se a parte auditada após o procedimento inicial de "*on boarding*" possui condições de permanecer e manter os padrões exigidos por parte de uma empresa auditora em seu ecossistema de terceiros e/ou fornecedores. Na certificação de terceiros, o espectro de análise dado ao risco em exposição no setor fabril, muitas vezes, inclui a análise de temas de saúde e segurança do trabalho, além de ambiental e aspectos de qualidade no processo de fabricação. Um exemplo clássico de problemas ocasionados por terceiros que acarretaram novas práticas de Compliance no Brasil é o da confecção espanhola Zara, que foi autuada pelo Ministério Público do Trabalho, por responsabilidade objetiva, tendo que pagar quantias vultosas de multas aplicadas, posto que ficou configurado que em sua cadeia de terceiros e fornecedores, ela indiretamente utilizava mão-de-obra em condições análogas a de trabalho escravo. No procedimento da Certificação de terceiros, na maioria das vezes, o trabalho de auditoria é realizado pela própria equipe de Compliance.

[217] Como ferramenta alternativa de avaliação de um Programa de Compliance, sugerimos a utilização do aplicativo disponível em www.theintegrityapp.com

[218] Art. 42. Para fins do disposto no § 4º do art. 5º, o programa de integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros: I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa; II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos; III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; V - análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade; VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da

pessoa jurídica; VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da pessoa jurídica; VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões; IX - independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento; X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé; XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade; XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados; XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas; XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013; e XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos.

§ 1º Na avaliação dos parâmetros de que trata este artigo, serão considerados o porte e especificidades da pessoa jurídica, tais como: I - a quantidade de funcionários, empregados e colaboradores; II - a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de departamentos, diretorias ou setores; III - a utilização de agentes intermediários como consultores ou representantes comerciais; IV - o setor do mercado em que atua; V - os países em que atua, direta ou indiretamente; VI - o grau de interação com o setor público e a importância de autorizações, licenças e permissões governamentais em suas operações; VII - a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o grupo econômico; e VIII - o fato de ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 2º A efetividade do programa de integridade em relação ao ato lesivo objeto de apuração será considerada para fins da avaliação de que trata o caput.

§ 3º Na avaliação de microempresas e empresas de pequeno porte, serão reduzidas as formalidades dos parâmetros previstos neste artigo, não se exigindo, especificamente, os incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e XV do caput.

§ 4º Caberá ao Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União expedir orientações, normas e procedimentos complementares referentes à avaliação do programa de integridade de que trata este Capítulo.

§ 5º A redução dos parâmetros de avaliação para as microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o § 3º poderá ser objeto de regulamentação por ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa e do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União.

[219] BRASIL. Controladoria-Geral da União. Portaria nº. 909, de 07 de abril de 2015. Disponível em <http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/portarias/portaria_cgu_909_2015.pdf>.

[220] BRASIL. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. Manual prático de avaliação de programa de integridade em Processo Administrativo de Responsabilização (PAR). Disponível em <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/manual-pratico-integridade-par.pdf>.

[221] Com relação a Cultura Organizacional de Integridade (COI), a empresa em exame deverá responder as seguintes perguntas: (i) A PJ possui uma estrutura organizacional formalizada, isto é: prevista em estatuto, contrato social, regimento interno ou outro normativo?; (ii) A estrutura organizacional está divulgada para o público interno?; (iii) A PJ disponibiliza informações sobre sua estrutura organizacional em sua página eletrônica?; (iv) A PJ possuiu em sua estrutura organizacional órgão(s) colegiado(s) para tratar de temas de ética e integridade que contam com a participação de membros da alta administração, como comitês e conselhos de ética?(v) A forma como ocorre a participação dos membros da alta administração nesse(s) órgão(s) está formalizada?; (vi) foram apresentados documentos que comprovam a realização de mais de uma reunião nos últimos doze messes, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade no PAR?

Com relação ao suporte da alta administração: (i) A PJ possui critérios formalizados para escolha dos membros da alta direção que incluem elementos de integridade, como o não envolvimento em atos de corrupção?; (ii) A aprovação das principais políticas relacionadas ao Programa de Compliance é feita pelas mais elevadas instâncias decisórias da PJ?; (iii)Os membros da alta direção da PJ participa da supervisão das atividades relacionadas ao Programa de Integridade?; Os membros da alta direção da PJ participaram de treinamentos sobre o Programa de integridade nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade no PAR?; (iv)Os membros da alta direção da PJ envolvidos nos atos lesivos ora investigados permanecem em seus cargos ou em outros cargos da alta administração da PJ?; Foram apresentadas manifestações de apoio ao programa de integridade feitas pela PJ? As manifestações de apoio apresentadas: a) São pessoalizadas, isto é, são manifestações assinadas diretamente pelos membros da alta administração que atuam na PJ ora avaliada?; b) Foram feitas de forma periódica (não isolada) nos últimos 12 meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade no PAR?; Foram feitas por membros da alta administração dos relatórios de perfil e conformidade no PAR?; d) Possuem conteúdo que expressa uma mensagem de incentivos para os empregados adotarem uma conduta ética, seguindo os ditames do programa de integridade?;e) São dirigidas ao público interno da PJ?; f) são dirigidas ao público externo da PJ? (v) A PJ deixou de apresentar evidências sobre o comprometimento e o apoio dos membros da alta administração ao Programa de integridade. Para indicar sim como resposta, o avaliador deve ter respondido NÃO (zero) a todas as demais perguntas do item 2.

Com relação a instância responsável pelo programa de Integridade: (i) A PJ possui uma instância interna responsável pelo Programa de integridade? (ii) A instância responsável pelo programa de integridade: a) Está formalmente constituída?; (b) Tem suas atribuições expressamente previstas em documento formal, aprovado pela alta direção da PJ?; c) Constitui um departamento específico da PJ, com atribuições relacionadas exclusivamente ao programa de integridade? d) Possui autonomia decisória, não estando subordinada a outros departamentos como Jurídico, Recursos Humanos, Auditoria Interna ou Financeiro? Existem empregados dedicados exclusivamente às atividades relacionadas ao programa de integridade; f) O responsável pela instância interna possui como prerrogativa a possibilidade de se reportar diretamente ao nível hierárquico mais elevado da PJ? g) Essa prerrogativa é de fato exercida, sendo possível constatar que nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade no PAR, o representante da instância interna responsável pelo programa se reuniu com o nível hierárquico mais elevado da PJ mais de uma vez? h) O responsável pela instância interna possui garantias expressas que possibilitam o exercício das suas atribuições com independência e autoridade, como proteção contra punições arbitrárias, mandato, autonomia para solicitar documentos e entrevistar empregados de qualquer departamento da PJ? (i) A PJ deixou de apresentar evidências sore a existência e o funcionamento de uma instância interna responsável pelo programa de integridade. Para indicar SIM como resposta, o avaliador deve ter respondido NÃO (zero) a todas as demais perguntas do item 3.

Com relação ao Código de Ética ou outros documentos equivalentes:(i) A PJ apresentou Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, disponível em Português?; (ii) A PJ deixou de apresentar Código de Ética ou de Conduta, ou documento equivalente, disponível em português? Se SIM como resposta, o avaliador deve responder NÃO (zero) a todas as demais perguntas do item 4. (iii) O documento foi formalmente aprovado pela alta direção da PJ? Em relação ao conteúdo do documento apresentado: a) Incluiu ética e/ou

integridade entre os princípios ou valores da PJ? b) Menciona a possibilidade de aplicação de sanções para os terceiros que cometerem violações éticas/legais?(iv) A PJ disponibiliza versões desse documento ou informa como ele pode ser acessado por esses terceiros?; (v) A PJ solicita que os terceiros declarem expressamente estarem cientes da existência desse documento e de seu conteúdo? (vi) Foram oferecidos treinamentos, nos últimos dois anos, sobre seu conteúdo aos principais terceiros com os quais a PJ se relaciona? (vii) A PJ deixou de apresentar evidências de realização de treinamentos sobre os seus padrões de conduta e ética para os agentes intermediários que atuam em seu nome, nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfile e conformidade no PARs?

Com relação a estrutura para realização de treinamentos relacionados ao Programa de Integridade: (i) A PJ apresentou um planejamento para a realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade? (ii) A instância responsável pelo programa de integridade participa do planejamento, elaboração, aplicação e/ou contratação dos treinamentos sobre temas de integridade? (iii) Existem controles para verificar a participação dos empregados nos treinamentos? (iv) Existem mecanismos para verificar a retenção dos conteúdos abordados nos treinamentos?

Com relação a realização de análise de riscos para a elaboração e/ou aperfeiçoamento do Programa de Integridade: (i) A PJ realizou uma análise de riscos que contempla expressamente riscos relacionados a corrupção e fraude? (ii) A análise de riscos foi realizada (ou refeita) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade no PARs? (iii) Há planejamento para que a análise de riscos seja realizada de forma periódica?

Com relação a prevenção de ilícitos nas interações da PJ com a Administração Pública: (i) A PJ apresentou políticas e procedimentos que: (i) A PJ apresentou políticas e procedimentos que: (a) vedam expressamente a concessão de vantagens indevidas, econômicas ou não, a agentes públicos? (b) Tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes Públicos? (c) Tratam da prevenção de conflitos de interesse nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos e seus familiares? (d) Estabelecem orientações e controles sobre temas como realização de reuniões, encontros e outros tipos de interações entre administradores e empregados da PJ com agentes públicos? (e) Estabelece orientações específicas para que seus administradores, empregados ou terceiros agindo em nome da PJ cooperem com eventuais investigações e fiscalizações realizadas por órgãos, entidades ou agentes públicos? (ii) As políticas e procedimentos foram abordados nos treinamentos realizados pela PJ nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade no PAR? (iii) Foram apresentados documentos que comprovam a aplicação nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade no PAR, das políticas e procedimentos que tratam dos seguintes temas: (a) oferecimento de brindes, presentes e hospitalidade? (b) Conflito de Interesses; (c) Interações com agentes públicos, como realização de reuniões e encontros? (iv) A PJ apresentou documentos que indicam o monitoramento da aplicação de políticas e procedimentos apresentados, como relatórios periódicos, estatísticas e indicadores? (v) A PJ deixou de apresentar políticas e procedimentos adaptados à legislação brasileira. (vi) A PJ deixou de apresentar evidências de que disponibiliza versões em português de suas políticas e procedimentos para as partes interessadas; (vii) A PJ deixou de apresentar evidências sobre a existência de políticas e procedimentos relacionados às suas interações com a Administração Pública. Para indicar SIM como resposta, o avaliador deve ter respondido NÃO (zero) a todas as demais perguntas deste item.

Com relação a políticas e procedimentos específicos para prevenção de fraudes e ilícitos no âmbito de Processos licitatórios e na execução de contratos administrativos: (i) Nas políticas e procedimentos apresentados existem orientações sobre a conduta esperada, nos processos licitatórios e na execução de contratos administrativos, dos: (a) empregados da PJ? (b) Terceiros que atuam em nome da PJ com seus concorrentes, a fim de evitar práticas anticoncorrenciais que possibilitem fraudes em processos licitatórios e na execução de contratos administrativos? (ii) Em relação ao conteúdo, as políticas e procedimentos apresentados: (a) Tratam da relação da PJ com seus concorrentes, a fim de evitar práticas anticoncorrenciais que possibilitem a fraude em processos licitatórios e na execução dos contratos administrativos? (b) Tratam do acompanhamento da execução dos contratos celebrados com a Administração Pública? (c) indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à participação em licitações e celebração/prorrogação de contratos administrativos? (iii) Foram realizados treinamentos específicos sobre as políticas e procedimentos existentes nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade no PAR? (iv) Foram apresentados documentos que comprovam a aplicação nos últimos (doze) meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade no PAR, das políticas e procedimentos que tratam de licitações e execução de Contratos celebrados com a administração Pública? (v) A PJ apresentou documentos que indicam o monitoramento da aplicação das políticas e procedimentos relacionados à participação em licitações e execução de Contratos administrativos, com relatórios periódicos, estatísticas e indicadores? (vi) A PJ disponibiliza ao público externo informações sobre licitações e contratos celebrados com a administração pública? (vi) a PJ deixou de apresentar políticas e procedimentos específicos para a prevenção de fraudes e ilícitos em licitações e contratos administrativos. Para SIM como resposta, o avaliador deve ter respondido NÃO (zero) a todas as demais perguntas deste tópico.

Com relação a mecanismos e controles para assegurar a precisão e a clareza dos registros contábeis, bem como a confiabilidade dos relatórios e demonstrações financeiras produzidos: (i) A PJ possui regras que estabelecem a segregação de funções e a definição de níveis de aprovação de receitas e despesas? (ii) A PJ possui regras que estabelecem a segregação de funções e a definição de níveis de aprovação de receitas e despesas? (iii) A PJ possui mecanismos para detectar receitas e despesas fora do padrão e/ou "*red flags*" durante a realização de lançamentos contábeis? (iv) A PJ possui regras que exigem a verificação do cumprimento do objeto do contrato para realização do pagamento? (v) A PJ possui uma área de auditoria interna formalmente estruturada? (vi) A PJ está submetida à auditoria contábil independente?

Com relação a diligências para contratação e supervisão de terceiros: (i) As diligências prévias realizadas pela PJ para contratação de terceiros incluem: (a) verificação do envolvimento de terceiros em casos de corrupção e práticas de fraude contra a administração pública? (b) verificação da existência de programas de integridade implementados nos terceiros avaliados, para mitigar os riscos de corrupção e fraude contra a administração pública? (c) realização de diligências aprofundadas em relação aos terceiros para celebração de parcerias, como consórcios, associações, joint venture e sociedades de propósito específico? (ii) As regras sobre a realização de diligências prévias à contratação de terceiros: (a) favorecem a contratação de terceiros que apresentam baixo risco de integridade?; (b) Estabelecem a necessidade de adoção de medidas para minimizar o risco da contratação de terceiro, caso o resultado das diligências realizadas indique alto risco de integridade do terceiro? (ii) Há segregação de função entre aqueles que realizam as diligências e os responsáveis por realizar contratação? (iii) Há participação da área responsável pelo Programa de Integridade na realização das diligências? (iv) Foram apresentados documentos demonstrando que as diligências de terceiros são aplicadas pela PJ, como formulários preenchidos por terceiros, e-mails solicitando informações a terceiros e avaliações do perfil de risco dos terceiros? (v) Nos Contratos celebrados com terceiros: (a) Há cláusula estabelecendo a obrigatoriedade do cumprimento de normas éticas e a vedação de práticas de fraude e corrupção? (Cláusula anticorrupção?) A PJ apresentou cópias de contratos celebrados comprovando a existência de Cláusula anticorrupção e da previsão de aplicação de penalidade pelo seu descumprimento? (vi) A PJ deixou de apresentar evidências de realização de diligências para contratação e supervisão de terceiros. Para indicar SIM como resposta, o avaliador deve ter respondido NÃO (zero) a todas as demais perguntas do item 11.

Com relação a realização de diligências prévias a processos de fusões, aquisições a fim de verificar o cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas nessa operação: (i) a PJ realiza diligências específicas

para verificar se as pessoas jurídicas envolvidas nas operações de fusão e aquisição possuem histórico de prática de atos lesivos previstos na Lei N. 12.846/2013 (Lei anticorrupção) e outros ilícitos relacionados a corrupção e fraude em licitações e contratos administrativos?; (ii) A PJ realiza diligências para verificar se os sócios das pessoas jurídicas envolvidas nas operações de fusão e aquisição possuem histórico de prática de ilícitos Relacionados a corrupção e fraude a licitações e Contratos administrativos? (iii) Caso o resultado das diligências indique a presença de histórico de prática de atos relacionados à corrupção e fraude a licitações e contratos administrativos, os procedimentos a serem adotados pela PJ para a realização da operação estão previamente definidos ?; e (iv) Há participação da área responsável pelo programa de integridade na decisão ou não da operação?.

Com relação ao canal de denúncia e irregularidades: (i) A PJ, no idioma português, canais para realização de denúncias: (a) Para os seus empregados?; (b) Para o público externo em geral? (ii) Os canais de denúncia existentes: (a) Indicam expressamente que podem ser utilizados para realização de denúncias relacionadas à corrupção e demais irregularidades previstas na Lei N. 12.846/2013? (b) indicam expressamente as garantias de proteção oferecidas aos denunciantes? (c) Possibilitam o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante? (ii) Nos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação dos relatórios de perfil e conformidade no PAR, a PJ realizou ações de divulgação dos canais de denúncia?; (iii) A PJ apresentou procedimentos formalizados que: (a) Regulamentam a apuração da denúncia realizada?; (b) Estabelecem as sanções a serem aplicadas?; (iv) Foram apresentadas estatísticas sobre denúncias recebidas e apuradas e/ou outras informações que indicam que os canais de denúncia são monitorados?. (v) A partir das estatísticas apresentadas é possível verificar uma proporcionalidade entre o número de denúncias recebidas e o número de denúncias apuradas? (vi) A PJ deixou de apresentar evidências de que disponibiliza canal para realização de denúncias, ou ainda que disponibilize, deixou de apresentar evidências de existência de uma estrutura mínima para que as denúncias apresentadas sejam apuradas?

Com relação ao Programa de Integridade anterior à ocorrência do ato lesivo: (i) a PJ, por meio dos controles existentes, conseguiu evitar a consumação da infração? (ii) A PJ comunicou o fato às autoridades competentes previamente à instauração do PAR? (iii) A PJ reparou integralmente o dano causado?; (iv) Em relação ao ato lesivo: (a) a PJ afastou de seus quadros funcionais os envolvidos no ato lesivo?; (b) Os envolvidos no ato lesivo, ainda que mantidos na PJ, foram afastados de cargos com poderes de administração, gestão e a representação legal?; (c) Os envolvidos no ato lesivo ainda que mantidos na PJ estão sendo monitorados? (v) A PJ implementou procedimentos específicos (ou aprimorou os já existentes) para evitar que atos semelhantes ao investigado no PAR ocorram novamente? (a) Os empregados responsáveis pela aplicação desses procedimentos receberam treinamentos específicos para implementá-los?; (b) A PJ apresentou documentos que comprovam a aplicação desses procedimentos específicos em sua rotina?; (c) A PJ realizou ou está realizando internamente investigação/auditoria para verificar se ocorreram atos semelhantes ao investigado no PAR? Ou contratou uma organização independente para realizar essa atividade?; (vi) A PJ deixou de demonstrar qualquer atuação do programa de integridade em relação ao ato lesivo? Para indicar SIM como resposta, o avaliador deve ter respondido NÃO (zero) a todas as demais perguntas deste tópico.

Com relação ao Programa de Integridade posterior à ocorrência do ato lesivo: (i) Em relação aos envolvidos no ato lesivo: (a) A PJ afastou de seus quadros funcionais os envolvidos no ato lesivo?; (b) Os envolvidos no ato lesivo, ainda que mantidos na PJ, foram afastados de cargos com poderes de administração, gestão e representação legal? (c) Os envolvidos no ato lesivo, ainda que mantidos na PJ, estão sendo monitorados? (ii) A PJ implementou procedimentos específicos para evitar que atos semelhantes ao investigado no PAR ocorram novamente?: (a) Os empregados responsáveis pela aplicação desses procedimentos receberam treinamentos específicos para implementá-los?; (b) A PJ realizou ou está realizando internamente investigação/auditoria para verificar se ocorreram atos semelhantes ao investigado no PAR? Ou contratou uma organização independente para realizar essa atividade?; (iii) A PJ deixou de demonstrar qualquer atuação do programa de integridade em relação ao ato lesivo? Para indicar SIM como resposta, o avaliador deve ter respondido NÃO (zero) a todas as demais perguntas deste tópico.

[222] Art.6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções:

I -multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e

II -publicação extraordinária da decisão condenatória.

§ 1º As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações.

§ 2º A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público.

§ 3º A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

§ 4º Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

§ 5º A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores.

§ 6º (VETADO).

[223] A Lei 12.846/13, em seu artigo 7°, inciso VIII, dispõe que será levada em consideração para a punição das empresas: a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica.

[224] Texto integral do *Principles of Federal Prossecution of Business Organizations* disponibilizado em <https://www.justice.gov/jm/jm-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations>

[225] Texto integral do *The United States Sentencing Guidelines* disponibilizado no link: https://www.ussc.gov/guidelines

[226] O segundo fator é a revelação do fato (self-reporting), a aceitação da responsabilidade, cuja previsão encontra-se no *The United States Sentencing Guidelines – Chapter 8 - §8c2.5.(f) (g).*

[227] O manual do "*Principles of Federal Prossecution of Business Organizations",* que deve ser utilizado pelos procuradores americanos, contêm a previsão de que em determinadas circunstâncias, pode ser recomendável a não propositura de uma ação penal (*indictment*), mas alternativamente a adoção de meios alternativos, quais sejam: (i) Os "*Non-prosecution Agreements (NPAs)"*; e (ii) os "*Deffered Prosecution Agreements (DPAs)"*, que funcionam como um equilíbrio paliativo entre a opção de deixar de processar a empresa e a de proferir uma condenação criminal.

[228] O texto do "*Evaluation of Corporate Compliance Program*" encontra-se disponibilizado no link: https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download

[229] Em 21 de julho de 2010, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assinou a Lei Pública 111-203, chamada de Lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e de Proteção a Consumidores, assim nomeada em honra de seus principais proponentes, o senador Chris Dodd e o deputado Barney Frank. Referida legislação também conhecida como *Whistleblower Program,* possibilita, entre outros aspectos, o pagamento de recompensas monetárias aos denunciantes que fornecerem informações sobre violações à legislação de *securities* americana (SEC). A referida legislação, reconhece a importância da colaboração prestada por denunciantes nas ações da SEC para penalizar as empresas e indivíduos que cometeram violações à legislação de *securities* e buscar a reparação aos investidores lesados com tais violações. O referido Programa baseia-se em três pilares centrais: possibilidade de recompensas em dinheiro aos denunciantes; proteção da identidade do denunciante; e proteção contra retaliação. O pagamento de recompensas em dinheiro aos denunciantes é um dos principais pilares, podendo o denunciante receber cifras milionárias, eis que o valor da recompensa a ser paga é uma porcentagem (10% a 30%) das sanções aplicadas que, sabidamente, já chegaram a patamares próximos de bilhões de dólares (a cifra que lidera o ranking de sanções por violações ao FCPA hoje é USD 965 milhões, aplicada à empresa sueca Telia).

[230] Na data de 9/09/2015 a então Procuradora Geral do DOJ, Sally Yates, emitiu um Memorando ("*Memorando de Yates*") demonstrando as novas tendências do órgão, sinalizando que o objeto das investigações conduzidas pelo DOJ é o de apurar a responsabilidade dos indivíduos por ilícitos praticados no âmbito das negociações das empresas. Tal documento instituiu um novo foco das investigações e punições: os executivos e demais funcionários que praticarem ou participarem de referidos ilícitos nas empresas. O Memorando ressalta em seu conteúdo, que é de conhecimento notório, que as corporações são ficções jurídicas, que ali quem comete os ilícitos são alguns indivíduos que têm autonomia e livre arbítrio para cometer os ilícitos e, assim sendo, nada mais eficaz que direcionar as investigações e as punições aos indivíduos. Em síntese, o documento dispõe que para que a cooperação da empresa em uma investigação possa ser considerada válida, ela deve divulgar completamente todos os fatos relevantes sobre condutas individuais nos fatos apurados pelo DOJ. Tal política buscou assegurar que a responsabilização de pessoas físicas esteja no foco das ações anticorrupção conduzidas pelo DOJ. O conteúdo integral do Memorando de Yates pode ser encontrado no link: https://www.justice.gov/archives/dag/file/769036/download

[231] Em 5 de abril de 2014, a Divisão Criminal do DOJ iniciou um "Programa Piloto" do FCPA de um ano de duração para incentivar denúncias e colaborações voluntárias por parte das empresas relativas às provisões da referida legislação. A orientação delineou o tipo de crédito que as corporações poderiam receber pela divulgação e cooperação e procurou aumentar a transparência do DOJ na identificação do crédito que a empresa pode receber pela divulgação voluntária, cooperação e remediação. Em 10 de março de 2017, o Procurador Geral Assistente Atuante, Kenneth A. Blanco, anunciou em um discurso no "*National Institute on White Collar Crime"* [Instituto Nacional sobre o Crime do Colarinho Branco] da American Bar Association [Associação dos Advogados dos EUA] que o programa piloto permaneceria em vigor após o vencimento do primeiro ano até que a Seção de Fraudes pudesse avaliar a utilidade e a eficácia do programa piloto, incluindo possível ampliação e quais revisões, se houver, seriam feitas ao programa.

Conteúdo disponível em: https://www.justice.gov/opa/speech/acting-assistant-attorney-general-kenneth-blanco-speaks-american-bar-association-national.

[232]. Há 10 anos atuando em Compliance, é um profissional com mais de 20 anos de experiência nacional e internacional nas áreas de governança corporativa (Compliance, Auditoria, Gestão de Riscos e Controles Internos) em empresas de Consultoria, Indústria Farmacêutica (Brasil, Suíça, América Latina e Canadá) e Varejo Farmacêutico. Graduado em Ciências da Computação pela UNESP e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. Certificado em Investigação de Fraudes (CFE – Certified Fraud Examiner) e em Compliance e Ética (CCEP – Certified Compliance and Ethics Professional) e em Compliance Anticorrupção (CPC-A). Criador do "COMPLIANCE PROGRAM – THE BOARD GAME".

[233] MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. *Moral Machine.* Disponível em <http://moralmachine.mit.edu>. Acesso em 15 out. 2018.

[234] WIKIPÉDIA. *Trolley Problem: Dilema do Bonde*. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/ Dilema_do_bonde>. Acesso em 15 out. 2018.

[235] PALAZZO, Guido; KRINGS, Franciska; HOFFRAGE, Ulrich. Ethical blindness. *Journal of Business Ethics*, v. 109, n. 3, (2012), p. 323-338. Disponível em <https://www.researchgate.net/ publication/256046104_Ethical_ Blindness>. Acesso em 15 out. 2018.

[236] WIKIPÉDIA. *Dual process theory*. Disponível em < https://en.wikipedia.org/wiki/Dual_process_theory>. Acesso em 15 out. 2018.

[237] KAHNEMAN, Daniel; EGAN, Patrick. *Thinking, fast and slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

[238] WIKIPÉDIA. *Framing (social sciences).* Disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/Framing_(social_ sciences)>. Acesso em 15 out. 2018.

[239] WIKIPÉDIA. *Fraud Triangle.* Disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/Fraud_deterrence#Fraud_ Triangle>. Acesso em 15 out. 2018.

[240]. Advogado especializado em Direito Público. Membro do Comitê de Medidas Disciplinares e consultor da presidência da Petrobras. Ex-Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo. Ex-Secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, o primeiro estado do Brasil a criar uma estrutura administrativa e a aplicar sanções administrativas com base na Lei Anticorrupção Empresarial e premiado pela Controladoria-Geral da União com o primeiro lugar no cumprimento das regras da Lei de Acesso à Informação (2015) e pelo Ministério Público Federal com o primeiro lugar no ranking dos melhores portais de transparência no Brasil (2015). Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV - Faculdade de Direito de Vitória e Doutor em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa (Portugal). É Professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV) nos cursos de graduação e pós-graduação.

[241] *Advogada com vinte anos de prática, incluindo dez anos com foco exclusivo em Compliance. Profissional certificada internacionalmente pela ECOA - Ethics & Compliance Office Association e Fordham University e nacionalmente, pela CPC-A – LEC Certification Board. Sólida experiência na implementação de programa de Compliance em empresas nacionais e internacionais, inclusive atuou em empresas que foram foco de investigação pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). Responsável por lidar com autoridades como FBI, INTERPOL e Política Federal do Brasil durante operação de combate ao cartel junto ao CADE. Professora do curso de pós-graduação em Gestão de Riscos de Fraudes e Compliance na FIA/USP e na LEC. Constantemente convidada para palestrar sobre diversos temas de Compliance, inclusive em Washington em 2016. Recebeu premiação como uma das 20 profissionais mais admiradas e destacadas em Compliance no Brasil pela LEC Compliance on Top/2018.*

[242] BARRETO, Margarida M. S. *Violência, Saúde, Trabalho - Uma jornada de humilhações*. 1.ed. São Paulo: EDUC – Editora da PUC-SP, 2003.

[243] INGENIEROS, *O Homem Medíocre* [Trad. Douglas Dias Ferreira, São Paulo, Quartier Latin, 2004], p. 217.

[244] INGENIEROS, *op. cit.*, p. 129. Essa involução humana é, na mesma obra, mais detalhada pelo mesmo autor: "Os remorsos da primeira culpa cedem à necessidade de acobertá-la com outras, ante as quais já não se importam. Seu caráter se decompõe e eles se perdem, caminham às cegas, tropeçam, tombam, recorrem a artifícios, disfarçam suas intenções, chegam por vias tortuosas, e então buscam cúmplices experientes em andar no escuro. Após as primeiras sondagens caminham depressa, até que as próprias raízes de sua moral se decomponham. Então escorregam pelos barrancos, aumentando a corte de lacaios e parasitas" (*id.*, *ibidem*, p. 165).

[245] Art. 4º da Lei nº 4.898/65. Constitui também abuso de autoridade: [...]. h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal.

[246] Art. 11 da Lei nº 8.429/92. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

[247] INGENIEROS, *op. cit.*, p. 172. O autor, na mesma obra, explica as vantagens da meritocracia: "Um regime em que o valor do mérito individual preponderasse seria perfeito. Excluiria qualquer influência numérica ou oligárquica. Não haveria interesses criados. O voto anônimo teria tão pouco valor quanto o brasão fortuito. Os homens buscariam ser cada vez mais desiguais entre si, preferindo qualquer originalidade criadora à mais tradicional das rotinas. Seria possível a seleção natural, e os méritos de cada um beneficiariam a sociedade como um todo. O respeito por parte dos menos úteis estimularia os favorecidos pela natureza. As sombras valorizariam os homens. O privilégio se mediria pela eficácia das aptidões, e se perderia com elas. É transparente, pois, a crença que, em política, o idealismo fundado na experiência poderia nos sugerir. Opõe-se à democracia quantitativa, que busca a justiça na igualdade, na medida em que afirma o privilégio baseado no mérito. E também à aristocracia oligárquica, que assenta o privilégio nos interesses criados, na medida em que afirma o mérito como base natural do privilégio. A aristocracia do mérito é o regime ideal frente à duas mediocracicas que obscurecem a história. Tem sua fórmula absoluta: 'a justiça na igualdade'" (*id. ibidem*, pp. 253-254).